

Février 2025

RAPPORT N°20.21



Institut des Études
et de la Recherche
sur le Droit et la Justice

Droit et intelligence artificielle

Quelle régulation du marché pour des outils de justice prévisionnelle dignes de confiance ?

Sous la direction de

Aurore HYDE et Agnès DELABORDE

Cette recherche est issue de l'appel à projet :

Les enjeux de la construction d'une justice prévisionnelle dans un contexte d'émergence d'un marché économique des outils d'IA (2019)

Sous la direction de

Aurore HYDE,

Professeure de droit privé à l'université Reims Champagne-Ardenne

Agnès DELABORDE,

Docteure en informatique, responsable de département au LNE

Chercheurs

Guillaume BERNARD,

Docteur en informatique, ingénieur de recherche au LNE

Bénédicte GIRARD,

Professeure de droit privé à l'Université de Strasbourg

Sophie HARNAY,

Professeure d'économie à l'Université Paris Nanterre

Christian LICOPPE,

Professeur de sociologie à Télécom Paris

Liza VEYRE,

Professeure de droit privé à l'Université Reims Champagne-Ardenne

RAPPORT FINAL
Convention n° 20.21

Intitulé du projet

***Droit et intelligence artificielle : quelle
régulation du marché pour des outils de justice
prévisionnelle digne de confiance ?***

Coordinatrice du projet

Aurore Hyde (Professeure de droit privé à l'université
Reims Champagne-Ardenne)

**Responsable scientifique
Adjointe**

Agnès Delaborde (Docteure en informatique, responsable
de département au LNE)

Laboratoire de rattachement

**Centre d'études juridiques sur l'efficacité des systèmes
continentaux universitaire (EA 4693) – Université
Reims Champagne-Ardenne**

Chercheurs

Guillaume Bernard (Docteur en informatique, ingénieur
de recherche au LNE)
Bénédicte Girard (Professeure de droit privé à
l'université de Strasbourg)
Sophie Harnay (Professeure d'économie à l'université
Paris Nanterre)
Christian Licoppe (Professeur de sociologie à Télécom
Paris)
Liza Veyre (Professeure de droit privé à l'université
Reims Champagne-Ardenne)

Partenaires

**Le Laboratoire national de métrologie et d'essais
La société LexisNexis
La société Lexbase**

Durée du projet

15 décembre 2020 – 15 septembre 2024

Sommaire

Introduction

Première partie – La nécessité de réguler les outils de justice prévisionnelle

Titre 1 – La justice prévisionnelle, une forme de réutilisation des données judiciaire en *open data*

Titre 2 – Réguler les outils de justice prévisionnelle pour garantir la qualité de la décision de justice : une analyse économique

Deuxième partie – Les cadres de la régulation des outils de justice prévisionnelle

Titre 1 – L'analyse des cadres réglementaires

Titre 2 – La mise en œuvre des mesures réglementaires des outils de justice prévisionnelle

Troisième partie – L'impact des outils de justice prévisionnelle sur la manière de faire du droit

Titre 1 – L'incidence des outils de justice prévisionnelle sur les pratiques de magistrats

Titre 2 – L'incidence des outils de justice prévisionnelle sur la jurisprudence

Conclusion générale

Introduction

1. **Contexte du projet de recherche.** Dans un ouvrage provocateur paru en 2016¹, Richard Susskind prédisait que les technologies de l'information allaient modifier en profondeur les services juridiques de base, et notamment le rôle des avocats et des juges. De fait, l'utilisation d'outils technologiques censés effectuer à la place des professionnels du droit les tâches qui leur étaient autrefois confiées s'est développée dans certaines entreprises ou dans certains cabinets² et, en 2016 déjà, de nombreux pays s'étaient dotés « d'applications informatiques dans le but d'améliorer la performance et l'efficacité de leurs systèmes judiciaires »³. À titre indicatif, l'Union européenne ou le Canada offrent notamment une plateforme de règlement des différends en matière de consommation⁴.

Depuis lors ce mouvement de digitalisation du droit et de la justice va croissant⁵, en particulier dans le contexte extrajudiciaire⁶, témoignant d'une vision utilitariste du droit portée par l'expansion du domaine occupé par le marché et poussée par un capitalisme exacerbé des plateformes⁷. En effet, le marché des « *legaltechs* » (les instruments technologiques au service du droit et de la justice) est particulièrement dynamique et prometteur⁸. En France notamment,

¹ Susskind R., *Tomorrow's Lawyers*, Oxford University Press, 2016.

² Outils de création d'actes juridiques (Captain Contract ; Legal Acte ; Attestation Légale ; Contract Factory ; Legal Start ; MaNewCo ; etc.) ; digitalisation des processus métiers par exemple (Uplaw ; ILoveTax ; Algonomia) ; moteurs de recherche analytiques (Predictice ; Doctrine ; Wuha) ; outils d'aide à la décision (Case Law Analytics ; JurisData Analytics ; Jurisprudence chiffrée ; LegalMetrics).

³ CEPEJ, « Lignes directrices sur la conduite du changement vers la cyberjustice. Bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques », 7 décembre 2016. Ces applications ont des utilités diverses : faciliter l'accès au juge (ex. services d'information en ligne, de visioconférence, d'*open data*) ; faciliter la communication entre les juridictions et les professionnels (avec notamment la dématérialisation des procédures) ; faciliter la rédaction d'actes ou assister le juge, le procureur et le greffier (avec des outils de gestion informatique des dossiers).

⁴ Pour l'UE : <https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=FR> (consulté le 29 nov. 2020) ; cf. règlement (UE) n° 524/2013 du Parlement européen et du Conseil du 21 mai 2013.

Pour le Canada : <https://www.opc.gouv.qc.ca/a-propos/parle/> (consulté le 29 nov. 2020).

⁵ Garapon A. et Lassègue J., *Justice digitale*, PUF, 2018.

⁶ Voir par exemple l'étude portée par Sandrine Chassagnard-Pinet pour l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice : <https://gip-ierdj.fr/fr/publications/le-e-reglement-extrajudiciaire-des-differends-le-deploiement-dune-justice-alternative-en-ligne/>.

⁷ « Les enjeux éthiques de la justice prédictive », Livre blanc de l'École de droit de Sciences Po, Wolters Kluwer et Predictice, 2018, spéc. p. 36

⁸ Aux États-Unis par exemple, ce marché a levé plus de 740 millions de dollars entre 2011 et 2016 : « Tech In The Courtroom: Legal Tech Companies See Lackluster Funding », CBS Insights, 01/07/2016: <https://www.cbinsights.com/research/legal-tech-startup-funding-2016/> (consulté le 23 déc. 2020).

Ces investissements ont bondi de 713 % sur la seule année 2018 : Pivovarov V., « 713% Growth: Legal Tech Set An Investment Record In 2018 », Forbes, 15/01/2019: <https://www.forbes.com/sites/valentinpivovarov/2019/01/15/legaltechinvestment2018/amp/> (consulté le 23 déc. 2020).

En 2019, la France se positionnait au niveau mondial juste derrière les États-Unis. Sur les 800 *legaltechs* recensées dans le monde, près du quart se situe sur le territoire français : De Jong N., « État des lieux des *legaltechs* en France », *La Semaine juridique Édition générale*, 2019, suppl. n° 44-45, p. 31 et s.

les *startups* tendant à développer les usages des algorithmes en droit se sont multipliées⁹ à tel point qu'un véritable salon leur est désormais dédié chaque année lors du « RDV des Transformations du droit »¹⁰. Or, le poids de l'industrie dans ce secteur rend important le risque de pressions tant sur les décideurs publics que sur les professionnels du droit. À cet égard, il est notable que les *legaltechs* prospèrent sans véritable encadrement alors même que la plupart des professions juridiques sont réglementées afin de ne pas abandonner la fourniture des prestations juridiques aux seules lois du marché¹¹.

Parmi ces outils, certains proposent d'effectuer, dans la masse des décisions accessibles, un gigantesque travail de tri et d'analyse. On peut notamment citer, au moment où le projet a débuté, Doctrine¹², Predictice¹³, Case Law Analytics¹⁴, JurisData Analytics¹⁵, LegalMetrics¹⁶ et Jurisprudence chiffrée¹⁷. Ce sont ces outils que l'on désigne généralement sous l'appellation de « justice prédictive »¹⁸, « justice quantitative »¹⁹, « modes algorithmiques d'analyse des décisions »²⁰, « jurimétrie »²¹ ou encore « justice prévisionnelle »²².

Or, il nous est apparu que le service fourni par les outils de justice prévisionnelle pouvait s'apparenter à de la consultation juridique lorsque ceux-ci sont utilisés directement par des

Et en France aussi, une forte hausse des levées de fonds a été enregistrée entre 2016 et 2019 (même si cette hausse n'a véritablement profité, pour l'année 2017, qu'à 28,6 % des *legaltechs*) : <https://www.maddyness.com/2019/01/23/legaltechs-francaises-les-grandes-tendances-de-lannee-2018/> (consulté le 23 déc. 2020).

⁹ Chassagnard-Pinet S., « Les usages des algorithmes en droit : prédire ou dire le droit », *Dalloz IP/IT*, 2017, p. 495 et s.

¹⁰ <https://www.transformations-droit.com> ; à partir de cet événement qu'il coorganise, le Village de la justice a développé un Observatoire de la Legaltech et tient à jour régulièrement un tableau de bord des solutions disponibles sur le marché : <https://lookerstudio.google.com/reporting/ace93e30-3621-42c5-8b51-cdd3cd165992/page/h8j3D?s=lcbsrwYYO90>.

¹¹ Wickers Th., « L'appropriation des technologies numériques par les professions réglementées – L'exemple de l'avocat », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2018, n° 3, dossier 18.

¹² <https://www.doctrine.fr>

¹³ <https://predictice.com>

¹⁴ <https://www.caselawanalytics.com>

¹⁵ Nous avons conservé la référence à JurisData Analytics car c'est l'outil qui a été évalué dans le cadre de la présente recherche mais il a vocation à être remplacé par Lexis+ AI <https://www.lexisnexis.fr/produits/Lexis-360-Avocats/Lexis360-JurisData-Analytics>

¹⁶ Là encore, nous avons conservé la référence à LegalMetrics car il était également l'objet de notre évaluation mais ce produit n'existe plus et la société Lexbase travaille à une autre solution.

¹⁷ <https://boutique.efl.fr/documentation/par-gamme/jurisprudence-chiffree.html>

¹⁸ Cf. notamment Dondero B., « Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire », *Recueil Dalloz*, 2017, p. 532 ; Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », *La Semaine juridique Édition générale*, 2017, p. 47.

¹⁹ Dupré J. et Lévy Véhel J., « L'intelligence artificielle au service de la valorisation du patrimoine jurisprudentiel », *Dalloz IP/IT*, 2017, p. 500.

²⁰ Godefroy L., Lebaron F., Lévy-Véhel J., « Comment le numérique transforme le droit et la justice vers de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision », *Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice*, 2019.

²¹ Rivollier V. et Quézel-Ambrunaz Ch., « Pour une étude raisonnée de la jurimétrie », *Jurimétrie. Revue de la mesure des phénomènes juridiques*, 2022, n° 1, p. 5 et s., halshs-03813731.

²² Auger A., « La justice prévisionnelle : état des lieux », *Expertise des systèmes d'information*, 01/05/2018, n° 435, p. 184 et s.

justiciables. D'ailleurs, le Conseil national des barreaux (CNB) préconise lui-même d' « ouvrir une réflexion sur la notion de consultation juridique à la lumière de l'utilisation des outils de jurimétrie »²³.

Ensuite, la place de ces outils parmi les sources du droit interroge. Vont-ils conférer une valeur normative aux décisions du fond ? Vont-ils accéder eux-mêmes au rang de source de droit ?

Le développement de ces outils dans un domaine aussi crucial que celui du droit implique de bien en saisir tous les enjeux²⁴ et interroge sur la nécessité ou non de leur régulation. La Mission de recherche Droit et Justice (MRDJ) ne s'y était pas trompée en lançant à l'été 2019, un appel à projets intitulé : « Les enjeux de la construction d'une justice prévisionnelle dans un contexte d'émergence d'un marché économique des outils d'intelligence artificielle ».

C'est pour répondre à cet appel qu'Aurore Hyde a réalisé un projet de recherche et constitué une équipe pluridisciplinaire pour le mener à bien.

2. Présentation de l'équipe de recherche et des objectifs. La présente recherche a été conduite entre décembre 2020 et juillet 2024 par une équipe pluridisciplinaire incluant cinq personnes du monde académique, dont trois professeures de droit (Aurore Hyde, Bénédicte Girard et Liza Veyre), une professeure d'économie (Sophie Harnay) et un professeur de sociologie (Christian Licoppe) ; deux sociétés d'éditions juridiques ayant développé des outils d'analyse algorithmique des décisions de justice (LexisNexis et Lexbase) ; et un organisme disposant d'une expertise notoire dans l'évaluation des produits et services (le Laboratoire national de métrologie et d'essais, représenté par Agnès Delaborde, docteure en informatique et responsable de département et Guillaume Bernard, également docteur en informatique et ingénieur de recherche).

²³ *Préconisations d'actions pour les legaltechs du domaine de la jurimétrie*, CNB, 2020 : <https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/preconisations-dactions-pour-les-legaltechs-du-domaine-de-la-jurimetrie>

²⁴ Enjeux juridiques, économiques, politiques, géopolitiques, sociaux, philosophiques, technologiques, etc.

3. **Objet de la recherche.** Cela a été dit, l'étude s'intéresse à la régulation des algorithmes prédictifs appliqués à la justice, ce qui a d'abord été désigné par l'expression « justice prédictive »²⁵. Bien que cette expression ait été à la mode, elle apparaît trompeuse²⁶, raison pour laquelle celle de « justice prévisionnelle » a été préférée²⁷.

Techniquement, il s'agit d'applications informatiques utilisant des technologies plus ou moins avancées en matière d'apprentissage machine (*machine learning*) et de traitement du langage naturel (*Natural Language Processing*) pour analyser un grand volume de décisions antérieures. Ces technologies sont utilisées dans le but de reproduire, par la machine, le travail de dépouillement des décisions judiciaires qu'une personne humaine aurait pu faire dans une moindre mesure²⁸. En cela, on peut parler d'intelligence artificielle (IA). En effet, en dépit de sa complexité²⁹ et de son manque d'homogénéité³⁰, l'IA peut se définir de manière générale³¹ comme un ensemble de sciences, de théories et de techniques dont le but est de reproduire, par une machine, des capacités cognitives humaine afin de lui confier des tâches plus ou moins complexes³².

Appliquées à la justice, ces technologies offrent un traitement algorithmique des décisions antérieures pour effectuer un gigantesque travail de tri et d'analyse de leur texte. À l'heure où

²⁵ Cf. notamment Dondero B., « Justice prédictive : la fin de l'aléa judiciaire », *Recueil Dalloz*, 2017, p. 532 ; Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », *La Semaine juridique Édition générale*, 2017, p. 47.

²⁶ Hyde A., « La justice prédictive : enjeux et perspectives », déjeuners-débats IRJS, École de droit de la Sorbonne, 28 février 2019. Le document de travail est disponible aux Archives ouvertes, réf. hal-02149092 : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02149092/document>

²⁷ Auger A., « La justice prévisionnelle : état des lieux », *Expertise des systèmes d'information*, 01/05/2018, n° 435, p. 184 et s.

²⁸ La différence fondamentale se situe en effet dans la rapidité du traitement auquel la machine procède, sans commune mesure avec le traitement manuel.

²⁹ Villani C., « Donner du sens à l'intelligence artificielle. Rapport pour une stratégie nationale et européenne », 2018, p. 1.

³⁰ Lassègue J., « L'intelligence artificielle, technologie de la vision numérique du monde », *Cahiers de la Justice*, 2019/2, p. 205 et s.

³¹ À ce stade, nous retenons une définition large de l'intelligence artificielle distincte de celle donnée par le règlement européen sur l'intelligence des « systèmes d'intelligence artificielle », cf. art. 3) 1 du règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689#:~:text=Règlement%20\(UE\)%202024%2F1689,%2FUE%2C%20\(UE\)%202016](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689#:~:text=Règlement%20(UE)%202024%2F1689,%2FUE%2C%20(UE)%202016)

³² Voir la définition de l'IA dans le glossaire annexé à la Charte éthique de la CEPEJ, adoptée le 4 décembre 2018, p. 55. La définition proposée par le groupe d'experts de haut niveau réunis par la Commission européenne va également dans ce sens : <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/definition-artificial-intelligence-main-capabilities-and-scientific-disciplines> (consulté le 15 nov. 2020).

nous avons élaboré le projet de recherche et lancé les travaux, il n'était pas encore question d'IA générative³³ et les fonctionnalités des outils se répartissaient principalement ainsi :

- identifier dans la masse du contentieux les décisions qui répondent avec le plus de pertinence au problème juridique posé en langage naturel (il s'agit alors d'un moteur de recherche nouvelle génération permettant à son utilisateur de retrouver une décision en formulant une requête) ;
- proposer, selon le type de contentieux et selon certains critères et certaines classifications, des probabilités statistiques (moyennes, médianes, fourchettes, écarts-types, etc.) fondées sur des éléments de fait et de droit comparables afin de rendre compte des solutions antérieurement apportées à un litige donné en fonction de critères plus ou moins précis ;
- élaborer, sur un contentieux déterminé, des juges virtuels sur la base de modélisations mathématiques des solutions antérieures afin de proposer un éventail de solutions qui pourraient s'appliquer à un dossier³⁴.

C'est la deuxième fonctionnalité que proposent les outils sélectionnés pour participer au projet de recherche, à savoir JurisData Analytics (LexisNexis) et LegalMetrics (Lexbase). En effet, JurisData Analytics est un service d'analyse quantitative et prospective de la jurisprudence française. Ce service introduit une nouvelle approche de la recherche en allant au-delà des mots-clés, grâce à l'extraction des données de la jurisprudence. Il permet de trouver les décisions de cours d'appel correspondant à des critères très précis, dans le but d'anticiper les suites possibles d'une affaire et de définir la meilleure stratégie juridique. Notamment, il offre une évaluation des indemnités susceptibles d'être accordées en fonction des types de contentieux³⁵, sur la base d'une recherche par critères³⁶ et d'une annotation manuelle des décisions. LegalMetrics poursuit un objectif identique mais la manière d'y procéder est différente puisque la recherche s'effectue par thème – et non par critère –, selon une méthode en entonnoir et une annotation automatique. En outre, LegalMetrics peut également produire la cartographie judiciaire d'une entreprise. Toutes les décisions dans laquelle une personne morale est partie, en demande ou en

³³ Depuis, l'impact de l'IA générative sur les professions juridiques préoccupe la puissance publique et fait l'objet de réflexions importantes. Sur cette question voir notamment le rapport d'information du Sénat *L'intelligence artificielle générative et les métiers du droit : agir plutôt que subir*, n° 216 (2024-2025), du 18 décembre 2024, pour lequel 88 personnalités ont été auditionnées, dont Aurore Hyde : https://www.senat.fr/rap/r24-216/r24-216_mono.html ; Méneceur Y., *IA générative et professionnels du droit. Comprendre et s'appropriier la langue des probables*, LexisNexis, coll. Numérique & Droit, 2024

³⁴ Godefroy L., Lebaron F., Lévy-Véhel J., *op. cit.*, p. 8.

³⁵ C'est ce dernier contentieux qui a été l'objet de l'expérimentation mise en place au sein du tribunal judiciaire d'une grande ville. Cf. *infra*, n° 342 et s.

³⁶ Cf. *infra* pour plus de précision sur le fonctionnement : n° 277 et s.

défense, sont ainsi réparties par thème et par date. Cette différence d'approche nous a semblé intéressante pour effectuer une comparaison entre les outils.

Nous avons travaillé sur la version la plus développée de ces outils au moment du lancement de la recherche mais le travail mériterait d'être repris et poursuivi maintenant que ces sociétés développent des outils intégrant la technologie dite d'IA générative³⁷. À cet égard, le caractère particulièrement évolutif de la technologie à l'œuvre dans les outils de justice prévisionnelle (et dans les *legaltechs* en général) constitue un facteur de complexité indéniable dans la réflexion à leur égard. Pour autant, il demeure possible d'élaborer un cadre d'exigences susceptible d'adaptation. Tel est du moins ce que nous avons tenté de réaliser.

4. Postulat sur la fonctionnalité des outils de justice prévisionnelle. Devant la masse considérable des décisions accessibles avec l'*open data*³⁸, ces outils offrent incontestablement aux professionnels du droit de réduire le temps passé aux recherches juridiques et de se décharger des tâches les plus chronophages³⁹. Ils apparaissent ainsi comme des moteurs de recherche nouvelle génération, évolution logique des bases de données informatiques existantes, essentiellement fournies par les éditeurs juridiques afin de faciliter, moyennant finance, la recherche documentaire des praticiens du droit comme des chercheurs en droit. Mais peut-on véritablement réduire ces outils à leur fonction élémentaire de recherche documentaire ?

Nous avons postulé que leurs fonctionnalités vont bien au-delà dès lors que l'analyse des décisions vise à rendre compte de l'issue probable d'un litige en appréciant les chances de succès d'une prétention. Ce faisant, ces outils s'inscrivent dans une démarche de prévisibilité en proposant des probabilités sur l'issue d'une affaire. Cette démarche est parfaitement connue du juriste dès lors que l'application du droit repose sur une exigence de prévisibilité, gage de sécurité juridique. Et le rôle du conseil juridique est notamment de renseigner son client sur les chances de succès ou d'échec de ses prétentions. Ce qui change et qui pose problème, c'est que les probabilités ne sont plus suggérées sur la base de compétences propres au professionnel du droit, issues de sa formation, de son expérience, de son analyse personnelle de l'état du droit antérieur et des textes à sa disposition. Les probabilités sont désormais suggérées par un

³⁷ Dès lors il serait pertinent de poursuivre la recherche objet du présent rapport en étudiant les solutions intégrant de l'IA générative comme GenIA-L (Dalloz) ou Lexis+ AI (LexisNexis).

³⁸ Plusieurs millions de décisions sont rendues chaque année, toutes juridictions confondues : Cadiet L., « Rapport sur l'*open data* des décisions de justice », Mission d'étude et de préfiguration sur l'ouverture au public des décisions de justice, 2017, § 59.

³⁹ Cassuto Th., « La justice à l'épreuve de sa prédictibilité », *Actualité juridique Droit pénal*, 2017, p. 334.

programme informatique particulièrement élaboré et parfaitement incompréhensible par le profane, le profane devenant ici le professionnel du droit lui-même⁴⁰.

5. **Incompétence des professionnels du droit.** Le professionnel du droit utilisant ce type d'outil sera bien souvent incapable de dire si le programme informatique remplit correctement la tâche qu'il attend de lui. Il ne pourra donc pas garantir la fiabilité du résultat appelé à influencer largement sa décision tant sont grandes la force persuasive des chiffres⁴¹ et la propension à privilégier les suggestions automatiques des systèmes de prise de décision⁴² en dépit d'informations contradictoires pertinentes. En outre, l'absence de compétence des professionnels du droit en matière d'intelligence artificielle comme en matière de statistiques ne garantit pas une bonne interprétation des résultats fournis par la machine. Or, il a déjà été montré comment une mauvaise connaissance de la théorie des probabilités pouvait conduire à de graves erreurs judiciaires⁴³.

6. **Fonctionnement opaque des outils.** En outre, les outils de jurimétrie aujourd'hui développés par les entreprises privées reposent sur un fonctionnement assez opaque. Si l'idée est généralement répandue que les chiffres parlent d'eux-mêmes, c'est une idée fausse. Au contraire, « de multiples médiations techniques sont indispensables pour leur faire signifier quoi que ce soit »⁴⁴. Selon les données fournies à la machine et le programme conçu, les résultats obtenus différeront quand bien même les critères de recherche sélectionnés seraient les mêmes. Outre que les données fournies en entrée à la machine sont certainement biaisées⁴⁵, toutes les opérations auxquelles elles seront soumises portent en elles des biais cognitifs des concepteurs⁴⁶, volontaires ou non. Tout modèle est par essence une approximation dont la

⁴⁰ Garapon A. et Lassègue J., *Justice digitale*, précité.

⁴¹ Tribe L. H., "Trial by Mathematics: Precision and Rituals in the Legal Process", 84 *Harvard Law Review* 1329 (1971) & "The Continuing Debate over Mathematics in the Law of Evidence: A Further Critique of Mathematical Proof", 84 *Harvard Law Review* 1810 (1971).

⁴² Parasuraman R. & Riley V., "Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse", *Human Factors*, 1997, Vol. 39, Issue 2 ; Méneceur Y., « DataJust face aux défis de l'intelligence artificielle », *La Semaine juridique Édition générale*, 2020, p. 1708 et s.

⁴³ Schneps L. et Colmez C., *Les maths au tribunal*, Seuil, coll. Science ouverte, 2015 ; Taroni F. et Mangin P., « L'interprétation de la preuve scientifique : les juristes, les scientifiques et les probabilités », *Médecine et droit* 1998, n° 30, p. 6 et s.

⁴⁴ Garapon A. et Lassègue J., *Justice digitale*, précité.

⁴⁵ « Algorithmes : contrôle des biais S.V.P. », Rapport de l'Institut Montaigne, mars 2020, accessible en ligne : <https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/algorithmes-contrôle-des-biais-svp.pdf>

⁴⁶ Bertail P., Bounie D., Cléménçon S., Waelbroeck P., « Algorithmes : biais, discrimination et équité », Télécom ParisTech, Fondation Abeona, février 2019, accessible en ligne : <https://www.telecom-paris.fr/wp-content-EvDsK19/uploads/2019/02/Algorithmes-Biais-discrimination-equite.pdf>

pertinence dépend en partie de son concepteur⁴⁷. Il existe ainsi divers types d'algorithmes qui remplissent différentes fonctions⁴⁸. Le choix de tel ou tel type d'algorithme pour élaborer un programme informatique aura donc nécessairement une répercussion sur la solution en sortie. Selon l'outil utilisé, les résultats proposés pourront donc être différents⁴⁹ et il faudrait sans doute, pour approcher la solution la plus juste, croiser les résultats obtenus à partir d'une pluralité d'outils⁵⁰.

7. **Répercussion sur la confiance dans le système juridique.** La confiance dans le système juridique repose largement sur la compétence des professionnels du droit. Lorsqu'une personne sollicite les conseils d'un avocat ou s'en remet à un juge pour résoudre son litige, elle fait confiance au savoir, à la compétence et à l'expérience qu'ils ont acquis pour manier les sources du droit et appliquer les méthodes nécessaires au traitement de son cas. De telles normes de compétences n'existent pas en présence d'outils dotés d'intelligence artificielle pour traiter des documents juridiques. L'absence de normes de compétences entrave alors non seulement la confiance dans l'utilisation de ces outils, mais peut aller jusqu'à saper la confiance dans le système juridique lui-même.

En outre, le marché des outils de justice prévisionnelle apparaît marqué par une très forte asymétrie d'informations entre les différents opérateurs : industriels, utilisateurs et justiciables, et enfin puissance publique. Cette asymétrie informationnelle dans un domaine normalement régalién suscite naturellement une grande méfiance⁵¹.

L'impact négatif sur le service public de la justice que portent en eux les outils de justice prévisionnelle implique de réfléchir aux moyens de restaurer la confiance, afin d'éclairer l'action publique. C'est d'ailleurs une problématique propre à l'IA en général que celle de la nécessité de restaurer la confiance par le biais de l'action publique. En effet, le groupe d'experts européen constitué par la Commission européenne pour poser le cadre éthique d'une « IA digne

⁴⁷ Jean A., *De l'autre côté de la machine*, Éditions de l'Observatoire, coll. De facto, 2019, spéc. p. 89 et s.

⁴⁸ Domingo P., *The Master Algorithm*, Penguin, Science/Tech, 2015.

⁴⁹ Des recherches comparatives menées sur plusieurs logiciels français de justice prévisionnelle ont par exemple montré que les résultats variaient d'un outil à l'autre sur la question des indemnités allouées au salarié ayant subi un licenciement abusif : Kirat Th. et Sweeney M., « Comparaison d'applications de "justice prédictive" : le cas du contentieux de l'indemnisation du licenciement abusif, 2012-2016. Predictice, Dalloz-Jurisprudence chiffrée et JurisData Analytics », in *Justice et numérique : quelles révolutions ?*, actes du séminaire e-juris Septembre 2018-Février 2019, coord. Sayn I., *Le Semaine juridique Édition générale*, 2019, supplément au n° 44-45, p. 53 et s.

⁵⁰ Hyde A., « Avocat et intelligence artificielle : quelles obligations, quelles responsabilités ? », *Recueil Dalloz*, 2019, p. 2107 et s.

⁵¹ Amrani-Mekki S. et al., *La justice prédictive*, actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à l'occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l'université Paris Dauphine PSL, Dalloz, 2018, 122 p. ; Garapon, A., « Les enjeux de la justice prédictive », précité.

de confiance » appelle de ses vœux une réaction politique⁵². Le comité *ad hoc* sur l'intelligence artificielle du Conseil de l'Europe va dans le même sens en invitant les États membres à se saisir du problème⁵³.

8. **Modification possible du statut français de la jurisprudence.** En offrant un accès effectif aux décisions de justice, les outils de justice prévisionnelle participent à la connaissance de l'activité judiciaire, particulièrement celle des juges du fond qui était largement inaccessible jusqu'alors⁵⁴. Mais ils vont au-delà car, parmi ces décisions, nombreuses sont celles qui n'ont aucun intérêt prises isolément. En revanche, leur traitement global, leur agrégation, est susceptible d'avoir une influence sur les sources du droit. En effet, il est probable que cela génère la constitution d'une « jurisprudence du fond »⁵⁵ de plus en plus uniforme dans la mesure où les magistrats pourront être tentés de ne pas trop s'écarter de la tendance majoritaire au détriment de l'individualisation de la décision. Les résultats statistiques fondés sur des décisions pourraient ainsi devenir sources de droit en servant de fondement, non seulement à des prétentions, mais aussi à des décisions. Ce phénomène est de nature à constituer une « porte d'entrée dans un système de précédent »⁵⁶ de nature à remettre en cause le paradigme de la jurisprudence du système juridique français et mérite dès lors d'être particulièrement observé. Cela n'a pas échappé à la Cour de cassation qui a sollicité un rapport sur cette question⁵⁷, rapport dont les recommandations seront ici étudiées⁵⁸.

9. **Problématique.** Au regard de ce qui précède, la présente recherche entend répondre à la problématique suivante : une régulation des outils de justice prévisionnelle est-elle

⁵² « Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI », AIHLEG, June 2019 : <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence>

⁵³ « Vers une régulation des systèmes d'IA. Perspectives internationales sur l'élaboration d'un cadre juridique fondé sur les normes du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit », CAHAI, décembre 2020, p. 5 : <https://rm.coe.int/prems-107420-fra-2018-compli-cahai-couv-texte-a4-bat-web/1680a0c17b>

⁵⁴ L. Cadiet, Rapport précité, § 60.

⁵⁵ Deumier P., « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond », in *La Justice prédictive, Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 49 et s. ; du même auteur, « Open Data - Une autre jurisprudence », *La Semaine juridique Édition générale*, 2020, p. 473 et s.

⁵⁶ Serverin E., « De l'informatique juridique aux services du justice prédictive, la longue route de l'accès du public aux décisions de justice dématérialisées », in *La Justice prédictive, Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 23 et s., spéc. p. 43 et s.

⁵⁷ Cadiet L., Chainais C. et Sommer J.-M. (dir.), Jobert S. et Jond-Necand E. (rapp.), « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation, juin 2022 : <https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/06/14/la-diffusion-des-donnees-decisionnelles-et-la-jurisprudence-quelle>

⁵⁸ Cf. infra, n° 446 et s.

souhaitable et le cas échéant est-elle possible ? Quelles pourraient en être les modalités ? Répondre à cette problématique générale a nécessité une méthodologie particulière.

10. **Méthodologie interdisciplinaire.** Pour traiter la problématique énoncée, il a fallu orienter les recherches autour de trois axes, chacun des trois axes faisant appel à l'interdisciplinarité, la discipline juridique demeurant représentée dans chaque axe : un premier axe droit-économie ; un deuxième axe droit-métrologie ; un troisième axe droit-sociologie.

L'interdisciplinarité est volontairement au centre de la recherche car le développement de l'informatique juridique avec le déploiement des bases données jurisprudentielles et des logiciels de traitement de ces données commande de nouvelles méthodes qui modifient le visage des productions de recherche⁵⁹. L'interdisciplinarité doit alors enrichir l'analyse juridique en mobilisant les connaissances d'autres disciplines afin de mieux saisir les objets de justice prévisionnelle et leurs enjeux.

11. **Objectifs et méthodes de l'axe droit-économie.** Envisager la nécessité ou non d'une régulation des outils de justice prévisionnelle impliquait, d'une part, de cerner le contexte d'émergence de ces outils, en l'occurrence celui de l'*open data* des décisions de justice, et les enjeux qu'un traitement par l'IA de ces données massives soulèvent, notamment en termes de risques d'atteinte aux droits fondamentaux des justiciables, et, d'autre part, d'examiner les conséquences du développement de ces outils sur la structuration de l'offre sur le marché des services juridiques, ainsi que d'analyser la nature de ce marché qui a partie liée avec la confiance nécessaire dans la justice et les risques de défaillances des mécanismes du marché. Réfléchir à la nécessité d'une régulation *ex ante* du marché des outils de justice prévisionnelle conduisait également à étudier les modalités d'une telle régulation en explorant les instruments existant (tant de droit dur que de *soft law*) pour faire émerger certaines obligations et principes en la matière, autant que des lacunes. Le rôle de la puissance publique dans cette régulation a été interrogé, de même que la place de l'évaluation des outils de justice prévisionnelle. Selon une première approche théorique, les différents types d'évaluation ont été envisagés (audit interne, certification volontaire, obligatoire) faisant ressortir l'intérêt d'une évaluation par un tiers indépendant.

⁵⁹ Serverin E., « De l'informatique juridique... », art. précité.

Les voies de la régulation *ex post* ont également été explorées, en examinant celles envisageables pour la responsabilité des opérateurs en la matière, tant au niveau interne qu'au niveau européen.

12. **Objectifs et méthodes de l'axe droit-métronologie.** Les travaux de cet axe sont venus compléter l'approche théorique relative à l'évaluation des outils de justice prévisionnelle. En effet, le travail conduit avec les experts du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE) a eu pour ambition d'analyser la chaîne de qualification des deux systèmes de justice prévisionnelle partenaires du projet, afin de déterminer si leur évaluation permettait d'attester de leur conformité à certains principes (tels que le principe de fiabilité du résultat, le principe de transparence ou celui d'explicabilité par exemple). Concrètement, nous nous sommes appuyés sur les principes issus de la Charte éthique européenne pour l'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires⁶⁰ afin de déterminer la mesure dans laquelle il était possible de les opérationnaliser.

Science des mesures, la métrologie⁶¹ permet notamment l'évaluation technique de certains produits par rapport à des références de qualité ou de sécurité qui constituent des étalons de mesure⁶². Depuis 2008, le LNE⁶³ dispose d'une équipe dédiée à l'évaluation des systèmes d'intelligence artificielle sollicitée notamment pour organiser des campagnes d'évaluation dans le traitement de la langue et des images. Pour autant, au moment du lancement du projet, aucune de ses missions n'avait encore porté sur un instrument de *legaltech* tel un système de justice prévisionnelle. Le travail fourni était donc particulièrement exploratoire, aucun cahier des charges n'étant disponible.

L'objectif était, sur la base d'une expérimentation technique des outils JurisData Analytics et LegalMetrics, de définir quels sont les éléments qui, dans la chaîne de qualification des outils étudiés, permettent de garantir une certaine traçabilité (notamment l'intégrité des données en entrée, l'intelligibilité du processus de traitement, la pertinence des résultats proposés).

⁶⁰ Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, CEPEJ, 3-4 décembre 2018 : <https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b> (consulté le 23 décembre 2020) ; commentaire Hyde A., « Vers une cyber-éthique de la justice dite prédictive », « Vers une cyber-éthique de la justice dite prédictive », *Dalloz IP/IT*, 2019, p. 324 et s.

⁶¹ <https://www.cnrtl.fr/definition/metrologie> (consulté le 23 décembre 2020).

⁶² <https://www.lne.fr/fr/comprendre/la-metrologie> (consulté le 23 décembre 2020).

⁶³ Le LNE a notamment pour mission de poursuivre des développements scientifiques et techniques pour anticiper les besoins en matière de mesure, d'essais, de qualification et d'évaluation liés aux évolutions technologiques, et de mettre au point de nouvelles méthodes.

Ce travail, qui pourrait certes être amélioré, constitue donc une première dans l'évaluation des outils de justice prévisionnelle en proposant un modèle d'analyse de risques ainsi qu'un plan d'évaluation.

13. **Objectifs et méthodes de l'axe droit-sociologie.** Cet axe a eu pour ambition, dans une approche théorique, de réfléchir à l'incidence des outils de justice prévisionnelle sur les sources du droit, tant du point de vue de la normativité de ces outils, que du point de vue de leur impact sur le statut, en droit français, de la jurisprudence. La Cour de cassation ayant missionné un groupe de travail pour réfléchir à ces questions, la recherche se fonde essentiellement sur le rapport qui en résulte pour en livrer une appréciation⁶⁴.

Dans une perspective de sociologie du droit, l'objectif a également été d'examiner concrètement la manière dont les outils de justice prévisionnelle sont effectivement utilisés dans des contextes d'usage, leur influence effective sur les décisions des magistrats et en quoi ils se distinguent d'autres dispositifs d'aide à la décision comme les barèmes⁶⁵ ou les listes de discussion entre magistrats par exemple⁶⁶.

Deux expérimentations d'usages devaient être menées auprès de magistrats, l'une avec l'outil JurisData Analytics au tribunal judiciaire d'une grande ville, l'autre avec l'outil LegalMetrics au tribunal judiciaire d'une autre grande ville. Malheureusement, le décès brutal de Fabien Waechter, le 25 septembre 2022, alors président de la société Lexbase, a empêché la mise en œuvre de l'expérimentation, la société Lexbase ayant été très affectée et tournée vers sa réorganisation.

Seule a donc été conduite l'expérimentation de l'outil JurisData Analytics auprès de magistrats du contentieux familial du tribunal judiciaire d'une grande ville.

14. **Plan du rapport.** La première partie du rapport s'intéresse à la nécessité de réguler les outils de justice prévisionnelle eu égard aux enjeux en la matière et à la nature particulière du

⁶⁴ Cadet L., Chainais C. et Sommer J.-M. (dir.), Jobert S. et Jond-Necand E. (rapp.), « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », rapport précité.

⁶⁵ Sur cette question, cf. notamment « La barémisation de la justice », dir. Gerry-Vernières S., Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2019 : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02490767> ; « Les barèmes (et autres outils techniques d'aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice », dir. Sayn, I., Perrocheau, V., Favier, Y., Merley, N., Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2019 : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02283040v2> ; « La barémisation de la justice : une approche par l'analyse économique du droit », dir. Bourreau-Dubois C., Rapport de recherche pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2019 : <http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/la-baremisation-de-la-justice-une-approche-par-l-analyse-economique-du-droit/> ; Sayn I. (dir.), *Le droit mis en barèmes*, Dalloz, coll. Thèmes et commentaires, 2014.

⁶⁶ Veyre L., « Les listes de discussion entre magistrats : vers une nouvelle forme de création et d'unification de la jurisprudence ? », *Le Semaine juridique Édition générale*, 2017, p. 1336 et s.

marché en cause (Première partie). La deuxième partie explore les modalités envisageables d'une régulation tant *ex ante* qu'*ex post* (Deuxième partie). La troisième partie enfin s'intéresse à ce que les outils de justice prévisionnelle modifient quant à la manière de faire du droit et de rendre la justice (Troisième partie).

Première partie – La nécessité de réguler les outils de justice prévisionnelle

Les outils de justice prévisionnelle prospèrent grâce à la mise à disposition du public des décisions de justice. Parce qu'elle repose sur le traitement de ces décisions, la justice prévisionnelle est finalement une forme de réutilisation des données judiciaires en *open data* (Titre 1). Du fait de la nature particulière des données judiciaires ainsi que du marché des services juridiques, il y a lieu de considérer que le marché des outils de justice prévisionnelle n'est pas un marché comme les autres (Titre 2).

Titre 1 – La justice prévisionnelle, une forme de réutilisation des données judiciaire en *open data*

15. Il s'agit ici de revenir sur le contexte de l'*open data* des décisions de justice (Chapitre 1) puis d'en cerner les enjeux pour le droit et la justice (Chapitre 2).

Chapitre 1 – Le contexte de l'*open data* des décisions de justice

Section 1 – Le choix français⁶⁷

16. **Définition de l'*open data*.** L'*open data* des décisions de justice, c'est-à-dire la mise à disposition du public de l'ensemble des décisions des juridictions de l'ordre judiciaire et administratif, à titre gratuit, dans un format électronique, relève du mouvement plus général d'ouverture massive des données numériques, désigné sous l'expression « *open data* », qui signifie « données ouvertes ». L'expression renvoie plus précisément à la mise en ligne, par les administrations, des données qu'elles détiennent, dans un but de libre réutilisation par les citoyens et les entreprises⁶⁸. L'ouverture des données publiques françaises répond aux objectifs posés par divers textes européens initiés dès 2003, et refondus par la directive du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public⁶⁹.

17. Les textes de référence :

- Décret n° 2011-194 du 21 février 2011 portant création d'une mission « Etalab » chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques.

⁶⁷ Par Liza Veyre.

⁶⁸ Sénat, Rapport d'information fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sur l'*open data* et la protection de la vie privée, par MM. Gaëtan Gorce et François Pillet, n° 469, session ordinaire 2013-2014, p. 5. Le rapport intitulé « L'*open data* des décisions de justice » (dir. Loïc Cadiet) remis à la garde des Sceaux en novembre 2017 (dit « rapport Cadiet »), p. 17 note que si, « au sens strict, l'*open data* désigne une donnée numérique, d'origine publique ou privée, qui est librement accessible et utilisable », « le terme a progressivement été associé à un mouvement, celui de l'ouverture des données publiques ».

⁶⁹ Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, *J.O.U.E* L 172/60 du 26 juin 2019 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN>

- Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui prévoit une mise à disposition des données détenues par les administrations, dont les décisions de justice.
- Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, qui autorise le traitement algorithmique des données en *open data*.
- Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2015-2022 et de réforme pour la justice, qui prévoit la mise en application de la diffusion des décisions de justice.
- Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
- Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.
- Décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre ».
- Arrêté du 6 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives

18. **Les étapes de l'*open data* des décisions de justice.** Ce mouvement d'ouverture des données détenues par les administrations, initié par le décret n° 2011-194 du 21 février 2011 portant création d'une mission « Etalab » chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques, a pris corps avec la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui porte notamment sur ces données particulières que sont les décisions de justice.

Cette loi a consacré l'*open data* des décisions de justice en instituant, en ces articles 20⁷⁰ et 21⁷¹, une mise à la disposition du public à titre gratuit de toutes les décisions de justice rendues publiquement par les juridictions des ordres administratif et judiciaire (ce qui exclut les décisions rendues à huit clos).

Le législateur a par ailleurs autorisé le traitement algorithmique de ces données par la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles⁷². La diffusion de ces données particulières, « en raison de leur source (les institutions juridictionnelles) autant que de leur objet (les droits des justiciables) »⁷³, que sont les décisions de justice, impliquait la mise en place d'un cadre législatif et réglementaire propre dont nous verrons qu'il a quelque peu délaissé la question de la réutilisation, à des fins commerciales, des données judiciaires⁷⁴. L'*open data* des décisions de justice ayant été consacré par la loi de 2016 et une réflexion sur l'ouverture au public des décisions de justice ayant été menée par la mission d'étude et de préfiguration dirigée par le professeur Loïc Cadiet, laquelle a remis son rapport intitulé « L'*open data* des décisions de justice » à la garde des Sceaux en novembre 2017⁷⁵, sa mise en application a pu être réalisée.

Cette mise en application de l'*open data* des décisions de justice a été définie par la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 et concrétisée avec le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 qui prévoit des mesures d'occultation des éléments d'identification des personnes physiques, parties ou tiers, ainsi que des magistrats ou membres de greffe, en cas d'atteinte à leur vie privée ou leur sécurité. En outre, le décret définit les conditions de mise à la disposition du public des décisions

⁷⁰ Selon ce texte, « L'article L. 10 du Code de justice administrative est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : Ces jugements sont mis à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces jugements.

Un décret en Conseil d'État fixe, pour les jugements de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article ».

⁷¹ Ce texte énonce : « Le chapitre unique du titre Ier du livre Ier du Code de l'organisation judiciaire est complété par un article L. 111-13 ainsi rédigé :

Art. L. 111-13. - Sans préjudice des dispositions particulières qui régissent l'accès aux décisions de justice et leur publicité, les décisions rendues par les juridictions judiciaires sont mises à la disposition du public à titre gratuit dans le respect de la vie privée des personnes concernées.

Cette mise à disposition du public est précédée d'une analyse du risque de ré-identification des personnes. Les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations entre le public et l'administration sont également applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans ces décisions.

Un décret en Conseil d'État fixe, pour les décisions de premier ressort, d'appel ou de cassation, les conditions d'application du présent article ».

⁷² Art. 8, 10° loi précitée.

⁷³ Rapport Cadiet, p. 17.

⁷⁴ Cf. infra, n° 180.

⁷⁵ <http://www.justice.gouv.fr/publications-10047/rapports-thematiques-10049/remise-du-rapport-sur-lopen-data-des-decisions-de-justice-31165.html>

de justice, précise le champ des décisions concernées et les mentions à occulter au sein des décisions et établit le calendrier de mise à disposition des décisions pour chacun des trois niveaux d'instance. Aux termes de ce décret, la mise à disposition des décisions sous format électronique est confiée au Conseil d'État pour les décisions de l'ordre administratif et à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Conformément au décret précité, un arrêté du 28 avril 2021 a ensuite précisément fixé le calendrier de la diffusion en *open data* des décisions de justice. Selon ce calendrier, l'ensemble des décisions de justice doit être mis en ligne progressivement, entre le 30 septembre 2021 et le 30 septembre 2025.

S'agissant de l'ordre judiciaire, les décisions sont accessibles via la base « Judilibre » du site internet de la Cour de cassation. Les décisions de l'ordre administratif sont quant à elles accessibles sur la plateforme « Décisions de la justice administrative ».

Au 1^{er} octobre 2021, seules des décisions de la Cour de cassation et du Conseil d'État étaient accessibles. En mars 2022, ce sont les décisions des cours administratives d'appel qui sont devenues accessibles et en avril 2022 celles des cours d'appel. Près de 35 000 décisions pour l'ordre administratif et 180 000 pour l'ordre judiciaire doivent ainsi venir enrichir annuellement les bases de données ouvertes.

En juin 2002, la mise à disposition du public des décisions des tribunaux administratifs a été inaugurée mais celles des tribunaux judiciaires ont dû attendre. Leur mise à disposition se fera progressivement selon un calendrier échelonné entre juin 2023 et septembre 2025, en fonction de la nature du contentieux⁷⁶.

Plus précisément, l'échéancier est le suivant en matière civile :

- 30 juin 2023 s'agissant des décisions rendues par les conseils de prud'hommes ;
- 31 décembre 2024 s'agissant des décisions rendues par les tribunaux de commerce ;
- 30 septembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les tribunaux judiciaires⁷⁷.

En matière pénale, le calendrier est ainsi fixé :

- 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues par les cours d'appel en matière contraventionnelle et délictuelle ;
- 31 décembre 2025 s'agissant des décisions rendues en matière criminelle⁷⁸ ;

⁷⁶ Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

⁷⁷ Art. 2, arrêté précité.

⁷⁸ Art. 3, arrêté précité.

- 31 décembre 2026 s'agissant des décisions des juridictions de premier degré en matière contraventionnelle et délictuelle⁷⁹ ;
- 31 décembre 2027 s'agissant des décisions rendues par les juridictions de premier degré en matière contraventionnelle⁸⁰.

Le modèle choisi n'était pas le seul possible, ainsi que le montre la comparaison avec d'autres systèmes.

Section 2 – La comparaison avec d'autres choix possibles⁸¹

19. **Choix réalisés par certains voisins européens.** Sans entrer dans le détail, nous pouvons par exemple relever qu'à la différence du législateur français, nos voisins européens n'ont pas tous fait le choix d'une mise à disposition totale. En effet, selon un tableau comparatif⁸², la Belgique et la Suède ont opté pour une sélection des décisions publiées, en fonction de leur intérêt pour le public ; l'Allemagne, l'Autriche, la Croatie, l'Espagne, l'Irlande et le Luxembourg s'engagent principalement à la mise à disposition du public des décisions émanant des plus hautes juridictions ; la Croatie, la Lettonie, le Portugal et l'Union européenne ne mettront à disposition que les décisions définitives.

Par ailleurs, certains États ont fait le choix de subordonner la mise à disposition au paiement de certains frais, comme l'Espagne lorsque la réutilisation est faite à des fins commerciales⁸³, ou ont restreint l'accès aux données par exemple en renforçant le système de cybersécurité ou en empêchant le téléchargement⁸⁴.

Par ailleurs, et comme nous le développerons plus loin, certains pays ont fait le choix d'un encadrement plus strict de la réutilisation, en particulier à des fins commerciales⁸⁵.

En revanche, la plupart des États prévoient, comme la France, d'exclure de la mise à disposition des décisions à caractère sensible, ce qui est le cas de celles rendues non publiquement⁸⁶.

⁷⁹ Art. 1, arrêté du 6 décembre 2024 modifiant l'arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

⁸⁰ *Ibid.*

⁸¹ Par Aurore Hyde.

⁸² Tableau comparatif sur l'encadrement de l'accès en données ouvertes aux décisions de justice, Synthèse des réponses, Ministère de la Justice, 2023, p. 1 : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/rapport_pfue_sem_cmjn%20%281%29.pdf

⁸³ *Ibidem.*

⁸⁴ Tableau précité, p. 3.

⁸⁵ Cf. infra, n° 180.

⁸⁶ Tableau précité, p. 1.

20. **Choix réalisé au Canada.** Lors de sa présentation à un atelier sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice⁸⁷, Maître Xavier Beauchamp-Tremblay a mis en évidence que le régime canadien était assez distinct du régime français. D'abord, la mise à disposition du public des décisions de justice est assurée par l'Institut canadien d'information juridique (Can LII, l'institut d'information juridique du Canada) qui est un organisme à but non lucratif et non gouvernemental financé sur la base de frais payés chaque année par les barreaux de toutes les provinces et territoires du Canada. Surtout, cette mise à disposition ne s'appuie sur aucune disposition juridique et l'État n'intervient pas dans cette diffusion (sauf dans la Province du Québec où une société d'État, la SOQUIJ, a un mandat pour le faire). Cependant, les autorités en matière de vie privée considèrent que les lois en ce domaine sont applicables. Me Xavier Beauchamp-Tremblay considère quant à lui qu'il n'existe pas vraiment de protection des données personnelles, même si des mesures techniques ont été mises en place pour empêcher les téléchargements massifs. Aucun compte ni mot de passe n'est requis, aucun recours en rectification, en opposition ou en effacement n'est prévu pour les justiciables, sauf si la décision fait l'objet d'une ordonnance de restriction à la publication ou si une loi prévoit expressément des restrictions à sa publication.

Si l'intervention de Can LII permet une publicité homogène, contrairement à une publication directement sur internet par chaque tribunal, ses procédés sont donc critiquables.

Pour y pallier, un modèle de politique de diffusion a été établi par le Conseil de la magistrature canadien, qui préconise notamment le fait de ne pas indexer dans les moteurs de recherche dits « généraux » les décisions publiées. L'affaire « Globe24h »⁸⁸ a démontré que l'indexation des décisions constitue le point de bascule dans l'équilibre entre vie privée et publicité des débats judiciaires.

Les lignes de conduite de ce modèle montrent une ouverture pour la diffusion en nombre des données aux *legaltechs* et aux chercheurs, mais soulignent l'importance du principe de

⁸⁷ Entre juin et octobre 2021, le ministère de la justice, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont animé cinq ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice. Les propos cités proviennent du rapport rendu public en juillet 2022, « Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice » : <https://www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/rapport-du-cycle-dateliers-sur-lethique-de-la-1>.

⁸⁸ L'affaire « Globe 24h » est une escroquerie fondée sur l'indexation massive de milliers de décisions de justice par un individu qui les avait publiées sur un site se prétendant journalistique. Il demandait le paiement de frais aux individus sollicitant leur retrait du site. Cette affaire a conduit à un nombre record de plaintes aux autorités de vie privée canadiennes, qui ont conclu que même si les décisions de justice sont publiques en vertu du principe constitutionnel de publicité des débats, leur manipulation est néanmoins assujettie à la réglementation sur la protection de la vie privée, <https://www.priv.gc.ca/fr/mesures-et-decisions-prises-par-le-commissariat/enquetes/enquetes-visant-les-entreprises/2015/lprpde-2015-002/>.

l'indépendance de la magistrature dont le corollaire serait que chaque tribunal doit rester maître de ses décisions et de l'accès à ces dernières.

Chapitre 2 – Les enjeux de l’*open data* des décisions de justice

21. Les enjeux de l’*open data* des décisions sont multiples. Dans ce chapitre, nous nous focaliserons sur les enjeux de transparence et de connaissance de l’activité judiciaire (Section 1) et sur les enjeux pour le procès équitable (Section 2), d’autres enjeux étant étudiés dans le titre suivant sous l’angle de l’analyse économique.

Section 1 – Les enjeux de transparence et de connaissance de l’activité judiciaire⁸⁹

22. **Transparence des décisions de justice de l’ordre judiciaire⁹⁰.** Jusqu’à récemment, assez peu de décisions de justice étaient finalement accessibles au public, la publicité étant surtout l’apanage des décisions rendues par la Cour de cassation. Alors que chaque année les juridictions rendent jusqu’à trois millions de décisions, le site Légifrance n’en recense annuellement qu’environ quinze mille, dont l’immense majorité sont des arrêts de la Cour de cassation⁹¹. Le premier intérêt de l’*open data* des décisions de justice est donc de porter à la connaissance les décisions des juges du fond jusqu’alors méconnues.

Cette transparence des données doit évidemment se faire dans le respect de la législation protectrice des données à caractère personnel⁹². C’est la raison pour laquelle l’occultation des noms et prénoms des parties, ainsi que de tout élément susceptible de permettre leur identification, a été posée comme condition préalable à leur mise à disposition⁹³. Afin de satisfaire à cette exigence de « pseudonymisation », la Cour de cassation a candidaté au programme Entrepreneurs d’intérêt général avec le projet Logiciel d’anonymisation d’une base enrichie labellisée (LABEL), lequel a été sélectionnée par Etalab (département de la direction interministérielle du numérique qui coordonne notamment la conception et la mise en œuvre de

⁸⁹ Par Liza Veyre.

⁹⁰ Nous excluons de notre étude les décisions de l’ordre administratif mais la plupart des développements y sont, en tant que de raison, transposables.

⁹¹ L. Cadiet, C. Chainais et J.-M. Sommer (dir.), « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », rapport à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation, juin 2022, p. 44.

⁹² Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ; Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

⁹³ Art. L. 10 al. 3 du Code de justice administrative ; Art. L. 111-13 al. 2 du Code de l’organisation judiciaire.

la stratégie de l'État dans le domaine de la donnée). L'objectif de ce programme a été de développer un outil d'annotation ergonomique et *open source* pour accélérer la pseudonymisation des décisions de justice et leur mise en *open data*⁹⁴. Le 4 décembre 2020, un webinaire a permis à Madame Estelle Jond-Necand, alors directrice du projet Open data à la Cour de cassation, de présenter les travaux conduits dans ce cadre à Mesdames Agnès Delaborde et Aurore Hyde. Cette présentation nous a permis de déceler certaines faiblesses du processus de pseudonymisation comme, par exemple, l'absence de vérification de l'explicabilité de la partie automatisée, ou encore, la difficulté à faire retrouver des catégories de remplacement pour combler les vides laissés par les occurrences pseudonymisées.

23. Le développement d'outils offrant un traitement algorithmique des décisions en *open data* aux fins de tri et d'analyse. Devant la masse des décisions rendues accessibles par l'*open data*, les outils numériques apparaissent utiles pour en tirer le meilleur profit. Des outils d'analyse de la jurisprudence existent déjà ou sont en voie de développement, mais ils pourraient prendre une tout autre ampleur avec la connaissance de l'ensemble des décisions des juges du fond.

D'abord, des logiciels pourront assurer un tri, une analyse et une hiérarchisation des décisions. Ensuite, des outils plus « qualitatifs », pourront offrir « une analyse des arguments des parties et de la motivation des décisions, dans le but de mettre en relation des décisions de justice entre elles afin de retrouver, dans la masse des décisions, les arguments et motivations identiques, susceptibles de conduire aux mêmes décisions »⁹⁵. Certains auteurs estiment même que les outils de justice prévisionnelle ou de jurimétrie⁹⁶ pourraient servir à sécuriser ou à systématiser des standards juridiques – notamment en droit des contrats – pour leur donner un contenu plus homogène⁹⁷. Si l'idée est séduisante, elle interroge néanmoins. Le propre du standard juridique

⁹⁴ https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2020/04/07/open-data-defi-de-la-cour-retenue-par-etablab?date_du=&date_au=&thematique%5B0%5D=41&thematique%5B1%5D=41&items_per_page=10&sort_bef_combine=created_DESC

⁹⁵ Rapport sur la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, préc. p. 27.

⁹⁶ Les termes « jurimétrie » ou « justice simulative » ont été retenus, plutôt que justice « prédictive », par le Conseil national des barreaux pour désigner les « outils décomposant les règles de droit et les formulant en langage informatique afin d'établir un arbre de décision constitué de ramifications successives associées à une logique conditionnelle » (Préconisations d'actions pour les legaltechs du domaine de la jurimétrie, 2020 : <https://www.cnb.avocat.fr/fr/actualites/preconisations-dactions-pour-les-legaltechs-du-domaine-de-la-jurimetrie>). Il a également été retenu par le groupe de travail dirigé par Loïc Cadet, Cécile Chainais et Jean-Michel Sommer pour analyser l'incidence de l'*open data* des décisions de justice sur la jurisprudence (La Diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence – Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ?, 2022 : <https://www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/la-diffusion-des-donnees-decisionnelles-et-la>).

⁹⁷ Mekki M., « If code is law, then code is justice ? Droit et algorithmes », *Gazette du Palais*, 27 juin 2017, n° 297, p. 10 et s. ; Ponsot D., « Le contrôle de proportionnalité en matière de contrats : l'exemple de cautionnement », *in*

n'est-il pas justement de laisser volontairement une place importante, dans la règle de droit, pour l'interprétation, autrement dit, pour l'indétermination ?

24. **Offrir un état des lieux du contentieux.** En permettant d'accéder à la connaissance des décisions du fond, les outils de justice prévisionnelle, ou de « jurimétrie » offriront une meilleure connaissance de l'activité judiciaire dans son ensemble, c'est-à-dire un état des lieux de chaque contentieux. Cela pourrait favoriser l'harmonisation des solutions au fond, voire conduire les avocats à recourir davantage aux modes amiables de règlement des conflits et favoriser le désencombrement des juridictions.

De ce point de vue, les outils de jurimétrie pourraient participer d'une plus grande prévisibilité et d'une plus grande célérité de la justice, ce qui sert le droit au procès équitable.

Section 2 – Les enjeux pour le droit au procès équitable⁹⁸

25. **Ambivalence.** Le droit au procès équitable est une expression polymorphe. Cette expression désigne une kyrielle de réalités qui se précisent au gré des espèces et particulièrement de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Le droit au procès équitable se décline donc en une pluralité de garanties⁹⁹ appelées à jouer lors de ces procédures tant à l'égard du juge (exigence d'un « tribunal »¹⁰⁰ indépendant et impartial notamment) qu'à l'égard de l'instance (droit au juge, principe du contradictoire, égalité des armes, droit à la preuve, délai raisonnable de jugement, publicité des débats, etc.) ou encore du jugement (spécialement motivation et exécution). En matière de droit au procès équitable, les outils de justice prévisionnelle peuvent donc nous faire gagner beaucoup mais aussi perdre beaucoup ! En effet, l'apport pour certaines garanties est bien réel¹⁰¹, notamment pour la

Le juge judiciaire face au contrôle de proportionnalité, Agresti J.-P. (dir.), PUAM, Coll. Droits, pouvoirs & sociétés, 2018, p. 108 et s.

⁹⁸ Par Aurore Hyde, propos adaptés à partir de Hyde A., « Procès équitable et intelligence artificielle », in *Droits fondamentaux et intelligence artificielle*, dir. Barbe V., Koumli Ch. et Mauclore S., Éditions l'Épilogue, 2022, p. 115 et s.

⁹⁹ Vuitton X., *Le procès équitable. L'article 6-1 de la CEDH : état du droit et perspectives*, préf. Ch. Jamin, LGDJ, coll. Systèmes, 2019 ; Sudre F. et al., *Droit européen et international des droits de l'homme*, PUF, coll. Classiques, 2021, 15^e éd., n^{os} 378 et s.

¹⁰⁰ Même la notion de tribunal est autonome, la Cour EDH admettant notamment qu'une simple autorité puisse être qualifiée de tribunal dès lors qu'il lui revient de trancher toute question relative à sa compétence : CEDH, *Sramek c/ Autriche*, 22 octobre 1984, n^o 8790/79, § 36.

¹⁰¹ Par exemple dans les procédures de *discovery* connues de la *common law*, l'utilisation de l'IA assure l'effectivité du droit à la preuve en permettant à une partie de rechercher des éléments pertinents pour ses prétentions dans la masse des documents fournis par l'autre partie. Sur ces procédures : Homoki P., « Quelques usages de l'IA par les avocats », *Cahiers de droit de l'entreprise*, n^o 4, juillet 2019, dossier 2019. On pourrait encore imaginer que l'IA soit utilisée pour permettre l'auto-exécution de certaines décisions afin de favoriser le droit à l'exécution.

rapidité avec laquelle ces outils effectuent les tâches qui leurs sont assignées. Cependant, il existe presque toujours un pendant négatif pour d'autres garanties¹⁰². Les outils de justice prévisionnelle peuvent donc tout aussi bien servir le procès équitable que le desservir. C'est précisément sur l'ambivalence propre à ces outils qu'il convient d'insister en confrontant quelques garanties topiques du procès équitable.

26. **Prévisibilité versus évolution du droit.** En offrant un état des lieux du contentieux sur un problème donné, les outils de jurimétrie œuvrent incontestablement à une justice plus prévisible¹⁰³ et sont ainsi porteurs de plus de sécurité juridique.

Cependant, en poursuivant cet objectif de prévisibilité, ces outils risquent de figer l'état d'un contentieux¹⁰⁴ alors même que le droit à une jurisprudence constante n'existe pas¹⁰⁵. C'est même tout le contraire. En effet, l'évolution du droit vivant est nécessaire pour assurer l'adaptation de la règle de droit par essence pérenne. L'objectif de prévisibilité du droit trouve donc sa limite dans l'évolution indispensable du droit.

27. **Prévisibilité versus individualisation de la décision.** Surtout, les outils de justice prévisionnelle peuvent aboutir à trop uniformiser les contentieux¹⁰⁶. Or, cela va à l'encontre du principe d'individualisation de la décision de justice. Ce principe assure une application personnalisée de la règle de droit par nature générale et impersonnelle. Il est donc de l'essence même du droit au procès équitable que chaque affaire soit examinée pour ce qu'elle est, avec sa part d'originalité et de complexité, qui ne saurait être systématisée par un logiciel¹⁰⁷, aussi puissant soit-il. Même pour un contentieux très répétitif, l'expérience professionnelle et la sensibilité personnelle des juges sont essentielles car la justice traite avant tout des personnes

¹⁰² Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement, CEPEJ, 4 décembre 2018 : <https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b>.

¹⁰³ Girard B., « L'algorithmisation de la justice et les droits fondamentaux du justiciable », in *L'algorithmisation de la justice*, dir. J.-P. Clavier, Larcier, Coll. « Création Information Communication », 2020, p. 181 et s., spéc. p. 184.

¹⁰⁴ Markou C. & Deakin S., « Ex Machina Lex: The Limits of Legal Computability » disponible sur https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3407856.

¹⁰⁵ Solution constante depuis Cass. civ. 1re, 9 oct. 2001, n° 00-14.564, *Bull. civ.* 2001, I, n° 249 ; CEDH, *Unédic c. France*, 18 décembre 2008, n° 20153/04, § 71 : « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ».

¹⁰⁶ Cf. infra, n° 464.

¹⁰⁷ Sauvé J.-M., Intervention à l'occasion du colloque organisé pour le bicentenaire de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation le 12 février 2018, accessible sur le site du Conseil d'État : <http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-justice-predictive>.

et de leurs litiges¹⁰⁸. La variété d'appréciations possibles des cas est donc, tout autant que la prévisibilité, un gage du procès équitable.

28. **Prévisibilité *versus* indépendance du juge.** Par ailleurs, en proposant un état des lieux du contentieux sur une question donnée, les outils de justice prévisionnelle peuvent réduire la liberté d'appréciation des magistrats¹⁰⁹. En effet, ceux-ci pourront être tentés de se ranger à l'opinion dominante ou majoritaire de leurs pairs¹¹⁰ soit par conformisme, soit – pire encore ! – par crainte que leur originalité soit mal vue de leur hiérarchie et constitue un frein à l'évolution de leur carrière.

En outre, le résultat statistique, en apparence scientifique et objectif, a toutes les chances de convaincre le juge de sa véracité. En effet, la force persuasive des chiffres est très grande¹¹¹ et l'on ne doit pas négliger la propension humaine à privilégier les suggestions automatiques des systèmes de prise de décision¹¹², et ce même en présence d'informations contradictoires pertinentes¹¹³.

Les juges risquent donc de se plier au résultat sous l'effet d'un biais d'autorité (aussi connu comme biais d'automatisation). Or, nous verrons plus loin que les résultats ne sont pas totalement objectifs dès lors qu'ils reposent sur de nombreux choix de conception¹¹⁴.

Qu'il s'agisse de la crainte de représailles ou du biais d'autorité associé au résultat « scientifique », il y a bien dans les deux cas des pressions sur le juge de nature à orienter sa décision, ce qui ne satisfait pas à l'exigence d'indépendance du tribunal¹¹⁵.

29. **Célérité *versus* accès au juge.** Un autre argument en faveur des outils de justice prévisionnelle concerne l'accélération du traitement des dossiers, ce qui satisfait le droit d'être

¹⁰⁸ Avis n° (2011)14 du Conseil consultatif des juges européens, Justice et technologies de l'information, novembre 2011, <https://www.euromed-justice.eu/fr/system/files/CCJE-Avis-N-14-Justice-et-technologies-de-l-information.pdf>.

¹⁰⁹ May-Ferrié S., « Les algorithmes à l'épreuve du procès équitable », art. précité.

¹¹⁰ J.-M. Sauvé, *op. cit.*

¹¹¹ Tribe L. H., « Trial by Mathematics: Precision and Rituals in the Legal Process », 84 *Harvard Law Review*, 1329 (1971) & « The Continuing Debate over Mathematics in the Law of Evidence: A Further Critique of Mathematical Proof », 84 *Harvard Law Review* 1810 (1971) ; Schneps L. et Colmez C., *Les maths au tribunal. Quand les erreurs de calcul font les erreurs judiciaires*, Seuil, Science ouverte, 2015.

¹¹² Parasuraman R. & Riley V., « Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse », *Human Factors*, 1997, Vol. 39, n° 2 ; Méneceur Y., « DataJust face aux défis de l'intelligence artificielle », *La Semaine juridique Édition générale*, 2020, p. 1708 et s.

¹¹³ Qui n'a pas expérimenté de suivre aveuglément, de manière contre intuitive, les indications erronées d'un GPS, même sur un itinéraire déjà connu ?

¹¹⁴ Cf. infra, n° 185 et s.

¹¹⁵ Voir par ex. CEDH, *Tourancheau et July c/ France*, 24 nov. 2005, n° 53886/00, § 78, qui retient la violation de l'article 6§1 en raison d'un pouvoir de fait exercé sur l'indépendance des juges (en l'occurrence un article de presse susceptible d'exercer une influence décisive sur l'issue de la procédure).

jugé dans un délai raisonnable. Notamment, les outils de jurimétrie ont vocation à oeuvrer au désengorgement des tribunaux. Parce qu'ils offrent à un justiciable, via son conseil juridique, un aperçu de l'issue probable de son litige, ces outils peuvent inciter les plaideurs à sortir du circuit juridictionnel lorsque les chances de succès de l'affaire auront été estimées insuffisantes. L'intéressé pourra alors, plutôt que faire entendre sa cause en justice, se résigner à conclure un accord transactionnel en négociant directement avec l'autre partie sur la base des prévisions algorithmiques¹¹⁶. Il pourra également privilégier un mode amiable de règlement du type médiation ou conciliation.

Si le recours à la transaction ou aux modes amiables n'est pas en soit attentatoire au droit au procès équitable, c'est à la condition que la déjudiciarisation ne soit pas recherchée à tout prix. L'effet pervers de la quantification de l'aléa judiciaire est que les cas estimés « perdus d'avance » ou « trop marginaux » ne trouvent pas de défenseur et soient privés, de fait, d'accès à un juge. Or, s'il a toujours été du rôle de l'avocat d'apprécier les chances de succès d'un litige, il ne serait pas souhaitable que l'opportunité d'agir ne relève plus que d'un bilan coûts-avantages établi sur la base de données judiciaires préexistantes au litige.

Là encore, le biais d'autorité découlant du produit statistique risque d'inciter les avocats à ne pas rechercher plus avant dans les faits¹¹⁷ de l'affaire, ce qui, en l'occurrence, mérite de se battre en dépit de données chiffrées défavorables.

Faut-il rappeler que le droit n'aurait jamais pu évoluer si les « causes perdues d'avance » n'avaient pas trouvé preneur.

En outre, pour que le droit d'accès au juge soit préservé, il est indispensable que la renonciation au droit d'agir ne soit pas viciée. Or, les résultats fournis par ces outils sont fonction du paramétrage décidé par les concepteurs et l'on sait que, d'un outil à l'autre, les solutions peuvent varier. Il est donc possible pour une partie qui en a les moyens (par exemple un assureur, un employeur, etc.) de choisir, parmi les solutions proposées, celle qui lui est la plus favorable pour peser dans les négociations¹¹⁸. Dans ces conditions, le consentement à la base de la renonciation pourrait apparaître mal éclairé, entraînant la nullité de la transaction pour erreur.

¹¹⁶ Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », *La Semaine juridique Édition générale*, 2017. 31, n° 26.

¹¹⁷ Il a déjà été montré comment une mauvaise connaissance par les juristes de la théorie des probabilités pouvait conduire à de graves erreurs judiciaires : Schneps L. et Colmez C., *Les maths au tribunal*, Seuil, coll. « Science ouverte », 2015 ; Taroni F. et Mangin P., « L'interprétation de la preuve scientifique : les juristes, les scientifiques et les probabilités », *Médecine et droit*, 1998, n° 30, p. 6 et s.

¹¹⁸ Chollet D., « La justice prédictive et les principes fondamentaux du procès civil », in *La justice prédictive*, *Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 223 et s., spéc. p. 228.

30. **Le droit au procès équitable, siège d'un droit de contestation.** Parmi les garanties du droit au procès équitable, certaines viennent fonder le droit pour toute partie de comprendre le fonctionnement des outils de justice prévisionnelle et d'en contester le résultat. En effet, les principes du contradictoire, de l'égalité des armes, des droits de la défense ou encore de la motivation plaident en ce sens. La contestation pourrait passer par une comparaison des outils afin de confronter les résultats. Mais cette solution pose inévitablement le problème de l'imputation du coût dès lors que l'utilisation de ces outils est onéreuse et qu'il est peu probable qu'un juge puisse contraindre des éditeurs de solutions logicielles à mettre leurs outils à disposition gratuitement pour les besoins de la procédure.

La solution la plus opportune semble alors de pouvoir exiger une parfaite compréhensibilité du système ayant produit le résultat litigieux¹¹⁹ : sur les données utilisées (tant dans la phase d'entraînement qu'après), sur son mode de fonctionnement et ses critères, sur son taux d'erreur notamment et même sur les métriques d'évaluation utilisées pour calculer ce taux d'erreur.

Il s'agit là d'une condition *sine qua non* de l'effectivité du droit de critique du justiciable¹²⁰ et il ne devrait pas pouvoir lui être opposé le secret des affaires ni aucun droit de propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs dans ce sens qu'a légiféré l'État de l'Idaho à propos des outils utilisés par l'administration judiciaire américaine afin d'apprécier la dangerosité des personnes poursuivies, et notamment le risque de récidive, sur la base d'évaluations algorithmiques fondées sur divers facteurs et variables¹²¹.

Cette exigence de compréhensibilité existe de manière embryonnaire dans les relations entre l'administrations et ses usagers¹²², désormais dans le règlement sur l'intelligence artificielle¹²³, mais surtout, elle découle de l'obligation de motivation résultant de l'article 6§1. En effet, « la motivation est l'exposé du raisonnement sur lequel le juge fonde son opinion »¹²⁴ ; l'obligation de motivation des décisions de justice trouve donc sa justification dans la nécessaire compréhensibilité de la décision pour le justiciable, qui permet tant l'acceptabilité de la décision que sa critique.

¹¹⁹ C'est là une recommandation pour garantir un véritable accès à la justice.

¹²⁰ Le parallèle peut d'ailleurs être fait avec l'exigence de transparence dans la composition de la juridiction appelée à statuer ainsi que dans l'exigence de publicité de la procédure qui découlent toutes deux du droit au procès équitable : CEDH, *Vernes c. France*, 20 avril 2011, n° 30183/06, § 41 et s.

¹²¹ Code de l'Idaho, titre 19, chapitre 19, section 19-1910 (2019), qui exige notamment que tous les éléments utilisés pour construire le système soient « ouverts à l'inspection, à l'audit et à des tests publics » ; cité par G'sell F., *Justice numérique*, Dalloz, coll. « À savoir », 1^{er} éd., 2021, p. 105.

¹²² Articles L. 311-3-1 et s. et R. 311-3-1 et s. du Code des relations entre le public et l'administration, créés par la loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, n° 2016-1321.

¹²³ Cf. infra, n° 233.

¹²⁴ Vuitton X., *Le procès équitable. L'article 6-1 de la CEDH : état du droit et perspectives*, préf. Ch. Jamin, LGDJ, 2017.

En conséquence, le droit au procès équitable vient opportunément fonder un droit de compréhensibilité du résultat d'un outil de justice prévisionnelle tant pour rendre acceptable ce résultat que pour pouvoir le contester.

31. **Conclusion.** Les enjeux que portent en eux les outils de justice prévisionnelle sont suffisamment importants pour que la puissance publique réfléchisse à leur encadrement. Nous verrons qu'il existe aujourd'hui des dispositions applicables à la réutilisation des données de justice à des fins commerciales. Pour autant, le cadre mériterait d'être repensé notamment pour offrir un meilleur accompagnement aux fournisseurs d'outils. Dans cette optique, le ministère de la Justice, le Conseil d'État et la Cour de cassation ont animé, entre juin et octobre 2021, cinq ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice, ateliers auxquels Aurore Hyde a participé. Le rapport, rendu public en juillet 2022¹²⁵, montre que de nombreuses voies sont envisageables mais que l'étude de chacune d'elles n'en est encore qu'aux prémices. La recherche dans le domaine de la régulation des outils de justice prévisionnelle s'avère donc particulièrement utile.

Tel est également la conclusion à laquelle aboutit l'analyse économique des outils de justice prévisionnelle.

¹²⁵ Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice : <https://www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/rapport-du-cycle-dateliers-sur-lethique-de-la-1>.

Titre 2 – Réguler les outils de justice prévisionnelle pour garantir la qualité de la décision de justice : une analyse économique¹²⁶

32. Les outils de justice prévisionnelle (OJP) sont aujourd’hui utilisés par les professionnels du droit dans une mesure encore difficile à déterminer mais un nombre croissant d’entreprises proposent ce type d’outils sur le marché des services juridiques¹²⁷.

Les OJP suscitent pourtant de vives controverses, qui ne sont pas totalement inédites pour l’institution judiciaire et renvoient à des débats déjà anciens sur l’opportunité des outils et des modèles quantitatifs dans le domaine judiciaire. Pour leurs partisans, les OJP constituent une voie contemporaine de modernisation de la justice. Ils permettraient en effet d’accroître la qualité de la décision judiciaire, en facilitant l’accès des « producteurs » de justice (les juges) et des « consommateurs » (les justiciables) à l’information juridique et judiciaire, en améliorant l’égalité de traitement devant la loi et l’harmonisation des décisions de justice, grâce à une meilleure information des juges sur les décisions prises par leurs pairs dans des cas similaires, et en diminuant l’aléa judiciaire par une réduction des biais entachant les décisions des juges. Les OJP amélioreraient en outre l’efficacité (la production à moindre coût) de la production des décisions de justice, dans un contexte de contrainte budgétaire et de rareté des ressources (humaines, financières) de l’institution judiciaire. Ils réduiraient en particulier l’encombrement des tribunaux et les délais de jugement, en orientant certains justiciables et types de conflits vers les modes alternatifs de règlement des litiges (MARL). Au contraire, pour leurs opposants, les OJP engendrent des risques de robotisation et d’automatisation de l’activité de juger, qui seraient susceptibles de conduire à une déshumanisation du jugement, à une justice à plusieurs vitesses et, *in fine*, à une dégradation de la qualité de la décision judiciaire. Ces effets négatifs seraient tout particulièrement à redouter dans les contentieux de masse et peu complexes, s’accommodant d’un règlement sous la forme de décisions standardisées et d’une gestion statistique et automatisée des conflits (par exemple, les prestations compensatoires et les pensions alimentaires, pour lesquelles des barèmes sont déjà utilisés).

¹²⁶ Par Sophie Harnay.

¹²⁷ Pour des exemples d’OJP en Europe : <https://www.coe.int/fr/web/cepej/practical-examples-of-ai-implemented-in-other-countries>.

33. La diffusion et l'utilisation des OJP soulèvent deux questions importantes. Tout d'abord, quels sont les effets – positifs et négatifs, observés et attendus – du recours aux OJP par les juges sur la qualité de la décision judiciaire ? Ensuite, si ces effets sont avérés, quelle régulation peut-on concevoir pour tirer parti au mieux d'éventuels effets positifs des OJP et, inversement, en limiter les effets négatifs ? L'analyse développée ici adopte une approche principalement inspirée des travaux d'économie publique, d'économie du droit et d'économie de l'information. L'idée est que l'opacité des OJP – largement documentée dans la littérature de data science et de sciences sociales – est à l'origine d'asymétries informationnelles entre concepteurs des OJP et utilisateurs (principalement, les juges), qui peuvent conduire au développement d'OJP mal conçus et à des utilisations socialement inefficaces, nuisibles pour la qualité de la décision judiciaire. Nous montrons que cette situation justifie la mise en place de régulations informationnelles et informatives visant à fournir aux utilisateurs de l'information sur les caractéristiques intrinsèques, le fonctionnement, les avantages et inconvénients et les conséquences des OJP. L'objectif d'une telle régulation est double. D'une part, il s'agit d'éviter une utilisation inefficace – parce qu'insuffisamment informée – des OJP par les juges, qui conduirait à une faible qualité de la production judiciaire. D'autre part, il s'agit d'éviter la sous-utilisation ou la non-utilisation des OJP, dont l'utilisation serait pourtant à l'origine d'effets positifs sur la qualité judiciaire et qui découlerait d'un manque de confiance des utilisateurs dans les outils, privant ainsi la société de gains potentiellement associés aux OJP. On propose une relecture en ce sens de certaines régulations mises en place dans les années récentes et on suggère quelques pistes d'analyse complémentaires.

34. Ce faisant, notre but n'est pas de proposer une analyse exhaustive de la question de la régulation des OJP – cette ambition excède de loin l'objectif de la présente contribution, qui se limite à étudier la régulation nécessaire pour éviter des comportements inefficaces des utilisateurs résultant de leur faible degré d'information sur les OJP. De la même façon, on limite le propos à l'étude de l'utilisation des OJP par les magistrats et à ses effets sur la décision judiciaire. D'autres professionnels du droit les mobilisent mais les effets de ces utilisations ne sont pas étudiés ici.

35. Le premier chapitre étudie les effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire qui sont incertains. Il montre que ces effets peuvent être positifs ou négatifs, en fonction notamment des dimensions de la qualité judiciaire considérées et de paramètres variés (type d'OJP considéré, caractéristiques intrinsèques et fonctionnement de l'OJP, utilisations et usages par

les juges...). Aussi l'effet global du recours aux OJP sur la qualité de la décision judiciaire est-il en définitive incertain. D'une part, l'effet positif attendu en termes de réduction de l'aléa judiciaire associé à la décision humaine est potentiellement contrebalancé par les biais contenus dans certains OJP. D'autre part, les gains attendus en termes d'efficacité managériale accrue, qui pourraient découler du recours aux OJP, sont susceptibles d'être compensés par les coûts résultant de certains usages (Chapitre 1).

Face à ce bilan incertain, le second chapitre préconise une régulation des OJP axée sur l'information des utilisateurs. Compte tenu des effets ambigus des OJP sur la qualité de la décision judiciaire, une régulation visant à accroître l'information des utilisateurs, par une transparence accrue concernant les choix de conception et de modélisation et le fonctionnement des OJP, leurs usages et leur explicabilité, peut en effet favoriser les utilisations vertueuses des OJP et dissuader les utilisations qualitativement coûteuses. Pour autant, une telle régulation est souvent difficile à mettre en œuvre. À l'heure actuelle, elle prend le plus souvent la forme de principes généraux dont l'efficacité est discutable (Chapitre 2).

Chapitre 1 – Les effets des outils de justice prévisionnelle sur la qualité de la décision judiciaire : un bilan coûts-avantages incertain

36. Le choix de réguler ou non l'utilisation des OJP dans le cadre de la production de décisions judiciaires et le contenu d'une régulation éventuelle de ces OJP ont pour préalable une évaluation des effets de ces OJP sur la qualité de la justice. Ces effets, réels et attendus, sont-ils globalement positifs ou négatifs ? La réponse à cette question n'est pas tranchée, tant il est vrai que les tentatives d'évaluation se heurtent aux difficultés d'appréciation de la qualité de la production judiciaire traditionnellement soulignées dans le domaine de la justice (Section 1). En conservant ces difficultés méthodologiques et pratiques à l'esprit, on peut identifier deux niveaux principaux auxquels les OJP exercent – ou pourraient exercer – un effet sur la qualité de la décision judiciaire. D'une part, un premier effet attendu porte directement sur la qualité de la décision judiciaire, en ce que les OJP pourraient permettre une réduction de l'aléa judiciaire inévitablement associé au caractère humain de la décision du juge. Leur effet à cet égard est toutefois incertain, les OJP étant eux-mêmes porteurs de certains biais (Section 2). D'autre part, un second effet attendu des OJP concerne l'efficacité managériale ou gestionnaire de l'institution judiciaire. Dans un contexte de rareté des ressources budgétaires et humaines, les OJP pourraient en effet fournir un instrument utile au service de la qualité du service judiciaire, en substitut ou complément à des ressources budgétaires et humaines insuffisantes, même si leur effet global à cet égard est également ambivalent (Section 3).

Section 1 – Les difficultés de l'évaluation des effets des OJP sur la qualité de la justice : qu'évaluer ?

37. Lorsqu'il s'agit d'évaluer les effets des OJP sur la qualité de la justice, les difficultés sont multiples, d'ordre méthodologique et pratique, tenant tout à la fois à la diversité des OJP (§1), à la difficulté d'une définition univoque de la qualité de la justice (§2), à l'identification des parties prenantes à intégrer dans le processus d'évaluation de la qualité (§3), ainsi qu'à la complexité de mesurer pratiquement ces effets des OJP (§4).

A. La place des OJP dans les *legaltechs*

38. Une première difficulté tient tout d'abord à la diversité des OJP. De quoi parle-t-on exactement lorsqu'on utilise ce terme ? Selon le rapport Cadiet (2017, p. 14), la justice prédictive se définit comme l'« ensemble d'instruments développés grâce à l'analyse de grandes masses de données de justice qui proposent, notamment à partir d'un calcul de probabilités, de prévoir autant qu'il est possible l'issue d'un litige ». Ces instruments « consistent, notamment, par le développement d'algorithmes entraînés à partir d'une grande quantité de décisions de justice déjà rendues, à extraire les informations utiles au sein des décisions afin de proposer des probabilités d'issues d'un litige » (*Ibid.*, p. 24). En pratique, ces outils peuvent par exemple permettre d'identifier les éléments de fait ou de droit déterminants dans la décision du tribunal, d'estimer statistiquement les probabilités de gain d'un litige, ou encore de prévoir le montant des indemnités auxquelles des parties peuvent prétendre. Ils peuvent en outre reposer sur l'utilisation de technologies d'IA diverses, symbolique ou connexionniste¹²⁸.

39. Quoiqu'éclairante, cette définition n'est qu'imparfaitement opérante pour saisir toute la diversité des OJP et leur place au sein des *legaltechs*. Il ne serait en effet pas pertinent d'assimiler *legaltechs* dans leur ensemble et OJP – les seconds étant considérés dans ce qui suit comme un sous-ensemble des premières, au service de la dimension prédictive de la décision de justice. Il ne serait pas non plus pertinent de considérer que le sous-ensemble des OJP au sein des *legaltechs* est fixe et insusceptible d'évolutions. En effet, les OJP sont loin de constituer un tout homogène et stable. Au contraire, ils se caractérisent par leur diversité et leur caractère fortement évolutif. Ainsi, certains outils des *legaltechs*, quoique non explicitement développés

¹²⁸ L'IA symbolique (ou cognitive, ou déterministe) cherche à reproduire le raisonnement humain sur la base d'un ensemble de faits et de connaissances établis et de règles logiques prédéfinies par l'humain. Elle consiste à programmer un ensemble de règles (de type « si x, alors y, sinon z ») pour faire accomplir à la machine une tâche donnée. Son résultat est donc « prévisible » car procédant du traitement logique des données entrées dans le système. Elle est donc au fondement des *systèmes experts* (*knowledge based expert systems*). Les *systèmes experts*, définis comme des algorithmes *simulant le savoir-faire des spécialistes d'un domaine spécifique, sur la base des connaissances fournies par ces spécialistes, permettent* de résoudre des problèmes complexes dans des domaines spécifiques (par exemple, évaluer un niveau de risque crédit, un taux de récidive...). L'IA connexionniste est une branche de l'intelligence artificielle basée sur des réseaux de neurones artificiels. Inspirée par le fonctionnement du *cerveau humain*, elle utilise notamment le *deep learning* et est capable d'apprentissage autonome et d'adaptation sans dépendre de règles posées initialement. Les concepteurs du système peuvent donc ne pas connaître le modèle de fonctionnement de la machine. Son degré d'explicabilité est donc beaucoup plus faible que celui de l'IA symbolique.

pour servir un objectif de justice prédictive, peuvent être utilisés à cette fin, notamment lorsqu'ils sont combinés avec d'autres *legaltechs*. La place des OJP en tant que sous-ensemble des *legaltechs* est donc susceptible d'évoluer dans le temps et selon les usages.

Il est à cet égard utile de reprendre la distinction opérée par Calzoialo (2019) entre « technologies de soutien » (ou *supportive technology*), « technologie substitutive » (*replacement technology*) et « technologie perturbatrice » (*disruptive technology*). D'une part, certains outils des *legaltechs* se présentent en effet comme de simples « technologies de soutien » visant à réduire le coût de l'information pour les professionnels du droit et à accroître leur productivité. L'objectif affiché est alors de dégager du temps professionnel pour des activités à forte valeur ajoutée, et non de guider la production de la décision judiciaire ou du service juridique. Les outils d'aide documentaire et de gestion de l'information destinés à faciliter la recherche de textes, législations et jurisprudences appartiennent à cette catégorie, de même que les outils d'échanges sécurisés de documents, de stockage sécurisé des données et de digitalisation des processus métiers. S'y rattachent aussi, de façon plus récente, les outils fondés sur le développement de l'IA générative, non plus limités à la recherche de documents, mais incluant par exemple l'analyse de documents, l'assistance à la rédaction, la génération automatique de documents, la révision de contrats (permettant notamment d'identifier la présence de clauses à risque ou incohérentes), ou encore la mise en place de *chatbots* juridiques¹²⁹.

40. De par leurs fonctionnalités, ces outils ne constituent pas *stricto sensu* des OJP, dès lors qu'ils ne permettent pas directement la production de justice prévisionnelle. Ils peuvent néanmoins s'en rapprocher, notamment lorsqu'ils sont utilisés de façon groupée ou complémentaire avec d'autres *legal techs*, contribuant ce faisant à la production de services de justice prévisionnelle. Ils témoignent ainsi de la difficulté fréquente à tracer précisément la frontière entre OJP et autres outils technologiques proposés par les entreprises de la *legaltech*. D'autre part, d'autres outils affichent explicitement leur dimension prévisionnelle. Dans la typologie de Calzoialo (2019), ils s'apparentent à une « technologie substitutive » (*replacement technology*), en ce qu'ils visent à remplacer – au moins de façon partielle – « des activités inhérentes à l'administration de la justice ». Dans certains cas, ils peuvent également s'analyser

¹²⁹ Sur l'IA générative et les professions juridiques, voir not. *L'intelligence artificielle générative et les métiers du droit : agir plutôt que subir*, Rapport d'information du Sénat n° 216 (2024-2025), du 18 décembre 2024, pour lequel 88 personnalités ont été auditionnées, dont Aurore Hyde : https://www.senat.fr/rap/r24-216/r24-216_mono.html ; Méneceur Y., *IA générative et professionnels du droit. Comprendre et s'appropriier la langue des probables*, LexisNexis, coll. Numérique & Droit, 2024.

comme une « technologie perturbatrice » lorsqu'ils mobilisent des modèles de décision fondés sur l'IA pouvant être utilisés pour directement juger un cas.

41. Dans le cas français, la difficulté à établir clairement la frontière entre OJP et autres services des entreprises de la *legaltech* s'est longtemps doublée d'une réticence à afficher explicitement la dimension prédictive de leurs services de la part de certains acteurs privés développant des outils pouvant être utilisés à des fins de justice prévisionnelle – probablement en raison du caractère sensible de la question et des réticences de nombreux professionnels de justice vis-à-vis des OJP. La prudence et l'ambivalence des discours peuvent être illustrées à partir de l'exemple de Predictice (voir encadré 1 pour une présentation rapide de l'entreprise). Alors que Predictice a été pionnière en matière de développement des OJP, la dimension prédictive de ses services n'est pas clairement revendiquée. Sur son site¹³⁰, Predictice affiche ainsi la possibilité pour l'utilisateur d'« organise[r] toute l'information juridique », d'« optimiser [ses] recherches de jurisprudence » et de « trier les décisions en fonction de leur sens ». Elle propose également des services de recherche et d'analyse de jurisprudence et de veille juridique et d'actualisation régulière des décisions judiciaires et de l'information juridique. Dans un entretien, l'un de ses fondateurs, Louis Larret-Chahine, précise en outre explicitement qu'« [u]ne partie de [l']outil est un moteur de recherche nouvelle génération et l'autre permet d'extraire des statistiques, exportables sous la forme d'un rapport de risques »¹³¹. En dépit des utilisations prédictives qui peuvent en être faites, l'offre de services est néanmoins présentée comme un « simple outil statistique de quantification des risques d'un litige » (Lebreton-Derrien, 2018, p. 5) et la dimension prédictive du service n'est pas mise en avant. Au contraire, « Predictice [...] exploite commercialement les résultats des calculs en attribuant plutôt le "saut prédictif", non à l'outil, mais à son utilisateur » (*Ibid.*, p. 5)¹³².

¹³⁰ Consultation le 17/2/2024 : <https://predictice.com/>.

¹³¹ Parmi les prestations proposées, on trouve une analyse statistique des décisions de justice, le logiciel proposant notamment une estimation du taux de succès en fonction de la juridiction, un montant d'indemnité, le moyen légal anticipé comme étant le plus efficace, ou encore la durée moyenne de la procédure. Ainsi, selon Larret-Chahine, « [l']outil ne prédit pas l'avenir, mais se contente de donner des informations statistiques permettant de prendre une bonne décision » (*in* « Comment ça marche : la justice prédictive ? », *Argus de l'Assurance*, 23 juin 2021, n° 7694).

¹³² Remarquons que l'offre d'OJP de Predictice s'adresse aux avocats davantage qu'aux magistrats. En 2017, une expérimentation – peu concluante – du logiciel de la société Predictice a été menée au sein des cours d'appel de Douai et de Rennes. À l'époque, Xavier Ronsin, alors premier président de la cour d'appel de Rennes avait estimé que « [l]e logiciel n'apporte aucune plus-value par rapport à d'autres moteurs de recherche qui permettent déjà une analyse très satisfaisante de la jurisprudence des cours d'appel et de la Cour de cassation. On se situe plus dans un projet d'approche statistique et quantitative que qualitative. Parfois, les résultats peuvent même être aberrants ». Il ajoutait que « [l']algorithme ne sait pas lire toutes les subtilités de la motivation, surtout lorsque la décision est complexe » et qu'« [i]l ne faut pas perdre de vue qu'une décision de justice est une œuvre intellectuelle complète et souvent complexe ». Enfin, interrogé sur l'avenir de la justice prédictive, il considérait que l'« [o]n est encore

À l'inverse, d'autres acteurs affichent plus explicitement la dimension prédictive de leurs services. Ainsi, sur son site, Case Law Analytics revendique « [l']alliance de l'intelligence juridique et de l'intelligence artificielle au service des professionnels du droit » et d'« analyse[r] [l]e risque juridique grâce à l'IA ». Dans un entretien de 2021¹³³, Jacques Lévy Véhel, co-fondateur de Case Law Analytics, déclarait explicitement que « l'objectif est d'enseigner à notre outil la manière dont raisonne un magistrat afin qu'il puisse ensuite reproduire son processus de décision ». Dès lors, précisait-il en 2023, « [i]l ne s'agit pas de générer de simples statistiques, mais de reproduire le raisonnement des magistrats »¹³⁴.

Encadré 1 – Predictice et Case Law Analytics

Predictice est une *startup* française créée en 2016 par Louis Larret-Chahine, Thomas Baduel et Alexandre Cheronnet. Sur son site¹³⁵, elle indique compiler et organiser des décisions de justice afin d'offrir à ses clients (essentiellement des professionnels du droit) des services permettant d'« optimiser [les] recherches de jurisprudence » et de « trier les décisions en fonction de leur sens », ainsi que des services de recherche et d'analyse de jurisprudence et de veille juridique et d'actualisation régulière des décisions judiciaires et de l'information juridique. Au-delà d'un accès à la jurisprudence, elle offre également à ses utilisateurs des analyses dans différents domaines de droit, en fonction de critères variés. Selon l'un de ses fondateurs, Louis Larret-Chahine, « [u]ne partie de [l']outil est un moteur de recherche nouvelle génération et l'autre permet d'extraire des statistiques, exportables sous la forme d'un rapport de risques. L'outil ne prédit pas l'avenir, mais se contente de donner des informations statistiques permettant de prendre une bonne décision »¹³⁶. Ainsi, en fonction des diverses informations recueillies, un client peut par exemple prévoir la probabilité de l'issue d'une affaire dans le contexte d'un litige

loin du fantasme de la "justice bouton". Le résultat de cette expérimentation permet de dire que le rôle de conseil assuré par l'avocat est irremplaçable et celui du juge qui tranche un cas précis l'est tout autant. Autrement dit, il faut concevoir ces nouveaux produits comme une aide complémentaire à la prise de décision ». Dans un droit de réponse du 8 mars 2019, la société Predictice a répondu n'avoir « jamais construit un outil capable "d'anticiper le résultat d'un contentieux", mais seulement une nouvelle génération de moteur de recherche » et que la version testée était une version beta. <https://www.dalloz-actualite.fr/interview/l-utilisation-de-l-outil-predictice-decoit-cour-d-appel-de-rennes> (consultation le 17/2/2024).

¹³³ « Comment ça marche : la justice prédictive ? », *Argus de l'Assurance*, 23 juin 2021, n° 7694.

¹³⁴ « Case Law Analytics, l'IA qui simule les décisions de justice », 8 décembre 2023. <https://www.village-justice.com/articles/case-law-analytics-qui-simule-les-decisions-justice,48131.html> (consultation le 17/2/2024).

¹³⁵ Dernière consultation le 17/2/2024 : <https://predictice.com/>.

¹³⁶ « Comment ça marche : la justice prédictive ? », *Argus de l'Assurance*, 23 juin 2021, n° 7694.

donné. L'outil proposé est donc un outil d'information et de recherche juridique mais il permet, au-delà, de prévoir ce que pourrait être la décision de justice.

Case Law Analytics a été créée en 2017 par Jérôme Dupré, avocat et ancien juriste d'entreprise puis magistrat, et Jacques Lévy Véhel, mathématicien ex-chercheur à l'Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA). L'entreprise, rachetée en 2023 par LexisNexis, indique sur son site réaliser « [l']alliance de l'intelligence juridique et de l'intelligence artificielle au service des professionnels du droit » et d'« analyse[r] [l]e risque juridique grâce à l'IA ». Son objectif est ainsi de mettre « les mathématiques au service du droit ». La démarche est précisément explicitée : « Case Law Analytics crée des modèles mathématiques qui s'appuient sur l'intelligence artificielle et sur une expertise juridique fine afin d'analyser rapidement les risques associés à un dossier contentieux ou un contrat. En simulant les raisonnements juridiques déployés dans une situation donnée, les modèles de Case Law Analytics permettent de gagner du temps et de construire la meilleure stratégie contentieuse ou de négociation contractuelle. L'alliance des mathématiques et du droit offre ainsi une nouvelle manière de faire du droit qui vient enrichir la panoplie des juristes : via des “expériences numériques”, il devient possible de mesurer précisément l'influence de tel ou tel élément d'un dossier dans la décision du juge ou de savoir comment ajuster au mieux une clause dans un contrat ». Les différentes dimensions de l'analyse du dossier sont exposées en détail : il s'agit dans un premier temps de « simule[r] les issues possibles d'une procédure contentieuse », d'« évalue[r] la probabilité d'entrée en voie de condamnation » et de « calcule[r] les montants possibles de la condamnation » ; dans un deuxième temps, il s'agit d'« adopte[r] la meilleure stratégie pour [le] client » et de « mesure[r] l'impact des critères [du] dossier sur les décisions de justice et [d']opte[r] le cas échéant pour un mode amiable de règlement des différends (MARD) ; il s'agit enfin de « trouve[r] la jurisprudence la plus proche d[u] dossier »¹³⁷. Pour mesurer le risque judiciaire, « Case Law Analytics identifie d'abord, avec l'aide de juges et d'avocats, jusqu'à 100 critères clés influençant les décisions judiciaires, puis analyse la jurisprudence disponible à la lumière de ces critères [...]. La dernière étape du processus consiste à construire des formules mathématiques pour évaluer les différentes issues possibles d'une affaire, en tenant compte des critères identifiés. Cette approche permet de refléter l'aléa judiciaire, car un même dossier présenté deux fois devant la même juridiction peut connaître des issues différentes. L'outil couvre divers domaines du droit, tels que le droit de la famille, le droit commercial, et le droit public, permettant aux professionnels d'affiner

¹³⁷ <https://www.caselawanalytics.com/>, site consulté le 17/2/2024.

leurs stratégies en s'appuyant sur une compréhension plus poussée des probabilités et des tendances judiciaires »¹³⁸. En pratique, on peut donc considérer que Case Law Analytics propose des simulations de décisions judiciaires.

B. De nombreuses expériences d'utilisation des OJP par les professionnels de justice

42. Dans divers pays, l'utilisation des OJP par les tribunaux est déjà largement répandue. Aux États-Unis, les outils d'évaluation des risques (*risk-assessment tools*) sont utilisés dans plusieurs juridictions de façon régulière. L'exemple de COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*) de l'entreprise Northpointe Inc. (aujourd'hui, Equivant), utilisé pour prédire les taux de récidive des prévenus aux États-Unis et de non-comparution au procès, est désormais bien connu. L'IA est également utilisée à l'appui de la décision des juges états-uniens en matière pénale dans le cadre du projet PSA (*Public Safety Assessment*), qui utilise des outils prédictifs pour décider de l'opportunité d'une remise en liberté provisoire d'un prévenu en attente de son procès. L'actualité judiciaire récente fait par ailleurs état de nombreuses autres expériences d'utilisation des OJP dans plusieurs pays ou juridictions. Par exemple, au Canada, dans l'Ontario, un juge virtuel est en charge de trancher les conflits entre voisins et les conflits entre salarié et employeur. Au Québec, un logiciel est chargé de régler les petits contentieux commerciaux. Depuis 2019, en Estonie, le système « Estonian e-Justice » confie à un juge virtuel la fonction de jugement pour les dommages inférieurs à 7 000 euros – les parties insatisfaites de la décision conservant la possibilité de faire appel devant un juge humain¹³⁹. En 2022, des chercheurs chinois du parquet de Shanghai ont annoncé la mise au point d'une IA capable de remplacer un procureur dans sa fonction d'autorité de poursuite d'une personne visée par une plainte pénale¹⁴⁰. En janvier 2023, un juge colombien a produit une décision de justice en utilisant ChatGPT, précédant une expérience similaire d'un

¹³⁸ Cité dans « Case Law Analytics, l'IA qui simule les décisions de justice », 8 décembre 2023, <https://www.village-justice.com/articles/case-law-analytics-qui-simule-les-decisions-justice,48131.html> (consulté le 17/2/2024).

¹³⁹ Voir par exemple Me Constance Cuvillier, « Intelligence artificielle : le point de vue du juriste », 19 avril 2024, <https://journal-du-palais.fr/au-sommaire/informations-juridiques/intelligence-artificielle-le-point-de-vue-du-juriste> (site consulté le 3/7/2024).

¹⁴⁰ Selon les créateurs de cette IA, cette dernière serait capable non seulement de prendre la décision de poursuivre ou non un citoyen après une analyse intelligente du procès-verbal d'accusation, mais également de sélectionner la sanction à appliquer parmi les chefs d'accusation les plus fréquents. La fiabilité alléguée de l'IA est estimée à 97% après avoir été testée sur près de 17 000 dossiers entre 2015 et 2020, sur une base de plusieurs milliers de paramètres différents. Voir à ce sujet Rémi Slama, 2022, « La Chine annonce avoir développé une intelligence artificielle capable de remplacer les juges », Cyberjustice laboratory, <https://www.cyberjustice.ca/2022/02/01/la-chine-annonce-avoir-developpe-une-intelligence-artificielle-capable-de-remplacer-les-juges/> (consulté le 10/2/2024).

juge pakistanais la même année. Aux États-Unis, en 2023 également, un avocat a utilisé ChatGPT pour préparer l'un de ses dossiers¹⁴¹. ChatGPT a par ailleurs, en 2023, passé et réussi le concours d'avocat¹⁴².

43. De manière générale, le marché des OJP est de plus en plus massivement investi par diverses *legaltechs*, en France et à l'étranger. En France, outre Predictice et Case Law Analytics, déjà mentionnées, sont notamment présentes doctrine.fr, Hyperlex, ou encore Supra Legem.

En France, des outils ont également été développés à destination des tribunaux en lien avec leur activité de production de décisions judiciaires, dont l'expérience DataJust fournit un exemple (voir encadré 2). Cela a été dit, le développement de ces outils a été rendu possible par l'exploitation conjointe des technologies algorithmiques, du *machine learning* et le mouvement d'*open data* des données de justice impulsé par la loi pour une République numérique votée le 7 octobre 2016, mettant gratuitement à la disposition de tous, les décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, préalablement anonymisées.

L'objectif affiché est de fournir aux juges français des outils d'aide à la prise de décision, en les informant de l'ensemble des jugements rendus par les tribunaux français dans des affaires similaires. Le site vie-publique.fr veille cependant à préciser explicitement que le magistrat conserve une marge de discrétion dans l'usage qu'il fait de l'algorithme. Ainsi, « [c]oncrètement, soit le magistrat choisit lui-même des critères (mots-clés, textes, etc.) dans une base de données pour en extraire les affaires similaires à celle qu'il doit traiter, soit l'extraction est effectuée automatiquement par un logiciel et le juge retient ce qui l'intéresse. L'IA accélère la recherche d'informations mais c'est le juge seul qui prend la décision ». Pour autant, il est clairement indiqué que « [l]a prédiction de décision va plus loin. Elle propose au juge une décision de justice. Dans ce cas, un logiciel analyse de très nombreux exemples et en tire "automatiquement" des règles de décision. Autrement dit, pour le professeur Bruno Dondero, "c'est tenter de prédire avec le moins d'incertitude possible ce que sera la réponse de la juridiction X quand elle est confrontée au cas Y". Par exemple, un logiciel peut prévoir l'indemnité de licenciement qu'un salarié pourrait obtenir en se basant sur l'ensemble des

¹⁴¹ <https://www.radiofrance.fr/franceculture/podcasts/esprit-de-justice/l-impact-du-chatgpt-sur-la-justice-et-sur-nos-vies-3012762>.

¹⁴² Nicolas Bastuck, Laurence Neuer, 2023, « ChatGPT, dois-je vous appeler maître ? », *Le Point*, 19 avril 2023, Le Point.fr Tech & Net, n° 202304 (consulté le 11/2/2024).

jugements rendus aux prud'hommes. Même processus : soit le magistrat choisit lui-même les critères, soit l'algorithme associe à chaque cas une indemnité »¹⁴³.

Encadré 2 – l'expérience DataJust

En France, un décret du 27 mars 2020 a officiellement initié le développement de l'algorithme d'évaluation des préjudices corporels DataJust. Mis au point par deux *data scientists* de la direction des affaires civiles et du Sceau en 2019, cet algorithme extrait automatiquement les données contenues dans les décisions de justice et recense, par type de préjudice, les montants demandés et offerts par les parties à un litige, ainsi que les montants alloués aux victimes en indemnisation de leur préjudice corporel dans les décisions de justice rendues en appel par les juridictions administratives et les formations civiles des juridictions judiciaires. Sur la base de ce recensement, l'objectif est d'évaluer les montants alloués aux victimes de préjudices corporels afin de construire un référentiel d'indemnisation pour les victimes, les magistrats, les avocats, les assureurs et les fonds d'indemnisation. En 2022, le Conseil d'État a validé cet algorithme contre lequel plusieurs recours avaient été déposés, notamment par des associations et des avocats¹⁴⁴. La même année, le projet DataJust a cependant été abandonné, en raison notamment des nombreuses réticences des professionnels du droit à son encontre, de certains défauts de conception du projet et au motif de son impact attendu en termes de moindre flexibilité des juges dans leur production de décision¹⁴⁵.

¹⁴³ <https://www.vie-publique.fr/eclairage/277098-lintelligence-artificielle-ia-dans-les-decisions-de-justice> (consulté le 11/2/2024).

¹⁴⁴ Émile Marzolf, 2022, *Acteurs publics*, 3 janvier 2022, « Le Conseil d'État valide l'algorithme d'évaluation des préjudices corporels DataJust », <https://acteurspublics.fr/articles/le-conseil-detat-valide-lalgorithme-devaluation-des-prejudices-corporels-datajust> (consulté le 11/2/2024).

¹⁴⁵ Sur les raisons du renoncement à DataJust en lien avec la complexité de la construction des OJP, on peut se reporter à <https://acteurspublics.fr/articles/exclusif-le-ministere-de-la-justice-renonce-a-son-algorithme-datajust> (consultation le 3/7/2024). Selon Aurélie Coviaux, avocate au barreau de Paris, membre de l'ANADAVI (Association nationale des avocats de victimes de dommages corporels), interrogée par le site <https://www.actu-juridique.fr/civil/responsabilite-civile/datajust-plutot-que-de-faire-de-la-justice-predictive-il-faut-engager-une-demarche-dindexation-et-de-tri-des-decisions/> (22/01/2022 ; consultation le 3/7/2024), « le décret était mal conçu. D'abord parce qu'il comportait des erreurs. Par exemple, il citait parmi les éléments qui devaient être pris en compte les pertes de gains professionnels alors qu'on ne peut en tirer aucune conséquence car cela dépend du salaire des personnes. De même, il évoquait les prédispositions pathologiques, alors que la jurisprudence de la Cour de cassation interdit qu'on les prenne en compte. Le texte n'était pas clair quant à la distinction entre les jurisprudences civiles et administratives, on ne comprenait pas si elles allaient être fondues ou traitées séparément. Or, ce ne sont pas les mêmes droits, ni les mêmes montants alloués, pensait-on à deux algorithmes ou un seul ? Tous ces éléments donnaient le sentiment que les concepteurs du futur algorithme n'avaient pas pris l'entière mesure de la complexité du sujet. À cela s'ajoutait une difficulté majeure liée à la lecture des décisions : elles ne sont jamais standardisées et souvent très complexes à comprendre et analyser. Par exemple, il faut être un professionnel pour déterminer quelle décision est pertinente ou pas. Seul un spécialiste peut savoir si une demande correspond réellement au préjudice ou si la somme allouée est inférieure à ce qui aurait pu être prononcé simplement parce que la demande a été mal formulée et que le juge ne peut pas s'en émanciper ».

S2 – Quelle définition de la qualité de la justice ?

44. Une deuxième difficulté dans le processus d'évaluation des effets des OJP sur la qualité de la justice tient à la définition même de cette qualité. De longue date, des travaux nombreux ont établi le caractère multidimensionnel de la qualité de la justice et la difficulté à l'appréhender (Breen, 2002 ; Cappellina, 2017a). Les travaux ont également souligné le risque d'éventuels effets pervers résultant d'une évaluation se focalisant sur les dimensions les plus visibles ou mesurables de la qualité, au détriment d'autres aspects moins facilement évaluables (Bacache, 2002 ; Lambert-Abdelgawad, 2016). Un consensus existe aujourd'hui pour appréhender la qualité de la justice à travers une batterie d'indicateurs destinés à en capter les différentes facettes (voir par exemple Cappellina, 2017b sur les travaux de la CEPEJ ; 2022). Certains critères se dégagent plus particulièrement dans la littérature comme étant décisifs pour la qualité de la justice. Parmi les principaux, Colombet *et al.* (2013) relèvent les « éléments de contexte », incluant les ressources allouées au système judiciaire, la qualité de la législation et la qualité de la formation des acteurs du système judiciaire, la « qualité du processus juridictionnel » conduisant à la décision de justice, incluant l'accès au juge, des critères de qualité de la procédure et des « critères de qualité intrinsèque de la décision » (notamment la clarté et la motivation de la décision), ainsi qu'un critère de « délai raisonnable » de production de la décision.

45. Pour autant, en dépit de l'abondante littérature sur la question, les études et discours sur l'effet des OJP sur la qualité de la justice explicitent rarement les dimensions sur lesquelles ils pourraient porter en priorité. Les dimensions de la qualité de la justice que les OJP pourraient plus particulièrement affecter ne sont ainsi que rarement spécifiées et les voies par lesquelles le recours aux OJP pourrait affecter le niveau de qualité de la production judiciaire ne sont pas identifiées. Aucune réponse n'est donc donnée aux questions suivantes, pourtant essentielles : les OJP affectent-ils la qualité de la justice par le canal des « éléments de contexte », en allégeant le coût de production de la décision judiciaire dans certains contentieux et en permettant alors de réallouer des ressources budgétaires rares vers des utilisations alternatives plus productives ? Concernent-ils avant tout les « critères de qualité intrinsèque » de la décision ? Le cas échéant, quel est alors leur effet global ? Contribuent-ils à accroître la qualité, par une réduction de la variabilité des décisions judiciaires et de l'aléa judiciaire ou, au contraire, se traduisent-ils par une diminution de cette qualité, par la substitution qu'ils

opèreraient d'une motivation statistique à la motivation juridique des décisions ? Permettent-ils réellement d'accroître la célérité de la justice, en facilitant le recours aux modes alternatifs de règlement des différends (MARD) et au désengorgement des tribunaux, comme cela est souvent mis en avant, ou s'agit-il d'un argument (pour l'instant ?) essentiellement théorique dont les effets ne sont à ce jour pas statistiquement mesurés ? Enfin, quel effet les OJP ont-ils ou peuvent-ils avoir sur la satisfaction des justiciables et usagers du service public de la justice ?

46. Les travaux sur les OJP ne posent généralement pas ces questions. Dans ces conditions, il apparaît difficile d'apprécier leur effet sur la qualité de la justice et d'établir rigoureusement si cet effet est positif ou négatif. Il s'ensuit que certains discours sur les OJP peuvent parfois donner l'impression d'une analyse excessivement générale, voire généralisatrice, extrapolant à l'ensemble des OJP et aux différentes facettes de la qualité de la justice des résultats locaux, obtenus sur la base de quelques observations particulières et pour certaines dimensions très spécifiques – pas toujours explicitées – de la qualité. De la même façon, ils peuvent apparaître comme faisant dans certains cas appel à des critères d'évaluation *ad hoc* et fluctuants, ou à géométrie variable, retenus en fonction de l'objectif recherché – c'est-à-dire promouvoir ou critiquer le développement du recours aux OJP dans le système judiciaire. Dans ce contexte, il nous semble qu'une évaluation des effets des OJP sur la qualité de la justice requiert de clarifier *ex ante*, au stade de l'adoption des OJP, les objectifs attendus en termes de qualité de la justice.

§3 – La cible de l'évaluation

47. Une troisième difficulté de l'évaluation des effets des OJP sur la qualité de la justice tient à la définition des groupes et individus par rapport auxquels on souhaite évaluer ces effets. Ainsi, cherche-t-on à évaluer les effets sur les justiciables, les magistrats, les professionnels du droit dans leur ensemble, la société, ou encore les effets sur les finances publiques ?

Selon la réponse retenue, des questions subsidiaires se posent. Par exemple, dans l'hypothèse où les effets seraient évalués au regard de la population des justiciables, la définition de cette dernière reste à préciser. Ainsi, lorsqu'on évoque les justiciables, de qui parle-t-on, sachant que ce groupe se caractérise par sa forte hétérogénéité et que la demande individuelle de justice est singulière – au moins dans certains domaines de droit (Karpik, 2007) ? Or, les travaux sur les OJP reconnaissent rarement la diversité des besoins des justiciables. Bordère (2024, p. 132) remarque à cet égard que, « dans le cadre particulier de la numérisation de la justice [...] au

sein du discours doctrinal le convoquant, le *justiciable* apparaît homogénéisé autour d'une logique de *victime-sauvée* ou de *gagnant-perdant* selon l'orientation des écrits.

Quel que soit l'outil analysé et quelles que soient ses interactions avec ce justiciable, ce dernier se situe toujours sur une ligne de crête entre les bénéfices qu'il aurait à retirer de cette numérisation de la justice et les risques qu'elle ferait peser sur lui, qu'il en soit la cible principale ou seulement secondaire. *Le justiciable*, dans ce discours comme dans les autres, apparaît alors plus volontiers comme le support argumentatif nécessaire au développement de certains arguments qu'il n'apparaît comme un acteur direct de leur développement, de leur déploiement et de leur réussite (ou de leur échec) ». Dans la même ligne, on peut ajouter que les arguments de la fonction objectif des justiciables – traditionnellement définie en économie comme la représentation des objectifs que l'agent économique cherche à atteindre selon ses préférences – sont rarement discutés dans les travaux sur les OJP, mais sont le plus souvent postulés. Si les objectifs mis en avant (par exemple, la célérité de la justice...) sont certes le plus souvent réalistes, il n'en existe pas moins un risque d'imputer aux justiciables des préférences univoques qui ne sont pas nécessairement les leurs.

48. S'il s'agit plutôt d'étudier les effets des OJP non pas sur les justiciables mais sur l'activité de production des magistrats, les difficultés ne sont pas moindres. La principale est probablement d'appréhender les usages réels faits par les juges des OJP dans leur pratique professionnelle, sachant que ces usages sont encore mal connus et que leur connaissance requiert d'entrer dans la boîte noire de la décision judiciaire (Christin, 2017).

49. Enfin, si l'évaluation vise avant tout à apprécier les effets du recours aux OJP sur le bien-être de la société dans son ensemble, il convient d'explicitier les préférences de la puissance publique sous la forme d'une fonction de bien-être social. L'ampleur des travaux et des débats sur la construction des fonctions de bien-être social en économie publique et du choix social, dont on ne peut rendre compte ici, témoigne des difficultés méthodologiques et pratiques de l'entreprise, à laquelle les travaux sur les OJP ne se risquent à notre connaissance jamais. En particulier, construire une fonction de bien-être social permettant d'évaluer les effets des OJP sur la société nécessiterait un consensus sur les objectifs du système judiciaire (quels sont les objectifs imputés au système judiciaire et, plus particulièrement, aux juges ?) – ce consensus étant loin d'être acquis dans la littérature aujourd'hui¹⁴⁶. De même, notons dans ce cadre que si

¹⁴⁶ On peut ici renvoyer aux grandes controverses, depuis les années 1970, entre les auteurs du courant *Law and Economics* et de l'économie du droit – au premier rang desquels Richard A. Posner – pour lesquels le juge et le

le recours aux OJP est motivé par un objectif managérial de rationalisation de l'activité judiciaire et de recherche d'une efficience accrue de la dépense budgétaire consacrée à la production judiciaire, cet objectif de la puissance publique doit être explicité pour faire l'objet d'une évaluation.

§4 – La mesure quantitative et qualitative des effets

50. Enfin, un dernier type de difficulté tient à la mesure quantitative et qualitative des effets des OJP sur la qualité de la justice. La mesure de ces effets soulève plusieurs questions, en lien avec les points précédents. Par exemple, lorsqu'un juge utilise un algorithme de justice prédictive permettant d'évaluer le risque de récidive d'un prévenu, comment mesurer *en pratique*, quantitativement et qualitativement, le gain social associé en termes de qualité de la décision judiciaire résultant de sa meilleure information ? Ou encore, comment mesurer *en pratique* l'effet pour les justiciables de décisions plus équitables, sachant que l'un des avantages des OJP régulièrement mis en avant concerne l'harmonisation des peines entre juridictions et la réduction de l'aléa judiciaire ?

Peu d'études à notre connaissance traitent directement de cette question. Il en résulte des arguments d'autorité, non étayés empiriquement, en faveur ou en défaveur de l'utilisation des OJP, l'incertitude alimentant des propos parfois alarmistes, parfois optimistes – et souvent idéologiques – sur les effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire, selon l'identité des locuteurs.

51. En gardant à l'esprit les difficultés précitées, nous allons nous attacher à restituer et ordonner les éléments avancés dans la littérature quant aux effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire.

système judiciaire poursuivent (dans la version positive de l'analyse) ou doivent poursuivre (dans la version normative) un objectif d'efficacité économique et de maximisation du bien-être social, et les tenants d'une vision selon laquelle le système judiciaire doit intégrer notamment des dimensions d'équité ou de justice sociale (par exemple, les auteurs du courant des *Critical Legal Studies* ou, aujourd'hui, du courant *Law and Political Economy*).

Section 2 – Les effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire – réduire l'aléa judiciaire, expliquer et prévoir la décision du juge

52. Un avantage attendu des OJP, largement souligné dans la littérature, est de réduire l'aléa judiciaire, en corrigeant les biais humains affectant la décision des juges. Ces biais peuvent être décisionnels (§1) ou cognitifs (§2). Dans les deux cas, les OJP sont vus comme un moyen de repérer et corriger ces biais (§3). Pour autant, les OJP peuvent eux-mêmes être à l'origine de biais algorithmiques, rendant nécessaire d'évaluer les gains associés à leur utilisation en termes de redressement des biais humains relativement aux coûts induits en termes de biais algorithmiques (§4).

§1 – Repérer les biais décisionnels des juges

A. L'analyse empirique des déterminants de la décision judiciaire et biais décisionnels des juges

53. L'analyse économique du droit s'intéresse de longue date à la détermination des variables explicatives expliquant les comportements judiciaires à travers le prisme du modèle de rationalité économique optimisatrice (ex. : Posner, 1993). Dans ce contexte, le tournant empirique de l'économie du droit dans les années 2000 s'est traduit par la multiplication des travaux visant à analyser économétriquement les décisions judiciaires et à en identifier les principaux déterminants. La démarche des *empirical legal studies* est alors de comparer les jugements selon les caractéristiques des cas – renvoyant principalement aux caractéristiques des prévenus – et des juges. Sont, dans ce cadre, identifiés plusieurs biais décisionnels des juges, en lien avec un effet des préférences politiques des juges sur leurs décisions et l'existence de biais ethniques et de genre dans la production de décisions judiciaires. Les travaux sur le sujet sont nombreux et il est impossible de les restituer ici de façon exhaustive. On se limite donc dans ce qui suit à mentionner quelques résultats particulièrement saillants concernant les déterminants des décisions judiciaires et les biais décisionnels associés.

La littérature empirique d'économie du droit met tout d'abord en évidence un effet des préférences politiques des juges sur la décision judiciaire. Selon les modèles attitudinaux, les juges prennent leurs décisions en fonction de leurs préférences et valeurs idéologiques (Segal et Spaeth, 1993). Empiriquement, cette dimension partisane de la décision judiciaire est principalement attestée sur les cours de niveau supérieur, par exemple la Cour suprême états-unienne et les cours constitutionnelles européennes qui ont fait l'objet de travaux nombreux et

attentifs (ex. : Epstein et Knight, 1998 ; Fischman et Law, 2009 ; Garoupa *et al.*, 2013, 2022 ; Anwar *et al.*, 2019a).

54. Des travaux nombreux établissent par ailleurs l'effet sur la décision judiciaire de certaines caractéristiques des juges et/ou des parties qui n'ont *a priori* aucune raison d'influencer la décision. Par exemple, l'apparence physique des prévenus semble affecter dans une certaine mesure la décision du juge (Mocan et Teci, 2010). La littérature fait aussi le constat de différences genrées dans la production de jugements (ex. : Butcher, Park et Piehl, 2017). Ainsi, elle établit un impact du genre du juge sur la décision (Steffensmeier et Hebert, 1999 ; Schanzenbach, 2005 ; Johnson, 2014 ; Knepper, 2018). De la même façon, la composition genrée du jury semble exercer une influence sur sa décision. Anwar, Bayer et Hjalmarsson (2019b) trouvent à cet égard que, si l'intégration de femmes dans les jurys anglais en 1919 n'a pas entraîné d'effet sur les taux de condamnation globaux, elle s'est traduite par des condamnations supplémentaires pour les délits sexuels et les délits violents, et cela que les victimes soient des femmes ou des hommes. Sur données françaises, Philippe (2020) montre que la différence de traitement entre condamnés des deux genres diminue lorsque la proportion de femmes est forte au sein du tribunal. Bourreau-Dubois *et al.* (2020) montrent sur données françaises (plus de 2 000 décisions de cours d'appel) que la composition par sexe des collègues a un effet important sur les montants des pensions alimentaires pour enfants dans les procédures judiciaires de divorce ou de séparation. Selon Hoekstra et Street (2021), la décision judiciaire est également influencée par la similitude de genre entre le juge et le prévenu, conduisant notamment à des taux de condamnation significativement moindres dans les affaires de stupéfiants, mais pas dans les autres types d'affaires.

55. Un effet de la variable ethnique est également constaté. Les juges tendent en effet à infliger des sanctions plus longues aux prévenus racisés (Kennedy, 2001 ; Loury, 2008 ; Blumstein, 2015). Arnold, Dobbie et Hull (2020) suggèrent ainsi qu'environ deux tiers de la disparité entre Noirs et Blancs dans les taux de remise en liberté pourraient être imputés à une forme de discrimination ethnique. Si Schanzenbach (2005) trouve que la composition raciale et de genre du tribunal de district n'a pas d'impact perceptible sur les disparités raciales et de genre dans les condamnations, Anwar *et al.* (2012) établissent sur données américaines (État de Floride, données de 2000 à 2010) un effet de la composition ethnique et genrée du jury sur la décision du juge. Ils documentent également l'impact de la présence d'un juré noir dans le groupe de jurés sur les condamnations pour crime. Gazal-Ayal et Sulitzeanu-Kenan (2010)

constatent pour leur part l'existence de préjugés de groupe dans les décisions des juges arabes et juifs israéliens dans les affaires pénales. Sur les décisions des tribunaux pour mineurs en Louisiane, Depew, Eren et Mocan (2017) trouvent que des accusés mineurs assignés de manière aléatoire à des juges reçoivent une peine plus sévère si le juge est un homme ou une femme appartenant au même groupe ethnique.

La littérature met aussi en évidence la sensibilité de la décision judiciaire à des facteurs externes dont on pourrait s'attendre à ce qu'ils n'exercent pas d'effet sur elle, tels que la chaleur (Heyes et Saberian, 2019).

56. De manière générale, les OJP apparaissent donc capables de prévoir les décisions judiciaires, sur la base d'un ensemble de variables potentiellement très large. En utilisant un logiciel d'analyse sémantique leur permettant d'analyser le contenu des décisions, Aletras *et al.* (2016) développent ainsi la première étude systématique des décisions jugées par la Cour européenne des droits humains en se basant uniquement sur le contenu du texte. Ils formulent ainsi une tâche de classification binaire où le contenu textuel extrait d'une affaire constitue l'*input* (entrée) de leurs classificateurs tandis que l'*output* (production) cible est le jugement réel quant à la violation d'un article de la convention des droits humains. Ils réussissent ainsi à prévoir les décisions de la Cour avec une précision élevée (79% en moyenne). Un résultat crucial est que les faits formels d'une affaire sont le facteur prédictif le plus important de la décision.

B. Les OJP comme outils de détection des biais décisionnels et de prévision de la décision judiciaire

57. Dans les années récentes, le développement de la puissance de calcul informatique, la constitution et la mise à disposition de grandes bases de données juridiques – notamment en conséquence de l'*open data* des décisions de justice – et l'accès à des données microéconomiques sur les comportements judiciaires ont rendu possible l'analyse statistique à grande échelle des décisions judiciaires et l'identification de leurs principaux déterminants.

58. Le développement des OJP s'inscrit dans cette dynamique. D'une part, les OJP peuvent se concevoir comme des outils de détection systématique des biais décisionnels, permettant de repérer les caractéristiques des juges et/ou des affaires donnant lieu à des jugements biaisés. D'autre part, ils peuvent également s'interpréter comme une tentative de produire – ou reproduire – et « prévoir » la décision judiciaire à partir de ses principaux déterminants

préalablement identifiés par l'analyse massive d'un grand nombre de décisions et de leurs caractéristiques. Il s'agit alors moins de dupliquer le raisonnement juridique et judiciaire en tant que tel que d'extrapoler le résultat prévisible de l'espèce à partir d'un grand nombre de données et de décisions. Dans ce contexte, les OJP utilisant une IA symbolique s'analysent comme une forme de système-expert, visant à dupliquer le raisonnement judiciaire sur la base d'un ensemble de faits et de connaissances établis et de règles logiques prédéfinies par l'humain – notamment le raisonnement judiciaire par syllogismes. À un degré de complexité plus élevé, les OJP s'appuyant sur l'IA connexionniste visent pour leur part à produire les décisions judiciaires de façon autonome et sans dépendre de règles posées initialement par l'humain.

§2 – Repérer les biais cognitifs des juges

A. L'importance des biais cognitifs des juges

59. Au-delà de leurs biais décisionnels, les biais cognitifs des juges ont été tout particulièrement étudiés par l'économie du droit comportementale (ou *Behavioral Law and Economics*) durant les deux dernières décennies. Au-delà de quelques rares travaux théoriques (Bordalo *et al.*, 2015), les travaux, situés à la confluence de l'économie du droit et des sciences cognitives, adoptent une démarche principalement empirique, facilitée par le développement des méthodes expérimentales en sciences sociales. Leur apport est double. D'une part, ils dressent le constat de la variabilité importante des décisions judiciaires en pratique. D'autre part, alors que les différences de traitement judiciaire pour des cas similaires étaient traditionnellement expliquées en alléguant de différences – même ténues – dans les affaires considérées, ils remettent en cause cette explication et établissent que ces différences ne sont pas réductibles aux différences dans les affaires (Kling, 2006), mais s'expliquent au contraire notamment par des facteurs extra-judiciaires influençant la décision du juge, renvoyant en particulier à ses caractéristiques personnelles ou à celles des justiciables et au contexte de la prise de décision (lieu, jour, voire heure de l'audience).

60. Dans ce cadre, plusieurs biais cognitifs des juges sont identifiés. Guthrie *et al.* (2007) mettent ainsi en évidence l'utilisation par les juges d'heuristiques conduisant à des biais systématiques dans leurs décisions. Sur la base de plusieurs variantes d'un questionnaire rempli par 167 juges fédéraux (*federal magistrate judges*) réunis à la Nouvelle-Orléans en novembre 1999, ces auteurs détectent chez les juges des erreurs de logique et illusions cognitives

similaires à celles identifiées de manière générale par la littérature dans l'ensemble de la population. Comme les autres individus, les juges apparaissent à ce titre victimes d'un biais de sur-confiance (*overconfidence*) – 56% d'entre eux pensant en effet être dans le quart des juges les moins infirmés en appel, tandis que 88% pensent être dans la moitié supérieure. De la même manière, Guthrie *et al.* (2007) établissent l'existence d'un biais de rationalisation chez les juges, les conduisant à considérer les événements passés de manière biaisée, en leur associant une probabilité d'occurrence *a priori* élevée. Les juges s'avèrent également affectés par un biais d'ancrage (*anchoring*). Ils sont donc influencés par la première information reçue, qu'ils utilisent comme une « ancre » pour leurs choix futurs, même lorsqu'elle n'a aucune pertinence en l'espèce. Soumis à un questionnaire dans lequel il leur est demandé de choisir un montant de dommages plus ou moins élevé dans une affaire de responsabilité civile, les juges accordent ainsi, en moyenne, un montant plus élevé lorsque l'ancre qui leur est initialement proposée dans le questionnaire (sous la forme d'un montant demandé par l'avocat) est elle-même plus élevée. Qui plus est, les travaux montrent que l'ancre produit un effet sur la décision même lorsqu'elle n'a aucun rapport avec cette dernière. En matière pénale, les travaux de Englich *et al.* (2006) mettent ainsi en évidence l'effet d'une ancre sur les décisions de juges allemands appelés à se prononcer sur la durée de la peine encourue par une femme arrêtée pour vol à l'étalage. Dans l'expérience menée par les chercheurs, il est en effet demandé aux juges de jouer à un jeu de dés – pipés pour l'occasion – avant de se prononcer sur la peine. Ils doivent ensuite indiquer s'ils choisissent une peine de durée supérieure ou inférieure, en mois, au chiffre donné par les dés. Les résultats montrent que le premier groupe de juges, pour lequel le résultat du jet de dés a été truqué à 3, prononce une peine plus faible que le second groupe, dont le jet de dés a été truqué à 9¹⁴⁷.

61. Des travaux empiriques montrent par ailleurs que les décisions des juges sont interdépendantes, les juges se révélant sensibles aux caractéristiques des cas récents qu'ils ont eu à juger, alors que leurs décisions devraient être indépendantes (Chen, Moskowitz et Shue, 2016). Ils sont en outre sensibles à des chocs émotionnels et événements sans aucun lien avec le monde judiciaire, par exemple les résultats sportifs (Eren et Mocan, 2018). Ils sont également perméables à l'influence médiatique (Ouss *et al.*, 2018) et à l'influence des normes sociales.

¹⁴⁷ Dans le domaine marchand, les études contrôlées en laboratoire réalisées par Admonavicius *et al.* (2013) mettent en évidence un effet similaire de manipulation des préférences des consommateurs par les algorithmes de recommandation sur les sites de e-commerce, les recommandations des sites jouant un rôle significatif dans la construction des préférences des consommateurs.

Sur données françaises et états-uniennes, Chen et Philippe (2023) trouvent ainsi que les juges sont plus cléments le jour de l'anniversaire du prévenu, vraisemblablement sous l'effet de la norme sociale qui veut que l'on offre des cadeaux aux individus le jour de leur anniversaire.

62. On peut en outre remarquer que les biais cognitifs affectent indistinctement les différentes familles de droit. Pour les juges des pays de *common law*, leur existence est documentée par une littérature très riche, alimentée par l'importance de la tradition jurisprudentielle dans ces pays et la variété des données judiciaires disponibles. Dans les pays de droit civil, des biais judiciaires ont également été observés. Dans tous les cas, il est démontré que le juge n'est en aucun cas un « automate » ou la « bouche de la loi », mais qu'il est au contraire perméable aux influences extérieures, au-delà des considérations de droit et des mérites du cas.

B. Les OJP comme outils de détection des biais cognitifs

63. Comme pour les biais décisionnels, l'étude empirique sur une grande échelle des décisions judiciaires rend possible l'identification et la détection des biais cognitifs affectant la décision judiciaire. Dans ce contexte, et comme nous le verrons, les OJP peuvent sous certaines conditions (de conception, d'utilisation) se concevoir comme un instrument de redressement des biais judiciaires.

§3 – Les OJP comme outils de correction des biais humains : corriger l'aléa judiciaire grâce aux OJP

64. Certes, le constat de biais dans la décision judiciaire n'est pas nouveau. Face à l'aléa judiciaire, le système judiciaire a mis en place divers mécanismes destinés à en limiter l'ampleur et les conséquences négatives pour les justiciables et la qualité de la justice. La jurisprudence constitue une première solution, d'ordre juridique, garantissant, autant que possible, la cohérence des décisions judiciaires. La mise en place de barèmes et autres *guidelines* fournit une deuxième série d'instruments visant à limiter la variabilité de la décision judiciaire¹⁴⁸. D'autres dispositifs, incluant normes juridiques et professionnelles, tels que l'obligation de motiver précisément et clairement les décisions, les engagements déontologiques, ou encore l'obligation de révéler ses conflits d'intérêts, constituent un

¹⁴⁸ Pour la France, voir par exemple Sayn *et al.* (2012) et Bourreau-Dubois *et al.* (2021).

troisième instrument de limitation de l'aléa judiciaire. Enfin, des solutions organisationnelles ont aussi été mises en place, via par exemple le principe de collégialité de la décision visant à limiter l'ampleur de l'aléa judiciaire individuel. Des travaux récents révèlent en outre que les magistrats sont conscients du risque de biais dans leurs jugements (Przygodzki-Lionet *et al.*, 2024)¹⁴⁹ – cette prise de conscience constituant indéniablement un premier pas pour limiter l'occurrence et l'ampleur des biais.

65. Ces diverses solutions ne garantissent cependant pas l'absence de biais judiciaire. Dans ce cadre, les OJP ont été présentés comme un moyen de réduire l'aléa judiciaire « résiduel » et de redresser ou « débiaiser » la production de décisions judiciaires, en remédiant à la faillibilité et à l'erreur humaines inhérentes au jugement. Ils sont également présentés comme un outil au service de l'équité et de l'impartialité de la justice. L'argument¹⁵⁰, récurrent dans la littérature (ex. : Garapon et Lassègue, 2018 ; Miller, 2018 ; Guiraud, 2019), est celui de la neutralité alléguée des algorithmes sur lesquels reposent les OJP. Le principe des OJP est en effet de prédire y (par exemple, un comportement de récidive, un montant de sanction...) à partir d'un ensemble de données x (par exemple, des caractéristiques individuelles d'un prévenu), la capacité prédictive de l'algorithme étant obtenue par son entraînement sur un ensemble de couples (x,y) constitué des décisions judiciaires antérieures. De ce point de vue, la supériorité de l'algorithme prédictif par rapport à la décision humaine tient à sa cohérence : les mêmes *inputs* x introduits dans la fonction de production judiciaire étant censés mener au même *output* y ¹⁵¹, il s'ensuit logiquement une réduction attendue de la variabilité des décisions produites pour des cas similaires et la garantie d'un traitement équitable et impartial de l'ensemble des prévenus. Dans les termes de Barraud (2019, p. 16), « [l]es algorithmes sont supposés être impartiaux, incapables de déloyauté ou de complaisance. L'ordinateur est dénué de libre arbitre.

¹⁴⁹ En France, une étude a été menée sur cette question par une équipe de chercheuses et magistrates auprès des auditeurs de justice de l'ENM en 2020 et 2021 (Przygodzki-Lionet *et al.*, 2024). Dans ce cadre, un questionnaire est adressé aux auditeurs pour recueillir notamment leur définition d'un biais de jugement, leur expérience personnelle en la matière et les manières dont ils envisagent que de tels biais soient évités ou minimisés. Les résultats montrent que 99% des auditeurs de justice sont conscients des biais de jugement influençant les décisions. Parmi les facteurs susceptibles d'influencer les décisions, les auditeurs de justice mettent en avant principalement un effet possible des variables organisationnelles (par exemple, surcharge de travail), ainsi que les variables individuelles (apparence des parties ou des avocats, racisme, homophobie) et contextuelles (contexte sociétal, influence des médias notamment). L'effet des biais cognitifs et émotionnels est également évoqué dans l'étude. Pour autant, les trois quarts d'entre eux considèrent n'avoir jamais été confrontés eux-mêmes à des décisions professionnelles influencées par des biais de jugement.

¹⁵⁰ Les arguments mobilisés à cet égard rejoignent largement les arguments favorables à la barémisation de certains contentieux.

¹⁵¹ L'effet Rashōmon (fait qu'un événement puisse être interprété différemment selon les individus impliqués) vient toutefois questionner l'argument de la cohérence et de la stabilité des décisions algorithmiques.

Il déduit mécaniquement les "sorties" en fonction des "entrées" qui lui sont fournies. Revient alors l'idée de "juge automate". Autant l'algorithme que le syllogisme seraient comparables à des recettes de cuisine : en mélangeant différents ingrédients précisément identifiés d'une manière prédéfinie, tout cuisinier quel qu'il soit obtiendra le même plat – tout juge quel qu'il soit aboutira à la même solution ». Ainsi, selon Barraud (*Ibid.*, p. 17), « [s]ur le fond, il n'est pas impossible que les syllogismes correspondant le plus logiquement à la stricte application du droit positif aux faits soient ceux de l'intelligence artificielle. Ceux des magistrats humains sont souvent suspectés d'être influencés par des considérations autres et subjectives. En ce sens, Jean Carbonnier disait que 'le juge est un homme et non une machine à syllogismes : autant qu'avec sa connaissance des règles et sa logique, il juge avec son intuition et sa sensibilité' » (Carbonnier, 2004, p. 23, cité par Barraud, 2009, p. 17). En définitive, selon cette vision des OJP, l'utilisation de ces derniers doit conduire à une amélioration qualitative de la décision judiciaire, en termes d'impartialité accrue, de réduction de la subjectivité judiciaire et d'homogénéisation et d'harmonisation des décisions produites sur le fondement d'espèces similaires.

66. En outre, toujours au titre des gains attendus de l'utilisation des OJP par les juges dans leur processus de prise de décision, on peut attendre que la prévisibilité accrue des décisions de justice en découlant soit créatrice d'externalités positives pour les autres professionnels du droit et l'ensemble des justiciables. En effet, si la décision du juge est davantage prévisible, alors il devient possible pour l'avocat dans son rôle contentieux ou de conseil d'adapter au mieux le contenu du service qu'il propose à ses clients, et d'accroître ainsi la qualité du service qu'il délivre.

Il est cependant important de remarquer que cette conception de la décision judiciaire, interprétant les différences de décision entre juges comme la manifestation d'une qualité dégradée de la justice, va à l'encontre de la vision alternative, également répandue dans la littérature, valorisant positivement la capacité du juge à adapter la règle aux demandes et besoins particuliers des justiciables et à produire une justice « sur mesure ». Selon cette seconde vision, « [l]e bon juge ne serait ainsi guère celui qui applique méticuleusement la loi aux faits mais celui qui adapte cette loi aux circonstances particulières de chaque espèce et, plus généralement, à l'état actuel de la société, prenant en compte les données sociales, morales, historiques ou encore économiques et pondérant les intérêts en présence. C'est pourquoi le droit appliqué devrait, dans bien des cas, prendre ses distances par rapport au droit applicable. Les magistrats, au moment de juger, peuvent ou même doivent ouvrir la porte à l'éthique et autres

formes de droit non officiel. En témoigne l'exemple des "délits altruistes", ces infractions commises dans l'intérêt général et non afin d'en retirer un profit personnel, par des "lanceurs d'alerte" notamment. Si les faits constitutifs de l'infraction (par exemple violation du secret professionnel ou de secret industriel) sont sans aucun doute constitués, les juges se montrent fort cléments et condamnent les auteurs de ces faits à des peines relativement légères. Parfois, il est bon que la morale, forme de droit souple, tempère le droit dur. Or il est beaucoup plus délicat d'apprendre à des algorithmes le droit souple que le droit dur. Sous cet angle, la qualité de la justice diminuerait peut-être inexorablement dès lors que les décisions seraient rendues par une intelligence artificielle plutôt que par une intelligence humaine. Et d'aucuns estiment que les algorithmes ne pourraient augmenter l'efficacité du procès qu'à proportion de la diminution de sa qualité » (Barraud, 2019, p. 17). Dès lors, il convient de garder à l'esprit que les gains allégués de l'utilisation des OJP dans le processus de production judiciaire ne sont probablement pas généralisables pour tous les segments de demande judiciaire : on peut ainsi s'attendre à ce que les OJP soient porteurs de gains qualitatifs sur les segments correspondants à des services judiciaires relativement simples, normalisés et répétitifs ; en revanche, pour des services judiciaires plus complexes et singuliers (Karpik, 2007), ces gains pourraient dans certains cas être plus limités.

§4 – Biais humain versus biais algorithmique : Dr Human contre Mr Algo ?

67. L'optimisme vis-à-vis des OJP est cependant tempéré par un certain nombre de limites. Alors que les algorithmes sur lesquels reposent les OJP peuvent donner l'impression d'être neutres, impartiaux, équitables et objectifs en comparaison de la décision humaine, ils sont associés à différents types de biais, identifiables à l'étape de leur conception, de leur entraînement et de leur utilisation.

A. Le problème de la qualité intrinsèque des OJP : les OJP comme artefacts humains

1. Le choix des critères présidant à la conception des OJP – le choix des outcomes (résultats) et des variables

68. Les OJP fonctionnent sur la base d'algorithmes. Logiquement, les résultats fournis par les OJP sont donc tout d'abord sensibles aux choix ayant présidé à la conception des algorithmes qu'ils utilisent. Dès le stade de la conception des algorithmes de justice prévisionnelle, un certain nombre de choix essentiels sont en effet réalisés, dont les utilisateurs finaux – et parfois

les concepteurs eux-mêmes – ne sont pas nécessairement pleinement conscients. Ces choix concernent notamment le résultat de l'algorithme (son *outcome*, ou ce qu'on attend qu'il « prédise ») et les prédicteurs retenus (par exemple, un ensemble de variables prenant la forme d'une combinaison d'éléments, tels que des facteurs sociodémographiques ou la trajectoire délinquante antérieure des prévenus...).

69. Or ces choix de conception et de programmation restent avant tout ceux d'êtres humains, dotés d'une subjectivité humaine : derrière le caractère apparemment neutre et « automatique » des OJP se dissimulent donc un certain nombre de choix humains et subjectifs, reflétant les valeurs des concepteurs de l'algorithme (par exemple, quant aux objectifs qui doivent être poursuivis par l'algorithme), leur adhésion à des analyses et modèles comportementaux particuliers (notamment, en matière criminologique), qui sont intellectuellement et socialement situés dans le temps et l'espace, voire leurs croyances et préjugés.

70. L'exemple du logiciel COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), développé par l'entreprise Northpointe Inc. (aujourd'hui Equivant) et utilisé aux États-Unis pour prédire les taux de récidive et de non-comparution au procès des prévenus, est emblématique et bien connu à cet égard. En 2016, une étude du média ProPublica a en effet mis en évidence l'existence de biais ethniques affectant cet algorithme (Angwin *et al.*, 2016). Étudiant une population de 18 610 détenus évalués par COMPAS en 2013 et 2014, les auteurs de l'étude observent un taux de faux-positifs dans les taux de récidive prédits par l'algorithme (défini comme le pourcentage d'individus évalués à haut risque et n'ayant pas récidivé) deux fois plus élevé pour les détenus afro-américains par rapport à leurs homologues blancs, et un taux de faux négatifs (défini comme le pourcentage d'individus considérés comme présentant un faible risque mais ayant récidivé) significativement supérieur pour les Blancs par rapport aux Noirs. Ce résultat est expliqué par les choix conceptuels sur lesquels repose l'algorithme. En effet, alors même que ce dernier n'intègre pas directement la couleur de peau dans ses critères, il utilise une batterie de questions et de variables dont certaines sont fortement corrélées avec l'appartenance à un groupe ethnique. Ces variables incluent notamment le casier judiciaire, le type de délit, les antécédents de consommation de drogue, ou encore le quartier de résidence et les fréquentations amicales. Le choix de ces questions et variables spécifiques fait donc de l'algorithme un artefact humain, dont l'apparente neutralité peut à ce titre être mise en question dès lors qu'il reflète les choix de ses concepteurs. En effet, dans les termes de O'Neil (2016, p. 16), « les modèles, en dépit de leur réputation d'impartialité, reflètent des objectifs et

une idéologie » et « les modèles sont des opinions intégrées dans des mathématiques » (O’Neil, 2016, p. 21). Rien ne garantit donc que les choix initiaux opérés par les concepteurs de l’algorithme ne conduisent pas à des résultats discriminatoires.

71. De même, rien ne garantit que ces choix soient compatibles avec les objectifs des juges humains ou les objectifs du système judiciaire, tels qu’ils sont déterminés et construits socialement. Rien ne garantit enfin que ces choix ne soient pas contradictoires avec des principes juridiques fondamentaux. À cet égard, Rudin *et al.* (2020, p. 5) montrent dans le cas du logiciel COMPAS combien ce dernier, qui s’appuie sur le « fruit d’années d’études sociologiques théoriques et empiriques minutieuses », est le reflet d’un modèle de comportement humain bien spécifique, déterminant implicitement sa modélisation¹⁵².

72. Un certain nombre de biais sont ainsi la conséquence des choix des concepteurs de l’algorithme (Ludwig *et al.*, 2021). Tout d’abord, un premier biais résulte de ce que la variable-objectif indiquée à l’algorithme ne reflète le plus souvent que de façon incomplète la variété des objectifs poursuivis en pratique par le juge dans son activité de production judiciaire (Kleinberg *et al.*, 2018). Ce problème, qualifié d’*omitted payoff bias* dans la littérature, conduit l’algorithme à se focaliser sur une dimension unique – ou sur un ensemble limitatif d’objectifs – de l’activité judiciaire. Contrairement à un juge humain capable – ou, pour le moins, soucieux – de prendre en compte les conséquences de sa décision dans ses différentes dimensions, l’algorithme se limite aux dimensions qui lui ont été explicitement indiquées au stade de sa conception et programmation. Cette focalisation sur un ensemble réduit d’objectifs peut donc l’amener à une décision biaisée par rapport à ce que serait, sur la même espèce, la décision d’un juge humain. Or, à l’exception de quelques cas simples et normalisés, la décision judiciaire est rarement réductible au seul *outcome* considéré par l’algorithme. Elle poursuit au contraire une combinaison d’objectifs variés, ordonnés et potentiellement contradictoires – intégrant par exemple la recherche de l’équité, l’aversion aux inégalités, la satisfaction de différents critères de justice sociale¹⁵³ ou encore l’efficacité économique – qu’il s’agit donc d’articuler selon une

¹⁵² Déconstruisant l’outil (propriétaire), Rudin *et al.* (2020) montrent comment le fonctionnement réel de COMPAS est tributaire du choix des critères retenus par les concepteurs du logiciel pour « faire produire » à ce dernier une évaluation du risque de récidive. Pour COMPAS, les variables requises incluent notamment le casier judiciaire, le type de délit, ou encore les antécédents de consommation de drogue. Le choix des variables retenues par les concepteurs de l’algorithme renvoie à des modèles comportementaux spécifiques, notamment à une théorie de l’apprentissage social mettant en avant des critères liés à la proximité avec des pairs antisociaux, ou encore aux théories des activités routinières et de la sous-culture.

¹⁵³ Une très riche littérature d’économie du droit, qu’on ne présente pas ici, étudie les préférences judiciaires.

hiérarchie qui peut varier. Dès lors, l'utilisation d'un algorithme programmé pour poursuivre un objectif exclusif, au détriment d'autres objectifs pourtant pris en compte par le juge humain, induit le risque d'un écart entre les objectifs – et la « décision » ou prédiction – de l'algorithme et ceux des décideurs humains. Cet écart ne peut cependant pas être interprété comme une « mauvaise » décision du juge – le juge prend en effet « sa bonne décision » en tenant compte d'un ensemble d'objectifs plus large que l'OJP. Il ne peut pas plus être entendu comme le signe de la faible performance prédictive de l'algorithme – car cette performance peut être tout à fait satisfaisante compte tenu de ce que les concepteurs de l'algorithme lui ont imputé comme objectif.

73. Une deuxième source de biais algorithmiques résulte du choix des *inputs* intégrés dans la fonction de production algorithmique par les concepteurs de l'algorithme. Il est en effet possible que l'algorithme ne prenne en compte qu'un ensemble incomplet de variables, créant ainsi un problème de variables omises. Par exemple, alors que la décision du juge humain de condamner ou non un prévenu intègre différentes variables propres à l'affaire (les faits et moyens particuliers de l'affaire, certaines circonstances particulières, la manifestation ou non d'un sentiment de remords par le prévenu, certaines singularités de l'espèce...), les algorithmes ne prennent en compte que certaines variables, notamment la récidive, à l'exclusion d'autres variables qui peuvent pourtant jouer un rôle déterminant dans la décision du juge (Cassuto, 2017). Ainsi, même programmé pour raisonner « toutes choses égales par ailleurs », l'algorithme ne peut prendre en compte que les variables qui lui sont fournies par ses concepteurs – et qui reflètent, on l'a dit, la vision du monde de ces concepteurs et les hypothèses des modèles comportementaux à partir desquels les algorithmes sont élaborés. En conséquence, l'OJP ne peut fournir au juge qu'une prédiction limitée à un sous-ensemble des variables pertinentes pour sa décision. La prédiction de l'OJP risque de ce fait de n'être que faiblement utile au juge, voire de fausser le contenu de sa décision effective si la décision humaine duplique la prédiction algorithmique.

74. À ce problème de variables omises s'ajoute le fait que les variables démographiques et socioéconomiques sélectionnées par les concepteurs des algorithmes peuvent cibler des groupes ou populations spécifiques. Or, selon certains auteurs (ex. : Starr, 2014, p. 821 et s. ; Cadiet, 2022, p. 95-96), ce choix s'apparente en pratique à une discrimination, prenant la forme de généralisations statistiques à certains groupes, alors même qu'une telle discrimination peut être

par ailleurs illégale ou inconstitutionnelle – et cela « même si ces généralisations reçoivent un soutien empirique » (Starr, 2014, p. 821).

75. Enfin, de nombreux algorithmes de justice prédictive impliquent des choix normatifs de la part de leurs concepteurs en matière de critères d’acceptabilité du risque, concernant notamment la fixation des seuils de risque à partir desquels un *outcome* doit être recommandé de préférence à un autre par l’algorithme (par exemple, dans les choix de mise en liberté *versus* maintien en détention d’un prévenu). Il est important de souligner ici, à nouveau, que ces choix comportent une dimension subjective et politique qui nécessiterait qu’ils ne soient pas opérés par les concepteurs des OJP seuls, mais en concertation avec leurs utilisateurs, les pouvoirs publics ou des représentants de la société.

2. Le choix des critères présidant à la conception des OJP – le choix des architectures de choix des utilisateurs

76. Par ailleurs, les concepteurs des algorithmes de justice prédictive opèrent des choix non neutres quant à l’architecture des choix des utilisateurs. Une architecture de choix se définit comme une façon de présenter les choix, les architectures possibles pour une même décision étant évidemment multiples. Or les travaux d’économie comportementale ont établi que des architectures de choix différentes peuvent induire des choix différents de la part des individus. En particulier, l’ordre dans lequel les différentes options sont présentées aux utilisateurs, leur formulation, le contexte des autres choix parmi lesquels elles sont présentées, influencent les choix des utilisateurs. Actant cette capacité des architectures de choix à orienter les décisions individuelles, la théorie des *nudges* se donne comme objectif d’aider les individus à prendre de meilleures décisions, en leur proposant les architectures de choix adaptées (Thaler et Sunstein, 2008).

77. Les juges sont évidemment sensibles aux architectures de choix. Dès lors, la sélection par les concepteurs des algorithmes d’OJP d’une architecture de choix particulière proposée aux utilisateurs n’est pas neutre. Selon Christin, dans un entretien réalisé par Bidou *et al.* (2022, p. 14), la présentation des informations par le logiciel COMPAS ne serait ainsi pas neutre sur les décisions judiciaires, mais il y aurait « un effet des tableaux de bord sur leur [des juges] perception des données et les couleurs rouges provoquent des réactions négatives beaucoup plus fortes que des couleurs bleues, vertes, plus neutres ». Or les choix d’architecture sont

effectués par les concepteurs des algorithmes parfois sans discussion préalable suffisante avec les utilisateurs, leurs représentants ou les pouvoirs publics – alors même qu’il s’agit aussi des choix juridiques et politiques et que les concepteurs des algorithmes « doivent arbitrer l’implémentation des valeurs des règles juridiques et de leur bonne interprétation par et pour l’algorithme alors qu’eux-mêmes, bien souvent, n’ont pas été formés au domaine juridique (Peri, 2017) » (cité par Guiraud, 2019, p. 5). Certes, ainsi que souligné par Thaler et Sunstein (2008, p. 372), « de même qu’il n’y a pas de bâtiment sans architecture, il n’y a pas de choix sans contexte », mais cette architecture doit être construite de façon consciente de sorte à intégrer ses possibles effets sur les décisions individuelles des juges.

78. Notons enfin que les divers biais conceptuels dans les algorithmes utilisés par les OJP ne relèvent pas nécessairement de la manipulation volontaire et consciente de la part des concepteurs, mais reflètent avant tout leur vision – pas toujours explicitée ou consciente – des comportements humains et de ce qui est souhaitable pour le bon fonctionnement de la société. En tout état de cause, il n’en demeure pas moins que, si l’idéal d’un algorithme parfaitement neutre s’avère probablement illusoire, les choix opérés à l’étape de la conception de l’algorithme requièrent *a minima* une explicitation de la part des concepteurs – voire une co-construction avec les utilisateurs et/ou des représentants de la société.

3. Biais et données

79. Le choix des données alimentant les algorithmes sur lesquels reposent les OJP fait également question. Une critique récurrente porte à cet égard sur le caractère incomplet et biaisé des données d’entraînement des OJP, pouvant entraîner une performance insatisfaisante de ces derniers.

80. Tout d’abord, dans le prolongement des critiques précédentes sur l’incapacité de l’algorithme à restituer les différentes dimensions de la fonction objectif judiciaire, une première critique porte sur la sélection, l’organisation et l’encodage des données. Pour être utilisées par l’algorithme, les données doivent en effet être exploitables et saisies dans une base de données informatique. Or cette opération n’est pas neutre, mais implique au contraire des choix d’encodage de l’information, requérant le choix de mots-clés. Les choix opérés par les créateurs des algorithmes ne sont donc pas neutres à cet égard.

81. Ensuite, les données sont incomplètes, ne reflétant qu'imparfaitement les objectifs des juges et la variété des informations sur la base desquelles ils produisent leurs décisions. Dans de nombreux cas, en effet, les juges possèdent une information plus fine que l'algorithme et prennent donc leurs décisions en intégrant des variables non observées par l'algorithme. Dès lors, des affaires que l'algorithme considère comme comparables ne le sont pas du point de vue du juge.

82. En outre, les résultats de l'algorithme peuvent être biaisés en raison d'un ensemble de données d'entraînement insuffisamment large et représentatif, induisant par suite un possible problème d'équité et d'impartialité. Face à ce problème, la recommandation classique est d'entraîner l'algorithme sur un ensemble de données suffisamment large, varié et représentatif. Pour autant, cette solution n'exclut pas tout risque de biais. D'une part, il peut exister des erreurs dans l'annotation des données d'entraînement (notamment manuelle) des données (Girard-Chanudet, 2023). D'autre part, des biais initiaux peuvent caractériser les données d'entraînement, qui seront donc reproduits dans l'algorithme. Plusieurs études ont ainsi montré que des outils d'évaluation des risques (*risk assessment*) utilisés aux États-Unis tendent à renforcer les inégalités sociales et ethniques (ex. : Harcourt, 2006). L'algorithme fonctionne en effet sur le principe de la mise en relation d'une quantité importante de données avec le profil d'un individu donné. Dès lors qu'historiquement, certains groupes (sociaux, ethniques) ont été discriminés par le système judiciaire, l'utilisation des données du passé pour prédire des comportements présents ou futurs, conduit à reproduire les erreurs et biais sociaux antérieurs, reflets du racisme et de la discrimination systémique d'une société. Si les données initiales sont biaisées, la prédiction de l'algorithme l'est donc également : si certains groupes ont été discriminés dans le passé, l'algorithme reproduira la discrimination dans ses prédictions.

83. Ce problème des *dirty data*, définies comme des données imprécises ou systématiquement biaisées, est loin d'être marginal. La polémique autour du logiciel COMPAS aux États-Unis à partir de 2016 illustre ce phénomène de « dépendance au sentier » des prédictions par rapport aux données d'entraînement (Angwin *et al.*, 2016). Richardson *et al.* (2019) étudient à cet égard 13 juridictions sélectionnées pour avoir dans le passé mis en œuvre des pratiques policières illégales et biaisées, mais avoir néanmoins entraîné leur système de police prédictive sur la base de ces *dirty data*. Ils concluent que le déploiement de systèmes de police prédictive dans des juridictions présentant des antécédents de pratiques policières illégales est associé à un risque élevé que des *dirty data* conduisent à des prédictions erronées ou illégales, engendrant de ce

fait des boucles de rétroaction perpétuant des situations non souhaitables. Reprenant les travaux de Richardson *et al.* (2019), Hao (2019) documente pour sa part le cas spécifique de l'utilisation consciente de données erronées par la police de la Nouvelle-Orléans pour entraîner ses algorithmes d'IA de prédiction du crime – alors même qu'une enquête du Department of Justice avait souligné la piètre qualité des données et les biais systématiques les entachant¹⁵⁴.

84. Dans ces conditions, il est certes envisageable de redresser des jeux de données biaisées. Cette option implique cependant d'être capable de définir ce qu'est la neutralité algorithmique – ce qui est évidemment loin d'être aisé. De plus, le redressement de données biaisées comporte également le risque d'introduire de nouveaux biais dans les données. Il amène en outre à poser des questions pour lesquelles ni les économistes, ni les philosophes, ni les juristes n'ont de réponse simple ou univoque. Par exemple, les biais doivent-ils toujours être combattus ? Peut-il exister des biais acceptables ou souhaitables ? Enfin, il pose des problèmes éthiques : a-t-on par exemple le droit d'exclure certaines données ? Dès lors que les biais dans les données initiales reflètent un biais social systémique, Richardson *et al.* (2019) préconisent de s'attaquer en premier lieu au traitement de ce problème systémique plutôt qu'à celui du redressement des données.

4. Biais humains contre biais algorithmiques : suivre ou ne pas suivre les recommandations de l'OJP ?

85. En présence de biais humains et algorithmiques, la question se pose de savoir s'il est toujours souhaitable que la décision humaine « suive » l'algorithme. Entre biais humain et biais algorithmique, l'issue du match est en effet incertaine et il pourrait donc ne pas être toujours socialement bénéfique que les humains « suivent » l'algorithme. Sur ce point, le débat n'apparaît pas clairement tranché aujourd'hui.

86. Tout d'abord, seul un petit nombre de travaux explorent à ce jour la question de la performance relative de l'humain contre la machine dans le domaine de la justice¹⁵⁵. Dans l'une

¹⁵⁴ Hao (2019) reprend ainsi les termes de Richardson dans un entretien pour la *MIT Technology Review* : « Your system is only as good as the data that you use to train it on. If the data itself is incorrect, it will cause more police resources to be focused on the same over-surveilled and often racially targeted communities. So what you've done is actually a type of tech-washing where people who use these systems assume that they are somehow more neutral or objective, but in actual fact they have ingrained a form of unconstitutionality or illegality ». Voir <https://www.technologyreview.com/2019/02/13/137444/predictive-policing-algorithms-ai-crime-dirty-data/> (consulté le 27 avril 2024).

¹⁵⁵ Hors du domaine judiciaire, on peut par exemple citer Yeomans *et al.* (2019).

des rares études consacrées à ce sujet, Kleinberg *et al.* (2018) concluent, sur données états-uniennes, à la supériorité de l'algorithme sur les décisions de justice humaines. Leurs résultats ne sont évidemment pas généralisables sans précaution, puisqu'inscrits dans un contexte juridique particulier (contentieux spécifiques, aux États-Unis).

87. Ensuite, répondre à cette question rend nécessaire de considérer l'arbitrage entre la quantité et la qualité des données dont disposent respectivement OJP et humains (Ludwig *et al.*, 2021, p. 28). Les premiers présentent certes une supériorité manifeste en termes d'accès à un volume important de données. Mais, dans certains cas, les juges humains possèdent pour leur part un ensemble de données plus large – plus varié – que l'algorithme (*Ibid.*, p. 86 – dans les termes des auteurs, les OJP possèdent « a 'longer' dataset » alors que les seconds se caractérisent par « a 'wider' dataset »). Dès lors, « [d]éterminer quand l'humain doit suivre ou non la prédiction de l'algorithme est ce que nous appelons un *override problem* » (Ludwig *et al.*, *Ibid.*, p. 86). Pour le résoudre, Ludwig *et al.* proposent de considérer deux sources possibles d'information : la première est constituée par de l'information captée à la fois par le juge humain et l'algorithme, alors que la seconde n'est captée que par le juge.

Deux scénarios doivent alors être distingués.

« Dans le premier scénario, le juge utilisant son information supplémentaire produit toujours une estimation plus précise, ce qui conduit à la correction d'erreurs qui auraient été faites par l'algorithme. En cas de désaccord entre l'algorithme et le juge, le juge a raison de ne pas suivre (*override*) l'algorithme – si l'algorithme avait eu l'information supplémentaire [du juge], il aurait pris la même décision que celle qu'a prise le juge. Dans le second scénario, le juge utilise son information supplémentaire d'une façon qui conduit toujours à une décision incorrecte. Si l'algorithme avait une information complète non pas seulement sur ses données observées, mais aussi sur l'information qu'il n'observe pas et que seul le juge observe habituellement, alors il continuerait à être en désaccord avec la décision du juge. Dans ce scénario, quand l'algorithme et le juge sont en désaccord, c'est l'algorithme qui est correct même sur la base d'une information limitée – parce que le juge tire une inférence erronée de son information plus complète. » (Ludwig *et al.*, *Ibid.*, p. 86-87)

Par suite, « résoudre le *override problem* requiert non pas seulement d'aider les juges à utiliser leur information aussi bien que possible, mais aussi de les aider à apprendre où ils ont un avantage comparatif sur l'algorithme et vice versa. Cela requiert de trouver les moyens d'aider les juges à mieux comprendre l'algorithme, ce qui est l'un des objectifs des travaux en informatique sur les algorithmes interprétables » (Ludwig *et al.*, *Ibid.*, p. 87).

B. Quel effet prescriptif et performatif des OJP sur la décision judiciaire ?

88. Les biais des OJP ne sont pas sans conséquence dès lors qu'ils influencent la production judiciaire. En effet, même si le résultat fourni par l'OJP ne se substitue pas à la décision judiciaire humaine, les juges utilisent l'information fournie par l'OJP dans leur processus de décision. Une « influence » de l'OJP est donc possible. Cela implique alors de questionner ce que les utilisateurs font « vraiment » avec les OJP.

89. D'une part, on l'a vu, les travaux d'économie du droit comportementale ont montré que les juges sont affectés des mêmes biais cognitifs que les autres individus dans la population (Guthrie *et al.*, 2001). À ce titre, ils sont sensibles au biais d'ancrage (*anchoring bias*). L'hypothèse d'un effet d'ancrage des décisions humaines induit par les informations fournies au juge par les OJP apparaît donc crédible. Ainsi, comparant des décisions humaines prises par les juges d'un tribunal hollandais selon que ces derniers utilisent ou non l'IA, Kolkman *et al.* (2024) observent une influence de l'OJP sur la décision humaine. Ce résultat corrobore l'hypothèse d'une « domination-prescription sur les professionnels » de l'algorithme émise par Lebreton-Derrien (2018, p. 11)¹⁵⁶, selon laquelle « des auteurs évoquent [...], au regard de la justice prédictive, des jugements sous influence, la pression de la multitude risquant de distraire le juge de sa propre expérience professionnelle, de l'empêcher de se laisser inspirer par son sens de la justice dans lequel entre une dimension intuitive et imaginative. Devenant son propre censeur par culpabilité ou par peur de ne pas être dans la norme, l'utilisateur de la justice prédictive se retrouverait alors dans ce que d'aucuns appellent l'enfermement algorithmique ou la bulle informationnelle filtrante. Il faut y voir le risque d'une domination du virtuel sur la part créative laissée à l'humain au moment de l'actualisation de la prédiction, ce qui pose juridiquement le risque d'une normativité seconde, c'est-à-dire le risque de voir la règle appliquée par le juge, norme d'application, se substituer à la règle de droit elle-même : c'est le risque de performativité ou risque performatif. Le juge saisi deviendrait alors la bouche d'autres juges et, ce qui serait nouveau, pas seulement des juges des juridictions suprêmes, mais aussi des juges du fond, dont les décisions seront désormais plus accessibles, propice en cela à la révélation de la jurisprudence du fond. Si un tel effet performatif a pu être constaté dans des systèmes complètement automatisés, dans lesquels la recommandation et la décision sont prises

¹⁵⁶ Ce premier risque s'accompagnerait par ailleurs d'un risque de « domination-dissuasion sur les justiciables ».

par la machine, le risque n'est évidemment pas le même dès lors qu'il y a intervention humaine ». Une telle situation de « domination-prescription » pose dès lors la question de l'atteinte à l'indépendance du juge, Mouriesse (2019, p. 136) rappelant à cet égard que le juge a « 'l'obligation de juger sans subir aucune pression directe ou indirecte', ce qui implique notamment l'autonomie du juge par rapport à ses pairs ».

Plusieurs auteurs insistent par suite sur les effets négatifs des OJP prescriptifs sur la qualité de la justice. Un phénomène d'inertie et de conformisme judiciaire serait en effet à redouter. Mouriesse (2019, p. 136) souligne ainsi que « l'expansion des procédés de justice prédictive pourrait provoquer une inertie des juges, qui pourraient refuser d'adopter des solutions novatrices, non parce qu'elles ne correspondent pas à l'affaire, mais simplement parce que le pourcentage fourni par l'algorithme concernant les décisions rendues dans un sens par les autres juridictions est tellement important, qu'il en devient écrasant ». Effectuant des prévisions à partir de bases de données intégrant des décisions passées, les algorithmes seraient incapables de s'adapter aux nouvelles conditions juridiques, économiques et sociales (Pasquale et Cashwell, 2018). Précisément, selon Cadiet (2017, p. 113), « le contexte normatif et sociétal évolue. La modélisation et la reproduction du raisonnement juridique par des machines n'offre que des résultats très limités. Une expérience menée sur 600 décisions rendues par la Cour européenne des droits de l'homme a montré une certaine agilité des machines à reproduire le raisonnement sur les faits, mais davantage de difficulté à reprendre le raisonnement sur le droit. Cela explique aussi que les résultats obtenus soient meilleurs dans les pays de *common law*, marqués par une culture du précédent, que dans les pays de droit continental ».

90. D'autre part, des travaux récents soulignent aussi l'importance d'étudier les interactions entre humain et machine. En effet, dans plusieurs domaines, l'algorithme n'est pas le « décideur final » (Ludwig, 2021), mais « les humains restent dans la boucle en tant que décideurs ultimes » (*Ibid.*, p. 86). De ce fait, il importe de comprendre comment les juges humains se saisissent des OJP en pratique, dans leur pratique professionnelle concrète, et comment – sous quels aspects, dans quelle mesure, dans quels domaines de la production judiciaire – les OJP influencent véritablement leurs décisions et affectent, le cas échéant, le processus de production judiciaire. Parmi les travaux précurseurs, Christin (2017) propose une étude ethnographique comparative de l'utilisation et de l'interprétation des algorithmes par les journalistes web et les professionnels du droit – principalement des magistrats d'une *criminal court* aux États-Unis – dans leurs pratiques professionnelles. Pour les deux professions, elle observe un hiatus entre le discours managérial « officiel » porté par les organisations et les pratiques réelles des acteurs,

se traduisant dans les faits par un écart entre les effets attendus des algorithmes et leurs effets réels.

Ce phénomène de « découplage » est ensuite interprété en référence aux travaux néo-institutionnalistes de sociologie des organisations¹⁵⁷. Précisément, alors que les managers et les chefs produisent un discours affichant une utilisation importante des algorithmes dans l'activité, une approche ethnographique révèle que les outils sont souvent peu ou pas utilisés dans la pratique professionnelle quotidienne (voir Pruss, 2023, pour un constat identique sur un tribunal de Pennsylvanie). À cet égard, Christin identifie trois stratégies principales mises en œuvre par les professionnels pour minimiser l'impact des algorithmes dans leur travail quotidien. Tout d'abord, les outils peuvent être tout simplement ignorés. Dans la *criminal court* enquêtée, cette stratégie – qualifiée de *foot-dragging* – passe par la non-utilisation des OJP disponibles et le contournement des scores de risque et des systèmes d'analyse de données associés – tout bonnement ignorés par les juges à l'étape de la prise de décision (Christin, *Ibid.*, p. 8). Ensuite, les OJP peuvent faire l'objet d'une stratégie de *gaming* de la part des professionnels, revenant pour ces derniers à utiliser les règles et chiffres en les détournant de leur objectif premier. Dans le tribunal étudié par Christin, les *probation officers* peuvent ainsi manipuler les chiffres qu'ils saisissent dans les outils d'évaluation des risques afin d'obtenir le score qu'ils considèrent comme adapté pour le prévenu considéré (*Ibid.*, p. 9). On retrouve ici des comportements et des stratégies identifiés dans d'autres contextes et organisations, par lesquels les agents s'emploient à donner l'impression de pratiques conformes aux règles et instructions, mais ne modifient pas substantiellement leurs pratiques réelles (Espeland et Sauder, 2016). Enfin, les acteurs peuvent se livrer à une critique ouverte des nouveaux outils (*Ibid.*, p. 9), la critique insistant alors sur le caractère problématique des données utilisées par les OJP et la logique de profit des entreprises qui les développent (*Ibid.*, p. 10). Le constat ethnographique de Christin fait en ce sens écho au concept d'aversion à l'algorithme évoqué dans d'autres champs disciplinaires – la psychologie, l'économie – par Dietvorst *et al.* (2015) et Ludwig *et al.* (2021, p. 86).

91. L'étude des interactions humain-machine est actuellement un champ de recherche en expansion (ex. : Alon-Barkat *et al.*, 2023) et, à ce jour, relativement peu de travaux s'intéressent explicitement à l'institution judiciaire (ex. : Pruss, 2023 ; Kolkman *et al.*, 2024). Si on accepte

¹⁵⁷ Selon Christin (2017, p. 9), cette approche considère que les organisations réagissent aux pressions de leur environnement externe en s'engageant dans des stratégies destinées à afficher leur conformité. Elles investissent par exemple en nouvelles technologies et adaptent leur structure organisationnelle. Pour autant, les pratiques réelles des membres de l'organisation évoluent plus lentement et un décalage peut s'installer entre la structure formelle de l'organisation et le travail quotidien de ses membres.

d'extrapoler les conclusions des travaux existants à la décision judiciaire, les principaux résultats suggèrent que les juges pourraient ne pas appliquer les recommandations des algorithmes aveuglément et sans faire usage de leur capacité discrétionnaire. Cette idée contraste apparemment avec le constat empirique d'un biais d'ancrage de la décision judiciaire, tel qu'identifié et documenté expérimentalement dans la littérature d'économie comportementale et de sciences cognitives. Les deux analyses ne sont pourtant peut-être pas incompatibles : il se peut que, tout en étant affectés d'un biais d'ancrage, les juges soient réticents à réduire la décision judiciaire – l'acte de juger – à une simple duplication du résultat de l'algorithme. Un élément d'explication d'une telle « prise de distance » des juges par rapport aux recommandations de l'OJP pourrait être, selon Christin (2017), que les juges forment une profession qui s'est constituée autour d'un champ d'expertise reconnue et légitime, et par conséquent en mesure de « concurrencer » l'expertise adverse de l'algorithme.

92. **Conclusion.** Si les OJP sont souvent présentés comme un moyen d'accroître la qualité de la décision judiciaire en réduisant l'aléa judiciaire et les biais décisionnels et cognitifs des juges, les gains qualitatifs retirés de l'utilisation des OJP ne sont pas systématiques, les OJP étant eux-mêmes affectés d'un certain nombre de biais. Au regard des effets sur la qualité de la production judiciaire, il apparaît, en définitive, que le bilan coûts-avantages de l'utilisation des OJP est incertain. Pour autant, l'utilisation des OJP par le juge pourrait être associée à un autre type de gains, en termes d'efficacité managériale ou gestionnaire accrue de l'institution judiciaire.

Section 3 – Les OPJ et l'efficacité managériale de l'institution judiciaire

93. L'utilisation des OJP peut être également motivée par des gains en termes d'efficacité gestionnaire des tribunaux. On examine dans un premier temps les gains de productivité qui pourraient découler du recours aux OJP par les juges dans le cadre de leur production de décisions (§1), puis l'argument selon lequel les OJP pourraient constituer un instrument de réduction de la charge judiciaire (§2).

94. En microéconomie, la fonction de production d'une organisation exprime la relation entre les facteurs de production (classiquement, capital et travail) et la quantité produite. Elle indique donc les niveaux de quantité qu'il est possible de produire à partir de diverses combinaisons de facteurs de production et, plus particulièrement, la production maximale qu'il est possible d'atteindre en utilisant différentes combinaisons de facteurs de production compte tenu de la dotation de facteurs et de la technologie disponibles. Le progrès technique modifie les fonctions de production. En utilisant une technologie plus efficace, il est possible de produire davantage avec la même quantité de facteurs de production. Le progrès technique peut également induire une modification du rapport capital / travail, menant à des substitutions entre facteurs de production.

95. Dans le contexte judiciaire, les « technologies de soutien » (ou *supportive technology*, Calzoialo, 2019) se déclinent sous des formes diverses. Différents outils d'aide documentaire, de plus en plus perfectionnés et performants, sont utilisés pour faciliter la recherche de textes, législations et jurisprudences. Au-delà du service d'information juridique qu'ils procurent, des gains de productivité sont attendus de l'utilisation de ces outils. Les nombreuses et nouvelles possibilités d'échanges sécurisés de documents, de stockage sécurisé des données et de digitalisation des processus métiers doivent ainsi permettre aux professionnels (juges et autres professions du droit) de dégager de la « ressource-temps » pour se consacrer à des activités plus intensives en contenu intellectuel ou à plus forte valeur ajoutée. De façon récente, le développement de l'IA générative a en outre élargi la gamme des outils disponibles, ne se limitant plus à la recherche de documents, mais incluant également l'analyse de documents, la lecture intelligente de textes juridiques, l'assistance à la rédaction et la génération automatique de documents, la révision de contrats (permettant notamment d'identifier des clauses à risque ou incohérentes), ou encore la mise en place de *chatbots* juridiques.

96. Dans tous ces cas, on attend que ces « technologies de soutien » accroissent la productivité des professionnels les utilisant, en leur permettant de produire plus (davantage de services judiciaires) avec la même quantité de facteurs de production. La logique est de procéder à l'automatisation des tâches répétitives et/ou peu complexes en termes d'expertise juridique, suivant l'objectif managérial classique d'organisation efficiente de la production. Il s'agit ainsi de rationaliser une partie du processus de production des décisions judiciaires, dans

l'objectif d'utiliser au mieux les ressources rares (humaines, financières, informationnelles) à la disposition de l'institution judiciaire. Par l'automatisation et le redéploiement de personnel qualifié vers des tâches à plus forte valeur ajoutée qu'elles autorisent, ces innovations technologiques sont présentées comme réduisant le coût de l'information juridique pour les utilisateurs.

97. Deux remarques rapides s'imposent concernant le lien entre OJP et gains de productivité. D'une part, on peut noter que les gains productifs attendus de l'utilisation des OJP par l'institution judiciaire ne diffèrent pas par leur nature des gains anticipés de l'adoption d'une nouvelle technologie plus efficace dans les autres activités et secteurs¹⁵⁸. D'autre part, bien que

¹⁵⁸ Le même raisonnement tient pour l'ensemble des professionnels du droit, incluant notamment les avocats, notaires, etc. L'idée générale est que la diffusion des *legaltechs* bénéficie(ra) à l'ensemble des utilisateurs (justiciables et professionnels) : il est en effet attendu que les gains de productivité que les nouvelles technologies rendent possibles et la réduction des coûts de production correspondante se répercutent sous la forme de baisses du prix des services juridiques et, par ce biais, induisent une augmentation de la demande de ces services. Le plan numérique déployé par le barreau de Paris est justifié par ce raisonnement économique, puisqu'il revendique de « [p]ermettre à tous les avocats de s'approprier les nouveaux usages digitaux du droit pour mieux travailler, pour gagner en productivité et développer leur clientèle » (<https://www.avocatparis.org/actualites/plan-numerique-des-outils-pratiques-au-service-des-avocats-du-barreau-de-paris>, consulté le 15 février 2024). Un argument complémentaire est que les OJP peuvent également contribuer à accroître la qualité des services proposés par les professionnels du droit à leurs clients, en leur permettant d'affiner les caractéristiques du service proposé aux besoins du client et en adaptant leur stratégie judiciaire en fonction d'éléments statistiques tirés de cas similaires survenus dans le passé. Ainsi, l'utilisation de bases de données regroupant les informations et réponses judiciaires produites dans un pays pour un domaine de droit considéré peut conduire un avocat à conseiller ou déconseiller la poursuite d'une action en justice à son client ou en chiffrer la probabilité de succès et la « rentabilité », adapter sa stratégie juridique en fonction des informations fournies par l'OJP, ou même prévoir la décision du tribunal. Suivant une logique d'efficience gestionnaire proche, certains outils peuvent aussi servir à « externaliser » une partie du coût de la production du service des professionnels du droit et de la justice sur les consommateurs finaux de justice (les justiciables), dans une logique de co-production des services juridico-judiciaires.

Témoignant de la similarité des discours du nouveau management public et du management privé, on retrouve donc les mêmes arguments développés pour les juges et les tribunaux également mobilisés à destination des professionnels privés du droit et du chiffre par les éditeurs juridiques pour promouvoir leurs services. De l'automatisation des activités « para-légales », il est attendu des gains de temps et de productivité, désormais très largement mis en avant par les professionnels du droit et du chiffre (notamment avocats, directeurs administratifs et financiers, juristes d'entreprise, comptables) pour justifier leur utilisation de ces nouveaux outils. Voir par exemple, chez LexisNexis, Lexis 360 Intelligence, proposant de « révolutionner [son] intelligence juridique » et se présentant comme la « plus grande base de données encyclopédique et jurisprudentielle pour les professionnels du droit », https://www.lexisnexis.com/fr-fr/ppc/lexis-360?lead-source=Ads&task_origin=Ads&gasource=Ads&channel=Google%20Ads&task_channel=Google%20Ads&gacampaign=23ALLSV006&access=23ALLSV006&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_9DFkd2KhW_MVOGhBAh2A4Q0IEAAYAAEgIVDvD_BwE ; GenIA-L de Lefebvre Dalloz, « expérience de recherche propulsée par IA générative », https://www.editions-legislatives.fr/genial?gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_9DFkd2KhW_MVOGhBAh2A4Q0IEAAYASAAEg_LjFPD_BwE ; La Base Lextenso, https://lp.labase-lextenso.fr/essai-gratuit?utm_source=ppc&utm_medium=google-search&utm_campaign=sea-google&utm_term=base%20de%20donn%C3%A9es%20jurisprudence&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI_9DFkd2KhW_MVOGhBAh2A4Q0IEAAYAAEgJIHvD_BwE ; ou encore chez Doctrine, se présentant comme « la première plateforme d'intelligence juridique », mettant « le meilleur de l'intelligence artificielle au service des professionnels du droit » et promettant : « Maîtrisez votre environnement juridique. Augmentez votre productivité. Gagnez en (c)réativité. », https://www.doctrine.fr/?utm_term=base%20de%20donn%C3%A9es%20jurisprudence&utm_campaign=G%C3%A9n%C3%A9rique&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=4473651037&hsa_cam=148750124

les gains de productivité découlant de l'utilisation des OJP soient très largement mis en avant dans les discours de leurs promoteurs (privés et publics), il n'existe à notre connaissance pas d'évaluation rigoureuse de leur montant – quelques rares études sont disponibles à ce sujet pour le secteur privé¹⁵⁹. Cela ne signifie évidemment pas que ces gains soient inexistant, mais plaide en faveur d'une évaluation quantitative et qualitative des effets des OJP sur la décision judiciaire pour dépasser le simple stade de l'allégation et des idées reçues à ce sujet.

§2 – Les OJP, des outils de réduction de la charge judiciaire

98. De façon complémentaire à l'argument les présentant comme un instrument au service des gains de productivité, les OJP sont en outre présentés comme des instruments de réduction de la demande adressée à l'institution judiciaire et, donc, de désengorgement des tribunaux. Dans les termes de Calzoialo (2019), ils s'apparentent dans ce rôle à une « technologie substitutive » (*replacement technology*), remplaçant directement « des activités inhérentes à l'administration de la justice ». En effet, certains OJP rendent possible – au moins dans certains cas simples ou correspondant à de faibles enjeux – l'autoproduction de services juridiques, renvoyant aux situations d'« autojuridication décrites par Barraud (2019), sur le modèle de l'automédication. Certains sites et applications permettent ainsi, par exemple, d'éviter ou d'alléger le recours à l'institution judiciaire, soit parce qu'ils permettent aux justiciables de s'informer en amont sur les solutions juridiques s'appliquant dans leur cas, désamorçant de ce fait la survenance de conflits qui pourraient déboucher sur une demande judiciaire, soit parce qu'ils organisent le règlement du conflit en dehors du recours au juge.

99. Plusieurs exemples illustrent le premier cas de figure. Ainsi, des simulateurs de calcul de pensions alimentaires ou de montants d'indemnités de licenciement permettent aux individus de s'informer et d'adapter leurs comportements *ex ante* de façon à limiter leur demande de décisions judiciaires *ex post*¹⁶⁰. De la même façon, le Code du travail numérique introduit depuis 2017 facilite l'accès aux textes réglementant le droit du travail et les conventions

[90&hsa_grp=127473208705&hsa_ad=550562054525&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-629556185172&hsa_kw=base%20de%20donn%C3%A9es%20jurisprudence&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gad_source=1&gclid=EAIAIQobChMI_9DFkd2KhW_MVOGhBAh2A4Q0IEAAYBCAAEgLvY_D_BwE](https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire) (sites consultés le 3/7/2024).

¹⁵⁹ Parmi les rares études visant à évaluer les effets de l'adoption de l'IA au niveau des firmes individuelles, on peut citer Czarnitzki, Fernández et Christian Rammer (2023), concluant à un effet positif de l'IA sur la productivité. Leur étude ne porte néanmoins pas de façon spécifique sur les acteurs du droit.

¹⁶⁰ Voir par exemple le simulateur proposé sur le site service-public.fr : <https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/pension-alimentaire> (site consulté le 3/7/2024).

collectives des salariés et des employeurs¹⁶¹. Se présentant sous la forme d'une boîte à outils mettant à disposition des fiches pratiques, des modèles de documents (ex. : lettres de démission, de convocation à un entretien préalable au licenciement pour motif personnel, de rupture de contrat...) et un simulateur, il propose également une recherche par mots-clés. Enfin, le projet DataJust, initié par le décret du 29 mars 2020 – mais abandonné début 2022 – fournit un autre exemple d'OJP visant à informer les justiciables et les aider à préparer au mieux leur demande judiciaire, dans un souci d'efficacité de la production judiciaire¹⁶². Dans tous ces cas, les OJP s'analysent comme un outil d'information des parties au conflit, mettant ces dernières en capacité d'« autoproduire » des services de règlement des conflits et réduisant d'autant leur demande de décisions de justice auprès de l'institution judiciaire.

100. Le second cas de figure renvoie aux OJP permettant le règlement des conflits en dehors du recours au juge. Dans plusieurs pays, les OJP sont en effet utilisés dans le cadre des modes alternatifs de résolution des différends (MARD) sous la forme de dispositifs d'*online dispute resolution* (ODR) mis à la disposition des individus et parties aux conflits. Cette offre d'ODR existe ainsi de longue date aux États-Unis et dans d'autres pays, tels que les Pays-Bas. En France, son développement est encouragé par l'obligation de recourir, depuis 2019, à la médiation pour les petits litiges, concernant des contentieux inférieurs à 5 000 euros¹⁶³. Dans ce cadre, plusieurs plateformes privées¹⁶⁴ proposent actuellement des services sur le créneau des litiges de faible montant, promouvant leurs services à travers un double argument. D'une part, elles mettent en avant leur rôle de facilitation dans l'accès à la justice, face à une institution judiciaire présentée comme peu accessible, complexe et peu réactive. D'autre part, elles soulignent les gains financiers et en temps résultant du contournement du système judiciaire

¹⁶¹ Voir par exemple <https://code.travail.gouv.fr/> (site consulté le 3/7/2024).

¹⁶² Le projet DataJust visait à collecter les décisions rendues en appel dans le domaine des préjudices corporels entre 2017 et 2019 et les montants correspondants alloués aux victimes pour différents types de préjudices corporels, dans l'objectif de développer un algorithme d'analyse jurisprudentielle fournissant un référentiel indicatif d'indemnisation. L'objectif était, d'une part, d'informer les individus sur les montants susceptibles de leur être versés à ce titre et, d'autre part, d'aider les magistrats dans leurs décisions, en fournissant en *open data* un référentiel d'indemnisation pour les différents types de préjudices

¹⁶³ Cf. la loi [n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice](#), dont le décret d'application a été publié le 12 décembre 2019, avec entrée en vigueur le 1er janvier 2020.

¹⁶⁴ Par exemple, plusieurs plateformes telles que eJust, Demanderjustice.com, Fastarbitre, Kleros, litiges.fr, saisirprudhommes.com, Voslitiges.com proposent ainsi des services de résolution de litiges en ligne. À titre illustratif, le site justice.cool propose aux justiciables de résoudre leurs petits conflits pour un forfait relativement modique, via « un ensemble de processus orchestrés par l'Intelligence Artificielle » et « un processus orchestré par des algorithmes mais contrôlé par des humains ». Cf. site : <https://www.justice.cool/justice-cool-la-premiere-plateforme-de-mediation-assistee-par-intelligence-artificielle-est-en-ligne/> (site consulté le 3/7/2024).

traditionnel, présenté comme coûteux et peu rapide¹⁶⁵. Dans ce contexte, les OJP sont vus comme un moyen de décharger les juges du « petit » contentieux. En définitive, selon Sauvé (2018), « [l]e recours à des algorithmes pour le traitement des dossiers les plus répétitifs et les plus simples, ceux par exemple qui ne nécessitent que l'évaluation d'un dommage, l'application d'un barème ou d'une trame prédéterminée, encouragerait aussi le règlement de nombreux litiges en amont même du recours au juge, par le développement des modes alternatifs de règlement, comme la médiation ou la conciliation. En réduisant le temps passé aux recherches fines fondées sur des éléments de fait et de droit comparables, l'utilisation des algorithmes permettrait également aux juges de se décharger des tâches les plus chronophages au profit de l'examen des questions nouvelles ou complexes. Il en résulterait, selon les cas, un évitement du recours à la justice lorsque le résultat est certain ou un allègement de son travail. La justice prédictive favoriserait ainsi le recentrage des juges sur les dossiers pour lesquels leur expertise apporte une plus grande valeur ajoutée ». La technologie des OJP se présente donc dans ce contexte comme un instrument au service d'une meilleure gestion des ressources de l'institution judiciaire.

101. Enfin, au-delà de leurs effets positifs sur l'institution judiciaire *stricto sensu*, en termes de désengorgement des tribunaux, les promoteurs des OJP soutiennent également leur diffusion en raison de leurs effets positifs en termes de bonne gestion de la population carcérale. Ainsi, les OJP de type *risk assessment tools* – aujourd'hui largement utilisés par les juges états-uniens – sont vus comme un moyen de limiter la surpopulation des établissements pénitentiaires, en permettant d'identifier les profils de prévenus à faible niveau de risque pouvant donc être libérés et les profils à haut risque, devant à ce titre être maintenus en prison. Le Public Safety Assessment (PSA), outil d'évaluation du risque pré-procès développé en 2015 aux États-Unis, s'inscrit précisément dans cet objectif (Christin, 2017, p. 6).

En définitive, les OJP semblent donc bien se présenter comme des outils pragmatiques permettant de pallier l'insuffisance des moyens matériels et humains de l'institution judiciaire. Ou, dans les termes de Guiraud (2019, p. 5), « [i]l semble que l'expansion de ces nouveaux

¹⁶⁵ Selon *Décideurs* 2019, « [L]e réseau européen d'avocats et de juristes Eurojuris a par exemple lancé madecision.com en partenariat avec eJust, dans le but de faciliter les procédures d'arbitrage et de médiation aux PME/TPE pour les litiges compris entre 10 000 et 500 000 euros. Parti du constat que la justice est souvent considérée comme longue et coûteuse, Clément Jaton, *counsel* et chef de projet d'eJust pour la création d'une plateforme de service d'arbitrage en ligne, souhaitait quant à lui « accélérer le processus sur des litiges à moins de 1 000 euros ». Et par là même, démocratiser l'accès à la justice. Des outils qui ne nécessitent donc pas forcément le recours à un avocat mais qui font gagner du temps aux particuliers ou professionnels ».

outils soit favorisée par certains dysfonctionnements liés à la pratique du droit. En effet, les délais de jugement ne cessent de s'allonger, l'organisation peut sembler complexe et les juridictions pointent du doigt le manque de moyens. En cela, l'automatisation est vendue comme un outil permettant de faciliter l'accès à la justice et de réduire tous les coûts y afférant ».

102. **Conclusion.** Les effets des OJP sur la qualité de la justice apparaissent ambivalents et incertains. Si on peut anticiper des effets positifs, tant en termes de réduction de l'aléa judiciaire, de redressement des biais décisionnels et cognitifs des juges et de prévisibilité de la décision judiciaire que d'accès élargi à la justice pour les justiciables et de production des services judiciaires à moindre coût, il n'en demeure pas moins que ces effets ne sont pour l'instant documentés que de façon très partielle dans le cas français. En outre, les gains attendus sont potentiellement compensés par des effets négatifs des OJP sur la qualité de la justice. En particulier, comme on l'a vu, la réduction attendue des biais judiciaires pourrait s'opérer au prix de l'introduction de biais algorithmiques, l'utilisation des OJP rendant ainsi nécessaire un arbitrage entre biais humains et algorithmiques. Elle pourrait également se traduire par une dégradation de la qualité si « l'autojuridiction » (Barraud, 2019) permise par les OJP devait entraîner la mise en place d'une « justice à deux vitesses ».

Dans ce contexte, et compte tenu de ce bilan coûts-avantages ambivalent de l'utilisation des OJP dans le processus de production judiciaire, il convient d'organiser au mieux l'utilisation des OJP afin de tirer parti des gains qualitatifs associés tout en évitant, autant que possible, les coûts correspondants. Dans la section suivante, on montre qu'une régulation des OJP visant à l'information des utilisateurs constitue un instrument au service d'un niveau élevé de qualité de la décision judiciaire.

Chapitre 2 – La régulation des outils de justice prévisionnelle et l’information des utilisateurs : informer pour garantir la qualité de la décision judiciaire

103. L’objectif n’est pas ici de proposer un panorama de l’ensemble des régulations *ex ante* et *ex post* s’appliquant – ou susceptibles de s’appliquer – aux OJP¹⁶⁶ pour garantir la qualité de la production judiciaire. Compte tenu des coûts et risques associés aux OJP en termes de qualité de la décision judiciaire, tels que décrits dans la partie précédente, on se concentre sur la motivation économique d’une régulation visant à garantir la bonne qualité des décisions judiciaires par l’information des utilisateurs des OJP (juges et justiciables). Après avoir rappelé en quoi les asymétries informationnelles entre offreurs et utilisateurs constituent une justification traditionnelle de régulation de la qualité pour l’analyse économique (Section 1), on étudie en quoi une régulation visant à réduire les asymétries informationnelles associées aux OJP peut contribuer à la qualité des décisions judiciaires (Section 2). On montre alors que, compte tenu de l’existence d’asymétries informationnelles entre régulateur et régulés, cette régulation pourrait cependant n’avoir qu’une faible effectivité (Section 3).

Section 1 - Les asymétries d’information, un motif de régulation pour l’analyse économique

104. Le plus souvent, la conception et le fonctionnement des algorithmes sur lesquels reposent les OJP restent opaques pour les utilisateurs finaux – juges et justiciables. Cette opacité est à l’origine d’asymétries informationnelles entre les entreprises conceptrices de l’algorithme et les juges, d’une part, et entre les juges et les justiciables, d’autre part (§1), ce qui rend nécessaire une régulation de la qualité des OJP (§2).

§1 – L’opacité des algorithmes, à l’origine d’asymétries informationnelles

105. La critique des algorithmes en tant que « boîtes noires » caractérisées par leur opacité est un lieu commun (ex. : Burrell, 2016 ; Pasquale, 2015 ; Gueraud, 2019 citant Forest, 2017). Dans les termes de l’analyse économique, cette opacité peut être appréhendée à travers le concept d’asymétrie informationnelle, décrivant une situation dans laquelle deux parties en relation (échange, transaction...) interagissent sur la base d’un niveau d’information différent

¹⁶⁶ Cet exercice sera l’objet de la deuxième partie.

en quantité ou qualité. Dans ce cadre, l'une des parties à la relation possède une information supérieure à l'autre partie sur la qualité du service qu'elle propose dans le cadre de la relation. De manière générale, dans le cas des OJP, l'asymétrie informationnelle tient à la complexité technologique des algorithmes intégrés dans les OJP. Il en résulte deux formes principales d'asymétries informationnelles¹⁶⁷.

A. L'asymétrie informationnelle entre juges et concepteurs des OJP

106. D'une part, les asymétries informationnelles caractérisent la relation entre utilisateurs (les magistrats, mais aussi plus largement l'ensemble des professionnels du droit et les justiciables) et les concepteurs des OJP. En pratique, cette asymétrie informationnelle est bilatérale. Compte tenu de la complexité technologique des algorithmes de justice prévisionnelle, les utilisateurs des OJP ne possèdent en effet le plus souvent pas l'expertise suffisante pour appréhender de façon critique ou réflexive les choix de modélisation et de programmation opérés par les concepteurs des outils, comprendre le fonctionnement de ces derniers, et en déterminer précisément les apports et limites. En d'autres termes, ils ne peuvent en général pas répondre facilement à des questions telles que : comment la décision a-t-elle été produite par l'algorithme ? Quel type d'IA l'OJP mobilise-t-il ? Quels ont été les choix (ou les non-choix) opérés par les programmeurs au stade de la conception de l'algorithme ? Quelles sont les données intégrées et exclues par l'algorithme ? Sur quelles données l'OJP a-t-il été entraîné ? De ce fait, les concepteurs de l'OJP, experts en algorithmique, possèdent une information supérieure aux utilisateurs des OJP quant aux caractéristiques intrinsèques de l'OJP et, par suite, sur la nature, le contenu et la qualité technologique du service fourni par l'algorithme.

107. Cela ne signifie pas pour autant que les concepteurs de l'OJP sont capables d'évaluer la qualité juridique du service offert par l'algorithme. Il résulte de la distinction entre qualité technologique de l'OJP et qualité juridique une seconde forme d'asymétrie informationnelle entre utilisateurs et concepteurs de l'OJP : s'ils sont mieux informés que les juges de la qualité technologique de l'OJP (comment il est construit, le caractère plus ou moins complet de l'ensemble des variables qu'il utilise, la qualité des données, la précision de la prédiction...),

¹⁶⁷ On se concentre ici sur les algorithmes utilisant l'IA symbolique et non connexionniste. Dans les modèles reposant sur l'IA connexionniste, les concepteurs de l'algorithme peuvent ne pas connaître le modèle de fonctionnement de la machine. S'il perdure de manière générale une asymétrie informationnelle entre concepteurs et utilisateurs, on peut cependant considérer que l'information des premiers est imparfaite.

on peut penser que les concepteurs de l'OJP sont en revanche moins aptes à évaluer la qualité juridique du service fourni par l'algorithme. En d'autres termes, ils sont généralement moins informés que les professionnels du droit sur la définition et les déterminants de cette qualité juridique, à laquelle les juges sont évidemment attentifs et qu'ils attendent de leur utilisation des OJP. Par rapport aux utilisateurs praticiens, les concepteurs sont ainsi moins aptes à répondre aux questions suivantes. Par exemple, quelles dimensions de la qualité de la décision judiciaire l'OJP doit-il privilégier ? Par rapport aux pratiques professionnelles effectives, quelles sont les dimensions de la qualité juridique insuffisamment ou non prises en compte par l'OJP ? Quel est l'objectif des juges dans leur activité de jugement ? Quels sont leurs principaux critères de jugement ? L'OJP considéré constitue-t-il un instrument réellement utile au juge dans son activité de production juridique ? On a rappelé, dans la section 1.1 combien la définition des dimensions de la qualité de la décision judiciaire est une question complexe, à laquelle il n'est pas apporté de réponse univoque. Dès lors, l'asymétrie informationnelle en défaveur du concepteur de l'algorithme quant aux caractéristiques – aux dimensions de la qualité juridique – de l'OJP recherchées par les professionnels est potentiellement importante et peut être difficile à combler parfaitement à travers des échanges d'information entre utilisateurs et concepteurs des OJP (à l'étape de la conception du produit ou sous la forme de « retours-clients »).

108. En pratique, elle peut conduire à l'élaboration d'OJP « mal taillés », inadaptés aux besoins des juges et du système judiciaire, parce que ne poursuivant pas la « vraie » fonction objectif des juges ou s'appuyant sur un modèle de prise de décision judiciaire erroné ou irréaliste : l'OJP visera par exemple une fonction objectif non conforme aux objectifs de ses utilisateurs humains, se focalisera sur un objectif unique au détriment des objectifs potentiellement pluriels des juges, ou n'intégrera qu'une petite partie des variables effectivement prises en compte par les juges dans leur activité de jugement. Une telle inadaptation de l'OJP est souvent analysée comme la conséquence de l'insuffisante concertation entre professionnels et concepteurs des algorithmes au stade de l'élaboration des OJP, empêchant des transferts d'information efficaces sur les caractéristiques des OJP souhaités par les utilisateurs et techniquement possibles du point de vue des concepteurs.

B. L'asymétrie informationnelle entre juges et justiciables

109. D'autre part, l'asymétrie d'information peut aussi caractériser la relation entre juges et justiciables. Elle porte alors sur le niveau de qualité de la décision judiciaire, que le justiciable

est, de manière générale, moins capable d'évaluer que le juge lui-même. Compte tenu de l'expertise juridique du juge par rapport aux justiciables, cette forme d'asymétrie informationnelle n'est pas propre aux situations impliquant l'utilisation d'OJP. Cependant, les OJP sont dans certains cas susceptibles de la renforcer¹⁶⁸. En effet, lorsqu'il fait l'objet d'une décision judiciaire, le justiciable ne connaît pas précisément la fonction de production judiciaire. Il peut donc ignorer si le juge a utilisé un OJP en tant qu'*input* dans la production de la décision qui le concerne et, lorsqu'un OJP a été utilisé dans ce cadre, ignorer comment cet OJP a été utilisé. *A contrario*, le juge sait s'il a ou non utilisé un OJP et comment il l'a utilisé (par exemple, dans l'objectif d'accéder à la documentation juridique la plus large et la plus précise possible de façon à accroître la qualité de la décision ou, inversement, en se contentant de dupliquer la solution prescrite par l'algorithme de façon à réduire son effort, au risque d'une dégradation de la qualité de sa décision). Selon la façon dont le juge s'est ou non servi de l'algorithme, il est également possible que le justiciable fasse l'objet d'une décision non équitable ou ne respectant pas les droits fondamentaux – l'affaire Loomis (à propos de l'utilisation du logiciel COMPAS) fournit un exemple d'une telle situation. Il s'ensuit que, de manière générale, le juge est mieux informé que le justiciable sur les effets de l'utilisation de l'OJP sur la qualité de la décision qu'il a produite.

110. Concernant les effets de l'asymétrie informationnelle entre juge et justiciable sur la qualité de la décision, une difficulté découle de ce que les effets de l'utilisation d'un OJP sur la qualité de la décision judiciaire ne sont pas univoques. Les OJP peuvent en effet soit améliorer la qualité de la décision, soit la diminuer, l'effet positif ou négatif sur la qualité dépendant du type d'utilisation de l'OJP par le juge et de la qualité de l'OJP (dont le juge peut ou non être informé, compte tenu de sa propre asymétrie d'information vis-à-vis de la qualité intrinsèque de l'OJP).

111. En outre, comme dans la relation entre concepteurs des OJP et juges, l'asymétrie d'information entre juge et justiciable est bilatérale. La relation entre justiciable et juge relève en effet typiquement de l'économie des services, qui se caractérise le plus souvent par une co-production du service par le producteur et le consommateur et une information du second plus fine que celle du premier sur certains aspects du service échangé – le producteur a donc besoin

¹⁶⁸ Dans le contexte de la justice prévisionnelle, cette configuration d'asymétrie informationnelle est à notre connaissance très peu étudiée dans la littérature. Ce constat fait écho à celui de Bordère (2024) soulignant la quasi-absence de la figure du justiciable dans les travaux et débats sur la justice prédictive.

de l'information et de la participation du consommateur pour produire le service adéquat et le niveau de qualité optimal. Par exemple, en matière judiciaire, le prévenu peut, concernant certains aspects de son affaire ou de sa personnalité, être mieux informé que le tribunal. Ainsi, dans le cas des outils d'évaluation du risque de récidive ou de non-comparution devant le tribunal pour les libérations sous caution, on peut penser que le prévenu est mieux informé que le juge et que l'OJP quant à son niveau de risque réel (qu'il connaît, alors que le juge et l'OJP ne peuvent que l'estimer).

112. Par ailleurs, un élément de complexité supplémentaire tient à ce que certains OJP peuvent contribuer à réduire l'asymétrie informationnelle entre juge et justiciable – il s'agit, typiquement, des outils d'information juridique ou de simulation de la décision juridique qui accroissent l'information du justiciable¹⁶⁹.

C. Asymétries informationnelles et comportements opportunistes de la partie informée

113. Selon l'analyse économique, l'existence d'asymétries informationnelles ouvre la voie à des comportements opportunistes de la part de la partie informée qui peut être tentée d'exploiter l'asymétrie informationnelle en sa faveur au détriment de l'intérêt de la partie pour laquelle elle est chargée de remplir une mission (Jensen et Meckling, 1976). En d'autres termes, l'asymétrie informationnelle rend possible des déviations dans les choix et comportements de la partie informée par rapport à ce que serait le choix optimal du point de vue de la partie non informée. En outre, le plus souvent, le coût prohibitif d'acquisition de l'information empêche un contrôle effectif des choix et des actions de la partie informée par la partie non informée – à supposer qu'elle en soit capable. Par exemple, dans le cas des OJP, le coût élevé de l'information peut conduire les juges à renoncer à investir dans le capital humain et l'expertise algorithmique qui leur permettraient d'appréhender de façon effective les technologies impliquées, leur fonctionnement et leurs limites, et de négocier sur un pied d'égalité informationnelle avec les fournisseurs d'OJP lorsqu'il s'agit de faire l'acquisition d'un OJP ou d'en préciser les objectifs, attendus, fonctionnalités et utilisations¹⁷⁰.

¹⁶⁹ Cf. les exemples donnés supra, n° 99 et s.

¹⁷⁰ Vuarin et Steyer (2023) évoquent divers comportements de renoncement de ce type dans d'autres domaines que la justice prédictive. Dans le cas des OJP, remarquons également que l'asymétrie informationnelle peut être renforcée par le fait que les utilisateurs ne sont pas systématiquement associés à la conception des logiciels, conduisant à une divergence entre les besoins des utilisateurs et l'offre des concepteurs. On peut également noter que l'asymétrie informationnelle peut être bilatérale. La conception d'un OJP inadapté peut en effet provenir d'une

114. Lorsque l'asymétrie informationnelle entre juges et concepteurs des OJP concerne la qualité technologique de l'algorithme, et est donc en défaveur des premiers, le comportement opportuniste de la partie informée (les concepteurs) peut prendre la forme de choix de conception et programmation non conformes aux préférences des utilisateurs. Par exemple, tirant parti de l'expertise algorithmique inférieure des juges, les concepteurs vont choisir une fonction-objectif, un jeu de variables ou des données non optimales du point de vue des utilisateurs, au risque de développer un OJP ne satisfaisant pas les besoins et attendus des utilisateurs en termes de qualité juridique. Ces choix sous-optimaux des concepteurs ne correspondent pas nécessairement, comme on l'a vu en section 1, à un comportement conscient ou volontaire, mais résultent de leur information imparfaite quant aux dimensions de la qualité de la décision judiciaire qui importent réellement pour les utilisateurs.

115. Lorsqu'on considère l'asymétrie informationnelle entre juges et concepteurs des OJP portant sur la définition de la qualité juridique d'une décision – renvoyant à la « performance juridique » attendue de l'algorithme par ses utilisateurs, le comportement opportuniste de la partie informée est plus délicat à caractériser. On conçoit en effet difficilement l'intérêt que la partie informée (le juge) peut avoir à dissimuler son information à la partie non informée (le concepteur), dès lors que l'objectif est de contribuer au développement de l'OJP le plus adapté aux besoins – les échanges d'information pouvant idéalement aller jusqu'au co-développement de l'outil. Pour autant, on peut envisager que, dans certains cas, les utilisateurs soient réticents à transmettre leur information privée aux concepteurs des OJP, soit qu'ils ne voient pas l'utilité de ces derniers dans leur activité professionnelle concrète, soit qu'ils soient par principe réservés vis-à-vis de l'utilisation d'OJP dans le processus de prise de décision judiciaire et à l'idée d'une justice « automatisée ».

On peut ici renvoyer à nouveau aux travaux de Christin (2017) soulignant, dans certains cas, la faible adhésion des juges aux OJP, se traduisant par la non-utilisation des OJP (la stratégie de *foot-dragging*), une posture ouvertement critique à leur encontre, ou une utilisation stratégique visant à « faire dire aux OJP ce qu'on veut » (la stratégie de *gaming*).

Plus largement, ces situations renvoient aux comportements d'aversion aux algorithmes¹⁷¹. De la même façon, elles peuvent refléter des conflits de valeurs entre offreurs et utilisateurs des OJP, découlant d'objectifs et logiques potentiellement divergentes entre juges et entreprises à

insuffisante information des concepteurs des OJP quant aux besoins des utilisateurs : de même que les juristes sont rarement informaticiens, les informaticiens sont rarement juristes.

¹⁷¹ Cf. supra, n° 67 et s.

but lucratif poursuivant un objectif de profit. Christin (2017, p. 10) suggère à cet égard que la logique des « *for-profit companies* » peut aller à l’encontre des convictions des juges, alimentant ainsi leur aversion aux algorithmes.

116. La critique tient alors à ce que les entreprises privées conceptrices des OJP cherchent moins à concevoir un outil adapté aux besoins de l’institution judiciaire qu’elles ne font primer leurs propres objectifs – par exemple, de rentabilité financière – sur l’objectif de justice qualitative recherché par les utilisateurs¹⁷².

De manière générale, l’analyse économique considère que les asymétries informationnelles sont à l’origine d’inefficacités. Dans la sous-section suivante, on soutient qu’une régulation des OJP est nécessaire pour lutter contre les effets négatifs des asymétries informationnelles sur la qualité de la décision judiciaire.

§2 – Réguler les OJP pour lutter contre les effets négatifs des asymétries informationnelles

117. Un consensus semble aujourd’hui se dégager quant à la nécessité d’une régulation des OJP. Néanmoins, des interrogations majeures perdurent quant au contenu de cette régulation.

A. Réguler les OJP pour garantir la qualité de la décision judiciaire

118. Compte tenu de l’utilisation croissante des OJP dans le processus de production judiciaire et de leurs effets – positifs et négatifs – sur la qualité de la décision judiciaire, il peut apparaître nécessaire de réguler les OJP. Pour l’analyse économique, une régulation de la qualité des services s’impose en effet dès lors que, d’une part, les comportements opportunistes de la partie informée engendrent une dégradation de la qualité du bien ou service qu’ils offrent et que, d’autre part, la dégradation de la qualité du bien ou service peut induire la partie non informée à renoncer à consommer le bien ou service de la qualité duquel elle est incertaine (Akerlof, 1970). Dans ce contexte, en présence des asymétries informationnelles décrites précédemment, la régulation des OJP doit viser à préserver non seulement la qualité « technologique » des OJP (l’objectif est alors de construire la confiance des utilisateurs dans

¹⁷² À titre d’illustration, on peut évoquer ici le refus opposé par la société Northpointe Inc. dans l’affaire des biais discriminatoires associé à son logiciel COMPAS à la demande qui lui avait été faite de rendre publiques des informations sur son code source, la société ayant opposé le secret des affaires et sa logique propriétaire à ces demandes pourtant destinées à évaluer les effets qualitatifs de l’utilisation de COMPAS sur la qualité de la décision judiciaire (Rudin *et al.*, 2020).

les outils) mais aussi, *in fine*, la « qualité juridique » de la décision judiciaire qu'ils servent à produire (l'objectif est de tirer parti des avantages des OJP en tant qu'ils améliorent la qualité de la décision judiciaire). En d'autres termes, compte tenu des effets positifs et négatifs attendus des OJP sur la qualité de la décision judiciaire (réduction de l'aléa judiciaire, prévisibilité accrue de la décision...), la régulation doit viser la réalisation des gains associés à l'utilisation des OJP (en évitant que la renonciation à leur utilisation par les agents ne revienne à se priver de ces gains) et à éviter les coûts correspondants. Le régulateur doit ainsi chercher à tirer le meilleur parti possible des algorithmes. En effet, « les algorithmes présentent un [...] avantage : lorsqu'ils sont bien régulés, leurs problèmes sont plus faciles à diagnostiquer et plus simples à résoudre que les problèmes de psychologie humaine » (Ludwig *et al.*, 2021, p. 73). En particulier, « [i]l est plus facile d'améliorer des algorithmes fragiles que des décideurs faillibles. [...] [D]es algorithmes mal conçus peuvent exacerber les biais ».

119. « Dans le même temps, des algorithmes bien conçus peuvent réduire les préjugés. Ils peuvent, en fait, être une force pour la justice sociale. Il y a donc lieu de faire preuve d'un optimisme prudent : les algorithmes peuvent encore faire du bien à la justice pénale, mais seulement si l'on fait preuve d'une grande prudence » (*Ibid.*). En définitive, selon cette vision, réguler les algorithmes peut constituer un outil puissant au service d'une meilleure qualité de la décision judiciaire.

120. Concrètement, la régulation des algorithmes a pris différentes formes, à l'initiative d'acteurs variés, selon des positions qui ont parfois évolué dans le temps. Pour les États-Unis, Beaudouin et Maxwell (2023, p. 95 s.) restituent ainsi de façon détaillée l'évolution des positions des principaux promoteurs de la régulation des OJP, en réaction aux débats sur le logiciel COMPAS et ses effets négatifs sur la qualité judiciaire. Ils montrent ainsi qu'alors que les ONG états-uniennes de défense des droits des détenus étaient initialement plutôt favorables à l'utilisation des OJP, dont elles anticipaient des effets positifs sur le caractère équitable des décisions de justice (et notamment de mise en détention provisoire), elles ont progressivement évolué vers une position plus critique. De fait, ces ONG sont aujourd'hui plutôt favorables à l'encadrement de l'utilisation des outils actuariels dans la production de décisions de justice, sous la forme d'une régulation stricte passant notamment par une transparence accrue des OJP, la mise en place d'audits réguliers des biais et une modification de la présentation des scores – dont on a vu qu'elle peut influencer les décisions des juges en présence de leurs biais cognitifs. À l'extrême, certaines ONG « vont jusqu'à préconiser l'abandon de ces algorithmes, estimant

que leur valeur ajoutée n'est pas suffisante pour contrebalancer les risques de biais » (*Ibid.*, p. 96). Corroborant la demande de régulation accrue des OJP, Beaudouin et Maxwell (*Ibid.*) signalent en outre plusieurs changements législatifs opérés dans divers états américains – dont l'Etat de New-York, l'Idaho et le Nevada – à partir de 2019, en réaction à la révélation publique des biais contenus dans certains OJP et dans un contexte de plus en plus critique vis-à-vis de ces derniers¹⁷³.

121. En France et plus largement en Europe, les questionnements suscités par les OJP ont été abordés à travers différents dispositifs de régulation qu'on ne décrit pas ici dans leur intégralité, mais dont on présente quelques jalons pour rendre compte de leur diversité. Ainsi, la loi informatique et libertés du 6 janvier 1978 établit la nécessité de conserver le caractère humain de la décision, notamment judiciaire, et de ne pas la « déléguer » complètement à des machines, ainsi que l'interdiction l'utilisation d'outils automatiques de prédiction dans le cadre de la justice pénale. Ce principe a été repris en droit européen dès une directive de 1995 et il est également central dans le règlement général sur la protection des données (RGPD)¹⁷⁴, dont l'article 22 consacre le droit pour toute personne concernée de ne pas faire l'objet d'une décision fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé, rendant ainsi possible de s'opposer à une décision judiciaire qui serait produite exclusivement par la mise en œuvre d'un OJP. Plus

¹⁷³ Avec force détail, Beaudouin et Maxwell (2023, p. 96-98) précisent ainsi que « [L]a loi du 1er avril 2019 de l'État de New York exige que les outils d'évaluation de risque soient "conçus et mis en œuvre de manière à garantir que les résultats soient exempts de discrimination par rapport à la race, l'origine nationale, le genre et tout autre groupe de population protégé". La loi de 2019 de l'État de l'Idaho définit l'absence de biais selon deux critères. D'abord, un taux de prédiction réussie (vrais positifs) identique entre les groupes de population protégés par la loi et les autres groupes de la population ; ensuite un taux d'erreur (faux positif ou faux négatif) "équilibré" entre les différents groupes de la population, un problème de biais mis en évidence dans l'affaire ProPublica. Les services de l'État d'Idaho doivent valider l'absence de biais, et le rapport de validation doit être disponible publiquement. L'algorithme lui-même, et les informations utilisées pour son développement et sa validation, doivent également être ouverts publiquement, y compris pour des tests et audits. Une ordonnance du 21 mars 2019 de la Cour suprême de l'État du Nevada impose l'utilisation d'un questionnaire papier d'une page, avec seulement une dizaine de questions pour évaluer les risques de non-parution ou de dangerosité d'un individu. La Cour ayant publié l'ordonnance indique que les commentaires de l'ONG ACLU ont été pris en compte dans le développement de ce questionnaire simplifié. Le niveau de risque résulte de l'addition des points en fonction des réponses aux dix questions. Le magistrat a la possibilité de changer l'appréciation du risque en raison d'autres facteurs, mais il doit expliquer les raisons pour le changement de catégorisation du risque. L'ordonnance prévoit une formation obligatoire de tous les magistrats sur l'utilisation du questionnaire. Ce questionnaire constitue un retour aux sources de la démarche algorithmique, qui avait débuté à Manhattan au début des années 1960 dans le cadre du "Manhattan Bail Project" (Ares *et al.*, 1963). À partir d'un simple questionnaire sur les liens qu'entretient le prévenu avec la communauté locale, et de quelques vérifications dans la communauté, le porteur du projet, l'institut Vera, a mis en place un système de points qui permettait de prédire, avec une grande justesse, la probabilité que le prévenu se présenterait devant le tribunal le jour de son procès (US Department of Justice, 1981) ». Les références contenues dans la citation sont celles de l'article de Beaudouin et Maxwell.

¹⁷⁴ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données.

récemment, le 8 décembre 2018, la Charte éthique européenne d'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires a été adoptée par le Conseil de l'Europe, énonçant un certain nombre de principes (respect des droits fondamentaux, principe de non-discrimination, qualité et sécurité dans le traitement des données, transparence, neutralité et intégrité intellectuelle, maîtrise par l'utilisateur) destinés à assurer que l'IA reste un outil au service de l'intérêt général.

122. En juin 2024, le règlement sur l'intelligence artificielle (RIA) a été adopté, avec l'objectif de promouvoir une IA digne de confiance en Europe et veillant à ce que les systèmes d'IA respectent les droits fondamentaux, la sécurité et les principes éthiques¹⁷⁵. Le RIA définit à cet égard quatre niveaux de risque (inacceptable, élevé, limité, minimal) en leur associant des obligations plus ou moins contraignantes. Dans cette catégorisation, l'administration de la justice est considérée comme à haut risque. La régulation correspondante implique donc dans ce domaine une évaluation des systèmes d'IA avant leur mise sur le marché et au long de leur cycle de vie, ainsi que des exigences de transparence¹⁷⁶, à la différence actuellement des OPJ destinés au secteur privé, cette différence étant problématique dans la mesure où les outils risquent de naviguer du secteur privé au secteur public, le juge désireux d'effectuer des vérifications pouvant chercher à utiliser le même outil que celui utilisé par l'avocat dont il a les conclusions¹⁷⁷.

B. Quelle régulation ?

123. L'idée d'une régulation des OJP fait donc largement consensus. Dès lors, selon Ludwig *et al.* (2021, p. 87), la question pertinente est plutôt de comprendre les lacunes et échecs de la

¹⁷⁵ Dans le même temps a été créé l'Office européen de l'IA pour mettre en œuvre l'application de l'IA Act : <https://digital-strategy.ec.europa.eu/fr/policies/ai-office> (consulté le 11/07/2024).

¹⁷⁶ Plus précisément, l'annexe III de l'IA Act considère comme étant à haut risque les systèmes d'IA destinés à être utilisés par les autorités judiciaires ou les organismes administratifs, ou en leur nom, pour les aider à rechercher et à interpréter les faits ou la loi, et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits, ou utilisés de manière similaire lors du règlement extrajudiciaire d'un litige. Dans la présentation de l'IA Act du ministère de la Justice (2024, p. 9), il est précisé que « le SIA [système d'intelligence artificielle] ne sera considéré à haut risque que s'il présente un risque significatif de préjudice pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes physiques et s'il influence de manière substantielle le résultat de la prise de décision. L'article 6.2 précise dans quels cas l'influence n'est pas jugée substantielle : a) le système d'IA est destiné à exécuter une tâche procédurale strictement définie ; b) le système d'IA est destiné à améliorer le résultat d'une activité humaine déjà achevée ; c) le système d'IA est destiné à détecter les modèles de prise de décision ou les écarts par rapport aux modèles de prise de décision antérieurs et n'est pas destiné à remplacer ou à influencer l'évaluation humaine précédemment effectuée, sans un examen humain approprié ; d) le système d'IA est destiné à effectuer une tâche préparatoire à une évaluation pertinente aux fins des cas d'utilisation énumérés à l'annexe III ».

¹⁷⁷ Cf. *infra*, n° 230.

régulation des algorithmes de justice prévisionnelle, ou « pourquoi tant d'algorithmes du monde réel n'ont-ils pas réussi à traiter des problèmes tels que le biais de gain omis, le problème des étiquettes sélectives et le problème de l'annulation ? ». Un premier élément de réponse, avancé par Ludwig *et al.* (*Ibid.*, p. 87), est qu'« [e]n bref, [...] qu'ils n'ont pas eu à le faire. Les parties impliquées dans l'élaboration et le déploiement des algorithmes ne disposent pas des informations ou de la motivation nécessaires pour résoudre ces problèmes, et il n'existe pas de mécanismes correctifs pour empêcher que les algorithmes défectueux qui en résultent ne soient déployés à grande échelle ».

124. Plus largement, la détermination du contenu et de la forme de la régulation optimale, ainsi que sa mise en œuvre pratique sont complexes, pour diverses raisons.

Tout d'abord, ainsi que souligné précédemment, l'ensemble des risques associés aux OJP ne sont pas parfaitement identifiés : tant les OJP eux-mêmes que leurs usages sont fortement évolutifs, ce qui rend délicates la détermination et la mise en œuvre d'une régulation efficace et stable. Ce point est mis en avant par Ludwig *et al.* (2021, p. 88), selon lesquels « [n]ous nous appuyons souvent sur la réglementation pour faire face aux consommateurs mal informés, mais (comme c'est souvent le cas avec les nouvelles technologies) la loi et l'appareil réglementaire plus large sont encore en train de se mettre à niveau concernant les moyens par lesquels l'intelligence artificielle peut causer des dommages. Par exemple, dans le domaine de la santé, la Food and Drug Administration exige que les nouveaux médicaments ou dispositifs médicaux soient rigoureusement évalués au moyen d'une série d'essais contrôlés randomisés avant d'être déployés. Aucune exigence similaire n'existe actuellement pour les algorithmes ». De la difficulté à identifier précisément les risques associés aux OJP et à délimiter, au sein de l'ensemble des OJP, ceux qui présentent des niveaux de risques particulièrement élevés¹⁷⁸, il résulte une incomplétude de la régulation : ne pouvant tout prévoir, le régulateur raisonne en incertitude et ne peut associer un dispositif régulateur à chaque situation susceptible d'advenir.

Deux sources liées d'inefficacité potentielle de la régulation découlent de cette situation d'incomplétude. D'une part, la régulation des OJP prend la forme de l'énonciation de principes le plus souvent larges et englobants, et donc susceptibles d'application dans une grande variété d'espèces, mais dont on peut néanmoins suspecter la faible effectivité dans un certain nombre

¹⁷⁸ Ainsi, l'IA Act classe le domaine de la justice dans les applications de l'IA à risque élevé. Pour autant, il est clair que, au sein des OJP, certains sont plus « risqués » que d'autres et nécessitent donc une attention supérieure de la part des régulateurs.

de circonstances – nous reviendrons sur ce point par la suite. D'autre part, le caractère incomplet de la régulation des OJP ouvre la porte à des comportements des acteurs exploitant les failles de la régulation, avec des conséquences possiblement négatives sur la qualité de la décision judiciaire. Cette situation renvoie plus particulièrement à la dialectique innovation – régulation, bien connue dans le secteur financier, qui caractérise les activités et secteurs innovants dans lesquels le régulateur s'évertue à réguler – souvent avec un succès limité – des innovations toujours plus sophistiquées tirant parti des « trous » de la régulation – cette situation est parfois décrite comme un « jeu du chat et de la souris » entre régulateur et régulés. L'innovation technologique et la « créativité » des agents régulés sont alors mises au service d'un contournement des régulations jugées contraignantes ou inadaptées, rendant ces dernières ineffectives à peine mises en œuvre.

125. Ensuite, les limites de la régulation ne se situent pas uniquement du côté des OJP. Mais elles ont aussi à voir avec l'inadaptation de certaines dispositions juridiques actuelles ne reconnaissant pas les problèmes soulevés par les algorithmes – et notamment les algorithmes utilisés par les OJP – alors même que ces problèmes sont explicitement pris en compte par le droit dans l'économie « *brick and mortar* » (évoquant le commerce traditionnel avec des points de vente physiques), en dehors du domaine algorithmique. Par exemple, en matière de discrimination, selon Ludwig *et al.* (2021, p. 88), « le droit actuel de la discrimination est conçu pour traiter les préjugés humains, mais ne traite pas de la manière dont les algorithmes discriminent [...]. Les lois sur la discrimination pour les humains se concentrent sur la garantie que les gens ne prêtent pas attention aux caractéristiques des groupes protégés. Le cerveau humain est la boîte noire par excellence, de sorte que nous ne pouvons pas dire quand une personne utiliserait ces caractéristiques pour améliorer les objectifs sociétaux acceptés ou pour s'en détourner. En revanche, [...] pour les algorithmes, l'utilisation des caractéristiques des groupes protégés peut en fait contribuer à éliminer les préjugés » (*Ibid.*). Ainsi, « [l]a législation en matière de discrimination conçue pour les humains ne dit rien sur ce dont nous, observateurs extérieurs, avons besoin pour surveiller les algorithmes en matière de partialité, comme l'accès aux données et à l'algorithme prédictif pour les "audits d'équité" et l'amélioration de la transparence en général ». En définitive, le droit peinerait encore à reconnaître dans le domaine algorithmique certaines situations (notamment de discrimination) qui sont pourtant lourdement sanctionnées dans les autres domaines¹⁷⁹.

¹⁷⁹ Remarquons que le même diagnostic est effectué dans un domaine différent de l'économie algorithmique, notamment dans le domaine de la lutte contre la discrimination dans le domaine du e-commerce.

126. En outre, en prolongeant le raisonnement, on pourrait reprocher au droit de la discrimination tel que conçu pour et s'appliquant dans le monde non algorithmique d'opposer des obstacles juridiques à la lutte contre les discriminations *au moyen* de l'outil algorithmique, en interdisant l'utilisation de catégories particulières (ethniques, sociales) pour corriger des biais pourtant identifiés comme tels. De ce fait, le droit de la discrimination pourrait limiter, en pratique, les possibilités d'utilisation des algorithmes en tant qu'outils de redressement des biais affectant certains groupes et individus.

127. De plus, une difficulté supplémentaire à mettre en place une régulation optimale des algorithmes tient à ce que l'horizon temporel visé par la régulation des OJP n'est pas clairement défini. Andler (2023, p. 332) oppose à cet égard « présentistes » et « futuristes », qui défendent des points de vue opposés quant à l'horizon temporel devant être pris en compte : s'agit-il ainsi de réguler les OJP pour les effets actuels qu'ils ont déjà, tels qu'ils sont déjà observables et documentés – par exemple, les biais des juges – ou d'anticiper et prévenir les risques que les OJP pourraient faire courir à la qualité de la justice – par exemple, par le basculement du système judiciaire vers des « juges-robots » (Barraud, 2017, p. 6) et la déshumanisation de la production judiciaire ?

128. Enfin, la détermination d'une régulation optimale tient également à ce qu'une approche fine – idéalement, au cas par cas – est nécessaire, en fonction du type d'OJP considéré. Le règlement sur l'IA adopte précisément une telle approche différenciée en fonction des niveaux de risque (inacceptable, élevé, limité, minimal) associés aux différents systèmes d'IA de risque, auxquels il fait correspondre des obligations plus ou moins contraignantes. Dans le cas des OJP, une approche fine est d'autant plus complexe à mettre en œuvre qu'il existe des OJP très variés¹⁸⁰ et que l'effet de l'utilisation des OJP sur la qualité de la décision judiciaire peut être positif ou négatif. Face à la difficulté et au coût associés à la définition d'une régulation fine, la solution est d'énoncer des régulations à contenu généraliste, s'appliquant à l'ensemble des OJP, mais au risque de l'ineffectivité¹⁸¹.

129. On vient de rappeler en quoi les asymétries informationnelles entre offreurs et utilisateurs constituent une justification traditionnelle de régulation de la qualité pour l'analyse économique. On étudie maintenant en quoi une régulation des OJP visant à informer les

¹⁸⁰ Cf. *supra*, n° 38 et s.

¹⁸¹ Cf. *infra*, n° 166 et s.

utilisateurs des caractéristiques et des effets des OJP pourrait contribuer à la qualité des décisions judiciaires.

Section 2 - Le contenu de la régulation : informer pour réduire les asymétries informationnelles

130. En présence d'asymétries informationnelles, un objectif de la régulation est d'assurer l'information de la partie non informée. Dans le cas des OJP, une régulation visant à informer les utilisateurs des OJP des caractéristiques et des effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire est donc essentielle. On a vu, dans la section 1, que les problèmes liés aux algorithmes utilisés par les OJP peuvent avoir une origine humaine, résultant des choix des concepteurs de l'algorithme et des comportements d'utilisation des utilisateurs. La régulation des OJP poursuit de ce fait un objectif d'information et d'explication. Elle vise ainsi à informer sur les choix humains opérés à l'étape de la conception des OJP (§1) et des usages (§2) et à organiser la transparence des algorithmes de justice prévisionnelle (§3).

§1 – Accroître la transparence des choix de conception des OJP

131. L'opacité des algorithmes est régulièrement décriée, au motif qu'elle permettrait aux algorithmes de façonner les préférences des utilisateurs et d'influencer leur comportement, dans un sens allant potentiellement contre leur intérêt. De cette critique découle une recommandation récurrente en faveur de plus de transparence (ex. : Rudin, 2020). Dans ce contexte, l'objectif de la régulation est de préserver l'autonomie des utilisateurs, leur souveraineté de consommateur et leur liberté de choix (Fassiaux, 2023). La régulation vise alors à limiter l'influence induite des algorithmes sur les utilisateurs et à les protéger contre les risques de manipulation algorithmique qui les conduiraient à réaliser des choix inefficaces.

132. Parallèlement, la transparence des algorithmes s'interprète aussi comme la condition de leur contrôle effectif : en facilitant le contrôle de leur fonctionnement interne (leur qualité « technologique »), elle facilite également le contrôle de la qualité des décisions de justice qui sont prises sur cette base (la qualité « juridique » des choix résultant de leur utilisation). Il s'agit donc, en d'autres termes, de faciliter la détection à moindre coût – par le régulateur et les utilisateurs finaux – de choix éventuellement problématiques qui auraient été opérés au stade

de la conception, modélisation et programmation de l'algorithme et/ou du choix des données d'entraînement et de leurs effets négatifs sur la qualité de la décision judiciaire. Ce faisant, il s'agit de faire en sorte que les concepteurs de l'algorithme, conscients du contrôle rendu possible par l'information des utilisateurs et du régulateur, réalisent spontanément des choix éthiques. La transparence renvoie ainsi, fondamentalement, à la question de l'*ethics by design*.

133. En pratique, un moyen d'accroître la transparence des algorithmes est tout d'abord d'informer les utilisateurs des OJP des caractéristiques intrinsèques et du fonctionnement interne des algorithmes. La régulation doit ainsi garantir que les utilisateurs sont effectivement informés des choix effectués lors de la conception, modélisation et programmation de l'algorithme de justice prévisionnelle. Par exemple, elle doit s'attacher à garantir la transparence de l'information fournie par le concepteur concernant la fonction-objectif imputée à l'algorithme et expliciter les valeurs retenues à ce stade (Andler, 2023, p. 342), ce qui implique notamment l'accessibilité du code source. Le but est alors moins de repérer une manipulation volontaire des résultats de l'algorithme par le concepteur de l'OJP que de mettre en lumière la nature humaine – et, partant, la faillibilité – des choix *humains* au fondement de l'algorithme, ainsi que les biais et préjugés éventuels des concepteurs et l'inadaptation ou l'irréalisme de leurs modèles. Dans la même ligne, la transparence doit aussi concerner les données qui sont entrées dans l'algorithme de justice prévisionnelle, le choix des données étant – on l'a vu – non seulement déterminant pour la performance de l'algorithme, mais aussi susceptible d'alimenter des biais dans les résultats algorithmiques, et cela quel que soit le type d'IA (analytique ou générative) utilisée. Dans cette perspective, il peut ainsi être important d'informer les utilisateurs des actions de mise à jour des données réalisées (ou pas). Idéalement, on peut estimer que ce suivi doit être réalisé par une équipe pluridisciplinaire associant non seulement des *data scientists*, mais aussi des juristes au fait des évolutions du droit et du contexte social dans lequel les décisions de justice s'inscrivent.

134. En définitive, on voit que la transparence passe par une demande adressée aux firmes conceptrices des OJP de rendre publique l'information sur les caractéristiques intrinsèques de leurs algorithmes, qu'il est coûteux d'observer pour les non-experts. Dans cette perspective, on peut penser que la généralisation des ADR (*architecture decision records*) pourrait fournir un outil simple et peu coûteux pour le régulateur permettant de rendre publiques les informations des décisions effectuées par les programmeurs et de les rendre intelligibles aux utilisateurs. En pratique, les ADR se présentent en effet comme un journal des décisions prises par l'équipe

de développement, relatant et justifiant les différents choix qui sont opérés aux différents stages de l'élaboration de l'algorithme (par exemple, choix de modélisation, d'architecture, de données, de langage...). Ils pourraient donc être utilisés pour accroître la transparence des OJP.

135. Par ailleurs, la transparence des OJP comporte aussi une dimension d'information quant aux conséquences des choix de conception et de programmation sur leur fonctionnement et, *in fine*, la qualité des décisions judiciaire qu'elles contribuent à produire. La régulation peut alors prendre la forme d'actions visant à faire prendre conscience aux utilisateurs des effets – positifs et négatifs – de l'utilisation des OJP sur la qualité de la décision et à encourager les utilisations vertueuses.

§2 – Accroître la transparence des usages

136. À notre connaissance, la question de la transparence en tant qu'outil de régulation permettant de réduire l'asymétrie d'information entre juge et justiciable en lien avec les OJP est peu traitée, que ce soit dans la littérature de *data sciences* ou dans l'analyse économique. Peu de travaux s'attachent à étudier les effets sur la qualité de la décision judiciaire de l'utilisation par le juge d'OJP, dans un contexte d'asymétrie informationnelle où le justiciable n'est pas (ou imparfaitement) informé du recours (ou non) à un OJP dans son affaire, des caractéristiques de cet OJP et des conséquences attendues de son utilisation sur la qualité de la décision le concernant¹⁸². Logiquement, peu de travaux portent donc sur la régulation d'une telle situation et sur les effets d'une régulation prenant la forme d'une information des justiciables sur les usages effectifs des OJP par les juges.

La question est en revanche de plus en plus abordée sous l'angle du droit, Mouriesse (2018, p. 129) faisant cependant état à ce sujet d'un « silence du droit positif », comblé par un nombre croissant de rapports (par exemple, Cadet, 2017, 2022) et d'articles sur cette dimension de la transparence des algorithmes de justice prévisionnelle. À ce sujet, l'article 10 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés prévoit qu'aucune décision de justice « impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ne peut avoir pour fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel destiné à évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne ». Mouriesse (2018, p. 127-128) remarque à cet

¹⁸² Cf. *supra*, n° 106 et s.

égard que, si cet article revient à interdire l'adoption de décisions de justice fondées sur le profilage, dont elle rappelle la définition selon l'article 4.4 du règlement général sur la protection des données (RGPD) comme « une utilisation automatisée de données personnelles visant à prédire le comportement d'une personne », un tel profilage est « loin de recouvrir tous les procédés de justice prédictive ». Elle souligne en outre que « [l]e RGPD, d'ailleurs, n'interdit pas l'utilisation d'algorithmes par le juge. Il précise simplement que, si une personne doit faire l'objet d'une décision ayant des effets juridiques à son égard, elle a droit à ce que cette décision ne soit pas fondée sur un traitement entièrement automatisé de ses données personnelles (tout en ajoutant que cela reste possible si des mesures de sauvegarde de ses libertés existent ou si ladite personne consent à ce traitement automatisé). Il exclut même l'interdiction du traitement automatisé des données sensibles pour l'exercice de la fonction juridictionnelle ». L'article 22 du RGPD consacre ainsi le droit pour toute personne concernée de ne pas faire l'objet d'une décision fondée *exclusivement* sur un traitement automatisé. Mouriesse (*Ibid.*, p. 128-9) note également que, si « [l]e développement des logiciels de justice prédictive d'aide aux magistrats pourrait [...] se propager très rapidement à tous les contentieux de masse ou impliquant une issue chiffrée (comme ceux des prestations compensatoires ou de la rupture abusive des relations contractuelles), qui sont plus faciles à traiter de façon automatisée », pour autant « [l]'utilisation de ce procédé n'est cependant encadrée par aucune exigence de transparence imposée par le droit positif. Les exigences de transparence imposées aux décisions individuelles fondées sur un algorithme, prévues par les articles L. 312-1-3 et L. 311-3-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA), ne sont pas applicables aux décisions de justice. Certes, l'article 39 de la loi du 6 janvier 1978 impose aux responsables de traitement des données personnelles de communiquer à une personne les informations "permettant de connaître et de contester la logique qui sous-tend le traitement automatisé [de ses données personnelles] en cas de décision prise sur le fondement de celui-ci et produisant des effets juridiques" à son égard. Cependant, la plupart des algorithmes de justice prédictive qui seront potentiellement utilisés par les juges devraient échapper à son champ d'application car ils se nourrissent de décisions de justice mises en *open data* et donc préalablement pseudonymisées, ce qui est censé exclure la présence de données personnelles ».

137. Accroître la transparence des usages des OJP appelle en outre trois remarques. D'abord, comme on l'a déjà indiqué précédemment, les travaux sur l'utilisation des OJP dans les juridictions restent rares. Les usages des OJP par les juges et leur impact sur la relation entre juges et justiciables sont donc encore mal connus et on ignore, notamment, s'ils évoluent dans

le temps et avec l'offre croissante d'outils. Dans un tel contexte, une régulation des usages pourrait s'avérer délicate, voire contreproductive dans la mesure où, selon les situations, les effets de l'utilisation des OJP sur la qualité de la décision judiciaire peuvent être négatifs ou positifs¹⁸³.

138. Ensuite, la régulation des usages peut aussi emprunter la voie de la pédagogie et de l'éducation des utilisateurs, dans l'objectif de rendre les juges conscients des effets – positifs ou négatifs – de l'utilisation par eux des OJP dans le cadre de leur processus de prise de décision. Cette remarque fait écho à l'éclosion de l'offre de diplômes et formations en « droit et numérique », observée de façon récente.

139. Enfin, la recherche d'une transparence accrue des algorithmes passant par l'information des utilisateurs se heurte en pratique à plusieurs obstacles. Tout d'abord, la transparence algorithmique ne suffit pas à résoudre le problème des biais dans les données d'origine sociale ou systémique, qui nécessite d'être appréhendé dans le cadre d'une réflexion globale sur les effets de la décision judiciaire dans la société (Richardson *et al.*, 2019). Ensuite, si la transparence peut constituer une voie et un objectif de régulation des OJP dans le cas des IA analytiques, elle apparaît plus difficile à opérationnaliser et à mettre en pratique dans le cas des nouvelles générations d'IA génératives, par nature plus opaques, auto-apprenantes et inaccessibles à la compréhension humaine.

140. Il apparaît que le consensus quant à la nécessité d'une transparence accrue des algorithmes masque des difficultés pratiques importantes dans la mise en œuvre de ce principe général qui en limitent l'effectivité concrète. C'est précisément à ces difficultés que nous nous sommes confrontés dans la deuxième partie¹⁸⁴.

§3 – Organiser l'explicabilité pour garantir la transparence des OJP

141. Dans le contexte d'asymétrie informationnelle décrit précédemment, la transparence des OJP est donc reconnue comme un objectif de la régulation. Elle peut néanmoins être difficile à mettre en œuvre concrètement. Pour répondre à cette critique, deux aspects complémentaires

¹⁸³ Cf. *supra*, n° 90 et s.

¹⁸⁴ Cf. *infra*, n° 173 et s.

sont à considérer, le premier directement orienté vers l'opérationnalisation de l'explicabilité algorithmique, le second – en lien avec le premier – d'ordre définitionnel.

D'une part, dans les années récentes, et en réponse à la critique de l'opacité des algorithmes, le champ de l'IA explicable (ou XAI, pour eXplainable Artificial Intelligence) a émergé afin de « fournir des explications post-hoc des modèles d'IA en boîte noire » (John-Matthews, 2023, p. 290). L'IA explicable est « entendue comme une intelligibilité de la machine – "comment ça marche ?" – et une capacité à rendre des comptes – une *accountability*, répondant à la question : "qui est responsable de son fonctionnement ?" » (Vuarin *et al.*, 2023). Selon Gunning (2007, p. 7, cité par Vuarin *et al.*, 2023, p. 185-6), l'objectif de l'IA explicable est de « produire des modèles plus explicables, tout en maintenant un niveau de performance d'apprentissage élevé (e. g. la pertinence prédictive) ; et d'aider les utilisateurs à développer une compréhension, une confiance raisonnable, et des capacités de pilotage effective de la nouvelle génération d'outils d'intelligence artificielle ». Selon le site de l'entreprise américaine Juniper Networks¹⁸⁵, qui offre elle-même des services d'IA explicable, l'IA explicable se définit ainsi comme « un ensemble de processus et de méthodes qui permettent aux utilisateurs de comprendre et de se fier aux résultats et aux informations générés par les algorithmes de *machine learning* (ML) de l'IA. Les explications qui accompagnent les résultats de l'IA/ML peuvent être destinées aux utilisateurs, aux opérateurs ou aux développeurs. Elles sont conçues pour résoudre des problèmes et relever des défis tels que l'adoption par les utilisateurs, la gouvernance et le développement de systèmes. Ce caractère "explicable" est essentiel pour permettre à l'IA de susciter la confiance indispensable sur le marché afin d'encourager une large adoption de l'IA et d'en tirer profit ». Ainsi, précise le site, « [u]n modèle d'IA explicable possède des caractéristiques ou des propriétés qui favorisent la transparence, la facilité de compréhension et la possibilité de remettre en question ou d'interroger les résultats de l'IA ». De ce fait, « [l]a transparence des données, des modèles et des processus permet aux opérateurs et aux utilisateurs de mieux comprendre et d'observer ces systèmes. Ils peuvent ainsi les optimiser grâce à un raisonnement clair et valide. Plus important encore, l'explicabilité permet de signaler plus facilement les défauts, les biais et les risques, puis de les atténuer ou les supprimer ». En définitive, il s'agit de « favoriser la transparence et la confiance » car « [s]i la XAI ne contribue pas à instaurer la confiance, il est peu probable que les utilisateurs déploient cette technologie à grande échelle ou en tirent profit ». L'objectif est donc d'apporter par l'IA explicable des

¹⁸⁵ <https://www.juniper.net/fr/fr/research-topics/what-is-explainable-ai-xai.html> (consultation le 11/7/2024).

solutions au problème de l'opacité des algorithmes et de créer les conditions propices à sa diffusion.

142. Dans le cas des OJP, l'enjeu de l'explicabilité des algorithmes utilisés est capital. Il s'agit non seulement de les rendre explicables aux utilisateurs-juges pour en faciliter l'adoption – et donc permettre la réalisation des gains associés à leur utilisation et en éviter les coûts, tels que précédemment décrits¹⁸⁶. Mais il s'agit également de garantir leur acceptabilité sociale du point de vue des justiciables « consommateurs » des décisions de justice produites grâce aux OJP. L'explicabilité concerne donc les deux facettes des asymétries informationnelles décrites plus avant – affectant non seulement la relation entre juges et concepteurs des OJP, mais aussi la relation entre justiciables et juges quant aux usages des OJP par ces derniers.

143. Pour autant, « la capacité des outils générés par ce champ à expliquer des algorithmes de plus en plus opaques reste limitée », notent Vuarin *et al.* (2023, p. 186) et « on constate un certain découplage entre les concepteurs des outils d'explicabilité et les usagers finaux » (*Ibid.*). Dans le même sens, Doha *et al.* (*Ibid.*, p. 1) remarquent que si l'IA explicable dans les systèmes de recommandation peut aider les utilisateurs à comprendre pourquoi et comment l'algorithme recommande une solution particulière, il n'en demeure pas moins qu'aucune explication standardisée ne satisfait les préférences et besoins des utilisateurs. Un problème supplémentaire, ajoutent-ils, est que « [b]ien que l'explicabilité soit nécessaire avant tout pour les utilisateurs qui ne comprennent pas l'IA, l'IA explicable actuelle est le plus souvent conçue pour les ingénieurs en apprentissage automatique ou les chercheurs qui ont déjà beaucoup de connaissances dans ce domaine ». Il est vraisemblable que cette remarque s'applique dans le cas des OJP, dans lequel beaucoup laisse à penser que, en moyenne, les juges comme les justiciables n'ont que peu de connaissances dans le domaine de l'IA et des algorithmes. Remédier de façon effective aux asymétries informationnelles caractérisant la relation entre juges et concepteurs des OJP d'une part, entre juges et justiciables d'autre part, implique donc de développer des outils d'explicabilité réellement pédagogiques.

144. D'autre part, une régulation des OJP axée sur l'explicabilité requiert de définir l'explicabilité recherchée. En effet, différentes formes d'explicabilité sont distinguées : l'explicabilité locale a pour objectif d'expliquer une décision particulière de l'algorithme, tandis

¹⁸⁶ Cf. *supra*, n° 36 et s.

que l'explicabilité globale vise à expliquer le fonctionnement de l'algorithme dans son intégralité. Dans le cas des OJP, la recherche d'une explicabilité locale semble mieux adaptée aux besoins du justiciable pour remédier à l'asymétrie informationnelle entre juges et justiciables. En revanche, on peut penser qu'une explicabilité globale doit être recherchée lorsque l'objectif est de réduire l'asymétrie informationnelle entre juges et concepteurs des OJP, lorsqu'il s'agit d'informer le juge, en tant qu'utilisateur régulier de l'OJP, des choix opérés par les concepteurs de l'OJP aux étapes de sa conception et modélisation notamment.

145. Dans la perspective d'une régulation des OJP visant à réduire les asymétries informationnelles associées aux OJP, il peut en outre être utile de s'intéresser aux concepts connexes à l'explicabilité développés dans la littérature sur les algorithmes. Doha *et al.* (2023, p. 2) proposent une définition précise de ces différents concepts, mise en regard du concept de transparence. Cette dernière est ainsi définie en référence à la question de savoir si un modèle est compréhensible par lui-même sans aide supplémentaire. Dans ce cadre, « la transparence vise principalement à aider les ingénieurs ou les concepteurs de produits, tandis que les non-experts auront du mal à comprendre les explications et seront incapables d'interpréter et d'analyser les algorithmes et les structures des modèles. La transparence dans la XAI ne tient pas compte des besoins des utilisateurs, car ces derniers ne peuvent pas comprendre pourquoi une certaine décision a été prise ».

146. L'explicabilité (*explainability*) définit pour sa part dans quelle mesure les décisions sont compréhensibles pour les humains. La compréhensibilité (*understandability*) vise quant à elle à aider les humains à comprendre les fonctions du modèle en révélant les caractéristiques du modèle, tandis que l'intelligibilité (*comprehensibility*) renvoie à l'apprentissage d'un algorithme d'une manière compréhensible. Enfin, l'interprétabilité (*interpretability*) se rapporte à la capacité d'expliquer ou de fournir une signification en termes compréhensibles à un humain et se concentre donc sur la signification de l'explication. Dans les termes de Doha *et al.* (2023, p. 2), « [p]lutôt que d'expliquer comment un algorithme ou un modèle est construit ou structuré, elle explique comment les résultats peuvent être interprétés et analysés. [...] L'objectif ultime de l'interprétabilité en XAI est de rendre l'explication compréhensible pour les humains. Non seulement l'interprétabilité améliore la compréhension des non-experts, mais elle permet aux utilisateurs de générer des significations qui explorent comment un modèle ou un algorithme peut être appliqué dans d'autres domaines ».

147. Cette richesse conceptuelle amène à observer que les régulations visant à réduire les asymétries informationnelles entre utilisateurs et concepteurs d'OJP n'abordent qu'une partie des problématiques informationnelles se rapportant à la transparence et à l'explicabilité. Une régulation visant à apporter des solutions effectives aux asymétries informationnelles créées par les OJP requiert ainsi de s'attacher non seulement à la transparence et l'explicabilité, mais aussi à la compréhensibilité (c'est-à-dire faire en sorte que les utilisateurs humains soient informés des caractéristiques du modèle et comprennent les fonctions du modèle – leur permettant ainsi de l'amender et de l'utiliser pleinement) et à l'interprétabilité (c'est-à-dire rendre le résultat fourni par l'OJP interprétable et analysable pour un humain, qu'il soit juge ou justiciable).

148. Une régulation visant à remédier aux asymétries informationnelles créées par les OJP apparaît donc un gage de qualité de la décision judiciaire. Pour autant, un autre type d'asymétries informationnelles, caractérisant cette fois la relation entre régulateur et régulés, soulève la question de l'effectivité d'une telle régulation des OJP.

Section 3 – L'effectivité de la régulation des OJP : quelle forme de la régulation en présence d'asymétries informationnelles ?

149. L'effectivité d'une régulation des OJP assurant l'information des utilisateurs et garantissant une qualité élevée des décisions judiciaires est conditionnée à la capacité qu'a le régulateur de déterminer et mettre en œuvre cette régulation. Or la mise en place d'une telle régulation se heurte au problème de l'information du régulateur, traditionnel en économie publique et de la réglementation (§1). En l'absence d'information suffisante du régulateur public sur la conception, le fonctionnement et les usages des OJP, l'analyse économique du droit recommande classiquement de déléguer la régulation aux agents informés, sous la forme de dispositifs d'autorégulation ou de co-régulation (§2). Dans le contexte de la régulation des OJP, cette solution pourrait n'avoir qu'une effectivité limitée, se traduisant par une faible capacité de la régulation à garantir une qualité élevée des décisions judiciaires produites en utilisant les OJP (§3).

§1 – Asymétries informationnelles entre le régulateur public et les offreurs d'OJP : les limites d'une régulation directe par la puissance publique

150. Les régulations existantes des OJP prennent, on l'a vu, les formes d'intervention traditionnelles de la puissance publique, qu'elles soient mises en place à l'échelon national ou européen. Cependant, à tous les échelons, l'effectivité de la régulation de type « *control-and-command* » est limitée par l'information limitée du régulateur public. De manière générale, les travaux d'économie de la réglementation montrent en effet que la capacité du régulateur public à réguler de façon efficace et effective certaines activités économiques est limitée en présence d'asymétries informationnelles entre régulateur public et agents régulés. Ces derniers possèdent une information plus fine que le régulateur sur les conditions de leur activité et le niveau d'effort qu'ils mettent réellement en œuvre pour remplir la mission qui leur est confiée. La conséquence de cette asymétrie informationnelle est que les entreprises régulées peuvent être tentées d'exploiter leur information en poursuivant des objectifs et en effectuant des choix différents de ceux poursuivis par le régulateur (Laffont et Tirole, 1993) – on retrouve ici l'idée de comportement opportuniste de la partie informée déjà évoquée¹⁸⁷. En outre, le coût élevé de l'information pour le régulateur empêche la mise en place d'un contrôle direct de l'action des entreprises régulées.

151. Dans le contexte des OJP, ce cadre théorique renvoie au fait que les entreprises offeuses d'OJP – le plus souvent des entreprises privées – se caractérisent par un degré d'expertise algorithmique supérieur au régulateur public chargé de veiller à la qualité de la production judiciaire. En particulier, alors qu'elles étaient déjà mieux informées que les utilisateurs des OJP des caractéristiques intrinsèques des OJP et de leur fonctionnement, elles sont aussi mieux informées que le régulateur. Il en résulte une inefficacité de la régulation publique produite et mise en œuvre par le régulateur pour gérer la conception et l'utilisation des OJP, et son incapacité à garantir une qualité élevée des décisions judiciaires¹⁸⁸.

¹⁸⁷ Cf. supra, n° 115 et s.

¹⁸⁸ Le cadre théorique général est en tout point semblable à celui présenté supra, n° 106 et s. On ne revient donc pas dessus en détail.

§2 – Associer les acteurs régulés à la production et la mise en œuvre de la régulation des OJP : la voie de l'autorégulation et de la co-régulation

152. L'association des acteurs privés à la production et la mise en œuvre de la régulation conduit à une régulation prenant souvent la forme de grands principes généraux, plus acceptable que d'autres formes de régulation par les acteurs régulés.

A. L'association des acteurs privés à la production et la mise en œuvre de la régulation

153. Dans ce contexte d'inefficacité relative de la régulation publique, des techniques alternatives de régulation ont été explorées, tenant compte de l'existence d'asymétries informationnelles entre régulateur et régulés. Dans le cas des OJP, l'objectif est donc de mettre en œuvre des méthodes de régulation assurant la qualité des décisions judiciaires, en dépit de l'aptitude limitée du régulateur public à agir en ce sens.

Actant la supériorité informationnelle des acteurs privés sur le régulateur public, les techniques de régulation mobilisées reposent de manière générale sur la délégation par le second aux premiers d'une mission de production et de mise en œuvre de la régulation. Une telle délégation n'est pas spécifique au domaine de la justice prévisionnelle, mais s'observe dans des domaines d'activités très divers, dès lors qu'ils se caractérisent par une asymétrie informationnelle entre régulateur et agents régulés (par exemple, dans le domaine de la finance). Ce faisant, l'objectif est de tirer parti de l'information privée des experts et de permettre au régulateur public d'économiser les coûts d'information associés à l'activité de régulation (Ogus, 1995). Les acteurs privés se voient conséquemment conférer un rôle actif dans le processus de régulation, notamment sous la forme d'une mission d'autorégulation ou de co-régulation, conjointement avec le régulateur public. Dans ce cadre, il leur revient de déterminer et de mettre en œuvre la régulation qui s'appliquera à eux dans le cadre de leur activité de production d'OJP – ou de participer à la détermination et mise en œuvre de cette régulation. La solution apportée à l'opacité des algorithmes et aux asymétries informationnelles qu'ils créent est donc d'associer les acteurs privés – eux-mêmes largement à l'origine de cette opacité – à la régulation des OJP.

154. En pratique, l'autorégulation et la co-régulation prennent la forme de chartes, guides de bonnes pratiques, recommandations éthiques et autres instruments de la *soft law*¹⁸⁹. Ainsi que

¹⁸⁹ Dans le domaine de l'IA, un exemple de co-régulation donnant lieu à l'énonciation de standards généraux est fourni par l'action du National Institute for Standards and Technology (NIST), agence de l'US Department of Commerce, en collaboration avec les acteurs privés : <https://www.nist.gov/> (consultation le 12/7/2024).

souligné par Andler (2023, p. 330), « [a]ujourd’hui, quantité de chartes, directives, déclarations, codes éthiques pour l’intelligence artificielle ont été élaborés par toutes sortes d’instances publiques et privées, relevant des plus hautes sphères nationales et transnationales ou d’initiatives souvent prises et financées par les entreprises du Big Tech, parfois par des professionnels du domaine agissant à titre individuel ». Dans le cadre de la régulation des OJP, une place importante est reconnue à l’autorégulation par les acteurs privés, à travers des codes de bonne conduite et autres chartes éthiques privées. Parmi les enjeux du règlement sur l’intelligence artificielle relevés dans sa présentation par le ministère de la Justice (2024, p. 10), il est ainsi clairement indiqué que ce texte ne comporte que « [d]es contraintes faibles hors obligation de transparence pour les IA génératives », que les « systèmes à haut risque [sont] limités aux IA qui ont un impact substantiel sur la décision judiciaire ou assimilés (arbitrage, médiation) », et que les « codes de conduites [sont] à encourager, [en] prenant en compte des éléments tels que : a) les éléments applicables prévus dans les lignes directrices éthiques européennes pour une IA digne de confiance ; b) [l’]évaluation et [la] réduction de l’impact des systèmes sur l’environnement ; c) [la] sensibilisation et [l’]acculturation des équipes aux impacts négatifs... ».

Il est également précisé que « [l]es codes de conduite peuvent être élaborés par des fournisseurs ou des développeurs de systèmes d’IA ou par des organisations qui les représentent, ou par les deux, y compris avec la participation des utilisateurs, des développeurs et de toutes les parties prenantes intéressées et de leurs organisations représentatives, y compris les organisations de la société civile et les universités. En outre, les codes de conduite peuvent couvrir un ou plusieurs systèmes d’IA en tenant compte de la similitude de l’objectif visé par les systèmes concernés »¹⁹⁰.

155. Parmi les enjeux du règlement sur l’intelligence artificielle identifiés pour les praticiens du droit, le même document note la nécessité d’une « sensibilisation aux systèmes d’IA utilisés (fonctionnement, performance, biais, respect du RGPD...) » et d’une « réflexion éthique et déontologique sur les utilisations et leur impact sur les pratiques professionnelles et le système judiciaire » (*Ibid.*, p. 11).

¹⁹⁰ <https://cloud.openlaw.fr/s/G7mq4zNMs2aPaHx> (consultation le 12/7/2024).

B. Une régulation caractérisée par un degré élevé de généralité et d'abstraction

156. Dans les faits, l'autorégulation et la co-régulation passent fréquemment par l'énonciation de principes à portée très générale – par exemple, la transparence, l'explicabilité, la redevabilité – que les chartes, guides de bonnes pratiques et recommandations produites par autorégulation ou co-régulation ne s'attachent que rarement à opérationnaliser. Selon Andler (*Ibid.*, p. 337), ces différents types de documents « ne diffèrent sur aucun point essentiel, mais seulement dans le niveau de détail, dans l'organisation des relations entre les différents principes, valeurs et injonctions et dans leurs priorités », et « [les chartes] sont d'abord défensives : elles visent à prévenir ou à réduire les dommages que pourraient causer les systèmes d'IA (et qu'ils ont effectivement causés ou causent encore). Ces dommages consistent en des violations, délibérées ou non, de certaines valeurs qui sont tenues comme indiscutables, et ce qui est préconisé, de manière plus ou moins détaillée, sont des contre-mesures et des garde-fous capables d'éliminer puis d'empêcher de telles violations. À ce volet défensif, le plus important, s'ajoute un volet offensif, moins développé, consistant en injonctions à poursuivre le bien que l'intelligence artificielle devrait faire dans certains domaines et qu'elle pourrait faire si elle était mieux orientée » (*Ibid.*). De manière générale, le constat est donc que les normes régulant les OJP sont « trop théoriques », (John-Matthews, 2023, p. 293). Elles restent « abstraites et générales, et doivent être complétées par des normes plus opératoires et aisément identifiables à la lumière de l'expérience, celles dont la violation, effective ou potentielle, a suscité la riposte éthique et dont le respect est l'objectif affiché des chartes » (Andler, 2023, p. 337).

157. Dans le domaine des OJP, le rapport Cadiet de 2017 (Cadiet, 2017, p. 25) émet par exemple la recommandation de « réguler le recours aux nouveaux outils de justice dite "prédictive" par : - l'édiction d'une obligation de transparence des algorithmes ; - la mise en œuvre de mécanismes souples de contrôle par la puissance publique ; - l'adoption d'un dispositif de certification de qualité par un organisme indépendant ».

158. De la même façon, la Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement publiée en décembre 2018 par la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe énonce une série de grands principes qui seront étudiés dans la deuxième partie et pour lesquels nous avons réfléchi aux moyens de les opérationnaliser.

Sur le site du Conseil de l'Europe est ainsi explicitement rappelé que « [l]e point de vue de la CEPEJ, tel qu'énoncé dans la Charte, est que l'utilisation de l'IA dans le domaine de la justice peut contribuer à améliorer l'efficacité et la qualité du travail des tribunaux. Sa mise en œuvre doit se faire de manière responsable en conformité avec les droits fondamentaux garantis notamment par la Convention européenne des droits de l'homme (CEDH) et la Convention du Conseil de l'Europe pour la protection des données à caractère personnel. Pour la CEPEJ, il est crucial de garantir que l'IA reste un outil au service de l'intérêt général et que son utilisation se fasse dans le respect des droits individuels »¹⁹¹.

C. L'acceptabilité d'une régulation générale et abstraite

159. La production d'une régulation sous la forme de l'énoncé de grands principes généraux et œcuméniques a plusieurs avantages. Ces derniers ont été identifiés dans d'autres domaines par l'économie du droit dans des travaux sur le degré de précision optimal des règles de droit (le débat « *rules versus standards* »).

160. Tout d'abord, du point de vue des agents régulés, la mise en conformité des pratiques privées par rapport à ces principes généraux est considérée comme flexible, car permettant des aménagements locaux en fonction des besoins et contraintes particulières des acteurs à l'intérieur du cadre général. En outre, elle est présentée comme moins coûteuse pour les acteurs régulés qu'une règle contraignante uniforme (Harnay et Sachs, 2018). Conséquemment, une régulation sous la forme de grands principes est supposée emporter plus facilement l'adhésion volontaire des acteurs privés. Dans le contexte des OJP, marqué par des asymétries informationnelles fortes entre régulateur public et entreprises régulées et par l'incapacité du premier à contrôler de façon efficace les choix des secondes, l'argument de la conformité volontaire des acteurs privés à une régulation sous la forme de grands principes est indéniablement un argument fort en faveur de cette modalité de régulation.

161. Ensuite, le respect *ex ante* des grands principes énoncés par une régulation générale évite aux entreprises régulées le coût financier, juridique et réputationnel du contentieux et des sanctions *ex post*. En d'autres termes, plutôt que d'encourir le risque de la révélation *ex post* de

¹⁹¹ <https://www.coe.int/fr/web/cepej/ethical-charter-on-ai1> (dernière consultation le 12/7/2024).

résultats biaisés et discriminatoires de leurs algorithmes, et le coût du scandale afférent, il est préférable pour les acteurs privés de respecter *ex ante* la régulation, en intégrant *ex ante*, dès le stade de la conception (du « *design* ») de l'algorithme, les grands principes juridiques et éthiques posés par la régulation. On retrouve ici la problématique de l'*ethics by design*, également préconisée en tant que solution aux asymétries informationnelles entre utilisateurs, régulateurs et concepteurs des algorithmes dans d'autres secteurs d'activité recourant à des outils algorithmiques (ex. : régulation des algorithmes par le droit de la concurrence...). Selon cette logique d'« éthique par conception *a priori* » (Fischer, 2019, p. 64), l'objectif est de « maîtriser de bout en bout la façon dont les outils "doivent" se comporter, *a priori*, d'un point de vue moral » (*Ibid.*). À cette fin, les préoccupations éthiques doivent être intégrées aux algorithmes dès leur conception, par un codage de l'éthique. L'*ethics by design* renvoie donc directement à une logique *ex ante* de prévention et de contrôle, se substituant à la logique de sanctions *ex post* du droit classique, rendue difficile par l'asymétrie d'information entre le régulateur public et les agents régulés¹⁹².

162. Enfin, l'affichage de leur conformité aux grands principes de l'IA permet aux entreprises privées d'accroître la confiance dans leurs produits et services et, par suite, la demande pour leurs produits. Le respect des grands principes de la régulation fonctionne alors comme un signal de sa (bonne) qualité envoyé par la partie informée (l'entreprise informée de la qualité des OJP qu'elle propose sur le marché) à la partie non informée (les utilisateurs, les pouvoirs publics), conformément à la théorie du signal développée sur les marchés caractérisés par une asymétrie d'information sur la qualité entre vendeurs et consommateurs (Spence, 1973).

Ce raisonnement, à la base de l'analyse économique des labels, processus de certification et autres standards de qualité, est directement transposable aux entreprises conceptrices des OJP. En définitive, l'autorégulation et la co-régulation, en tant que techniques de régulation complétant la régulation publique ou s'y substituant, reposent donc largement – même si non exclusivement – sur l'affirmation de grands principes juridiques et éthiques de régulation des OJP, assez généraux et peu contraignants.

¹⁹² Lorsque le régulateur public encourage une telle régulation éthique *by design*, via la législation sur le numérique par exemple, l'*ethics by design* s'inscrit directement dans une logique de co-régulation par laquelle les acteurs régulés sont étroitement associés à la mise en œuvre des objectifs de la régulation. Incapable de contrôler *ex post* les choix et comportements des régulés, la puissance publique délègue à ces derniers la mission de contrôler eux-mêmes que leurs choix ne conduiront pas à des résultats inefficaces ou biaisés. Ce mode de régulation renvoie à la technique de la *compliance* (conformité) appliquée aujourd'hui dans de nombreux secteurs d'activités pour lesquels la puissance publique a délégué sa mission de régulation aux acteurs privés régulés – principalement en raison de leur supériorité informationnelle.

Ils reposent aussi sur l'hypothèse, largement implicite et donc peu remise en question, que les acteurs privés adhéreront spontanément à ces grands principes et les mettront volontairement en œuvre, y compris en l'absence de régulation publique les y contraignant. Certes, plusieurs organismes publics (la CNIL, l'Office européen de l'intelligence artificielle créé dans le sillage du RIA) sont en charge de faire respecter la régulation. Pour autant, l'autorégulation et la co-régulation ne s'appuient que sur peu d'outils contraignants pour assurer l'effectivité de la régulation sur les OJP. Le risque est donc celui qu'au-delà d'un consensus de façade sur les grands principes de régulation des OJP, l'effectivité de la régulation ne soit que limitée dans les faits.

§3 – Quelle effectivité d'une régulation des OJP ?

163. Plusieurs éléments font redouter que la régulation des OJP sous la forme de principes généraux largement produits conjointement avec les acteurs privés – au premier rang desquels les entreprises proposant les OJP – ne souffre d'une effectivité limitée, se traduisant par un effet négatif sur la qualité de la décision judiciaire.

164. Tout d'abord, les entreprises développant les OJP pourraient, dans certains cas, n'avoir qu'une capacité limitée à contrôler la qualité des résultats et décisions produits sur la base de leurs algorithmes. Ainsi, l'utilisation d'algorithmes de nouvelle génération, autonomes et fondés sur l'IA connexionniste, pourrait rendre difficile, voire impossible, la vérification de la conformité des OJP considérés aux règles de droit en vigueur, que le contrôle soit opéré par le régulateur public ou par les entreprises régulées. Il est utile de rappeler ici que l'IA connexionniste, basée sur des réseaux de neurones artificiels et le *deep learning*, capable d'apprentissage autonome et d'adaptation sans dépendre de règles posées initialement, est moins appréhendable par des humains (y compris donc ses concepteurs humains et les régulateurs) que les formes d'IA symbolique, et possède donc un degré d'explicabilité beaucoup plus faible que cette dernière. Les entreprises proposant des algorithmes fondés sur l'IA connexionniste pourraient donc se trouver dans l'incapacité de connaître le modèle de fonctionnement de l'algorithme et, par suite, d'exercer un contrôle sur son fonctionnement, ses résultats et ses performances. Conséquemment, les méthodes de contrôle *ex ante* et *ex post* s'appliquant pour des algorithmes utilisant l'IA symbolique pourraient ne plus être efficaces, amenant dès lors à repenser la régulation moins en termes de gestion du risque algorithmique que de gestion de l'incertitude – ce qui est vraisemblablement plus complexe.

165. En outre, les acteurs régulés pourraient dans certains cas ne faire preuve que d'une volonté limitée de respecter les grands principes de la régulation posés par le régulateur public. Par exemple, le principe de transparence pourrait n'avoir qu'une effectivité limitée si les acteurs régulés opposent l'argument du secret des affaires à la demande de transparence de leurs algorithmes qui leur est faite par la régulation, sous la forme d'une révélation de leur code source¹⁹³ (Pasquale, 2015 ; Lacour et Piana, 2019). Une entreprise à laquelle il est demandé de révéler son code source peut en effet arguer du caractère propriétaire de son algorithme et de ce que ses choix de conception initiaux ou de traitement des données constituent un avantage compétitif par rapport aux concurrents, dont le détail ne peut donc être divulgué. Une opposition peut alors se faire jour entre le principe juridique de transparence de l'algorithme et le secret commercial. On peut noter, cependant, que les forces de marché pourraient jouer un rôle disciplinant vis-à-vis des entreprises récalcitrantes. Ainsi, « [s]elon certains acteurs, cette opacité [des algorithmes] pourrait néanmoins être réduite par une décision étatique : puisque les tribunaux (et dans une moindre mesure les avocats) sont les seuls clients de COMPAS, ils contrôlent le marché et peuvent exiger l'application de nouvelles normes de transparence. Le marché est donc en situation de monopsonne, principalement contrôlé par la demande » (Bidou *et al.*, 2022, p. 10-11).

166. De plus, le contrôle de la qualité de leurs algorithmes a un coût pour les entreprises. Ce coût soulève la question de leur incitation à contrôler effectivement cette qualité, dès lors que leur supériorité informationnelle vis-à-vis des utilisateurs rend peu probable la détection des biais algorithmiques et de la faible performance des produits. Richardson *et al.* (2019) expliquent ainsi la réticence des offreurs d'OJP à s'atteler au problème des *dirty data*. Devant la faible probabilité que ne soient détectés les biais algorithmiques découlant de l'utilisation de données elles-mêmes biaisées ou de mauvaise qualité, les entreprises offrant les algorithmes pourraient faire sciemment le choix de la mauvaise qualité.

167. Par ailleurs, la conformité des entreprises à une régulation pourrait être principalement de façade. Dans ce contexte, les entreprises se conformeraient aux grands principes de la

¹⁹³ Cf. *supra*, n° 30. Tel avait été le cas dans l'affaire *State v. Loomis*, 881 N.W.2d 749 (Wis. 2016) où Monsieur Loomis s'est vu opposer le secret des affaires par la société Northpointe lorsqu'il a souhaité avoir des explications sur le fonctionnement de COMPAS afin de contester le score élevé de récidive qui lui avait été attribué par le logiciel.

régulation parce qu'ils y ont un intérêt économique et financier, mais se contenteraient du « service minimal ». Cette stratégie de conformité minimale serait notamment permise par l'infériorité informationnelle du régulateur public¹⁹⁴, incapable d'évaluer le niveau réel de conformité des acteurs privés à la régulation, et pourrait alors donner lieu à des pratiques d'*ethics washing*, principalement motivées du point de vue des entreprises régulées par la recherche de leur intérêt privé. Cette situation rejoint les analyses d'Andler (2023) définissant, parmi différentes conceptions de l'éthique des systèmes d'intelligence en vigueur aujourd'hui, une conception « constitué[e] par ce qu'on pourrait appeler la propagande éthique : il s'agit, pour les entreprises et divers groupements industriels, d'afficher des objectifs de responsabilité sociale. Cet affichage peut être motivé par le souci de corriger une image négative de la profession dans son ensemble ou d'une entreprise particulière, et de convaincre un public hostile de sa bonne volonté et de sa capacité à résoudre certains problèmes : bref, d'instaurer un climat de confiance entre la technologie et les citoyens, en convainquant ces derniers que la technologie en cours d'élaboration est, justement, digne de confiance (« *trustworthy* »). Mais il peut aussi s'agir de détourner l'opinion et les pouvoirs publics de toute velléité d'imposer des contraintes réglementaires qui freineraient l'innovation et compromettraient la rentabilité » (Andler, 2023, p. 334).

168. Enfin, la régulation des OJP pourrait n'être que faiblement effective parce que capturée par les agents qu'elle est censée réguler. L'information asymétrique du régulateur public le place en effet en situation de dépendance informationnelle par rapport aux entreprises privées régulées, qui peuvent être tentées d'influencer le contenu de la régulation des OJP dans le sens de leurs intérêts particuliers, en transmettant au régulateur public une information biaisée. Ce phénomène, identifié dans la littérature économique comme une situation de capture informationnelle, est documenté dans de nombreux secteurs d'activités. Il prend notamment la forme de la transmission d'information excessivement sophistiquée et complexe, impossible ou trop coûteuse à traiter pour un régulateur dépourvu de l'expertise suffisante et des ressources financières, humaines et techniques suffisantes (Hakenes et Schnabel, 2014). « Noyé » sous l'information transmise par les acteurs régulés, le régulateur public n'a alors pas d'autre choix pour produire et mettre en œuvre la régulation que d'utiliser cette information dont il n'a pas les moyens de vérifier la véracité et le caractère « désintéressé ». Il en résulte, dans de nombreux cas documentés empiriquement, une capture de la régulation par les intérêts privés. Dans le cas

¹⁹⁴ Cf. supra, n° 105 et s.

des OJP, et au-delà de la complexité réelle et indéniable des systèmes d'IA impliqués, cette stratégie pourrait par exemple expliquer le choix d'une régulation sous la forme de grands principes, et non pas (ou moins) sous la forme de dispositifs techniques contraignants, les acteurs privés ayant souvent, on l'a vu, intérêt à une régulation générale et englobante.

169. **Conclusion.** Les effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire sont en définitive ambigus, et peuvent être positifs ou négatifs, selon les dimensions de la qualité judiciaire considérées, les caractéristiques intrinsèques et le fonctionnement des OJP envisagés et les utilisations et usages qui en sont faits par les juges. Ce constat motive la mise en place d'une régulation des OJP orientée vers l'information des utilisateurs, passant par une transparence accrue en matière de choix de conception et de modélisation des OJP, de fonctionnement de leurs algorithmes et d'explicabilité. Cependant, pour souhaitable qu'elle soit, une telle régulation peut n'être que faiblement effective, dès lors qu'elle prend aujourd'hui le plus souvent la forme de principes généraux faiblement contraignants pour les entreprises conceptrices des OJP et les utilisateurs. Plus que sur les contenus des grands principes de la régulation des OJP, qui font aujourd'hui consensus et sont largement intégrés dans le droit, il semble donc important de réfléchir à l'opérationnalisation de ces grands principes et à des formes juridiques innovantes garantissant leur effectivité. Tel est l'objectif de la deuxième partie du rapport qui, en outre, analyse plus substantiellement les cadres – existants ou souhaitables – de la régulation des OJP.

Deuxième partie – Les cadres de la régulation des outils de justice prévisionnelle

170. À l’analyse des cadres réglementaires – actuels et/ou souhaitables – des outils de justice prévisionnel (Titre 1) succèdera une étude des moyens de leur mise en œuvre (Titre 2).

Titre 1 – L’analyse des cadres réglementaires¹⁹⁵

171. Actuellement il existe un petit nombre de dispositions assurant spécialement la régulation des outils de justice prévisionnelle (Chapitre 1) mais un nombre important de dispositions générales peuvent venir assurer cette régulation (Chapitre 2).

Chapitre 1 – Les dispositions spéciales applicables aux outils de justice prévisionnelle

172. Au niveau international, européen, comme national, il n’existe véritablement aucune règle de droit, à proprement parler, applicable spécialement aux outils de justice prévisionnelle, à l’exception des dispositions françaises concernant la réutilisation des décisions de justice (Section 1). En revanche, il existe des principes éthiques adoptés dans le cadre du Conseil de l’Europe, qui sans être spécifiques aux outils de justice prévisionnelle, sont propres à l’utilisation de l’intelligence artificielle en matière de droit et de justice (Section 2).

Section 1 – Les textes français relatifs à la réutilisation des décisions de justice en *open data*

173. **Faible intérêt du législateur pour la réutilisation des décisions de justice en *open data*.** En France, nous l’avons vu, un nombre important de lois et de règlement organisent l’*open data* des décisions de justice¹⁹⁶ mais parmi ces textes, les dispositions encadrant spécifiquement

¹⁹⁵ Par Aurore Hyde

¹⁹⁶ Cf. *supra*, n° 17 et s.

la réutilisation des données judiciaires en *open data* sont peu nombreuses et s'appliquent sans distinction selon que la réutilisation se fait à des fins commerciales ou non.

174. Réutilisation largement ouverte. L'article L. 111-13 du Code de l'organisation judiciaire régit la mise à disposition du public des décisions judiciaires. Son alinéa 4 prévoit que les articles L. 321-1 à L. 326-1 du Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) sont applicables à la réutilisation des informations publiques figurant dans les décisions rendues par les juridictions judiciaires qui sont mises à la disposition du public à titre gratuit sous forme électronique.

En substance, ces dispositions prévoient que la réutilisation peut se faire par toute personne hors cadre de mission de service public¹⁹⁷, dans le respect de l'intégrité des données réutilisées¹⁹⁸ et des dispositions de la loi relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés lorsque la réutilisation porte sur des données contenant des données à caractère personnel¹⁹⁹.

Il est également prévu que la réutilisation puisse faire l'objet d'une licence²⁰⁰. À ce titre, la Cour de cassation a adopté une licence ouverte, qui indique de façon générale que « le "réutilisateur" est libre de réutiliser l' "information" : de la reproduire, la copier, de l'adapter, la modifier, l'extraire et la transformer pour créer des "informations dérivées", des produits ou des services, de la communiquer, la diffuser, la redistribuer, la publier et la transmettre, de l'exploiter à titre commercial, par exemple en la combinant avec d'autres informations, ou en l'incluant dans son propre produit ou application »²⁰¹.

175. Pratiques interdites. Au titre des seules pratiques interdites, on relève celles consistant à réutiliser les données judiciaires à des fins de profilage du personnel judiciaire. L'article L. 111-13 al. 3 du Code de l'organisation judiciaire²⁰² prévoit en effet que « les données d'identité des magistrats et des membres du greffe ne peuvent faire l'objet d'une réutilisation ayant pour objet ou pour effet d'évaluer, d'analyser, de comparer ou de prédire leurs pratiques professionnelles réelles ou supposées. La violation de cette interdiction est punie des peines

¹⁹⁷ Article L. 321-1 CRPA.

¹⁹⁸ L'article L. 322-1 CRPA dispose : « La réutilisation des informations publiques est soumise à la condition que ces dernières ne soient pas altérées, que leur sens ne soit pas dénaturé et que leurs sources et la date de leur dernière mise à jour soient mentionnées ».

¹⁹⁹ Article L. 322-2 CRPA.

²⁰⁰ Art. L. 323-1 CRPA.

²⁰¹ <https://www.courdecassation.fr/conditions-generales-dutilisation-pour-la-reutilisation-des-donnees-issues-des-decisions-de-justice>

²⁰² L'interdiction est la même s'agissant des juges administratifs et des membres du greffe (cf. art. L. 10 al. 3 du Code de justice administrative)

prévues aux articles 226-18, 226-24 et 226-31 du Code pénal, sans préjudice des mesures et sanctions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ». Et l'on retrouve cette interdiction dans les conditions générales pour la réutilisation des données issues des décisions de l'ordre judiciaire diffusées en *open data* par la Cour de cassation²⁰³. L'encadrement de la réutilisation des décisions de justice est donc minimal. Face aux craintes exprimées, dès 2017, à propos des outils dits, à l'époque, de justice prédictive, on pouvait légitimement s'attendre à ce que le législateur encadre mieux la réutilisation des décisions de justice à des fins commerciales afin de restaurer la confiance²⁰⁴. Mais c'est la protection des données à caractère personnel qui a concentré les efforts du législateur en la matière.

176. Concentration de l'encadrement sur la protection des données à caractère personnel. La seule limitation de la réutilisation à des fins de profilage du personnel judiciaire s'explique peut-être par le fait que la protection des données à caractère personnel ait focalisé toute l'attention du législateur. Allant plus loin que la loi du 7 octobre 2016²⁰⁵, celle du 23 mars 2019²⁰⁶ a organisé, avec son décret d'application²⁰⁷, le régime des occultations nécessaires avant toute mise à disposition des décisions de justice au public. Les noms et prénoms des personnes physiques mentionnées dans la décision doivent ainsi être systématiquement occultés²⁰⁸. Et si malgré cette occultation, la mise à disposition de la décision risque de porter atteinte à la sécurité ou au respect de la vie privée des personnes physiques mentionnées dans la décision ou de leur entourage, le président de la formation de jugement ou le magistrat ayant statué ou bien encore un magistrat ou un membre du greffe peut solliciter l'occultation d'éléments de nature à porter atteinte à sa sécurité ou à sa vie privée auprès du président de la juridiction uniquement²⁰⁹. L'occultation de certaines informations sensibles susceptibles de porter atteinte au secret des affaires ou aux intérêts fondamentaux de la nation pour les

²⁰³ <https://www.courdecassation.fr/conditions-generales-dutilisation-pour-la-reutilisation-des-donnees-issues-des-decisions-de-justice>

²⁰⁴ Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », *Revue pratique de la prospective et de l'innovation*, 2016, étude 4 ; Dondero B., « Justice prédictive, la fin de l'aléa judiciaire ? », *Recueil Dalloz*, 2017, p. 532 et s. ; Rouvière F., « La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », *Revue trimestrielle de droit civil*, 2017, p. 527 et s. ; Cassuto Th., « La justice à l'épreuve de sa prédictibilité », *Actualité juridique Droit pénal*, 2017, p. 334.

²⁰⁵ Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui prévoit une mise à disposition des données détenues par les administrations, dont les décisions de justice.

²⁰⁶ Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2015-8-2022 pour la justice, qui prévoit la mise en application de la diffusion des décisions de justice.

²⁰⁷ Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

²⁰⁸ Art. L. 111-13 al. 2 COJ.

²⁰⁹ Art. R. 111-12 COJ ; art. R. 741-14 CJA.

juridictions administratives est également possible sur décision du procureur de la République ou du procureur général²¹⁰.

La Cour de cassation étudie l'élaboration d'une doctrine des occultations complémentaires. Des groupes de travail ont été mis en place et ont préconisé notamment que cette doctrine s'élabore par type de contentieux²¹¹.

Par ailleurs, la haute juridiction s'est attelée à la pseudonymisation²¹² des décisions disponibles avant de les mettre en *open data*. Pour ce faire, elle a conçu le projet LABEL (Logiciel d'anonymisation d'une base enrichie labellisée)²¹³.

À noter également, l'interdiction résultant des alinéas 1 et 2 de l'article 47 de la loi Informatique et Libertés qu'une décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne ait pour seul fondement un traitement automatisé de données à caractère personnel pour évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne, ou qu'une décision produisant des effets juridiques à l'égard d'une personne ou l'affectant de manière significative soit prise sur le seul fondement d'un traitement automatisé de données à caractère personnel (sauf exceptions). Cependant, ces hypothèses ne visent pas directement les outils de justice prévisionnelle dans la mesure où ceux-ci ne sont pas des outils de prise de décision mais seulement des outils d'aide à la décision²¹⁴.

177. **Pistes pour un encadrement renforcé.** Le législateur français aurait pu aller plus loin et, à l'instar de voisins européens, interdire certaines finalités pour la réutilisation des données judiciaires²¹⁵, ou prévoir un accès payant lorsque la réutilisation est employée à des fins commerciales²¹⁶.

En effet, si le principe est celui de la gratuité de l'accès à la donnée publique, le Code des relations entre le public et l'administration prévoit la possibilité de solliciter une redevance de

²¹⁰ Art. R. 168 COJ

²¹¹ « Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice », p. 12 : <https://www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/rapport-du-cycle-dateliers-sur-lethique-de-la-1>

²¹² La pseudonymisation vise à rompre tout lien entre des données à caractère personnel et leur titulaire. Elle consiste généralement à substituer aux données à caractère personnel d'autres éléments (une lettre à la place d'un nom par exemple, ou un mot [ex. localité] à la place d'une adresse (art. 4 § 5 RGPD)

²¹³ <https://www.courdecassation.fr/la-cour-de-cassation/demain/lopen-data-des-decisions-judiciaires>

²¹⁴ Sur cette distinction voir la thèse de L. Huttner, *La décision de l'algorithme*, Étude de droit privé sur les relations entre l'humain et la machine, préf. J. Rochfeld, Dalloz, coll. Nouv. Bibliothèque des thèses, vol. 235, 2024

²¹⁵ L'Irlande et le Portugal ont interdit que les données judiciaires soient réutilisées à des fins commerciales ou publicitaires, ou de manière frauduleuse, malhonnête, fallacieuse, offensante, immorale, offensante : *Tableau comparatif sur l'encadrement de l'accès en données ouvertes aux décisions de justice, Synthèse des réponses*, Ministère de la justice, 2023, p. 4 : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/rapport_pfue_sem_cmjn%20%281%29.pdf

²¹⁶ C'est le cas de l'I : *Tableau comparatif* précité, p. 1

réutilisation lorsque « les administrations sont tenues de couvrir par des recettes propres une part substantielle des coûts liés à l'accomplissement de leurs missions de service public ». Le coût auquel doit faire face la Cour de cassation pour mettre en œuvre l'*open data* (retravailler les données judiciaires pour les mettre dans un format lisible sur Judilibre ; pseudonymiser les données ; maintenance de l'API Judilibre ; etc.) pourrait ainsi être en partie compensé.

Par ailleurs, la directive du 20 juin 2019 relative à la réutilisation des données publiques ouvertes n'empêche pas une différence de tarification selon que la réutilisation est commerciale ou non commerciale²¹⁷ (considérant 46).

On aurait pu encore envisager de limiter l'usage des outils de justice prévisionnelle aux matières civile, commerciale et sociale, à l'exclusion donc de la matière pénale.

178. L'absence de dispositions propres aux outils de justice prévisionnelle est contrebalancée par l'existence de normes éthiques en la matière.

Section 2 – Les principes issus de la Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement

179. **Contexte d'adoption de la Charte éthique.** Pour répondre aux diverses craintes exprimées à l'égard des outils dits, à l'époque, de justice prédictive, la Commission européenne pour l'efficacité de la justice (CEPEJ) du Conseil de l'Europe a adopté, le 4 décembre 2018, une Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement²¹⁸. Ce travail avait essentiellement pour ambition de proposer des pistes pour une utilisation éthique et vertueuse des applications reposant sur l'intelligence artificielle dans le domaine de la justice. Il en résulte une série de cinq principes éthiques²¹⁹ censés guider la conception, le déploiement et l'utilisation de l'IA dans le domaine de la justice. En cela donc, les outils de justice prévisionnelle entrent directement dans le champ de la Charte.

180. **Normativité des principes éthiques contenus dans la Charte éthique.** L'instrument choisi – une charte éthique – ne crée pas directement d'obligations à la charge des fournisseurs

²¹⁷ Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 concernant les données ouvertes et la réutilisation des informations du secteur public (refonte).

²¹⁸ <https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b>

²¹⁹ Cf. infra, n° 184 et s. pour leur présentation.

ni de droits subjectifs à l'égard des justiciables. Il constitue à cet égard du droit souple²²⁰ dont l'application dépend largement de la bonne volonté des opérateurs de s'y conformer.

Les principes éthiques qui en résultent n'en sont pas pour autant privés de toute force normative²²¹. Ils pourront notamment guider l'action du juge en cas de litige. En effet, lorsqu'elle n'est pas traduite dans une norme juridique, la norme éthique peut être mobilisable à l'appui ou à l'encontre d'une norme juridique, pour en préciser la portée par exemple. En cela, la norme éthique apparaît comme une source complémentaire du droit²²².

181. Principe de respect des droits fondamentaux. Ce principe entend « assurer une conception et une mise en œuvre des outils et des services d'intelligence artificielle qui soient compatibles avec les droits fondamentaux »²²³. Était-il utile de rappeler la nécessité de respecter les droits fondamentaux, à tous les stades de la vie d'un outil intégrant de l'IA, dans un ordre juridique entièrement soumis à la « fondamentalisation »²²⁴ ? Une réponse affirmative s'impose car ce faisant, les risques graves d'atteintes que porte en elle l'utilisation de l'intelligence artificielle en matière de justice sont ainsi mis en avant²²⁵. S'agissant des outils de justice prévisionnelle, il s'agit bien sûr du droit au procès équitable et des prérogatives qui en découlent, comme cela a été montré dans la première partie du rapport²²⁶.

Sont également en cause le droit à la protection des données à caractère personnel²²⁷ et le droit au respect de la vie privée²²⁸. En France, le respect de ces droits passe par l'effort de

²²⁰ « Le droit souple », Étude annuelle du Conseil d'État, La Documentation française, 2013.

²²¹ Thibierge C. (dir.), *La force normative. Naissance d'un concept*, LGDJ, Hors collection, 2009

²²² Voir à cet égard les travaux conduit par Emmanuelle Marceau dans ses cycles de séminaires à l'IERDJ sur le thème de « L'éthique comme source complémentaire du droit dans la fonction de juger » : <https://gip-ierdj.fr/fr/evenements/atelier-lethique-comme-source-complementaire-du-droit-dans-la-fonction-de-juger-cycle/>

²²³ <https://www.coe.int/fr/web/cepej/ethical-charter-on-ai>

²²⁴ Ce néologisme d'origine doctrinale désigne le phénomène par lequel les droits fondamentaux se diffusent et s'imposent dans toutes les branches du droit. Cf. Benezech L., « La diffusion des droits fondamentaux dans l'ordre juridique interne sous l'influence de la Convention européenne des droits de l'Homme. : contribution à l'étude de la fondamentalisation des droits », thèse de droit, Université Clermont Auvergne, 2019.

²²⁵ De manière général, l'impact des systèmes d'IA sur les droits fondamentaux est un critère essentiel pour la détermination de la gravité du risque encouru, selon l'approche par les risques retenue par la Commission européenne pour l'encadrement de l'IA.

²²⁶ Cf. supra n° 25 et s.

²²⁷ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil, 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (RGPD) ; Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; article 8 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.

²²⁸ En France, la loi pour une République numérique a rappelé la nécessité que l'*open data* des décisions de justice se fasse « dans le respect de de la vie privée des personnes concernées » (articles 20 et 21 de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016).

pseudonymisation²²⁹ des décisions de justice fourni par la Cour de cassation. Néanmoins, à la différence de l'anonymisation, la pseudonymisation n'empêche pas totalement toute réidentification²³⁰. Les fournisseurs d'outil de justice prévisionnelle sont donc également tenus de veiller au respect de la protection des données à caractère personnel et de la vie privée, même pour les données en *open data* et *a fortiori* pour les données hors *open data*, récupérées auprès de services de greffe par exemple. Par ailleurs, cette exigence s'impose encore dans l'hypothèse où ils obtiennent des flux intègres en contrepartie d'une redevance²³¹, comme le faisaient les partenaires industriels du projet au moment où les travaux de recherche ont débuté²³². Le respect de cette exigence a été particulièrement étudié au stade de l'analyse de risques²³³.

En outre, les fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle peuvent aller plus loin que les exigences légales et pseudonymiser ou anonymiser par exemple le nom des magistrats pour éviter toute tentation d'un profilage des décisions²³⁴.

On pense encore au droit à la non-discrimination mais le respect de ce droit fait l'objet d'un principe spécifique.

182. Principe de non-discrimination. Ce principe vise à « prévenir spécifiquement la création ou le renforcement de discriminations entre individus ou groupes d'individus »²³⁵. Il était là encore utile d'en faire un principe autonome indépendamment du fait que le droit à la non-discrimination est un droit fondamental. En effet, les systèmes d'intelligence artificielle sont naturellement des amplificateurs de biais.

D'une part, les données ne parlent pas d'elles-mêmes. Au contraire, « de multiples médiations techniques sont indispensables pour leur faire signifier quoi que soit »²³⁶. Tout modèle est par

²²⁹ La pseudonymisation est une exigence minimale pour le respect de la vie privée des personnes concernées : Cadiet L., « L'open data des décisions de justice », Rapport remis à Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, novembre 2017, spéc. p. 65 et s.

²³⁰ La réidentification peut se faire soit par méthode de l'« insider », quand on part d'informations personnelles pour trouver une décision, soit par méthode de l'« outsider », quand on part d'une décision et que l'on croise différents éléments pour retrouver la personne concernée : Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice, p. 12 : <https://www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/rapport-du-cycle-dateliers-sur-lethique-de-la-1>

²³¹ Arrêté du 23 mars 2009 fixant le montant des redevances perçues notamment en contrepartie de la délivrance des décisions de justice par la Cour de cassation sur le fondement de l'article R. 421-10-1 du Code de l'organisation judiciaire, disposition abrogée par le décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

²³² La distinction entre les types de flux (intègre ou non) pourrait continuer d'ailleurs à conserver une utilité afin que l'État ne perde pas la valeur de la matière première que représentent les données jurisprudentielles (Épineuse H. et Garapon A., « Les défis d'une justice à l'ère numérique de "stade 3" », *Enjeux numériques*, n° 3, sept. 2018, Annales de l'école des Mines, p. 18 et s.).

²³³ Cf. infra, n° 282 et s.

²³⁴ Ce que faisait Lexbase pour LegalMetrics.

²³⁵ <https://www.coe.int/fr/web/cepej/ethical-charter-on-ai>

²³⁶ Garapon A. et Lassègue J., *Justice digitale*, PUF, 2018, p. 131.

essence une approximation reflétant les choix de son concepteur²³⁷ : choix des données d'entraînement, choix dans leur annotation²³⁸ ou dans leur étiquetage, choix des critères retenus pour le traitement des données, choix dans la pondération entre les critères, choix des algorithmes²³⁹, etc. Chacune de ces opérations porte en elle les biais cognitifs des concepteurs²⁴⁰ (issus de préjugés ou de connaissances insuffisantes).

D'autre part, toutes les données reflètent naturellement quantité de biais et de manière générale, leur traitement massif par l'IA peut créer ou renforcer des discriminations²⁴¹. Une étude de chercheurs du Massachusetts Institute of Technology a par exemple montré que le manque de données relatives au crédit pour les minorités faussait la précision des algorithmes prédictifs en matière d'attribution de crédit²⁴².

Cette difficulté est transposable à la matière judiciaire, les données issues des décisions de justice reflétant quantité de biais historiques, politiques, culturels, sociétaux. Si l'utilisation de l'IA pour le traitement des données judiciaires peut s'avérer particulièrement utile pour un chercheur, afin précisément de faire ressortir les biais existants dans les décisions (en donnant à voir par exemple qu'à conditions égales, les hommes sont généralement moins bien traités que les femmes dans le contentieux familial), il en est autrement en matière de justice prévisionnelle où l'IA risque d'avoir pour effet de figer les biais existants et de les reproduire à grande échelle.

183. Multitude de biais possibles. Parmi les multiples biais algorithmiques possibles, les plus fréquents sont :

- les *biais de sélection*, quand certaines données ne sont pas du tout considérées (ex : un algorithme d'octroi de crédit ne s'entraîne que sur les crédits octroyés dans le passé) ;

²³⁷ Jean A., *De l'autre côté de la machine*, Éditions de l'Observatoire, coll. De facto, 2019, spéc. p. 89 et s.

²³⁸ L'annotation des données est un processus clé en matière d'IA. Il permet par attribution, marquage ou étiquetage des données d'aider les algorithmes d'apprentissage automatique à comprendre et à classer les informations qu'elles contiennent.

²³⁹ Domingo P., *The Master Algorithm*, Penguin, Science/Tech, 2015.

²⁴⁰ Bertail P., Bounie D., Cléménçon S., Waelbroeck P., « Algorithmes : biais, discrimination et équité », Telecom ParisTech, Fondation Abeona, février 2019, accessible en ligne : <https://www.telecom-paris.fr/wp-content/uploads/2019/02/Algorithmes-Biais-discrimination-equite.pdf> ; « Algorithmes : : contrôle des biais S.V.P. », Rapport de l'Institut Montaigne, mars 2020, accessible en ligne : <https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/algorithmes-contrôle-des-biais-svp.pdf>

²⁴¹ O'Neil C., *Weapons of Math Destruction: How Big Data increases inequality and threatens democracy*, NY Broadway Books, 2016 ; Cui G., Evidence-Based Sentencing and the Taint of Dangerousness, 125 *The Yale Law Journal Forum*, 315 (2016), <http://www.yalelawjournal.org/forum/evidence-based-sentencing-and-the-taint-of-dangerousness>

²⁴² <https://www.technologyreview.com/2021/06/17/1026519/racial-bias-noisy-data-credit-scores-mortgage-loans-fairness-machine-learning/>

- les *biais de représentation*, quand les données sélectionnées ne reflètent pas la diversité de la réalité du fait d'une équipe de conception non inclusive (ex : un algorithme de reconnaissance faciale n'a été entraîné qu'à partir de photos d'homme blancs car l'équipe de conception n'est composée que d'hommes blancs) ;
- les *biais historiques*, quand les données contiennent les biais sociaux de son époque et de son territoire (ex : un algorithme de sélection des curriculum vitae entraîné à partir de données dans lesquelles ce sont les hommes qui ont été sélectionnés pour les postes à haute responsabilité) ;
- les *biais de mesure*, quand les critères choisis pour traiter les données ne sont pas pertinents (ex. un système de diagnostic médical formé pour prédire la probabilité de maladie sur la base de mesures indirectes, telles que le nombre de visites médicales de la personne plutôt que le nombre de symptômes réels) ;
- les *biais d'agrégation*, quand le modèle repose sur des données traitées globalement sans avoir été suffisamment structurées puis contextualisées (ex. un modèle qui compare le taux de réussite d'étudiants en distanciel ou en présentiel sur la base de données ne faisant pas état du statut des étudiants – salariés ou non – ou de leur situation familiale – avec ou sans enfant par exemple) ;
- les *biais d'évaluation*, quand un modèle est évalué selon une métrique non pertinente (ex : valider un modèle sur MNIST ne garantit pas sa portabilité sur la graphie française des chiffres).

184. **Illustration 1 : biais dans l'annotation des décisions de justice.** En matière de justice prévisionnelle, cela peut se traduire par exemple au stade de l'annotation des décisions. Certains éléments peuvent avoir été étiquetés à tort comme à prendre en compte dans la solution du litige (ex. le genre de la personne concernée) et devenir ensuite un critère pour la détermination de solutions à venir. Or, une différence de traitement fondée sur le genre peut être une cause de discrimination²⁴³.

Dès lors, il convient de prêter attention à la mesure dans laquelle certains critères sont choisis pour annoter une décision aux fins de traitement algorithmique. En effet, certains motifs sont

²⁴³ En effet, en vertu de l'art. 225-1 du Code pénal, « constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement (...) de leur sexe (...) ».

illicites pour fonder une distinction dans le traitement des personnes²⁴⁴, à moins que leur utilité soit spécialement justifiée²⁴⁵.

185. Illustration 2 : biais dans le choix de la métrique d'évaluation d'un outil de justice prévisionnelle. Le choix de la métrique d'évaluation du système peut également être une source de discrimination. Tel est l'enseignement à tirer des travaux de recherche sur le logiciel d'analyse de risques de récidive COMPAS (*Correctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions*), utilisé par les juges américains comme aide à la décision dans la détermination du quantum de la peine pénale. Des chercheurs ont montré que l'outil COMPAS désavantageait systématiquement les populations noires américaines dans la prédiction du risque de récidive²⁴⁶, ce qui est de toute évidence discriminatoire. En réponse, la société ayant développé le logiciel a montré qu'elle avait évalué son outil et que celui-ci avait un bon score de « rappel ». Autrement dit, selon cette métrique d'évaluation, le système se fondait sur un nombre important de données pertinentes pour proposer un résultat (vrais positifs). Mais les chercheurs ont montré que le logiciel manquait en revanche de « précision » (une autre métrique de référence en matière d'évaluation de l'IA). Il prenait donc également en compte de nombreuses données non-pertinentes. Or, ce manque de précision avait eu pour effet de fausser la prédiction au détriment des afro-américains, créant de ce fait une discrimination. Selon la métrique d'évaluation privilégiée donc, l'impact ne sera pas le même sur des groupes d'individus minoritaires ce qui peut aboutir à créer des discriminations à leur encontre²⁴⁷. Il n'est donc pas souhaitable de laisser le choix des métriques d'évaluation des biais à l'initiative du concepteur car cela peut lui permettre de dissimuler une discrimination²⁴⁸.

186. Illustration 3 : manque de représentativité des données contenues dans les décisions. Si les données judiciaires traitées allouent des indemnités plus importantes aux femmes qu'aux hommes dans un contentieux déterminé, ce biais se répercutera en sortie du

²⁴⁴ L'article 225-1 précité liste les motifs illicites.

²⁴⁵ Par exemple, l'âge comme l'état de santé sont des critères légaux à prendre en considération dans la détermination du montant de la prestation compensatoire (art. 271 du Code civil).

²⁴⁶ Angwin J., Larson J., Mattu S., Kirchner L., May 23, 2016, « Machine Bias », ProPublica : <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

²⁴⁷ Tarissan F., « Algorithm and Machine Learning. The biases of predictive models under scrutiny », Workshop on Big Data in the Counter Terrorism Context, Asser Institute & ICCT, 25 janvier 2021.

²⁴⁸ Besse Ph. Et Castets-Renard C., « Responsabilité ex ante de l'AI act : entre certification et normalisation, à la recherche des droits fondamentaux au pays de la conformité », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 597 et s., spéc. n° 26.

traitement pour proposer systématiquement des indemnités d'un montant amoindri lorsque le demandeur est un homme.

Il est donc nécessaire pour un fournisseur d'outil de justice prévisionnelle d'avoir conscience des biais pouvant exister et de veiller à les corriger²⁴⁹. Pour cette raison, la représentativité des données a fait l'objet d'une étude dans les analyses de risques conduites auprès des partenaires industriels²⁵⁰.

187. **Le principe de qualité et de sécurité.** Ce principe implique, pour le traitement des données judiciaires, « d'utiliser des sources certifiées et des données intangibles avec des modèles conçus d'une manière multi disciplinaire, dans un environnement technologique sécurisé »²⁵¹. Le fait que les conditions de l'*open data* soient assurées en France, pour l'ordre judiciaire, par la Cour de cassation, est de nature à garantir la qualité tant de la source que des données elles-mêmes. Mais les fournisseurs d'outils, comme les utilisateurs, doivent veiller à ce qu'elles ne peuvent pas, par la suite, être corrompues ou détournées par des tiers. Là encore, le respect de cette exigence a été étudié concrètement dans les analyses de risques conduites²⁵². S'agissant des modèles, le principe de qualité implique que les fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle doivent collaborer avec les professionnels de la justice pour préciser les besoins et les attentes en la matière. Par ailleurs, il est souhaitable que les équipes affectées à l'élaboration de ces outils mêlent plusieurs compétences : celles des juristes évidemment, mais aussi celles des linguistes, des éthiciens, ou encore des économistes.

S'agissant spécifiquement des compétences juridiques, il est crucial de confier la détermination des critères propres à traiter les décisions à des experts du contentieux analysé. C'est là une manière de s'assurer que les critères retenus sont suffisamment pertinents et qu'aucun critère pertinent n'a été délaissé.

188. **Illustrations.** Dans le traitement du contentieux de la responsabilité pour faute par exemple, il est nécessaire que le critère tiré de la faute de la victime ait été pris en compte pour analyser les données. À défaut, les résultats en sortie ne seront pas pertinents. En effet, la faute de la victime est de nature à diminuer son droit à indemnisation. À dommage égal, les décisions

²⁴⁹ Cf. infra, n° 197 et s.

²⁵⁰ Cf. infra, n° 282 et s.

²⁵¹ <https://www.coe.int/fr/web/cepej/ethical-charter-on-ai-l>

²⁵² Cf. infra, n° 282 et s.

alloueront donc nécessairement une indemnité moindre à la victime qui aura contribué, par sa faute, à son dommage.

Un autre exemple est fourni dans le contentieux relatif aux indemnités de licenciement. Si l'état de santé du salarié n'est pas un critère récurrent pour déterminer le montant des indemnités, il devient un critère important lorsqu'il est pris en compte. Dès lors, une démarche de conception consistant à ne retenir comme pertinents que les critères récurrents dans un nombre important de décisions pose question en termes de qualité car il n'est pas rare que, d'une décision à l'autre, des critères soient pris en compte de manière exceptionnelle tout en étant prépondérants dans la décision.

189. **Le principe de transparence, de neutralité et d'intégrité intellectuelle.** Ce principe implique de « rendre accessibles et compréhensibles les méthodologies de traitement des données, autorisant les audits externes »²⁵³. En réalité, sous ce principe, plusieurs objectifs sont visés. D'abord, il s'agit de rendre publics les choix réalisés pour concevoir un outil de justice prévisionnelle (**transparence**) mais aussi de rendre le système intelligible pour un expert du domaine et compréhensible pour un profane (**explicabilité**).

L'accès à la démarche de conception du système, à sa logique de fonctionnement, doit donc être assuré pour rendre la décision (c'est-à-dire le résultat) qu'il prend explicable. En effet, une décision algorithmique devient explicable s'il est possible de mettre en relation les valeurs prises par certaines variables (les caractéristiques) et leurs conséquences sur la prévision, par exemple un score²⁵⁴. Le respect de cette double exigence implique notamment de tenir à jour une documentation sur « le processus de constitution des bases de données [et] de la logique présidant à la constitution d'échantillons d'apprentissage »²⁵⁵ ou encore sur « les variables utilisées »²⁵⁶. Cela implique également de choisir des méthodes et des modèles qui se prêtent mieux à l'explicabilité (ce qui est moins le cas des systèmes d'IA reposant sur l'apprentissage machine profond).

En matière de justice prévisionnelle, il y a lieu de considérer que seuls les outils permettant l'accès aux décisions qu'ils traitent sont suffisamment transparents et explicables, à la différence des systèmes reposant sur des juges virtuels déconnectés de tout accès aux décisions.

²⁵³ <https://www.coe.int/fr/web/cepej/ethical-charter-on-ai>

²⁵⁴ Besse Ph., Castets-Renard C., Garivier A., « Loyauté des décisions algorithmiques », Contribution au débat public initié par la CNIL : Éthique et numérique, 2017, hal-01544701 : <https://hal.science/hal-01544701/document>

²⁵⁵ « Livre blanc des étudiants de la Clinique de l'École de droit : les enjeux éthiques de la justice prédictive », Sciences Po Paris, Wolters Kluwer, Predictice, 2018, spéc. p. 52 (recommandations 1 et 2).

²⁵⁶ « Algorithmes et droits humains, Étude du Conseil de l'Europe », Comité d'experts sur les intermédiaires d'internet (MSI-NET), DGI(2017)12, publiée en mars 2018, spéc. p. 46.

La transparence et l'explicabilité d'un système de justice prévisionnelle sont une condition *sine qua non* pour pouvoir critiquer le résultat proposé. Or, nous l'avons dit, il est possible de trouver le siège de ce droit de critique dans le droit au procès équitable²⁵⁷.

Par ailleurs, et dans un autre ordre d'idées, la transparence exige encore que l'utilisateur d'un outil de justice prévisionnelle (par exemple un avocat) communique avec la personne concernée (son client notamment) sur le fait qu'il a utilisé un tel outil pour prendre sa décision.

190. Quant aux principes de **neutralité** et d'**intégrité scientifique**, ils impliquent de faire toujours prévaloir l'intérêt de la justice dans la conception et le fonctionnement des outils de justice prévisionnelle. Parce que la justice est une mission de service public, le fonctionnement d'un outil ne doit pas avoir été manipulé pour parvenir à un résultat qui servirait des intérêts catégoriels privés. En effet, les biais précédemment décrits sont généralement involontaires mais il est possible d'imaginer qu'ils résultent de la volonté d'un fournisseur pour l'intérêt de son client. Ce parti pris serait tout à fait contraire à l'intérêt de la justice qui s'impose ainsi comme une limite à la liberté de conception des outils de justice prévisionnelle.

191. **Illustration du principe de transparence, de neutralité et d'intégrité scientifique en matière de justice prévisionnelle.** Reprenons l'exemple d'un outil de justice prévisionnelle en matière de responsabilité pour faute, c'est bien la transparence et l'explicabilité qui permettront de mettre en évidence le défaut tenant à l'absence de critère relatif à la faute de la victime. L'utilisateur ayant conscience de ce défaut pourra être plus circonspect vis-à-vis des résultats proposés et pourra ainsi plus facilement refuser, à tout le moins négocier la transaction proposée le cas échéant. Au contraire, dans l'hypothèse où ce défaut n'aurait pas été apparent, une victime non fautive qui aurait accepté une transaction avec l'auteur du dommage (ou son assureur) sur la base d'un résultat minoré pourrait invoquer un vice du consentement, en l'occurrence l'erreur, pour solliciter la nullité de la transaction.

Par ailleurs, dans cet exemple, le principe de neutralité et d'intégrité intellectuelle implique que l'absence de critère lié à la faute de la victime ne procède pas d'un oubli volontaire (pour biaiser le résultat au détriment des victimes). Auquel cas, le consentement à la transaction ne serait plus seulement vicié par erreur mais par dol, entraînant, outre l'annulation de la transaction, l'allocation de dommages et intérêts spécifiques.

²⁵⁷ Cf. *supra*, n° 30.

192. **Le principe de maîtrise par l'utilisateur.** La justice n'est acceptable qu'autant qu'elle est humaine. Contrairement à l'algorithme²⁵⁸, le juge n'est pas « une machine à syllogismes »²⁵⁹. Les outils de justice prévisionnelle ne doivent donc être utilisés que pour éclairer la personne humaine dans sa décision, et certainement pas pour prendre la décision²⁶⁰. Autrement dit, la personne appelée à prendre la décision doit pouvoir se sentir libre par rapport à la solution qui lui aura été suggérée par un outil de justice prévisionnelle ; elle doit pouvoir s'en écarter.

La difficulté est qu'en pratique, toute personne est sensible aux informations reçues, même lorsqu'elles ne sont pas pertinentes. Ce biais cognitif, connu comme le biais d'ancrage²⁶¹, est d'autant plus fort lorsque les informations ont l'apparence de la scientificité, de l'objectivité. Or, même les mathématiques ne sont pas neutres. Le simple calcul d'une moyenne peut se faire de différente façon selon l'importance que l'on souhaite accorder à une forte variation ponctuelle²⁶².

193. En matière de justice prévisionnelle, le biais d'ancrage a donc de fortes chances de réduire la part d'autonomie de l'utilisateur. S'agissant des juges, il a été montré qu'en matière civile, l'utilisation d'algorithmes prédictifs pour l'évaluation du montant de la prestation compensatoire avait une incidence significative sur les montants alloués²⁶³.

Et il est évident que les résultats auront également une incidence sur les avocats ou les directions juridiques. C'est vrai pour les outils qui proposent d'évaluer les chances de gains comme de pertes, mais c'est vrai également des outils qui offrent un service plus qualitatif en se targuant d'identifier la décision la plus pertinente pour un contentieux donné. Dans ce dernier cas, il est possible qu'un outil sélectionne une décision dont la solution a fait depuis l'objet d'un revirement (les délais de mise à jour des données sont assez importants et il est possible que la

²⁵⁸ Barraud B., « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », *Les Cahiers de la Justice*, 2017, n° 1, p. 121 et s.

²⁵⁹ Carbonnier C., *Droit civil – vol. I : Introduction*, PUF, coll. Quadrige, 2004, p. 23.

²⁶⁰ L'article 22 du RGPD interdit à cet égard qu'une décision ayant des effets juridiques sur une personne repose entièrement sur un traitement automatisé de ses données à caractère personnel, et la règle est reprise à l'article 47 alinéa 2 de la loi Informatique et Libertés. Par ailleurs, l'alinéa 1^{er} du texte interdit qu'une décision de justice impliquant une appréciation sur le comportement d'une personne soit fondée sur un traitement automatisé de données à caractère personnel pour évaluer certains aspects de la personnalité de cette personne.

²⁶¹ Tversky A. et Kahneman D., « Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases », *Science*, vol. 185, n° 4157, p. 1124 (1974).

²⁶² Houlou-Garcia A. et Maugey Th., *Le théorème d'hypocrite. Histoire de la manipulation par les chiffres*, Albin Michel, 2020.

²⁶³ Vergès E., « Le juge face à la boîte noire : l'intelligence artificielle au tribunal », *Recueil Dalloz*, 2022, p. 1920 et s.

décision figure dans la base de données de l'outil mais qu'elle n'ait pas encore été correctement étiquetée²⁶⁴).

Si l'avocat a fondé les prétentions de son client sur la base d'une solution obsolète, il assumera à l'égard de son client l'entière responsabilité en cas d'échec. En effet, qui dit autonomie dit responsabilité. Autrement dit, le principe de maîtrise par l'utilisateur a pour corollaire le principe de responsabilité personnelle²⁶⁵.

Ainsi, si un avocat fonde ses prétentions sur une décision suggérée par un outil de justice prévisionnelle, il assume l'entière responsabilité en cas d'échec vis-à-vis de son client s'il apparaît que la décision n'était pas (ou plus pertinente).

C'est que les professionnels du droit ne doivent pas abandonner trop facilement leur expertise juridique à la machine. Ils doivent donc conserver un esprit critique et vérifier la pertinence ou la véracité du résultat proposé²⁶⁶. C'est notamment une application de l'exigence déontologique de compétence, de diligence et de prudence qui pèse sur les avocats à l'égard de leur client²⁶⁷.

194. Difficultés de mise en œuvre des principes éthiques. La première difficulté tient au fait que la charte est un instrument de droit souple. Sa mise en œuvre dépend donc assez largement de la bonne volonté des opérateurs en matière d'outils de justice prévisionnelle (fournisseurs comme utilisateurs). La seconde difficulté tient aux principes eux-mêmes qui, en étant relativement vastes, ne donnent pas d'indication suffisamment précises relativement à ce qu'ils impliquent, concrètement, pour un opérateur. Si la dernière annexe de la Charte éthique propose un modèle d'auto-évaluation sous-forme de *checklist* celui-ci méritait d'être affiné. Tel a été l'un des objectifs de la présente recherche²⁶⁸.

De manière concomitante, la CEPEJ a travaillé à l'adoption d'un outil pour l'opérationnalisation des principes éthiques issus de la Charte. Ce travail, confié à Alexandra Tsvetkova et Matthieu Quiniou a été adopté les 4 et 5 décembre 2023²⁶⁹. Se présentant comme

²⁶⁴ Hyde A., « Avocats et IA : quelles obligations, quelles responsabilités ? », *Recueil Dalloz*, 2019, p. 2107 et s.

²⁶⁵ Du moins au stade de l'obligation à la dette, ce qui n'empêche pas de rechercher la responsabilité du fournisseur au stade de la contribution à la dette.

²⁶⁶ Un parallèle peut être fait avec l'affaire relatée dans le *New York Times* l'année dernière et pointant un avocat américain ayant fondé sa demande sur six jurisprudences inexistantes, forgées de toute pièce par chat GPT : <https://www.nytimes.com/2023/05/27/nyregion/avianca-airline-lawsuit-chatgpt.html>

²⁶⁷ Règlement intérieur national de la profession d'avocat, article 1.3 : <https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin>

²⁶⁸ Cf. infra, l'étude de faisabilité réalisée en partenariat avec le Laboratoire national de métrologie et d'essais, n° 274 et s.

²⁶⁹ Outil d'évaluation pour l'opérationnalisation de la Charte éthique européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle ans les systèmes judiciaires et leur environnement, CEPEJ, 2023 : <https://rm.coe.int/cepej-2023-16final-operationalisation-de-la-charte-ethique-ia-fr/1680adcc9d>

une succession de questions de nature à détailler concrètement les principes de la Charte, le document préconise de reconsidérer le déploiement du système d'IA lorsque l'écart est trop important. Ainsi en est-il quand une réponse négative a été donnée à certaines questions telles que « le problème que le système d'IA vise à résoudre dans le domaine judiciaire est-il clairement défini ? »²⁷⁰, « le code source est-il auditable ? »²⁷¹, « les données utilisées pour entraîner le modèle sont-elles vérifiables ? »²⁷², « les critères et les pondérations sont-ils clairs et compréhensibles ? »²⁷³, « le modèle d'IA est-il entraîné uniquement à partir de données officielles ? »²⁷⁴, etc.

195. Aussi louable soit ce travail, il ne règle pas toutes les difficultés. Par exemple, s'agissant de la mise en œuvre du principe de maîtrise par l'utilisateur, le document vise surtout à faire de l'utilisateur un acteur éclairé (par la documentation et la formation notamment)²⁷⁵. Mais d'autres questions sont en suspens. Par exemple, faudra-t-il exiger du juge dont la décision s'écarte des prévisions algorithmiques un surplus de motivation pour expliquer cet écart²⁷⁶ ? Quant à l'avocat qui serait lui aussi tenté de ne pas se fier aux faibles chances de succès annoncées et qui inciterait son client à préférer le circuit juridictionnel à la voie transactionnelle, risquerait-il de voir sa responsabilité engagée en cas de défaite pour son client ? Par ailleurs, le principe de maîtrise par l'utilisateur va-t-il jusqu'à permettre aux professionnels du droit d'ignorer purement et simplement les outils de justice prévisionnelle et de travailler « à l'ancienne » ? Ou au contraire, faut-il considérer que ces outils appartiennent à l'état de l'art de la discipline juridique et qu'ils doivent être utilisés par les professionnels faute pour eux d'engager leur responsabilité²⁷⁷ ?

Autre exemple à propos du principe de non-discrimination, le guide d'évaluation pointe la nécessité de faire auditer les données, les modèles ou les résultats avant le déploiement des systèmes d'IA pour identifier les biais²⁷⁸. S'il faut appuyer cette recommandation, la question

²⁷⁰ Outil d'évaluation précité, p. 8.

²⁷¹ Outil d'évaluation précité, p. 21.

²⁷² *Ibidem*.

²⁷³ Outil d'évaluation précité, p. 16.

²⁷⁴ Outil d'évaluation précité, p. 15.

²⁷⁵ Outil d'évaluation précité, pp. 17 et 18.

²⁷⁶ Buat-Ménard E. et Giambiasi P., « La mémoire numérique des décisions de judiciaires », *Recueil Dalloz*, 2017, p. 1483 et s.

²⁷⁷ Bourcier D., « Cyberjustice : ennemie ou alliée du droit », Intervention dans le cadre de la 1^{re} Conférence Cyberjustice Europe 2016, organisée par l'IHEJ devant le Conseil de l'Europe le 5 décembre 2016. Toutes les conférences de cette journée sont accessibles sur : <http://ihej.org/agenda/1ere-conference-cyberjustice-europe-2016/>

²⁷⁸ Outil d'évaluation précité, p. 12.

se pose en creux de savoir quelle sera la personne compétente pour réaliser cet audit. Peut-il s'agir d'un audit interne à l'entreprise qui déploie le système ? Doit-il s'agir d'un audit externe ? Et auquel cas, un audit par un cabinet privé est-il admis ou faut-il s'adresser à des instances publiques ? Où l'on voit que la puissance publique a encore un rôle important à jouer.

196. **Perspectives pour la puissance publique.** La justice étant une mission de service public, il n'est pas souhaitable de déléguer aux seules initiatives privées la fonction de veiller au respect des principes éthiques quant à l'utilisation, dans ce domaine, de l'intelligence artificielle. Des limites doivent donc être apportées et des mécanismes de contrôle mis en place²⁷⁹. Telle est également la conclusion à laquelle aboutissent les auteurs du rapport sur « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence »²⁸⁰. En effet, selon la recommandation n° 9 du rapport, il est nécessaire de « soutenir l'élaboration, au niveau national ou européen, d'un cadre normatif garantissant la transparence, la robustesse et l'exactitude des algorithmes pour réguler les outils d'intelligence artificielle dont les analyses et résultats seront produits par les parties dans le débat judiciaire et auront un effet, direct ou indirect, sur la fabrique de la jurisprudence ».

Concrètement, cela peut passer par la constitution d'une plateforme nationale d'audit des algorithmes²⁸¹, par une procédure d'agrément avec l'élaboration d'un cahier des charges²⁸², par l'élaboration d'un dispositif de certification²⁸³ ou encore par la création d'un algorithme public avec le concours des experts des établissements publics d'enseignement supérieur et des grands organismes publics de recherche²⁸⁴.

C'est également la formation des acteurs qui doit être repensée, notamment avec le développement de doubles cursus droit-IA²⁸⁵.

²⁷⁹ Beynel J.F. et Casas D., « Chantiers de la justice – Transformation numérique », Rapport pour Madame la garde des Sceaux, ministre de la Justice, 2018, spéc. p. 13.

²⁸⁰ Cadet L., Chainais C. et Sommer J.-M. (dir.), Jobert S. et Jond-Necand E. (rapp.), « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation, juin 2022 : <https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/06/14/la-diffusion-des-donnees-decisionnelles-et-la-jurisprudence-quelle>

²⁸¹ CNIL, « Comment permettre à l'homme de garder la main ? », 2017, recommandation 4, p. 57 : https://www.cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf

²⁸² Agostini F. et Molfessis M., « Chantiers de la justice – Amélioration et simplification de la procédure civile », Min. Justice, janv. 2018, spéc. p. 27 (à propos des plateformes privées de résolution en ligne des litiges).

²⁸³ L'un des axes du projet avait précisément pour objet d'étudier cette piste : cf. infra, étude de faisabilité, n° 274 et s.

²⁸⁴ Cadet L., « Technologies de l'information. Les promesses d'une justice dite prédictive reposant sur des décisions de justice déjà rendues sont à tempérer », *Revue pratique de la prospective et de l'innovation*, 2018, entretien 2.

²⁸⁵ Villani C., « Donner du sens à l'intelligence artificielle. Rapport pour une stratégie nationale et européenne », 2018, p. 19

L'adoption d'instruments propres à réguler les systèmes d'intelligence artificielle en général ne remet pas en cause la nécessité d'intervention de la puissance publique, bien au contraire.

Chapitre 2 – Les dispositions générales applicables aux systèmes d’intelligence artificielle

197. Le 13 juin 2024, le Parlement européen et le Conseil ont définitivement adopté un règlement sur l’intelligence artificielle²⁸⁶ (RIA). L’adoption de ce texte est intervenue dans un contexte de forte mobilisation des organisations intergouvernementales, tant au niveau régional qu’au niveau international, pour encadrer le développement de cette technologie. La présentation des principaux instruments issus de ces organisations intergouvernementales (Section 1) précèdera donc celle du règlement sur l’intelligence artificielle (Section 2).

Section 1 – Les instruments issus d’organisations intergouvernementales

198. Le cadre d’adoption des instruments sera brièvement étudié (§1) avant que soient envisagés leurs principaux points de convergence et de divergence (§2).

§1 – Les cadres d’adoption des instruments

199. **Multitude d’instruments.** À côté de nombreuses initiatives du secteur privé²⁸⁷ témoignant de la volonté des entreprises de différer voire d’éviter une régulation contraignante²⁸⁸, les instruments issus d’organisations intergouvernementales se sont multipliés depuis 2019. Bien qu’ils ne soient pas, pour l’heure actuelle, véritablement contraignants, ils sont néanmoins, comme les principes issus de la Charte éthique de la CEPEJ, doués d’une certaine force normative. Les principaux instruments seront présentés selon leur cadre d’adoption respectif. Ainsi, ne seront pas étudiés par exemple les travaux entrepris dans le cadre du G7, du G20 ou encore du Global PartnerShip on Artificial Intelligence, bien que ces derniers

²⁸⁶ Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l’intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l’intelligence artificielle) : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689#:~:text=Règlement%20\(UE\)%202024%2F1689,%2FUE%2C%20\(UE\)%202016](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689#:~:text=Règlement%20(UE)%202024%2F1689,%2FUE%2C%20(UE)%202016)

²⁸⁷ Cf. la base de données accessible en ligne des Temps Électriques, réunissant plus de 400 textes : <https://lestempselectriques.net/index.php/2020/05/06/ia-algorithmes-big-data-data-science-inventaire-des-cadres-ethiques-et-politiques/>

²⁸⁸ R. Ochigame, The invention of ‘Ethical AI’, The Intercept, 20 décembre 2019 – Accessible en ligne : <https://theintercept.com/2019/12/20/mit-ethical-ai-artificial-intelligence/>, consulté le 25 mai 2021

visent à créer un espace d'échange international pour forger, en matière d'IA, un modèle socio-politique à vocation universelle²⁸⁹.

Seront seulement présentés ici les instruments adoptés dans le cadre de l'OCDE, de l'UNESCO et du Conseil de l'Europe.

200. **Principes de l'OCDE.** L'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) et son comité de la politique de l'économie numérique (CPN) a travaillé la première à l'adoption d'un cadre pour réguler, au niveau international, le développement et l'utilisation de l'IA. C'est ainsi que le conseil de l'OCDE, réuni au niveau des ministres, a adopté, le 22 mai 2019, une recommandation sur l'intelligence artificielle. Cette recommandation contient des principes pour une IA de confiance, ces principes ayant fait l'objet d'une révision en avril 2024²⁹⁰. Ces principes sont : croissance inclusive, développement durable et bien-être ; transparence et explicabilité ; robustesse, sûreté et sécurité ; responsabilité. Ces principes ont une valeur principalement déclaratoire et visent surtout à encourager le développement de politiques publiques vertueuses en matière d'IA.

201. **Recommandation de l'UNESCO.** C'est ensuite l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (UNESCO), avec son groupe d'experts *ad hoc* (AHEG), qui s'est attelée à la tâche début 2020. Il en résulte un instrument sous forme de recommandation sur l'éthique de l'IA adopté par l'ensemble de ses cent quatre-vingt-treize États membres en novembre 2021²⁹¹. Cette recommandation énonce notamment quatre séries de valeurs devant guider les acteurs de l'IA : respecter les droits de l'homme et les libertés fondamentales ; assurer un environnement et des écosystèmes prospères ; promouvoir la diversité et l'inclusion des minorités ; favoriser l'édification de sociétés pacifistes et justes. En outre, elle énonce dix principes devant être promus par les États membres dans la régulation de l'IA : proportionnalité et innocuité ; sûreté et sécurité ; équité et non-discrimination ; durabilité ; droit au respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel ; surveillance et décision humaines ; responsabilité et redevabilité ; sensibilisation et éducation ; gouvernance et collaboration multipartites et adaptatives.

²⁸⁹ Sur ces travaux, voir l'ouvrage très riche de Florence G'Sell : *Regulating Under Uncertainty. Governance Options for Generative AI*, Stanford Cyber Policy Center, août 2024 (à paraître), spéc. p. 413 et s., disponible en ligne https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4918704

²⁹⁰ <https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-0449>

²⁹¹ https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000380455_fre

Comme l'instrument de l'OCDE, la recommandation de l'UNESCO invite surtout les États membres à adopter sous forme de lois, *lato sensu*, des mesures pour donner effet aux principes formulés²⁹². La valeur du texte est donc surtout incitative (on remarque d'ailleurs dans le texte l'emploi récurrent du conditionnel en lieu et place de l'indicatif).

202. Il est important de noter que l'UNESCO a particulièrement à cœur de sensibiliser les professionnels du droit et de la justice aux enjeux de l'IA dans ce domaine et de les accompagner, notamment avec son programme sur l'IA et l'État de droit²⁹³.

Par ailleurs, un sondage mené par auprès des opérateurs judiciaires du monde entier a mis en évidence un manque significatif d'orientation institutionnelle et de formation sur l'utilisation des systèmes d'IA²⁹⁴. En réponse, l'UNESCO, en collaboration avec des experts internationaux, a élaboré des projets de lignes directrices pour l'utilisation de l'IA dans les tribunaux et les juridictions²⁹⁵. Ces lignes directrices, façonnées par la recommandation de l'UNESCO sur l'éthique de l'IA, visent à garantir que les technologies d'IA soient intégrées dans les systèmes judiciaires d'une manière qui respecte la justice, les droits humains et l'État de droit. Elles ont été ouvertes à la consultation publique jusqu'au 5 septembre 2024.

203. **Convention-cadre du Conseil de l'Europe.** En parallèle, le Conseil de l'Europe a donné mandat à un comité *ad hoc* sur l'intelligence artificielle (CAHAI) d'examiner la faisabilité et les éléments potentiels d'un cadre juridique international pour la conception, le développement et l'utilisation d'une IA fondée sur les normes du Conseil de l'Europe en matière de droits de l'homme, de démocratie et d'État de droit. Publiée en décembre 2020, cette « étude de faisabilité »²⁹⁶ a révélé les principes clés essentiels requis par le cadre juridique devant s'appliquer à l'IA. Suite à ce travail, des « éléments potentiels d'un cadre juridique sur l'intelligence artificielle, fondés sur les normes du Conseil de l'Europe en matière de droits de

²⁹² art. I. b du Règlement relatif aux recommandations aux États membres et aux conventions internationales prévues par l'article IV, paragraphe 4, de l'Acte constitutif.

²⁹³ Ce programme se décline soit à distance sous forme de MOOC : <https://www.iau-hesd.net/action/unesco-mooc-artificial-intelligence-and-rule-law#:~:text=The%20Massive%20Open%20Online%20Course,on%20the%20rule%20of%20law.>

Des séminaires sont également organisés auprès de magistrats dans le monde entier sur la base du Manuel de formation réalisé sur le même thème : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387331_fre

En juillet 2024, s'est tenu l'acte 1^{er} d'un séminaire de formation organisé sur ce thème conjointement par l'UNESCO, l'European Judicial Training Network et l'École nationale de la magistrature, programme auquel Aurore Hyde a participé en qualité d'experte.

²⁹⁴ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000389786>

²⁹⁵ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390781>

²⁹⁶ <https://rm.coe.int/cahai-2020-23-final-eng-feasibility-study-/1680a0c6da>

l'Homme, de démocratie et d'État de droit » ont été publiés le 3 décembre 2021²⁹⁷. Il y était notamment recommandé d'adopter un instrument intergouvernemental contraignant selon une approche par les risques. C'est dans ce contexte qu'a été adoptée, le 17 mai 2024, la convention-cadre du Conseil de l'Europe sur l'intelligence artificielle²⁹⁸. Cette convention-cadre énonce notamment les principes généraux communs que chaque État partie devra mettre en œuvre à l'égard des systèmes d'intelligence artificielle, étant précisé que chaque partie doit fournir régulièrement un rapport contenant les détails des activités qu'elle a entreprises pour assurer le respect des principes et des garanties procédurales qui y sont associées²⁹⁹. Ces principes³⁰⁰ sont : dignité humaine et autonomie personnelle ; transparence et contrôle ; obligation de rendre des comptes et responsabilité ; égalité et non-discrimination ; respect de la vie privée et protection des données à caractère personnel ; fiabilité ; innovation sûre.

Cette convention-cadre ne crée pas d'effet juridique directement dans l'ordre juridique des États parties tant que ceux-ci n'auront pas exprimé leur consentement à être liés³⁰¹ (au sens de la convention de Vienne sur le droit des traités)³⁰². Cela permet donc à certains États « de rester en retrait, sans bloquer le processus pour d'autres »³⁰³.

§2 – Les points de convergence et de divergence entre les instruments

204. **Complémentarité des instruments.** Derrière l'apparente concurrence entre les tentatives de régulation intergouvernementale de l'IA, c'est plutôt de complémentarité qu'il s'agit. D'abord, ces différents travaux sont complémentaires dans leur vocation pluraliste. En effet, il ne faut pas négliger le poids de la culture dans l'éthique³⁰⁴ et demeurer à un échelon régional pour traiter de ces questions risque de ne traduire qu'une certaine conception éthique, une conception des valeurs relatives à une culture particulière. Dans la mesure où certains États sont représentés dans certaines organisations mais pas dans d'autres³⁰⁵, la pluralité d'instruments assure une meilleure représentativité de tous.

²⁹⁷ <https://rm.coe.int/cahai-2021-09rev-fr-elements/1680a6d90e>

²⁹⁸ <https://www.coe.int/fr/web/artificial-intelligence/la-convention-cadre-sur-l-intelligence-artificielle>

²⁹⁹ Art. 24 de la convention cadre.

³⁰⁰ Ils sont énoncés et explicités aux articles 7 à 13 de la convention cadre.

³⁰¹ Art. 30 §§ 1 et 2 de la convention cadre.

³⁰² Art. 11 de la convention de Vienne sur le droit des traités, Nations unies, 1969.

³⁰³ Y. Méneceur, « Analyse des principaux cadres... », précité, p. 24.

³⁰⁴ R. Goffi, « De l'importance des particularismes culturels en éthique de l'IA », *Beyond the Horizon*, Jan. 29, 2021 : <https://behorizon.org/de-limportance-des-particularismes-culturels-en-ethique-de-lia/>

³⁰⁵ Ainsi par exemple, la Chine est membre de l'UNESCO mais elle ne participe pas aux travaux du CAHAI. Au contraire, la Russie participait aux travaux du CAHAI mais pas à ceux de l'UNESCO...

La complémentarité résulte ensuite du fait que ces organisations travaillent en synergie³⁰⁶. Notamment, le président du CAHAI et le secrétariat ont participé au lancement de l'observatoire sur les politiques en matière d'IA de l'OCDE le 27 février 2020. Et des échanges ont régulièrement lieu avec des représentants de l'OCDE, de l'Union européenne (UE) et de l'UNESCO, notamment sur les travaux en cours au sein de chaque organisation. Par ailleurs, l'UE et l'UNESCO sont membres du partenariat mondial sur l'intelligence artificielle.

205. Convergence des instruments sur les éléments essentiels et fonctionnels des systèmes d'IA. Dans leur dernier état, les instruments convergent pour retenir une définition des systèmes d'IA à la fois essentielle et fonctionnelle : essentielle car fondée sur *ce qu'ils sont* (des « technologies de traitement de l'information »³⁰⁷ ou des « systèmes automatisés »³⁰⁸, présentant en outre un « degré d'autonomie »³⁰⁹) ; fonctionnelle car fondée sur *ce qu'ils font* (générer des résultats³¹⁰ – tels que des contenus, des prévisions ou prédictions, des recommandations – sur la base d'objectifs³¹¹).

206. Convergence des instruments quant à l'exigence d'une IA digne de confiance, centrée sur l'humain. Il ressort de l'ensemble des instruments étudiés la nécessité que l'IA soit digne de confiance (ou responsable), c'est-à-dire conçue au service de l'humain, dans le respect de ses droits et libertés fondamentaux, de la démocratie et de l'État de droit. En effet, si l'on ne retrouve pas toujours les principes énoncés dans les mêmes termes, l'objectif demeure la réalisation de cet objectif global.

207. Convergence des instruments quant à l'exigence de transparence. Parmi tous les principes, celui de transparence est celui qui fait le plus consensus puisqu'il figure dans tous les instruments. Cela n'est pas étonnant dans la mesure où l'essentiel des problèmes éthiques soulevés par l'utilisation des systèmes d'IA (biais, perte d'autonomie, impacts sur la société, la démocratie, etc.) tient précisément dans l'opacité de ces systèmes³¹². Mais derrière le terme de

³⁰⁶ Y. Méneceur, « Droits de l'homme, numérique et intelligence artificielle – La perspective du Conseil de l'Europe », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. C. Castets-Renard et J. Eynard, Bruylant, 2023, p. 135 et s., spéc. p. 153 et s.

³⁰⁷ Cf. I § 2 (a) de la recommandation de l'UNESCO.

³⁰⁸ Cf. I. de la recommandation de l'OCDE ; art. 2 de la convention-cadre du CE.

³⁰⁹ Les trois instruments font référence à ce degré d'autonomie.

³¹⁰ Les trois instruments font référence aux résultats produits.

³¹¹ Cf. La recommandation de l'OCDE et la convention-cadre.

³¹² C. Villani (dir.), « Donner du sens à l'intelligence artificielle. Rapport pour une stratégie nationale et européenne », Rapport à Monsieur le Premier ministre, 2018, spéc. p. 21 : <https://www.vie-publique.fr/sites/default/files/rapport/pdf/184000159.pdf>

transparence, tous les instruments ne désignent pas la même réalité. Certains y associent l'explicabilité quand d'autres non.

208. **Divergences des instruments sur le contenu du principe de transparence.** L'OCDE et l'UNESCO s'accordent pour poser un principe de transparence et d'explicabilité quand le Conseil de l'Europe ne vise que le principe de transparence. L'absence de référence à l'explicabilité est regrettable dans la mesure où la transparence et l'explicabilité n'ont pas exactement la même finalité. En effet, la transparence répond à la question « quoi ? » quand l'explicabilité répond à la question « pourquoi ? ».

209. **Distinction de la transparence et de l'explicabilité.** On l'a dit, la **transparence** implique de rendre publiques des informations relatives au système d'IA. Au minimum il faut communiquer sur les éléments les plus pertinents du système (la nature des données utilisées, le type d'algorithmes utilisés, la finalité poursuivie, le résultat des évaluations, l'analyse des risques, voire le modèle économique, les domaines de compétences professionnelles des personnes ayant conçu le système, ou encore les bénéfices escomptés). Évidemment, cela peut soulever des questions qui devront être tranchées : faut-il communiquer le code source ? peut-on opposer le secret des affaires ? si oui dans quelle mesure ? etc. Là encore, la puissance publique aura un rôle à jouer pour préciser l'étendue de cette exigence en matière d'outils de justice prévisionnelle.

210. Quant à l'**explicabilité**, elle implique de rendre le fonctionnement de l'IA intelligible tant pour un profane que pour un régulateur. Il s'agira ici d'expliquer les choix réalisés : la sélection des données d'entraînement, les processus d'annotation, la logique d'optimisation choisie, les critères utilisés pour analyser les données, la pondération des critères, la manière dont le système est susceptible d'affecter les intérêts d'une personne le cas échéant, etc. On distingue généralement les explications locales, qui consistent à expliquer comment le SIA parvient au résultat proposé, des explications globales, qui portent sur la logique générale du système³¹³.

Ainsi, « l'explication locale fournit une explication du comportement algorithmique pour une donnée en particulier. Par exemple, pour un algorithme d'estimation du risque de récidive, on s'attache à comprendre l'influence de paramètres d'entrée décrivant un profil de personne en

³¹³ Hyde A., « La compliance en matière d'IA », in *Memento Compliance*, dir. M. Roussille, E. Breen, A. Gaudemet, Éditions Francis Lefebvre, 2024 (à paraître).

particulier, sur la réponse algorithmique. L'explication globale livre la logique générale de l'algorithme à produire une réponse, et donc une suggestion de décision. Pour un algorithme de mesure du risque de récidive, on s'assure que le genre ou la localisation géographique n'est pas un critère décisif pour le modèle en général. Enfin, les explications contrefactuelles, [qui sont en réalité] un cas particulier d'explications locales, cherchent à comprendre la logique de l'algorithme dans des cas imaginés. Pour cela, elles tentent de répondre à des questions de l'ordre du "et si...?", qui impliquent la variation d'une ou plusieurs valeurs d'entrée »³¹⁴.

211. Comprendre l'explicabilité eu égard à sa finalité. L'explicabilité n'est pas une chose facile. Elle n'est pas bien définie et ne fait pas consensus dans la communauté. En vérité, c'est un champ de recherches à part entière pour les sciences de l'IA. On ignore donc encore jusqu'où l'on peut aller dans l'explicabilité, surtout en présence de systèmes fonctionnant en « boîtes noires », la difficulté étant que plus un système d'IA est performant et moins il est explicable³¹⁵. Les implications concrètes de l'explicabilité diffèrent certainement selon le domaine d'application du système ainsi que selon la personne « créancière » de l'explicabilité. Le degré d'explication à fournir ne sera donc pas le même pour un régulateur ou pour un utilisateur, et là encore, la puissance publique a un rôle à jouer pour préciser le contenu de cette exigence en matière d'outils de justice prévisionnelle.

Toujours est-il que la finalité de l'explicabilité est assez claire. Elle impose au fournisseur d'un système d'IA de rendre des comptes dans une logique de responsabilisation, notamment pour permettre à la personne affectée par une décision prise sur la base du résultat du SIA de contester ce résultat.

À cet égard, il est regrettable qu'aucun instrument ne pose d'exigence relative à la justification des choix réalisés.

212. Pour un principe de justification. Par la justification, on répond à la question du « pourquoi ? ». Il ne s'agit plus seulement de rendre un système d'IA intelligible mais de rendre son résultat acceptable, de démontrer que le résultat est fondé.

Contrairement à l'explicabilité, qui est endogène, la justification est exogène. Elle fait référence à un élément extérieur, à une norme qui vient justifier le système (ou un de ses résultats).

³¹⁴ Basdevant A., Jean A., Storchan V., *Mécanisme d'une justice algorithmisée*, Fondation Jean Jaurès éditions, coupdata.fr, 2021, p. 26 : <https://www.jean-jaures.org/wp-content/uploads/2021/07/justice.pdf>

³¹⁵ Lambin X. et Raizonville A., « From black box to glass box: algorithmic explainability as a strategic decision », June 4, 2024 : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4455428

Clément Hénin et Daniel Le Métayer prennent comme exemple un système d'aide à la décision pour traiter des demandes de prêt bancaire. L'explication pourrait être « votre demande de prêt est refusée car votre taux d'endettement dépasserait le tiers de vos revenus ». Cette information explique le refus mais ne le justifie pas. Une justification pourrait être : « votre demande de prêt est refusée car la loi interdit aux banques d'octroyer des prêts conduisant à un taux d'endettement dépassant le tiers des revenus »³¹⁶. La justification apparaît donc utile pour permettre la contestation des résultats issus des systèmes d'IA et la puissance publique pourrait l'exiger pour les outils de justice prévisionnelle.

213. Transparence, explicabilité et justification : conditions d'effectivité des autres principes. La transparence, l'explicabilité et la justification permettent une meilleure compréhension et partant une meilleure maîtrise d'un outil de justice prévisionnelle par son utilisateur (principe de maîtrise par l'utilisateur). De même, la lumière sur les choix réalisés permet de garantir l'absence de biais volontaires et la réduction des biais involontaires (principes d'équité, de non-discrimination, d'égalité, d'inclusion). Ces principes permettent encore de vérifier que des mesures ont été prises pour assurer la protection des personnes (principes de sécurité, d'innocuité, de robustesse, de respect de la vie privée et de protection des données à caractère personnel). La transparence, l'explicabilité et la justification servent également à vérifier la pertinence du résultat proposé (principe de fiabilité, principe de sécurité) et oblige le fournisseur à rendre des comptes (principe de responsabilité). Ces principes doivent donc être au cœur de la conception, du déploiement et de l'utilisation des outils de justice prévisionnelle.

214. Transparence, explicabilité et justification : conditions de l'évaluation par un tiers. La transparence, l'explicabilité et la justification apparaissent également nécessaires pour mettre en œuvre une évaluation par un tiers³¹⁷.

215. Divergence des instruments sur l'exigence de contrôle humain. Parmi les trois instruments présentés, seule la convention-cadre pose un principe de contrôle (associé au principe de transparence). Ce principe est pourtant une nécessité pour assurer la confiance dans les systèmes d'IA. D'ailleurs, il est présent dans la Charte éthique de la CEPEJ sous

³¹⁶ <https://linc.cnil.fr/fr/clement-henin-et-daniel-le-metayer-fournir-des-explications-du-fonctionnement-des-algorithmes>

³¹⁷ Cf. infra, n° 274 et s.

l'appellation « maîtrise par l'utilisateur ». Il figure également à l'article 22 du RGPD ainsi que dans le règlement sur l'intelligence artificielle qui sera étudié dans la prochaine section au titre de l'obligation de surveillance humaine incombant aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque³¹⁸.

216. **Caractéristiques du contrôle humain.** Après avoir relevé qu'il existait de nombreuses expressions pour désigner le contrôle humain³¹⁹, Winston Maxwell dégage trois conditions cumulatives pour qu'un tel contrôle soit effectif : « (i) avoir une connaissance du fonctionnement de l'algorithme et de ses limitations, (ii) s'engager dans un processus cognitif de réflexion, qui pour certains doit tenir d'autres informations telles que le contexte de la décision, et (iii) avoir l'autorité et la capacité matérielle d'intervenir dans le système et changer la décision »³²⁰. Ce type de contrôle échoit aux « personnes responsables du système »³²¹, c'est-à-dire son fournisseur ou son utilisateur.

Il peut porter soit sur le fonctionnement global du système (« contrôle système »), soit sur une décision algorithmique individuelle (« contrôle individuel »)³²². Dans le cas du contrôle système, les exigences seront différentes selon la technologie à l'œuvre dans le système³²³. Si le système repose sur de l'IA symbolique (à base de règles notamment), c'est l'humain qui doit définir les règles, les modèles et les critères. Le contrôle s'opère donc au stade de cette définition. En revanche, en matière d'IA connexionniste (à base d'apprentissage automatique notamment), l'humain définit l'objectif à optimiser par l'algorithme d'apprentissage, sélectionne les données d'apprentissage, veille à leur nettoyage et à leur étiquetage. Il choisit également les seuils de sensibilité, la priorisation de certains types d'erreurs par rapport à d'autres (ex. priorisation des faux positifs par rapport aux faux négatifs) et les métriques d'évaluation privilégiées pour prioriser le type d'erreur choisi (ex. rappel plutôt que précision). Il décide enfin du caractère approprié de la technologie utilisée par rapport à l'objectif visé et de son déploiement ou non³²⁴. Le contrôle s'opère donc à chacune de ces étapes.

³¹⁸ Art. 14 RIA.

³¹⁹ Parmi ces expressions nous trouvons : « intervention humaine » ; « surveillance et vérifications humaines » ; « évaluation humaine » ; « *human-in-the-loop* » ; « *human-on-the-loop* » ; « *human-in-command* », « maîtrise par l'utilisateur », etc.

³²⁰ Maxwell W., « Le contrôle humain pour détecter les erreurs algorithmiques », in *Un droit de l'intelligence artificielle*. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 707 et s., spéc. p. 711.

³²¹ *Ibid.*, p. 712.

³²² *Ibid.*, p. 711.

³²³ *Ibid.*, p. 712.

³²⁴ *Ibid.*, p. 713.

217. S'agissant du contrôle individuel, il est pertinent de distinguer, pour les systèmes générant un résultat conduisant à une décision individuelle, le contrôle *ex ante* et le contrôle *ex post*³²⁵. Le contrôle individuel *ex ante* est particulièrement important pour les outils de justice prévisionnelle car il implique que ce soit l'humain, et non le système, qui prenne *in fine* la décision en s'appuyant plus ou moins sur le résultat algorithmique³²⁶. C'est typiquement ce contrôle que l'on retrouve exigé dans la Charte éthique de la CEPEJ au titre du principe de maîtrise par l'utilisateur. En matière de justice prévisionnelle, cela signifie que le résultat algorithmique ne peut pas avoir un poids prépondérant dans la décision. Il ne peut pas en constituer l'élément central. Il ne peut être qu'un élément parmi d'autres. Le contrôle individuel *ex post* est également très important en matière de justice prévisionnelle car il est associé à la contestation du résultat dont nous avons dit qu'elle était une condition d'effectivité du droit au procès équitable. En effet, « un droit de contestation avec un contrôle humain *ex post*, [doit pouvoir] exister même lorsqu'il y a eu un contrôle individuel *ex ante* »³²⁷.

218. La plupart des principes précédemment évoqués se retrouvent en filigrane des dispositions européennes relatives à l'intelligence artificielle.

Section 2 – Les textes européens sur l'intelligence artificielle

219. **Pluralité de textes applicables aux systèmes d'IA.** De manière générale, l'IA repose essentiellement sur un traitement automatisé de nombreuses données de nature très variée et les outils de justice prévisionnelle ne font pas exception. Leurs fournisseurs comme leurs utilisateurs doivent donc respecter la législation en matière de données, qu'il s'agisse de données à caractère personnel (avec en particulier le règlement général sur la protection des données à caractère personnel du 27 avril 2016³²⁸ et la loi Informatique et Libertés³²⁹) ou non personnel (avec le règlement du 14 novembre 2018 sur les données à caractère non personnel

³²⁵ *Ibid.*, p. 713.

³²⁶ *Ibid.*, p. 714.

³²⁷ *Ibid.*, p. 716.

³²⁸ Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

³²⁹ Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/article_lc/LEGIARTI000037823131

dans l'Union européenne³³⁰, la directive du 8 juin 2016 sur les secrets d'affaires³³¹ et la loi du 30 juillet 2018 sur la protection du secret des affaires³³².

Pour autant, seuls les textes européens ayant spécialement vocation à régir les systèmes d'intelligence artificielle seront étudiés ici. Il s'agit du règlement sur l'intelligence artificielle (§1) et de deux propositions de directive intéressant la responsabilité de l'intelligence artificielle (§2)

§1 – Le règlement sur l'intelligence artificielle (RIA)

220. **Contexte d'adoption du RIA.** Dévoilée le 21 avril 2021 par la Commission européenne, la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle³³³ est l'aboutissement des réflexions conduites par la Commission sur sa stratégie en matière d'IA, à l'aide du groupe d'experts de haut niveau sur l'intelligence artificielle qu'elle a nommé. Ce groupe d'experts a produit cinq livrables entre 2018 et 2020 : une définition de l'IA³³⁴, des lignes directrices pour une IA digne de confiance³³⁵, des recommandations en matière de politiques et d'investissement pour une IA digne de confiance³³⁶, des considérations sectorielles en matière de politique et d'investissement³³⁷, une liste d'évaluation finale pour une IA digne de confiance³³⁸.

Avec ce texte, l'Union européenne ambitionne de promouvoir le développement et l'utilisation d'une intelligence artificielle conforme aux valeurs européennes, c'est-à-dire à une intelligence artificielle digne de confiance, centrée sur l'humain et le respect de ses droits fondamentaux. Dans le même temps, il s'agit de créer les conditions du déploiement de systèmes d'intelligence artificielle. Adopté sur le fondement de l'article 114 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (relatif au marché intérieur), la proposition de règlement vise aussi, et peut-être

³³⁰ Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32018R1807>

³³¹ Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32016L0943>

³³² LOI n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires : <https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000037262111#:~:text=%2DToute%20personne%20ayant%20accès%20à,des%20informations%20qu'elle%20contient>

³³³ <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX%3A52021PC0206>

³³⁴ https://ec.europa.eu/futurium/en/system/files/ged/ai_hleg_definition_of_ai_18_december_1.pdf

³³⁵ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/ethics-guidelines-trustworthy-ai>

³³⁶ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence>

³³⁷ <https://futurium.ec.europa.eu/en/european-ai-alliance/document/ai-hleg-sectoral-considerations-policy-and-investment-recommendations-trustworthy-ai>

³³⁸ <https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/library/assessment-list-trustworthy-artificial-intelligence-altai-self-assessment>

surtout, à favoriser l'innovation, la croissance économique et la compétitivité de l'UE au niveau international. En cherchant à adopter le premier texte d'application universelle juridiquement contraignant pour la régulation de l'IA, l'UE entend se positionner comme cheffe de file en la matière. Elle souhaite proposer une troisième voie entre le modèle américain³³⁹ et le modèle chinois³⁴⁰ dans le façonnement des normes mondiales en matière d'intelligence artificielle.

221. Opportunité du type d'instrument choisi. Le choix d'un règlement plutôt que d'une directive vise l'uniformisation des législations sur le territoire de l'Union européenne, ce qui a pour avantage d'éviter l'éclatement des législations nationales. Les produits et services qui intègrent de l'IA étant appelés à se déployer dans tous les pays membres de l'Union européenne, c'est une bonne chose qu'ils soient traités de la même façon. Il serait en effet difficilement tolérable que la protection des droits fondamentaux soit moins bien assurée d'un État membre à l'autre.

222. Adoption définitive du RIA et entrée en vigueur. Le texte a fait l'objet de plusieurs propositions d'amendement³⁴¹, au gré des changements de présidence du Conseil de l'UE, avant d'être définitivement adopté le 13 juin 2024³⁴², et publié au Journal officiel le 12 juillet suivant. Le laps de temps (3 ans) séparant la proposition du règlement définitif n'apparaît pas choquant au regard des enjeux du texte. Les discussions portaient notamment sur la définition même des systèmes d'intelligence artificielle au cœur de la législation européenne (fallait-il retenir une

³³⁹ Sur ce modèle : G'Sell F., *Regulating Under Uncertainty. Governance Options for Generative AI*, Stanford Cyber Policy Center, août 2024 (à paraître), spéc. p. 296 et s. : disponible en ligne https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4918704

³⁴⁰ Sur ce modèle : G'Sell F., ouvrage précité, spéc. p. 264 et s.

³⁴¹ Le 25 novembre 2022, le Conseil de l'Union européenne a arrêté son orientation générale sur le texte (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-14954-2022-INIT/fr/pdf>). Puis le Parlement européen a proposé des amendements (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_EN.html), avant d'adopter un texte a été adopté en session plénière le 14 juin 2023, ouvrant ainsi la phase des trilogues (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0236_FR.pdf). Après trois jours d'après négociations, le Conseil et le Parlement sont parvenus, le 9 décembre 2023, à un accord provisoire (<https://www.consilium.europa.eu/fr/press/press-releases/2023/12/09/artificial-intelligence-act-council-and-parliament-strike-a-deal-on-the-first-worldwide-rules-for-ai/>). Le texte qui en est résulté a été adopté à l'unanimité le 26 janvier 2024 par les 27 États membres de l'Union (<https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-5662-2024-INIT/en/pdf>). Enfin, le 13 mars 2024, le Parlement européen a adopté un amendement de compromis correspondant à ce dont les institutions étaient convenues entre elles (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2024-0138_FR.pdf).

³⁴² Règlement (UE) 2024/1689 du Parlement européen et du Conseil du 13 juin 2024 établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle et modifiant les règlements (CE) n° 300/2008, (UE) n° 167/2013, (UE) n° 168/2013, (UE) 2018/858, (UE) 2018/1139 et (UE) 2019/2144 et les directives 2014/90/UE, (UE) 2016/797 et (UE) 2020/1828 (règlement sur l'intelligence artificielle) : [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689#:~:text=Règlement%20\(UE\)%202024%2F1689,%2FUE%2C%20\(UE\)%202016](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL_202401689#:~:text=Règlement%20(UE)%202024%2F1689,%2FUE%2C%20(UE)%202016)

définition large ou restreinte des systèmes d'IA ?), ainsi que sur la nécessité d'inclure ou non dans le champ du dispositif les systèmes d'IA générative. Au final, c'est une définition plutôt restrictive des systèmes d'IA qui a été retenue³⁴³ et les IA génératives sont rentrées dans le champ du texte (sous le terme de système d'IA à usage général).

Sur la forme, le texte final contient cent quatre-vingts considérants, cent treize articles organisés autour de treize chapitres, et treize annexes.

Il est entré en vigueur le 1^{er} août 2024 mais l'application de ses dispositions est reportée à des dates ultérieures³⁴⁴, soit au 2 août 2026 pour l'essentiel, à l'exception des dispositions générales et de celles relatives aux pratiques interdites, applicables à compter du 2 février 2025 ; des dispositions relatives aux autorités notifiantes et aux organismes notifiés (chapitre III, section 4), de celles relatives aux mesures de soutien à l'innovation (chapitre V), de celles relatives aux bases de données de l'UE ou les systèmes d'IA à haut risque (chapitre VII), de celles relatives aux sanctions (chapitre XII), et de celles relatives à la confidentialités des données obtenues par les régulateurs dans le cadre de leurs missions (article 78) qui sont applicables à compter du 2 août 2025 ; des obligations incombant aux fournisseurs de systèmes d'IA à haut risque, qui seront applicables à partir du 2 août 2027.

223. Choix d'une approche par les risques. La Commission européenne a opté pour une approche par les risques consistant à adopter un régime graduel en fonction des risques engendrés par un système d'intelligence artificielle selon les cas d'usage. Par risque, il faut comprendre « la combinaison de la probabilité d'un préjudice et de la sévérité de celui-ci »³⁴⁵. Le règlement classe ainsi les systèmes d'IA en trois catégories : les systèmes d'IA présentant un risque inacceptable, les systèmes d'IA à haut risque et les systèmes d'IA à faible risque. Cette approche par les risques montre que l'instrument se situe à mi-chemin entre la régulation économique et la protection des droits fondamentaux³⁴⁶.

³⁴³ Aux termes de l'article 3 § 1) du règlement sur l'intelligence artificielle, un système d'intelligence artificielle est « un système automatisé conçu pour fonctionner à différents niveaux d'autonomie, et [qui] peut faire preuve d'une capacité d'adaptation après son déploiement, et qui, pour des objectifs explicites ou implicites, déduit, à partir des entrées qu'il reçoit, la manière de générer des sorties telles que des prédictions, du contenu, des recommandations ou des décisions qui peuvent influencer les environnements physiques ou virtuels ». Pour un tour d'horizon des différentes définitions proposées et les points de distinction entre elles : Latil A., « Droit de l'intelligence artificielle (droit international et droit européen) », Fasc. 988 – *JurisClasseur* Communication, 24 juillet 2024, § 50 et s.

³⁴⁴ Art. 113 RIA.

³⁴⁵ Art. 3 § 2 RIA.

³⁴⁶ Latil A., « Fasc. 988 - Droit de l'intelligence artificielle (droit international et droit européen) », *JurisClasseur* Communication, LexisNexis, 2024.

224. **Régime graduel selon le niveau de risque.** Cette approche par les risques permet d'établir un régime graduel selon le degré de risque associé à certains cas d'usage :

- les systèmes d'IA présentant un risque inacceptable sont interdits sauf exceptions³⁴⁷ (ex. les techniques subliminales de manipulation aux fins d'altérer le comportement d'une personne ; l'identification biométrique à distance en temps réel) ;
- les systèmes d'IA à haut risque constituent le cœur du texte et sont visés par la plupart des obligations qu'il édicte³⁴⁸, et le domaine de la justice figure parmi ceux identifiés à haut risque ;
- les systèmes d'IA présentant un risque « faible » (c'est-à-dire tous les systèmes d'IA à l'exception de ceux à haut risque ou inacceptables) ne sont soumis qu'à des obligations spécifiques de transparence selon les cas³⁴⁹, par exemple quand ils interagissent directement avec des humains.
- le texte ménage une place particulière pour les modèles d'IA à « usage général »³⁵⁰ (GPAI), tel ChatGPT, qui sont également soumis à des obligations spécifiques de transparence³⁵¹ qui se renforcent lorsque le GPAI présente un risque systémique³⁵².

225. **Obligations du fournisseur de systèmes d'IA à haut risque.** Le « fournisseur » de systèmes d'IA à haut risque est celui qui assume le plus d'obligations et des obligations particulièrement lourdes de mise en conformité, requérant pour leur mise en œuvre des moyens matériels et humains considérables. C'est donc lui le principal responsable. Par fournisseur, il faut comprendre la personne qui met sur le marché un système d'IA (ou le met en service) sous son nom propre ou sa marque³⁵³. Sans entrer dans le détail, il s'agit principalement d'établir –

³⁴⁷ Art. 5 RIA.

³⁴⁸ Art. 6 RIA.

³⁴⁹ Art. 50 RIA.

³⁵⁰ Ces systèmes d'IA se caractérisent en particulier par « la généralité et la capacité d'exécuter de manière compétente un large éventail de tâches distinctes » (considérant 97 RIA).

³⁵¹ Art. 53 RIA.

³⁵² Art. 55 RIA.

³⁵³ Art. 3 § 3 RIA : « fournisseur : une personne physique ou morale, une autorité publique, une agence ou tout autre organisme qui développe ou fait développer un système d'IA ou un modèle d'IA à usage général et le met sur le marché ou met le système d'IA en service sous son propre nom ou sa propre marque, à titre onéreux ou gratuit ».

et de conserver³⁵⁴ – une documentation technique complète³⁵⁵, claire et intelligible, sur les éléments permettant au régulateur de vérifier le respect des exigences³⁵⁶ liées à :

- la gestion et la prévention des risques³⁵⁷ ;
- l'adoption de mesures adéquates pour une bonne gouvernance et gestion des données (garantissant notamment que les jeux de données d'entraînement, de validation et de test sont pertinents, représentatifs, exempts d'erreurs et complets)³⁵⁸ ;
- la journalisation (ex. : l'enregistrement automatique des événements)³⁵⁹ ;
- la transparence à l'égard du « déployeur » (identité et coordonnées du fournisseur ; caractéristiques du système d'IA ; capacités et limites de performance du système tel que le niveau d'exactitude ; de robustesse et de cybersécurité ; information relative aux risques que l'utilisation du système d'IA peut engendrer pour la santé ; la sécurité ou les droits fondamentaux des personnes ; spécifications relatives aux données d'entrée ; mesures de contrôle humain mises en place pour vérifier l'interprétation des résultats ; durée de vie attendue du système ; mesures de maintenance et de suivi nécessaires ; mécanismes de collecte, de stockage et d'interprétation des journaux)³⁶⁰ ;
- la surveillance humaine (interface homme-machine) tout au long du cycle de vie, notamment pour prévenir ou réduire les risques pour la santé, la sécurité ou les droits fondamentaux³⁶¹ ;
- l'exactitude, la robustesse et la cybersécurité, adaptés au contexte d'utilisation et aux risques identifiés³⁶² ;
- la gestion de la qualité³⁶³ ;
- l'analyse d'impact du système d'IA sur les droits fondamentaux³⁶⁴ ;
- l'évaluation de la conformité³⁶⁵ et les mesures correctrices prises³⁶⁶ le cas échéant.

Par ailleurs, le fournisseur de systèmes d'IA à haut risque devra apposer le marquage CE avant la mise sur le marché ou la mise en service³⁶⁷, enregistrer son système dans la base de données

³⁵⁴ Art. 18 RIA.

³⁵⁵ La documentation technique est simplifiée pour les PME.

³⁵⁶ Art. 11 RIA.

³⁵⁷ Art. 9 RIA.

³⁵⁸ Art. 10 RIA.

³⁵⁹ Art. 12 RIA.

³⁶⁰ Art. 13 RIA.

³⁶¹ Art. 14 RIA.

³⁶² Art. 15 RIA.

³⁶³ Art. 17 RIA.

³⁶⁴ Art. 27 RIA.

³⁶⁵ Art. 43 RIA.

³⁶⁶ Art. 20 RIA.

³⁶⁷ Art. 16, h) et art. 48 RIA.

de l'UE prévue à l'article 71 du texte avant la mise sur le marché³⁶⁸ et coopérer avec les autorités compétentes³⁶⁹.

L'ensemble de ces obligations de mise en conformité vise lui aussi à garantir le déploiement d'une IA responsable et digne de confiance. Là encore, les exigences mériteront d'être précisées, en fonction des secteurs d'utilisation notamment, et ce sera précisément l'objet des normes harmonisées³⁷⁰ que d'y parvenir.

226. Obligations du « déployeur » de systèmes d'IA à haut risque. Le « déployeur », c'est-à-dire toute personne (physique ou morale, autorité publique, agence ou organisme) qui utilise le système d'IA sous sa propre autorité et à des fins professionnelles³⁷¹, assume également certaines obligations³⁷² et notamment celle de vérifier que le fournisseur a bien respecté ses obligations propres. En outre, le déployeur doit effectuer un contrôle humain, contrôler les données d'entrée, mettre en place la journalisation, notifier les incidents, et coopérer avec les autorités compétentes. Pour les systèmes d'IA qualifiés à haut risque à raison du domaine d'utilisation (annexe III), le déployeur doit par ailleurs effectuer une analyse d'impact (laquelle peut venir compléter celle mise en œuvre au titre du RGPD).

La justice figurant dans la liste des domaines d'utilisation à haut risque, on pourrait penser que les fournisseurs comme les déployeurs d'outils de justice prévisionnelle assument les obligations précitées. Mais une réponse plus nuancée s'impose.

227. Hésitation sur la qualification des outils de justice prévisionnelle. La qualification de système d'IA à haut risque est donnée soit aux composants de certains produits couverts par les législations européennes harmonisées visées à l'annexe 2 – directives ou règlements (par exemple, actes législatifs d'harmonisation européenne listés à l'annexe II du RIA, tels la directive 2009/48/CE du parlement européen et du conseil du 18 juin 2009 relative à la sécurité des jouets ou le règlement UE 2016/424 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 relatif aux installations à câbles et abrogeant la directive 2000/9/CE), soit au domaine d'application. En effet, l'annexe III du RIA liste des domaines d'application dans lesquels l'utilisation de systèmes d'IA est considérée à haut risque. Si le secteur de la justice figure parmi

³⁶⁸ Art. 49 RIA.

³⁶⁹ Art. 21 et 73 RIA.

³⁷⁰ Sur la normalisation technique, cf. infra, n° 252 et s.

³⁷¹ Art. 3 § 4 RIA.

³⁷² Art. 26 RIA.

les domaines à haut risque³⁷³, une restriction de taille est néanmoins prévue. En effet, la qualification de système d'intelligence artificielle à haut risque est réservée aux systèmes d'IA « destinés à être utilisés par les autorités judiciaires ou en leur nom, pour les aider à rechercher et à interpréter les faits ou la loi, et à appliquer la loi à un ensemble concret de faits, ou à être utilisés de manière similaire lors du règlement extrajudiciaire d'un litige ».

Or, les outils de justice prévisionnelle actuellement sur le marché ne sont pas directement destinés à l'administration de la justice ou à ses modes alternatifs de règlement. Ils ne s'adressent pas directement aux personnes mettant fin au litige (juge, arbitre, médiateur). L'enquête que nous avons réalisée auprès de nos partenaires industriels a au contraire montré que ces outils s'adressent plutôt au marché des avocats, des directions juridiques, des assureurs, ou encore des banques. C'est donc le secteur privé qui est visé en priorité.

Pourtant, à suivre le texte, la qualification d'un outil de justice prévisionnelle dépend de la qualité de son utilisateur. S'il s'agit d'une personne mettant fin à un litige l'outil de justice prévisionnelle utilisé est à haut risque, s'il s'agit d'un conseil juridique ou plus généralement d'un acteur du secteur privé, le même outil ne sera pas considéré à haut risque.

228. **Critique.** Pareille différence de traitement n'est pas une bonne chose³⁷⁴. Même utilisés en dehors du système judiciaire ou de ses modes alternatifs, ces outils sont de nature à produire un impact sur les sources du droit en générant la constitution d'une « jurisprudence du fond »³⁷⁵. Surtout, ces outils peuvent favoriser le recours aux transactions. Or, dans la mesure où les résultats dépendent du paramétrage des outils, il est possible pour une partie qui en a les moyens (par exemple un assureur, un employeur, etc.) de choisir, parmi les solutions proposées, celle qui lui sera la plus favorable pour peser dans les négociations³⁷⁶. Dans ces conditions, le consentement de l'autre partie à la base de la transaction peut apparaître mal éclairé au détriment du droit d'accès au juge qui découle du droit à un procès équitable garanti par l'article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Autre exemple, une banque pourrait utiliser un outil de justice prévisionnelle pour évaluer les chances de gain d'un contentieux et déterminer si elle accorde ou non un crédit pour le financement du procès. Là encore, si le refus de crédit est accordé sur la base d'un résultat établi

³⁷³ Annexe III, 8. a).

³⁷⁴ Hyde A., « Plaidoyer pour l'inclusion des outils de jurimétrie dans le futur règlement européen sur l'intelligence artificielle », *La Semaine juridique Édition générale*, 2023, doct. 1112.

³⁷⁵ Deumier P., « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond », in *La Justice prédictive, Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p.49 et s.

³⁷⁶ Chollet D., « La justice prédictive et les principes fondamentaux du procès civil », in *La justice prédictive, Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 223 et s., spéc. p. 228.

dans des conditions qui ne garantissent ni sa transparence, ni son exactitude, il y a un risque important d'atteinte au droit d'accès au juge.

Où l'on voit que le risque pour les droits fondamentaux est le même qu'un outil de justice prévisionnelle soit utilisé dans le cadre de l'institution judiciaire ou dans un cadre privé. Peut-être même est-il moins grand en matière de service public de la justice où les voies de recours sont, sauf exceptions, largement ouvertes.

Quitte à choisir une approche par les risques, il aurait sans doute été plus pertinent de définir le haut risque en fonction de l'impact sur les droits fondamentaux des individus, leur santé, leur sécurité, ou sur des grands intérêts collectifs comme la lutte contre les discriminations ou la lutte contre le réchauffement climatique, plutôt que de dresser une liste des secteurs dans lesquels les utilisations sont sujettes à caution.

229. Conformité des fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle. Une application volontaire du RIA par les fournisseurs et les utilisateurs d'outils de justice prévisionnelle demeure néanmoins souhaitable, notamment sur la base de codes de bonnes pratiques ou de bonne conduite, ainsi que le prévoit d'ailleurs le règlement³⁷⁷. En effet, rien n'empêche un magistrat d'utiliser ce type d'outil, bien au contraire, dans la mesure où les prétentions des avocats vont l'y inciter si elles se fondent sur leurs résultats. Or cela devrait avoir pour conséquence de modifier la qualification du système si bien que le fournisseur serait bien avisé d'avoir anticipé...

L'initiative d'Open law visant à élaborer collectivement un référentiel de bonnes pratiques³⁷⁸ répond ainsi à cet objectif.

230. Perspectives pour la puissance publique. Il revient à la puissance publique de prendre des mesures pour garantir la loyauté des outils de justice prévisionnelle. Si le principe de loyauté n'est pas directement consacré par le règlement européen ou par les instruments éthiques, ses finalités le sont³⁷⁹. Il apparaît ainsi en filigrane de la plupart des règles ou des principes. En effet, la loyauté implique, d'une part, de « dire ce que l'on fait », ce que recouvre également les principes de transparence, d'explicabilité et de justification. Et précisément, la transparence est au cœur du RIA, tant à l'égard du déployeur qu'à l'égard du régulateur. Quant à l'explicabilité,

³⁷⁷ Art. 56 RIA.

³⁷⁸ <https://openlaw.fr/notre-actualite/la-saison-ia-et-economie-numerique-du-droit-bat-son-plein/>

³⁷⁹ Hyde A., « La loyauté de l'intelligence artificielle », *Expertises*, octobre 2024.

elle est visée dans deux considérants du RIA³⁸⁰ et l'article 86 § 1 qui consacre un « droit à l'explication de la prise de décision individuelle ». La justification, enfin, n'est pas totalement ignorée du texte dans la mesure où, à l'occasion de l'étude d'impact d'un système d'IA sur les droits fondamentaux, son fournisseur devra justifier la pertinence des choix entrepris, eu égard aux finalités poursuivies. D'autre part, la loyauté implique de « faire ce que l'on dit », ce que recouvrent également les exigences de pertinence des choix de conception, de qualité et d'adéquation des données utilisées, d'exactitude et de robustesse des résultats.

Il s'agit là des exigences minimales auxquels les outils de justice prévisionnelle doivent se conformer pour être dignes de confiance³⁸¹. À ce titre, l'évaluation par un tiers selon un référentiel de qualité est sans doute une piste intéressante à explorer.

C'est précisément dans cette démarche que s'est situé le travail d'interfaçage droit-métronologie de la présente recherche³⁸².

231. Le RIA se concentre sur les mesures préventives (régulation *ex ante*) et ne s'est pas intéressé à la question de la responsabilité des fournisseurs et des dépoyeurs (régulation *ex post*). Cet aspect est l'objet des deux propositions de directive en matière d'IA.

§2 – Les propositions de directive en matière de responsabilité de l'IA

232. **Dualité de textes.** La Commission européenne a présenté, le 28 septembre 2022, une proposition de directive relative à l'adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l'IA³⁸³. Le même jour, elle a présenté une proposition de directive réformant la responsabilité du fait des produits défectueux³⁸⁴, réforme spécialement destinée à intégrer « les actions en réparation des dommages en rapport avec les nouvelles technologies, y compris l'IA »³⁸⁵. Présentons tour à tour la proposition de directive sur la

³⁸⁰ Considérants 27 et 59.

³⁸¹ Dans un sens proche pour les décisions algorithmiques en général : Besse Ph., Castets-Renard C., Garivier A., « Loyauté des décisions algorithmiques », Contribution au débat public initié par la CNIL : Éthique et numérique, 2017, hal-01544701 : <https://hal.science/hal-01544701/document>

³⁸² Cf. infra, n° 282 et s.

³⁸³ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l'intelligence artificielle (Directive sur la responsabilité en matière d'IA), COM(2022) 496 final : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0496>

³⁸⁴ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, COM(2022) 495 final : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0495>

³⁸⁵ Considérant 3.

responsabilité de l'IA (A) et la directive réformant la responsabilité du fait des produits défectueux (B).

A. La proposition de directive sur la responsabilité de l'IA

233. **Objet de la proposition de directive sur la responsabilité en matière d'IA.** La proposition de directive sur la responsabilité de l'IA est d'harmonisation minimale³⁸⁶. Elle n'a pas pour objet d'établir un nouveau régime de responsabilité, mais de poser quelques règles applicables lorsque le juge interne met en œuvre les règles nationales de responsabilité civile. Elle concerne uniquement les cas dans lesquels la responsabilité pour faute est recherchée pour un dommage causé par l'intelligence artificielle, sur le fondement de règles nationales de responsabilité. Dans un tel cas, elle permet à la victime d'obtenir un allègement de la charge de la preuve. Cette démarche résulte du constat selon lequel « compte tenu des caractéristiques spécifiques de l'IA, notamment la complexité, l'autonomie et l'opacité (l'effet dit de « boîte noire »), il peut être difficile ou excessivement coûteux pour les victimes d'identifier la personne responsable et d'apporter la preuve des conditions requises pour obtenir gain de cause »³⁸⁷.

234. **Principaux apports du texte.** L'allègement de la charge de la preuve pour la victime résulte de deux mesures. D'une part, l'article 3 du texte dispose qu'une juridiction peut ordonner la *divulcation des éléments de preuve pertinents* concernant des systèmes d'IA à haut risque spécifiques soupçonnés d'avoir causé un dommage. Les demandes de preuves sont adressées au fournisseur d'un système d'IA, à la personne soumise aux obligations du fournisseur prévues à l'article 24 ou à l'article 28, paragraphe 1, de la législation sur l'IA ou à l'utilisateur conformément à la législation sur l'IA. D'autre part, l'article 4 institue une *présomption réfragable de lien de causalité entre la faute et le résultat*. Le demandeur doit prouver la faute commise par le défendeur conformément aux règles nationales ou de l'Union, tel pour un SIA, le non-respect de l'une des nombreuses obligations prévues par le RIA. Plus généralement, pour les outils de justice prévisionnelle, le non-respect des exigences de la Charte

³⁸⁶ Boine C., « La responsabilité civile liée à l'intelligence artificielle dans l'Union européenne », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 677 et s., spéc. p. 696.

³⁸⁷ Exposé des motifs.

éthique de la CEPEJ nous semble pouvoir constituer une base sérieuse pour la caractérisation d'une faute³⁸⁸.

La juridiction peut également présumer une telle faute sur la base du non-respect d'une injonction judiciaire de divulgation ou de conservation d'éléments de preuve en vertu de l'article 3, paragraphe 5. Néanmoins, la présomption joue seulement s'il est possible de considérer comme probable que la faute en cause a influencé le résultat du système d'IA concerné ou l'incapacité du système d'IA à produire un résultat, ce qui peut être évalué sur la base des circonstances générales du cas d'espèce. Il s'agit donc d'une simple présomption de fait.

235. Complémentarité avec les régimes existants. Nous verrons plus loin comment les régimes de responsabilité existants peuvent appréhender le cas du dommage créé par un outil de justice prévisionnelle et comment le régime mis en place par la proposition de directive aurait vocation à alléger les charges probatoires.

236. Absence de reconnaissance d'une responsabilité de plein droit. Alors que des voix se sont élevées pour que soit consacré un régime de responsabilité de plein droit³⁸⁹ à l'égard du fournisseur, la proposition de directive sur la responsabilité de l'IA n'a pas suivi cette orientation. Cependant, la Commission n'est pas restée complètement sourde puisqu'elle a entrepris, dans le même temps, de réformer le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux – qui est précisément un régime de responsabilité de plein droit – afin d'inclure dans le champ de la directive « les actions en réparation des dommages en rapport avec (...) l'IA »³⁹⁰.

B. La directive réformant la responsabilité des produits défectueux

237. Objet de la réforme. Le 23 octobre 2024, l'Union européenne a adopté une nouvelle directive relative à la responsabilité des produits défectueux³⁹¹ afin de moderniser le régime actuel « à la lumière des nouvelles technologies, y compris l'intelligence artificielle »³⁹². Notamment il est apparu que la charge de la preuve (c'est-à-dire la nécessité, pour obtenir

³⁸⁸ Cf. infra où l'on verra que cela peut être rattaché au devoir général de prudence et de diligence : n° 333.

³⁸⁹ Deffains B., de Montcuit G., « Proposition d'un régime de responsabilité objective applicable au dommage causé par une machine auto-apprenante », *Revue trimestrielle de droit civil*, 2022, p. 257.

³⁹⁰ Considérant 3.

³⁹¹ Dir. N° 2024/2853 du Parlement européen et du Conseil, abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil : https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=OJ:L_202402853

³⁹² Considérant 3.

réparation, de prouver que le produit était défectueux et que ce défaut avait causé le dommage subi) posait des difficultés aux personnes lésées dans des cas complexes, concernant par exemple, des produits dotés d'IA, alors même que les systèmes d'IA sont de plus en plus répandus sur le marché et jouent un rôle accru pour la sécurité des produits³⁹³. L'un des objectifs du texte est donc d'alléger la charge probatoire des victimes de produits incorporant de l'IA.

238. Principaux apports du texte. La directive *étend le champ d'application de la responsabilité du fait des produits défectueux*. D'abord, le texte énonce expressément que la notion de produit inclut « les fichiers de fabrication numériques et les logiciels »³⁹⁴, à l'exception des « logiciels libres et ouverts »³⁹⁵. Ensuite, il élargit la catégorie des défendeurs en établissant une responsabilité subsidiaire des différents « opérateurs économiques » de la chaîne lorsque le fabricant du produit défectueux ne peut être identifié. Enfin, il ajoute à la catégorie des dommages réparables « la perte ou la corruption de données ». La directive *facilite la preuve des conditions de la responsabilité*. D'abord, son article 9 habilite les juridictions nationales, sur sollicitation de la victime ayant présenté des éléments de preuve étayant la plausibilité de sa demande, à ordonner au défendeur de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose. Ensuite, il est institué une présomption simple de défectuosité³⁹⁶ et de lien de causalité³⁹⁷ dès lors que certaines conditions sont réunies. Par ailleurs, des présomptions sont admises également, à la discrétion des juridictions, en cas de complexité technique ou scientifique rendant l'établissement de la preuve particulièrement difficile pour le demandeur³⁹⁸.

³⁹³ Considérant 13.

³⁹⁴ Art. 4 § 1.

³⁹⁵ Art. 2 § 2.

³⁹⁶ Art. 10 § 2 « La défectuosité du produit est présumée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : a) le défendeur n'a pas respecté l'obligation de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose conformément à l'article 9, paragraphe 1 ; b) le demandeur démontre que le produit n'est pas conforme aux exigences de sécurité obligatoires prévues par le droit de l'Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque de survenance du dommage subi ; ou c) le demandeur démontre que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d'une utilisation raisonnablement prévisible ou dans des circonstances ordinaires ».

³⁹⁷ Art. 10 § 3 « Le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est présumé lorsqu'il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d'une nature généralement compatible avec le défaut en question ».

³⁹⁸ Art. 10 § 4.

Les recours collectifs sont possibles via les actions représentatives prévues par la directive européenne relative aux recours collectifs dans l'intérêt des consommateurs³⁹⁹ mais les États-membres sont par ailleurs libres de prévoir leurs propres mécanismes de recours collectifs⁴⁰⁰

239. **Impact limité sur le dommage dans lequel est impliqué un outil de justice prévisionnelle.** Pour que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux trouve à s'appliquer, une condition tenant à la nature du dommage doit cependant être satisfaite. En effet, le préjudice réparable s'entend exclusivement du préjudice corporel, du préjudice matériel strictement entendu (atteinte aux biens – et pas au patrimoine), de la destruction ou de la corruption de données⁴⁰¹. En effet, la directive n'a pas souhaité aller au-delà et réparer les atteintes à la vie privée ou la discrimination⁴⁰² par exemple. Plus généralement donc, elle n'a pas vocation à réparer une atteinte à un droit fondamental à l'exception de la protection des données à caractère personnel. Or, en matière de justice prévisionnelle, le risque de préjudice est pour la personne concernée, outre l'atteinte à la protection de ses données – personnelles ou non –, celui d'une atteinte aux garanties du procès équitable⁴⁰³. Le régime issu de la directive ne pourra donc pas être mobilisé pour en obtenir la réparation.

240. **Conclusion.** Le cadre applicable aux outils de justice prévisionnelle est particulièrement dense et complexe. Les instruments, de sources diverses, n'ont pas tous le même degré d'obligatorité et ne posent pas tous les mêmes exigences. Cependant, il est possible d'observer un certain noyau dur parmi tous les principes étudiés et toutes les obligations analysées. Ce noyau dur est composé des principes essentiels visant à assurer la confiance dans les outils de justice prévisionnelle, ce qui passe concrètement par des garanties concernant la protection des données, la fiabilité des résultats (en ce compris l'absence de biais volontaires et la minimisation des biais involontaires), un contrôle humain permettant de rendre compte des choix opérés, de rendre intelligible et acceptable le fonctionnement du système, et d'en assumer la responsabilité en cas de dommage.

³⁹⁹ Directive (UE) 2020/1828 relative aux actions représentatives visant à protéger les intérêts collectifs des consommateurs et abrogeant la directive 2009/22/CE : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32020L1828>

⁴⁰⁰ Considérant 29.

⁴⁰¹ Art. 6 § 1.

⁴⁰² Il a été estimé (cf. exposé des motifs) que cela n'était pas nécessaire car ces atteintes « seraient traitées de manière plus appropriée dans le cadre d'autres législations ».

⁴⁰³ Cf. supra, n° 25 et s.

Titre 2 – La mise en œuvre des mesures régulatrices des outils de justice prévisionnelle

241. Il résulte des développements précédents que la régulation du marché des outils de justice prévisionnelle dans le sens d'une plus grande confiance vise, en premier lieu, à prévenir la réalisation de dommage et, en second lieu, à réparer le préjudice résultant de la survenance du dommage. Comment concrètement réaliser ce double objectif ?

C'est ce que nous allons voir en étudiant la mise en œuvre *ex ante* (Chapitre 1) puis la mise en œuvre *ex post* (Chapitre 2).

Chapitre 1 – La mise en œuvre *ex ante*⁴⁰⁴

242. **La mise en conformité, modalité de la *compliance*.** Le règlement pour l'intelligence artificielle a opté pour « le modèle normatif de la conformité »⁴⁰⁵, adoptant ainsi une logique de *compliance*⁴⁰⁶ en exigeant des opérateurs leur mise en conformité⁴⁰⁷. Cette démarche a pour objectif de garantir une IA digne de confiance dès l'origine (*by design*) et de prévenir autant que possible la réalisation des risques identifiés et, avec elle, des dommages.

Cela étant, le recours à la *compliance* n'est pas toujours la panacée lorsque les opérateurs ne sont pas accompagnés dans leur mise en conformité (Section 1). Pour cette raison, la normalisation technique peut s'avérer utile pour guider les opérateurs dans leur démarche de conformité. Le rôle que peut jouer la normalisation technique dans la mise en conformité des outils de justice prévisionnelle sera donc étudié (Section 2), avant de voir comment nous avons tenté d'en poser les jalons en concevant la première analyse d'impact en matière d'outils de justice prévisionnelle (Section 3).

Section 1 – Les limites de la régulation des outils de justice prévisionnelle par la *compliance*

243. **Un mode de régulation à la mode.** La *compliance*, ou mise en conformité, constitue un mode de régulation à la mode en matière de nouvelle technologie. S'il est vrai qu'en la matière, les modes traditionnels de régulation apparaissent relativement inefficaces tant l'objet à saisir est technique, évolutif et protéiforme⁴⁰⁸, les modes plus souples de type auto-régulation

⁴⁰⁴ Par Aurore Hyde.

⁴⁰⁵ Besse Ph. Et Castets-Renard C., « Responsabilité ex ante de l'AI act : entre certification et normalisation, à la recherche des droits fondamentaux au pays de la conformité », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 597 et s., spéc. n° 8.

⁴⁰⁶ La conformité est en effet un des outils de la *compliance* : Frison-Roche M.-A., « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », février 2024 : <https://mafr.fr/fr/article/compliance-et-conformite-les-distinguer-et-les-art/#:~:text=Distinguer%20les%20deux%20permet%20de,rôle%20majeur%20pour%20ce%20faire>

⁴⁰⁷ Méneceur Y., « Analyse des principaux cadres supranationaux de régulation de l'Intelligence artificielle : de l'éthique à la conformité », *Les Temps Électriques*, 27 mai 2021 : <https://lestempselectriques.net/index.php/2021/05/27/analyse-des-principaux-cadres-supranationaux-de-regulation-de-lintelligence-artificielle-de-lethique-a-la-conformite/>

⁴⁰⁸ Merabet S., *Vers un droit de l'intelligence artificielle*, préf. H. Barbier, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, vol. 197, 2020 ; Scherer M., « Regulating artificial intelligence systems: risks, challenges, competencies, and Strategies », *Harvard Journal of Law & Technology*, 29, 2016, 354 ; Pasquale F., *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard, Harvard University Press, 2015, 320.

n'apparaissent pas forcément plus efficaces en matière d'algorithmes de traitement des contenus⁴⁰⁹. Pour cette raison, de nombreuses voix préconisent une voie médiane permettant de faire la synthèse entre des sources trop rigides et des sources trop souples de régulation. Cette voie serait celle de la *compliance*. La *compliance* serait donc un palliatif à la faible efficacité tant de la régulation juridique centralisée que de la régulation de marché.

244. **Définition.** La *compliance* peut se définir comme « l'internalisation dans certains opérateurs de l'obligation de se structurer pour concrétiser des buts qui ne leur sont pas naturels, buts qui sont fixés par les autorités publiques qui ont en charge le futur des groupes sociaux, buts que ces entreprises doivent de gré ou de force viser à concrétiser, du seul fait qu'elles sont en position de les atteindre »⁴¹⁰. La *compliance* tend donc à rendre les opérateurs débiteurs de la norme en instaurant à leur égard une délégation de production des moyens de mise en œuvre de l'orientation générale. Et il est vrai qu'au regard notamment de leurs connaissances et de leurs savoir-faire technologiques, ces opérateurs apparaissent les mieux placés pour déterminer la meilleure manière de parvenir aux buts fixés par la puissance publique tels que par exemple, en matière de protection des données à caractère personnel, l'obligation de fournir à la personne concernée une information compréhensible sur le traitement réalisé sur ses données⁴¹¹.

245. Pour autant, la *compliance* soulève la question de l'influence des intérêts privés sur la production de la régulation publique et sur sa mise en œuvre, au point que cette modalité de régulation a pu à juste titre être décrite comme « un instrument de capture informationnelle de la régulation publique »⁴¹² dont la généralisation s'explique par « la capture cognitive des régulateurs »⁴¹³.

246. **Faiblesses intrinsèques de la *compliance*.** En outre, la définition précédemment exposée soulève quantité de questions :

- quels opérateurs (tous, ou seulement les « grands ») ?
- à quel(s) niveau(x) de conception doit-elle intervenir ? quels sont les buts à atteindre ?
- comment sont-ils fixés par la puissance publique ?

⁴⁰⁹ « Modalités de régulation des algorithmes de traitement des contenus », Pavel I., Rapport pour la Direction de l'information légale et administrative, 2016 : <https://www.vie-publique.fr/rapport/273514-modalites-de-regulation-des-algorithmes-de-traitement-des-contenus>

⁴¹⁰ Frison-Roche M.-A., « Le droit de la compliance », *Recueil Dalloz*, 2016, p. 1871.

⁴¹¹ art. 12 du RGPD.

⁴¹² Harnay S., « Co-réguler, se conformer, capturer : la compliance comme modalité de capture de la régulation ? », *Revue française d'administration publique*, 2024 (à paraître).

⁴¹³ *Ibid.*

- quelles sont les autorités publiques compétentes pour ce faire ?
- quelles sont les sanctions en cas de manquement ?
- qui est compétent pour prononcer les sanctions le cas échéant ?
- quels sont les moyens d'internalisation ?
- qu'est-ce qui caractérise le fait d'être en position d'atteindre ces buts ?

247. Ces questions à elles seules révèlent les faiblesses intrinsèques de la *compliance*. Cela s'est vérifié en matière d'outil de justice prévisionnelle, dans l'affaire COMPAS, la justice pénale étant un domaine dans lequel la réalisation d'un même « *but* » (en l'occurrence, l'équité) pouvait être atteinte par différentes voies (« rappel » ou « précision »). Or, selon que l'on privilégie une voie par rapport à une autre, les incidences sur les personnes concernées peuvent varier substantiellement⁴¹⁴.

248. Dans ces conditions, il apparaît nécessaire de ne pas laisser les fournisseurs d'outils livrés à eux-mêmes dans la détermination des moyens à mettre en œuvre pour respecter certains buts. Au contraire, il est important de définir un cadre plus précis et d'accompagner la mise en conformité. À cet égard, la normalisation technique peut être une voie intéressante.

Section 2 – La normalisation technique, accompagnement dans la mise en conformité des outils de justice prévisionnelle

249. **Cadre national de la normalisation technique.** La normalisation est, de manière générale, l'activité consistant à élaborer des solutions « standardisables » à des difficultés généralement techniques que rencontrent les professionnels. Elle a été pendant le XIXe siècle une initiative spontanée des acteurs privés avant que les pouvoirs publics n'interviennent en créant, en 1918, la première Commission permanente de standardisation⁴¹⁵. Cet interventionnisme s'est soldé par la mise en place d'une véritable tutelle de l'État sur l'activité de normalisation, par un décret de 1941⁴¹⁶. Il faudra attendre le décret du 26 janvier 1984⁴¹⁷

⁴¹⁴ Cf. supra, n° 188.

⁴¹⁵ Franck P., « La normalisation des produits industriels », PUF, 1981, p. 59.

⁴¹⁶ Rouland M., « La normalisation technique (instrument de concurrence à la loi) », intervention lors du colloque : Le droit mou, une concurrence faite à la loi, Université Paris X-Nanterre, 3 décembre 2004, intervention reprise sous forme d'article et accessible sur [glose.org](http://www.glose.org/CEDCACE7.pdf) : <http://www.glose.org/CEDCACE7.pdf>

⁴¹⁷ Décret n°84-74 du 26 janvier 1984 fixant le statut de la normalisation.

pour que cette tutelle prenne fin, et c'est également à cette période que la normalisation connut un essor considérable et devint progressivement un outil au service de la libéralisation des échanges en Europe et à l'international⁴¹⁸. Depuis lors, un nouveau décret du 16 juin 2009 a abrogé le précédent et la normalisation est désormais définie comme « une activité d'intérêt général qui a pour objet de fournir des documents de référence élaborés de manière consensuelle par toutes les parties intéressées, portant sur des règles, des caractéristiques, des recommandations ou des exemples de bonnes pratiques, relatives à des produits, à des services, à des méthodes, à des processus ou à des organisations »⁴¹⁹. Cette mission d'intérêt général a été confiée à l'Association française de normalisation (AFNOR). Ces « documents de référence » constituent des normes dont l'application est soumise par principe au volontarisme des industriels, à moins que leur application n'ait été rendue obligatoire par arrêté du ministre chargé de l'industrie. Dans ce cas, leur communication doit se faire à titre gratuit sur le site de l'AFNOR⁴²⁰.

250. **Pluralité des cadres de la normalisation technique.** La normalisation technique connaît un essor considérable, depuis quarante ans, au niveau régional, international ou encore transnational. En effet, nombreuses sont les instances dans lesquelles s'élaborent cette normalisation. Plusieurs organismes auront ainsi un rôle à jouer dans l'élaboration de normes techniques et de standards pour l'intelligence artificielle. Sans prétendre à l'exhaustivité, on peut citer par exemple :

- au niveau international, l'Organisation internationale pour la standardisation⁴²¹ (ISO) créée en 1947, l'Organisation mondiale pour le commerce (OMC) avec l'accord sur les obstacles techniques au commerce signé en 1995⁴²², ou la Commission technique internationale⁴²³ (IEC) fondée en 1906 ;
- au niveau européen, le Comité européen de normalisation (CEN) et le Comité européen de normalisation en électronique et en électrotechnique⁴²⁴ (CENELEC) fondés en 1960,

⁴¹⁸ Rouland M., « La normalisation technique... », article précité.

⁴¹⁹ Art. 1^{er} du décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation ; comparaison avec la définition donnée par l'art. 1^{er} du décret de 1984 : « la normalisation a pour objet de fournir des documents de référence comportant des solutions à des problèmes techniques et commerciaux concernant les produits, biens et services qui se posent de façon répétée dans des relations entre partenaires économiques, scientifiques, techniques et sociaux ».

⁴²⁰ Art. 17 du décret de 2009.

⁴²¹ <https://www.iso.org/fr/home.html>

⁴²² https://www.wto.org/french/tratop_f/tbt_f/tbt_f.htm

⁴²³ <https://www.geneve-int.ch/fr/commission-electrotechnique-internationale-cei-0>

⁴²⁴ <https://www.cencenelec.eu>

ou encore l'Institut européen des normes de télécommunications⁴²⁵ créé en 1988 (ETSI) ;

- aux États-Unis, le National Institute of Standards and Technology⁴²⁶ (NIST), agence du département du commerce des États-Unis fondée en 1901, qui produit des travaux importants notamment dans le domaine de l'IA.

Ces différents organismes peuvent élaborer des normes de manière isolée ou conjuguée. Ainsi, il n'est pas rare que le CEN et l'ISO aient des procédures conjointes d'élaboration.

251. **Normes, référentiels, standards.** À côté des normes techniques au sens strict, il existe des normes techniques au sens large qui sont autant d'instruments de référence pour l'évaluation des produits ou des services. Il s'agit essentiellement des référentiels et des standards. Il existe un nombre important d'entités ayant compétence pour produire de telles normes de référence. Ce peut être une entité publique ou privée. On peut notamment citer, au niveau national, le Laboratoire national de métrologie et d'essais, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) en matière de protection des données à caractère personnel, ou encore l'ARCOM, qui s'est récemment vue confier le pouvoir d'élaborer un référentiel pour la vérification de l'âge des utilisateurs de service en ligne. Au niveau transnational, il y a lieu de citer l'Institut des ingénieurs en électricité et électronique⁴²⁷ (IEEE), qui joue un rôle important en matière informatique.

252. **Traits caractéristiques des normes techniques.** Les normes techniques ont vocation à appréhender des problèmes récurrents et cette finalité leur confère un caractère général. Ensuite, ces normes sont toujours écrites. Elles sont toujours contenues dans un document qui constitue la « référence ». Elles sont toujours adoptées selon un mode multipartite et consensuel. En effet, les normes résultent d'échanges entre les différentes parties prenantes, sous l'égide d'une entité tierce reconnue par la communauté. L'objectif est de parvenir à dégager un consensus de la communauté sur les contraintes que ses membres devront ensuite s'imposer. L'objet des normes techniques est parfaitement indifférent. Cela peut porter tant sur des produits que des services, en ce compris des modalités de management.

⁴²⁵ <https://www.etsi.org>

⁴²⁶ <https://www.nist.gov>

⁴²⁷ <https://www.ieee.org>

253. **Valeur juridique des normes techniques.** Ces « documents de référence » constituent des normes dont l'application est soumise par principe au volontarisme des industriels, à moins que leur application n'ait été rendue obligatoire par la loi. Le décret du 16 juin 2009 prévoit ainsi que les normes de l'AFNOR peuvent avoir été rendues obligatoires par arrêté du ministre chargé de l'industrie, auquel cas leur communication à titre gratuit s'impose sur le site de l'AFNOR⁴²⁸. C'est là une condition de l'accessibilité du droit. Par ailleurs, il est de plus en plus fréquent que les textes européens, spécialement les textes dans le secteur du numérique, fassent référence à des « normes harmonisées », c'est-à-dire aux normes élaborées par les organismes européens de normalisation (CEN, CENELEC, ETSI) sur mandat de la Commission européenne pour l'application de la législation d'harmonisation de l'Union⁴²⁹. Le respect de ces normes harmonisées a pour effet de conférer une présomption de conformité à la législation européenne. Tel est ce que prévoit l'article 40 du RIA au profit du fournisseur de systèmes d'IA à haut risque ou d'IA à usage général. Pour autant, le RIA ne fait pas du respect des normes harmonisées en matière d'IA une obligation. L'application demeure donc volontaire et en cas de non-respect, cela aura un impact sur la procédure d'évaluation de la conformité⁴³⁰.

Cependant, le caractère volontaire des normes harmonisée peut être remis en cause dans la mesure où la Cour de justice de l'Union européenne a jugé, dans l'affaire *James Elliot Construction* qu'une norme harmonisée, adoptée sur le fondement d'une directive et dont les références ont fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne, fait partie du droit de l'Union, en raison de ses effets juridiques⁴³¹.

Récemment, la Cour de justice de l'Union européenne a précisé que, lorsqu'elles s'intégraient de la sorte au droit de l'UE, les normes harmonisées devaient être rendues accessibles gratuitement⁴³². Cette décision constitue une avancée majeure dans le sens de l'accessibilité du droit.

⁴²⁸ Art. 17 du décret du 16 juin 2009.

⁴²⁹ Art. 2 §1 b et c du Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025>

⁴³⁰ Art. 43 RIA.

⁴³¹ CJUE, 27 octobre 2016, *James Elliott Construction*, C-613/14, pt. 40 : <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?jsessionid=9ea7d2dc30d61a0054c1763649049871f3bf5974bf60.e34KaxiLc3qMb40Rch0SaxyLchn0?text=&docid=173893&pageIndex=0&doclang=FR&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=512351>

⁴³² CJUE, 5 mars 2024, *Public.Resource.Org, Inc. et. Right to Know CLG. contre Commission européenne e.a*, C-588/21 : <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283443&pag%3C/body%3E%3C/html%3E>

254. À noter qu'en cas de retard important dans l'élaboration de normes harmonisée en matière d'IA, notamment du fait de la complexité technique de la matière, la Commission européenne devra fournir des spécifications communes⁴³³.

255. **Normes techniques pour l'IA.** Parce que l'IA repose sur un vaste traitement de données pouvant avoir un caractère personnel, il convient de citer la norme internationale ISO/IEC 27701 relative à la gouvernance et aux mesures de sécurité à mettre en place en la matière. Plus spécifiquement, l'ISO et l'IEC (Commission électrotechnique internationale) ont publié, en décembre 2023, une nouvelle norme internationale volontaire pour offrir un système de management de l'intelligence artificielle (SIAM) : ISO/IEC 42001. Il s'agit d'un référentiel fixant « des principes généraux quant à la protection des données, la spécification des informations utilisées pour nourrir l'IA, sa robustesse mais aussi sa transparence et son explicabilité »⁴³⁴. Cette norme fait suite aux normes déjà élaborées par ces organisations : ISO/IEC TR 24028 (sur la thématique de l'IA de confiance) ; ISO/IEC TR 24027 (analyse des biais propres à l'IA) ; ISO/IEC 20546 et ISO/IEC TR 20547-1 (sur le *big data* et l'architecture des métadonnées) ; ISO/IEC 23894 (sur le management du risque). Tout fournisseur ou utilisateur de système d'IA peut désormais acquérir cette norme pour la modique somme de 448,80 euros⁴³⁵. Une fois la norme implémentée, il pourra ensuite solliciter sa certification auprès d'un organisme accrédité. En effet, « ISO 42001 » est, comme la plupart des normes techniques, un référentiel certifiable⁴³⁶.

En Europe, l'ETSI et le CENELEC ont publié des agendas ambitieux pour la normalisation, en partie stimulés par le cadre proposé par le règlement de l'UE sur l'IA concernant les normes. L'ETSI s'est concentré sur les questions de sécurité entourant l'IA et l'apprentissage automatique, tandis que le CENELEC met fortement l'accent sur la fiabilité et l'éthique⁴³⁷.

Nous pouvons encore citer la série des standards P700x élaborés par l'IEEE et intéressant l'IA⁴³⁸ (ainsi par exemple : IEEE P7000: Model Process for Addressing Ethical Concerns

⁴³³ Considérant 121 et article 41 du RIA.

⁴³⁴ <https://www.afnor.org/actualites/une-norme-et-une-certification-qualite-pour-lia/>

⁴³⁵ https://www.boutique.afnor.org/fr-fr/norme/iso-iec-420012023/technologies-de-linformation-intelligence-artificielle-systeme-de-managemen/xs142381/355348%20?utm_source=afnor.org&utm_medium=NormeIA&utm_campaign=siteafnor_actu&utm_content=link

⁴³⁶ <https://www.afnor.org/actualites/une-norme-et-une-certification-qualite-pour-lia/>

⁴³⁷ « Harmonising Artificial Intelligence », Oxford Commission on AI and Good Governance, p. 10.

⁴³⁸ <https://ethicsinaction.ieee.org>

During System Design ; IEEE P7001: Transparency of Autonomous Systems ; IEEE P7002: Data Privacy Process ; IEEE P7008: Standard for Ethically Driven Nudging for Robotic, Intelligent and Autonomous Systems), ou la série des travaux du NIST sur l'IA (comme l'outil « Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0) »⁴³⁹ ou le document « Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence »⁴⁴⁰.

En France, le LNE a également produit en 2021 un référentiel pour la certification des processus d'IA (processus de spécification des algorithmes, d'entraînement, de test, et de maintien en conditions opérationnelles)⁴⁴¹. Lors de notre travail avec les partenaires industriels, il est apparu que les équipes techniques dédiées à la conception des outils de justice prévisionnelle n'avaient aucune connaissance de ces normes techniques.

256. **Une cartographie des activités de normalisation de l'IA en cours.** AI Watch, le service de connaissance de la Commission européenne sur le développement, l'adoption et l'impact de l'IA en Europe, a produit une synthèse des activités de normalisation de l'IA en cours des organisations de normalisation européennes et internationales par rapport aux exigences du projet de règlement sur l'IA. À ce jour, AI Watch a cartographié les normes ISO/IEC et ETSI en référence au projet de règlement. AI Watch constate que dans les huit principaux domaines de normalisation du projet de règlement sur l'IA, de nombreuses normes pertinentes ont déjà été publiées ou sont en cours de développement⁴⁴².

257. Nous reproduisons ici la carte élaborée dans le document de recherche de l'Oxford Commission on AI and Good Governance de 2021.

⁴³⁹ <https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/ai/nist.ai.100-1.pdf>

⁴⁴⁰ <https://www.nist.gov/publications/towards-standard-identifying-and-managing-bias-artificial-intelligence>

⁴⁴¹ <https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-processus-ia>

⁴⁴² Nativi, S. and De Nigris, S., « AI Watch, AI standardisation landscape state of play and link to the EC proposal for an AI regulatory framework », Commission européenne, Centre commun de recherche, Publications Office, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2760/376602>

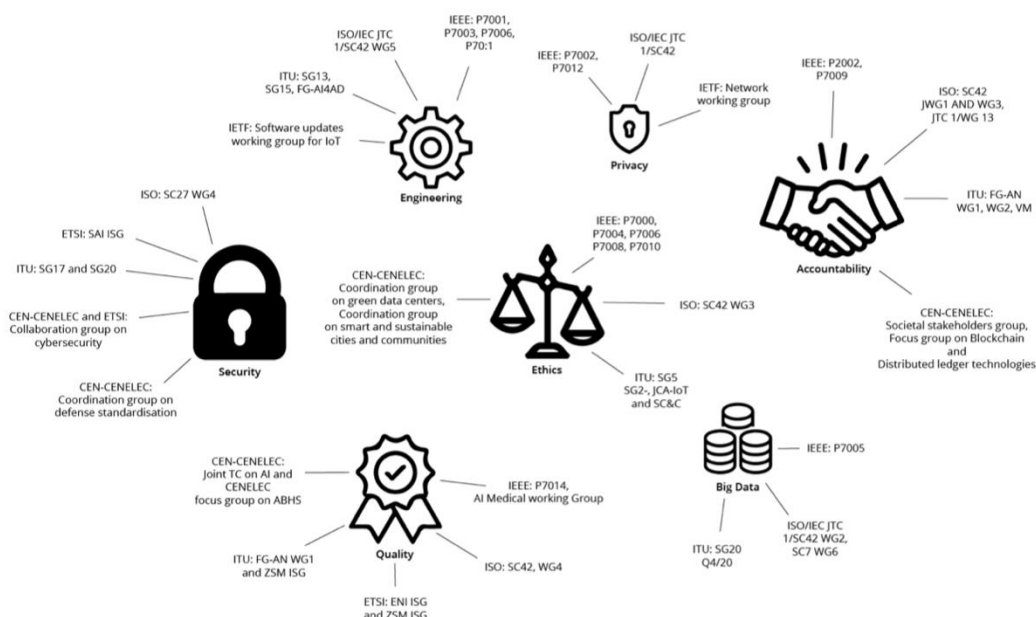


Figure 1 – Activité des organisations de développement de normes sur l'IA en 2020⁴⁴³

258. **Normalisation et certification.** Comme le relève justement Yannick Méneceur, il existe trois catégories de procédures pour vérifier la conformité d'un produit ou d'un service à des normes⁴⁴⁴. Il s'agit d'abord des procédures internes par lesquelles l'entité met en place un service dédié en interne pour réaliser des audits de conformité. Il s'agit ensuite des procédures externalisées auprès d'un tiers ayant un intérêt vis-à-vis de l'entité sollicitant la vérification, comme un client par exemple. Il s'agit enfin des procédures externalisées auprès d'un tiers parfaitement indépendant de l'entité sollicitant cette vérification, ce tiers pouvant être tant un établissement public (comme le Laboratoire national de métrologie et d'essais) qu'un établissement privé habilité par la puissance publique. C'est véritablement cette troisième voie que désigne la certification. En effet, la certification est définie par l'AFNOR comme : « une preuve irréfutable, délivrée suite à un audit mené par un organisme certificateur impartial et objectif, qu'un produit, service ou une organisation, respecte les exigences d'un cahier des charges strict »⁴⁴⁵. Quant à l'ISO (International Organization for Standardization), elle définit la certification comme « l'assurance écrite (sous la forme d'un certificat) donnée par un tiers qu'un produit, service ou système donné est conforme à des exigences spécifiques »⁴⁴⁶. La certification est « l'action par laquelle un organisme reconnu par une accréditation et

⁴⁴³ « Harmonising Artificial Intelligence », précité, p. 11.

⁴⁴⁴ Méneceur Y., « La procédure de certification... », art. précité, spéc. p. 19.

⁴⁴⁵ <https://certification.afnor.org/besoins/premiere-certification>

⁴⁴⁶ <https://www.iso.org/fr/certification.html>

indépendant [des parties en cause] donne une assurance écrite (un certificat) qu'une organisation, un processus, un service, un produit ou des compétences particulières sont conformes à des exigences prédéfinies »⁴⁴⁷.

Pour cette activité de certification, l'AFNOR n'a aucun monopole et d'autres organismes peuvent avoir été accrédités par le Comité français d'accréditation⁴⁴⁸ (COFRAC). C'est notamment le cas du Laboratoire national de métrologie et d'essais qui est un établissement public industriel et commercial et qui a été associé aux travaux de la présente recherche.

259. Normes techniques et droits fondamentaux. La multiplication des références à la normalisation technique en matière d'IA a suscité un débat sur la capacité des standards à protéger les droits fondamentaux. D'un côté certains auteurs se sont montrés particulièrement sceptiques⁴⁴⁹ quand d'autres au contraire se sont montrés plutôt enthousiastes⁴⁵⁰. S'il est certain qu'il n'est pas évident de déterminer à l'avance des critères neutres et objectifs pour appréhender les valeurs que constituent les droits fondamentaux, il n'en demeure pas moins possible d'établir un « cadre de la matrice éthique » à l'image de ce que propose la société de Cathy O'Neil : O'Neil Risk Consulting & Algorithmic Auditing⁴⁵¹ (ORCAA), cadre spécifique aux outils de justice prévisionnelle.

Tel est notamment ce que nous avons tenté de réaliser en proposant une première trame pour l'analyse des risques des outils de justice prévisionnelle⁴⁵². Mais ce premier travail mériterait non seulement d'être poursuivi⁴⁵³ mais aussi adapté à chaque outil⁴⁵⁴ pour tenir compte de la technologie qu'il implémente, notamment avec l'arrivée de l'IA générative dans les outils à destination des professionnels du droit.

260. Identifier les droits fondamentaux les plus pertinents. Toute analyse d'impact sur les droits fondamentaux mérite de s'interroger au préalable sur la nature des droits fondamentaux

⁴⁴⁷ <https://www.lne.fr/fr/comprendre/la-certification>

⁴⁴⁸ <https://www.cofrac.fr>

⁴⁴⁹ Besse Ph. et Castets-Renard C., « Responsabilité ex ante de l'AI act : entre certification et normalisation, à la recherche des droits fondamentaux au pays de la conformité », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 597 et s., spéc. n° 30 et s. ; Gornet M. et Maxwell W., « Intelligence artificielle : normes techniques et droits fondamentaux, un mélange risqué », *The Conversation*, 28 sept. 2022 : <https://theconversation.com/intelligence-artificielle-normes-techniques-et-droits-fondamentaux-un-melange-risque-189587>

⁴⁵⁰ Lewkowicz G. et Sarf R., « Taking Technical Standardization of Fundamental Rights Seriously for Trustworthy Artificial Intelligence », *La Revue des juristes de Science Po*, 2024, n° 25, p. 42 et s.

⁴⁵¹ <https://orcaarisk.com>

⁴⁵² Cf. Annexe n° 1.

⁴⁵³ Il n'a malheureusement pas pu totalement aboutir pour les raisons expliquées plus bas (cf. infra, n° 298).

⁴⁵⁴ Nous ne l'avons réalisé que pour deux alors que d'autres existent.

en cause⁴⁵⁵. Il s'agit d'identifier les droits et libertés les plus pertinents selon le contexte d'utilisation du système d'IA. En matière de justice prévisionnelle, ce sont particulièrement le droit à la non-discrimination, le droit au respect de la vie privée et à la protection des données à caractère personnel et le droit au procès équitable qui risquent d'être particulièrement atteints⁴⁵⁶.

Ensuite, pour chaque droit identifié, cela nécessite de répertorier un ensemble de questions permettant de cerner la conscience du risque qu'a le fournisseur d'un outil de justice prévisionnelle, la manière dont il en a tenu compte dans la conception et ce qu'il a fait pour y remédier.

261. Élaborer des référentiels adaptés au territoire. Les différences internationales dans l'interprétation et l'application des droits fondamentaux deviennent plus saillantes, réduisant ainsi la capacité à établir des standards communs. Les différences sont importantes, selon les régions, dans l'interprétation et l'application des droits fondamentaux. Au niveau international bien sûr (par exemple la liberté d'expression n'est pas protégée de la même façon aux États-Unis, en Europe ou en Chine), mais également au niveau européen (la liberté d'expression n'est pas protégée de la même façon en France et en Pologne malgré la vocation uniformisatrice du droit européen). Dans ces conditions, il est important que les outils utilisés par les professionnels du droit en France soient évalués en fonction de référentiels reflétant la conception française des droits fondamentaux en cause.

262. Assurer une plus grande représentativité de toutes les parties prenantes (et spécialement une expertise en matière de droits fondamentaux) dans la réalisation des référentiels. La prépondérance des acteurs industriels au sein des organismes de normalisation soulève des questions quant à la légitimité et à la capacité de ces organismes à protéger les droits fondamentaux. Cette prépondérance risque effectivement de rendre ces organismes vulnérables au lobbying industriel⁴⁵⁷. Cela s'est récemment illustré avec l'exclusion de l'Institut

⁴⁵⁵ Hyde A., « La compliance en matière d'IA », in *Memento Compliance*, dir. M. Roussille, E. Breen, A. Gaudemet, Éditions Francis Lefebvre, 2024 (à paraître).

⁴⁵⁶ Cf. supra, n° 25 et s.

⁴⁵⁷ McFadden M., Jones K., Taylor E., Osborn G., « Harmonizing Artificial Intelligence: The role of standards in the EU AI Regulation », Oxford Information Labs, 2021, p. 20 : <https://oxcaigg.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/11/2021/12/Harmonising-AI-OXIL.pdf>

européen des normes de télécommunications (ETSI) du projet de demande de normalisation de la Commission pour l'application du règlement pour l'intelligence artificielle⁴⁵⁸.

La protection des droits fondamentaux et des valeurs qui les fondent est un sujet d'intérêt général qui mérite un plus grand débat démocratique et une plus grande représentativité de toutes les parties prenantes dans les organismes de normalisation ou plus généralement les organismes élaborant des référentiels et des standards.

Par ailleurs, il est essentiel que les compétences juridiques soient représentées, spécialement l'expertise en matière de droits fondamentaux, notamment car les implications concrètes de leur protection sont très contextuelles. C'est pour cette raison que les travaux réalisés dans le cadre de cette recherche pour l'évaluation de deux systèmes reposent sur un interfaçage droit-métronologie⁴⁵⁹. Cet interfaçage est destiné à garantir une bonne traduction technique des impératifs juridiques afin de réaliser un cahier des charges et mettre à l'épreuve les métriques existantes. Il s'est ainsi agi d'expliquer aux experts en IA les implications concrètes de certains droits ou principes éthiques issus de la Charte de la CEPEJ.

263. Pour la certification des outils de justice prévisionnelle. Bien que la certification constitue la solution la plus coûteuse et la plus complexe parmi les modalités réglementaires envisageables⁴⁶⁰, cette voie nous semble la mieux à même de garantir la confiance dans les outils de justice prévisionnelle.

264. Analogie avec la certification des services en ligne de conciliation, médiation et arbitrage. En matière d'aide à la résolution amiable des différends en ligne, le ministère de la Justice a opté pour une régulation du secteur via la certification volontaire des services, pour favoriser la sécurité juridique et instaurer un climat de confiance pour le justiciable qui décide d'y recourir⁴⁶¹.

En effet, l'article 4 de la loi de programmation pour la justice⁴⁶², modifiant l'article 4 de la loi de modernisation pour la justice au XXI^e siècle⁴⁶³, prévoit un socle d'obligations incombant à tous les services en ligne ainsi qu'une procédure de certification facultative⁴⁶⁴ par un organisme

⁴⁵⁸ Lewkowicz G. et Sarf R., « Taking Technical Standardization of Fundamental Rights Seriously... », article précité, spéc. p. 44.

⁴⁵⁹ Cf. infra, n° 274 et s.

⁴⁶⁰ Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice, précité, p. 16.

⁴⁶¹ Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice, précité, p. 15, présentation de Mesdames Elodie Guennec et Delphine Chevalier.

⁴⁶² Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

⁴⁶³ Loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016.

⁴⁶⁴ Art. 4-7 de la loi du 23 mars 2019.

préalablement accrédité⁴⁶⁵ par le COFRAC. Par exception, la certification est accordée de plein droit aux conciliateurs de justice, aux médiateurs inscrits sur la liste au titre de leur activité de médiation de consommation ainsi qu'aux personnes inscrites, dans le ressort d'une cour d'appel, sur la liste des médiateurs.

En dehors de ces hypothèses donc, la certification se fait sur demande, et atteste du respect des exigences mentionnées aux articles 4-1 à 4-6 de la loi. Il s'agit du respect :

- des obligations relatives à la protection des données à caractère personnel ;
- de l'obligation de confidentialité sauf accord des parties ;
- de l'obligation de délivrer une information détaillée sur les modalités selon lesquelles la médiation est réalisée ;
- de l'obligation de ne pas avoir pour seul fondement un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel ;
- de l'obligation d'informer les usagers que le service est proposé à l'aide d'un traitement algorithmique ou automatisé de données à caractère personnel par une mention explicite et le recueil exprès du consentement de l'utilisateur ;
- de l'obligation de fournir une information détaillée et intelligible à la partie qui en fait la demande sur la manière dont le traitement a été mis en œuvre à son égard ;
- des obligations d'impartialité, d'indépendance, de compétence, et de diligence.

Les services certifiés bénéficieront ensuite du droit d'usage de la marque Certilis et du kit associé, lequel comprend la charte d'usage de la marque, la charte graphique de la marque, le logo de la marque Certilis sous ses différentes déclinaisons.

265. Déterminer le caractère volontaire ou obligatoire de la certification des outils de justice prévisionnelle. Choisir la voie de la certification ne résout pas toutes les difficultés car il faudra encore déterminer le caractère obligatoire ou non de cette procédure. Si c'est la certification volontaire qui a été choisie pour les services en ligne de règlement amiable des différends, ce choix nous paraît critiquable. L'apposition de la marque Certilis peut finalement apparaître plus comme un argument commercial que comme un gage de confiance. Surtout, ce choix permet à des plateformes peu scrupuleuses de continuer à prospérer sur le marché des services juridiques. Il nous paraît donc important que la conformité des outils de justice prévisionnelle à un référentiel soit rendue obligatoire et soumise à l'expertise d'un tiers certificateur. Outre que cela garantit leur fiabilité, cela prévient le risque d'une multiplication

⁴⁶⁵ Le décret n° 2020-1682 du 23 décembre 2020 précise les modalités de l'audit d'accréditation, de la suspension et du retrait de l'accréditation ainsi que les conséquences de la cessation d'activité de l'organisme certificateur.

des débats purement procéduriers et dilatoires sur les outils de justice prévisionnelle utilisés, aux dépens de l'examen du fond de la question examinée par une juridiction⁴⁶⁶.

C'est la raison pour laquelle il a été fait appel à l'expertise du Laboratoire national de métrologie et d'essais pour étudier la faisabilité d'un référentiel et d'une procédure de certification. Le caractère obligatoire de la certification assurerait, outre la confiance dans les outils, une plus grande publicité de l'accès au référentiel. En effet, la Cour de justice de l'Union européenne a récemment jugé que les normes harmonisées dont les références avaient été publiées au Journal officiel de l'UE s'incorporaient au droit de l'Union, ce dont il résulte qu'elles doivent être rendues accessibles gratuitement⁴⁶⁷. Or, il ne fait aucun doute que les normes ou référentiels rendus obligatoires au niveau national s'incorporent au droit français et doivent dès lors être rendus accessibles.

266. Expertise du LNE pour la certification des systèmes de justice prévisionnelle. Pour bénéficier de la qualité de tiers certificateur, il faut avoir été accrédité par une entité compétente. En France, il s'agit du Comité français d'accréditation créé en 1994 et devenu « instance nationale d'accréditation, seule habilitée à délivrer les certificats d'accréditation en France » avec la loi de modernisation de l'économie en 2008⁴⁶⁸ et son décret d'application⁴⁶⁹. L'accréditation est « l'attestation de la compétence des organismes qui effectuent des activités d'évaluation de la conformité »⁴⁷⁰. Cette compétence peut s'apprécier au regard de la conformité à la norme ISO/IEC 17065:2012 (Évaluation de la conformité – Exigences pour les organismes certifiant les produits, les procédés et les services)⁴⁷¹. Cette norme internationale fixant les exigences des organismes réalisant la certification est largement utilisée par les organismes de certification dans divers secteurs, comme l'agriculture, les produits électroniques, les dispositifs médicaux, etc. Elle établit des critères relatifs à la compétence, à la fiabilité et à l'impartialité de ces organismes dans leurs activités de certification. Les exigences couvrent, entre autres, la qualification et la formation du personnel impliqué dans le processus de certification, les processus suivis (de l'évaluation initiale réalisée durant la certification, jusqu'à la surveillance continue après la délivrance du certificat). L'accréditation par le COFRAC atteste alors de la

⁴⁶⁶ Dans le même sens, voir la recommandation n° 9 du rapport sur « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », dir. Cadiet L., Chainais C. et Sommer J.-M., précité.

⁴⁶⁷ CJUE, 5 mars 2024, *Public.Resource.org Inc & Right to know c. CEN et a.*, C-588/21 : <https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=283443&pag%3C/body%3E%3C/html%3E>

⁴⁶⁸ Loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, art. 137.

⁴⁶⁹ Décret n° 2008-1401 du 19 décembre 2008 relatif à l'accréditation et à l'évaluation de conformité pris en application de l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.

⁴⁷⁰ Art. 137 loi de 2008 précité.

⁴⁷¹ <https://www.iso.org/fr/standard/46568.html>

conformité de l'organisme certificateur à cette norme, ce qui permet de renforcer la confiance des consommateurs et des autorités réglementaires dans les éléments certifiés. Elle n'est pas obligatoire pour délivrer des certifications volontaires mais l'est pour délivrer des certifications obligatoires.

267. Le LNE est justement accrédité ISO/IEC 17065:2012 pour la certification de plus d'une centaine de produits de l'industrie, et maîtrise à ce titre les exigences de qualité et d'impartialité. Par ailleurs, nous l'avons dit, le LNE a produit en 2021 un référentiel pour la certification des processus d'IA (processus de spécification des algorithmes, d'entraînement, de test, et de maintien en conditions opérationnelles)⁴⁷². Cette certification, dont le référentiel a été créé avec un collectif de parties prenantes, permet d'attester que l'entreprise développant le produit adopte les « bonnes pratiques », en termes notamment de gestion de la qualité, de contrôle des activités de développement, et de traçabilité de ces actions dans le domaine de l'intelligence artificielle. Cette certification est agnostique au secteur industriel cible de l'IA (santé, agriculture, finance, etc.). Le LNE propose en outre une certification des systèmes de management pour l'IA, sur la base de la norme ISO/IEC 42001:2023 (Technologies de l'information – Intelligence artificielle – Système de management)⁴⁷³. Cette norme permet de veiller à un développement et un usage responsable de l'IA. Les exigences relatives aux organismes certificateurs sont actuellement en cours de définition au niveau international avec l'élaboration d'une norme ISO/IEC DIS 42006 (Information technology — Artificial intelligence — Requirements for bodies providing audit and certification of artificial intelligence management systems)⁴⁷⁴. Enfin, en réponse au Grand challenge sur l'IA d'usage général lancé par l'État⁴⁷⁵, le LNE a récemment formé un partenariat avec l'Institut national de recherche en informatique et en acoustique (INRIA) pour créer le Centre français de l'évaluation de l'IA⁴⁷⁶. Ce centre assumera différentes missions dont la création de méthodes d'évaluation des systèmes d'IA et de mesures de référence. La place des activités de recherche et d'expérimentation en son sein en fait le partenaire idéal pour penser le cadre de l'évaluation des outils de justice prévisionnelle et plus largement de l'IA appliquée dans le domaine du droit et de la justice (on pense par exemple à la preuve biométrique).

⁴⁷² <https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-processus-ia>

⁴⁷³ <https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-iso-42001-systeme-management-intelligence-artificielle>

⁴⁷⁴ <https://www.iso.org/standard/44546.html>

⁴⁷⁵ <https://www.lne.fr/fr/on-en-parle/intelligence-artificielle-cadre-confiance>

⁴⁷⁶ <https://www.lne.fr/fr/actualites/ia-partenariat-ambitieux-lne-inria>

268. **Déterminer l'effet du respect du référentiel par un fournisseur sur sa responsabilité civile.** Enfin, il conviendra également de préciser l'incidence de la conformité sur la responsabilité civile du fournisseur du système. Le respect d'une norme technique par un fournisseur, même d'une norme d'application obligatoire, ne suffit généralement pas à écarter sa responsabilité civile en cas de dommage. L'article 1386-10 du Code civil le prévoit d'ailleurs expressément en matière de responsabilité du fait des produits défectueux⁴⁷⁷. Et de manière générale, ce n'est qu'associé à d'autres circonstances que le respect de la norme technique est pris en compte par le juge pour écarter la responsabilité du professionnel⁴⁷⁸.

269. **Déterminer l'étendue de la certification.** Lorsque l'on envisage une procédure de certification, il est essentiel de déterminer l'étendue de celle-ci. En matière de justice prévisionnelle, il s'agira de déterminer si la seule procédure de conception doit être certifiée ou s'il faut également que les données utilisées le soient ou que les résultats en sortie le soient. Là encore, il appartiendra à la puissance publique de réaliser ces choix.

270. La présente recherche a étudié la faisabilité de la certification des outils de justice prévisionnelle en concentrant son attention sur les données.

Section 3 – Notre étude de faisabilité de la certification de deux outils de justice prévisionnelle⁴⁷⁹

271. Le travail conduit a été organisé en deux parties : d'une part, l'analyse de risques des systèmes de justice et, d'autre part, la création des plans d'évaluation des systèmes d'IA. Malheureusement, cette seconde étape n'a pas pu véritablement aboutir.

272. Bien que la seconde étape n'ait pas pu aboutir, le LNE a pu rendre des conclusions sur la faisabilité d'une certification pour ces deux systèmes de justice prévisionnelle. Après une présentation du cadre général de l'étude de faisabilité (§1), nous exposerons les analyses de risques (§2) puis les plans d'évaluation (§3).

⁴⁷⁷ Selon ce texte : « le producteur peut être responsable du défaut alors même que le produit a été fabriqué dans le respect des règles de l'art ou de normes existantes ou qu'il a fait l'objet d'une autorisation administrative ».

⁴⁷⁸ Civ. 1ère, 4 nov. 1992, *Recueil Dalloz*, 1994, 45. – 1er déc. 1999, *Recueil Dalloz*, 2000, 287, note J. Mouly

⁴⁷⁹ Par Guillaume Bernard, avec le concours d'Aurore Hyde.

273. **Mission du LNE et objectif de l'étude.** Le LNE a eu pour objectif d'étudier la chaîne de qualification de deux systèmes de justice prévisionnelle choisis, à savoir JurisData Analytics et LegalMetrics, fournis par les partenaires industriels du projet de recherche, à savoir respectivement LexisNexis et Lexbase. L'objectif principal de cette étude était d'analyser le degré de maturité de ces systèmes vis-à-vis d'une potentielle certification.

274. **Fonctionnalités des outils analysés.** Pour rappel, JurisData Analytics est un service d'analyse quantitative et prospective de la jurisprudence française. Ce service introduit une nouvelle approche de la recherche en allant au-delà des mots-clés, grâce à l'extraction des données de la jurisprudence. Il permet de trouver les décisions de cours d'appel correspondant à des critères très précis, dans le but d'anticiper les suites possibles d'une affaire et de définir la meilleure stratégie juridique. Notamment, il offre une évaluation des indemnités susceptibles d'être accordées, par exemple dans le contentieux de la responsabilité civile ou dans le contentieux familial⁴⁸⁰, sur la base d'une recherche par critères. LegalMetrics poursuit un objectif identique mais la manière d'y procéder est différente puisque la recherche s'effectue par thème – et non par critère – et selon une méthode en entonnoir. En outre, LegalMetrics peut également produire la cartographie judiciaire d'une entreprise. Toutes les décisions dans laquelle une personne morale est partie, en demande ou en défense, sont ainsi réparties par thème et par date. Les deux outils permettent aux utilisateurs de consulter, à tout moment, les décisions ayant servi à produire les résultats proposés.

275. **Place de l'IA dans les outils analysés.** Les deux systèmes intègrent une à plusieurs fonctionnalités d'IA mais ils ne le font pas de la même façon. Lors des premières réflexions sur la conception de l'analyse de risques (en février 2021), le règlement sur l'intelligence artificielle était encore loin d'être adopté. Rapidement néanmoins, la philosophie générale du texte ainsi que son orientation étaient déjà connues du LNE : une classification des systèmes d'IA selon leur niveau de risque avec des exigences plus ou moins importantes en fonction de cette classification. Nous avons fait le choix de considérer que les systèmes d'IA dans le domaine

⁴⁸⁰ C'est ce dernier contentieux qui a été l'objet de l'expérimentation mise en place au sein du tribunal judiciaire d'une grande ville. Cf. infra n° 341 et s.

juridique seraient classés à haut risque et devraient de ce fait répondre à un certain nombre d'exigences pour pouvoir être certifiés et utilisés sur le sol européen. Au fur et à mesure de notre travail, il nous est apparu que cette qualification ne serait pas retenue. Pour autant, nous sommes restés sur notre idée de départ en considérant que « qui peut le plus, peut le moins ». La définition de l'IA non plus n'était pas fixée mais le choix a été fait de retenir une définition restrictive. Selon cette définition, un SIA est un système reposant sur l'apprentissage automatique – ou *machine learning*. Ce choix d'exclure les systèmes experts s'explique par le fait que les systèmes fondés sur l'apprentissage automatique sont actuellement majoritaires dans le paysage de l'IA et la plupart des outils de justice prévisionnelle – et des *legaltechs* en général – vont être appelés à utiliser cette technologie.

Au moment où la grille d'analyse a été réalisée, il a été possible de déceler l'utilisation de l'IA dans une seule brique du système JurisData Analytics (à savoir la thématisation des documents) et dans quatre briques pour LegalMetrics (à savoir la thématisation du document, son découpage ou le « burger », l'anonymisation du document, et l'établissement de la chaîne du contentieux).

276. Normes de références pour l'étude de faisabilité de la certification. Au moment de la réalisation de ce travail, les normes étaient encore pour la plupart en cours d'élaboration, spécialement ISO 42001 et ISO 23894 par exemple. Bien qu'elles aient été entre temps publiées, ces normes font l'objet d'une actualisation récurrente et le travail présenté dans ce document vient alimenter les réflexions en cours. Afin d'étudier la faisabilité d'une certification pour les deux systèmes analysés, l'étude s'est également appuyée sur les recommandations et bonnes pratiques de la communauté scientifique, la Charte éthique d'utilisation de l'IA dans les systèmes judiciaires et leur environnement, la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle dans ses différentes versions, ainsi que sur le référentiel élaboré par le LNE « Certification de processus pour l'IA »⁴⁸¹.

L'ensemble des éléments à étudier pour définir si un système d'IA peut être certifié étant supérieur au périmètre de cette étude, nous nous sommes concentrés sur l'évaluation des modules d'IA des deux systèmes.

277. Méthodologie générale. L'évaluation des systèmes d'apprentissage est fondée sur le principe de comparaison entre des données de référence, aussi appelées « vérité terrain » et les sorties du système évalué, appelés données d'hypothèse. Les données de référence et

⁴⁸¹ <https://www.lne.fr/fr/service/certification/certification-processus-ia>

d'hypothèse sont comparées en s'appuyant sur des métriques d'évaluation, dont les résultats permettent d'évaluer la performance d'un système d'IA.

Les données ont une importance primordiale dans la performance d'un système d'IA fondé sur l'apprentissage automatique : la qualité et la quantité des données contenues dans le jeu de données permettant d'entraîner le système sont évidemment importantes, mais c'est aussi le cas pour la sélection du jeu de données de référence qui permet d'évaluer le système d'IA.

Les données collectées ont une influence décisive sur les résultats de l'évaluation : elles peuvent comporter des caractéristiques ou biais, qu'il est nécessaire de maîtriser pour ne pas produire une évaluation faussée du système. Parmi ces caractéristiques, il faut notamment citer les cas « rares », c'est-à-dire les phénomènes sous-représentés dans les bases de données habituellement utilisées par les systèmes, mais dont la mauvaise gestion pourrait avoir des conséquences dramatiques, par exemple en conduisant à une mauvaise décision lors d'un jugement. Du fait de la potentielle sous-représentation de ces événements rares, il convient de les identifier par le biais d'une analyse de risques. L'objectif est d'identifier les erreurs des systèmes pouvant avoir des conséquences graves et d'estimer leur probabilité d'occurrence. Par ailleurs, l'analyse de risques permet aussi d'identifier les facteurs d'influence contenus dans les données et ainsi aider à la construction du jeu d'évaluation. En conséquence, le travail a été organisé en deux grandes parties : d'une part, l'analyse de risques des systèmes de justice et, d'autre part, la création des plans d'évaluation des systèmes d'IA. Malheureusement, cette seconde étape n'a pas pu véritablement aboutir.

Pour chacune de ces étapes, des échanges ont eu lieu et l'organisation du travail a été discutée avec les partenaires industriels. Cette démarche répond notamment à l'objectif de sensibilisation et de formation des industriels aux risques associés à la conception, au déploiement et à l'utilisation des outils qu'ils fabriquent, ainsi qu'aux besoins futurs liés à la certification. À cette fin, les échanges sont primordiaux. L'étude a en effet permis de mettre en évidence un certain scepticisme des équipes affectées à la conception des outils pour qui les exigences liées à la mise en conformité étaient « du jus de cerveau de juristes ». L'étude aura donc permis une prise de conscience forte.

§2 – L'analyse de risques

278. Après avoir présenté la démarche générale (A), nous expliquerons le déroulement du processus de création de l'analyse de risques avec nos partenaires industriels (B) avant de livrer nos conclusions (C).

A. La démarche

279. **Spécificité de l'analyse de risques des systèmes d'IA d'aide à la décision.** En règle générale, l'analyse de risques explore peu les aspects logiciels des machines, et l'exploration systématique des performances du logiciel est peu couverte. De façon standard, l'analyse se limite généralement à une simple vérification de performance fonctionnelle. Il s'agit alors de vérifier si le système subit un arrêt critique ou non. Or dans le cas des systèmes intégrant des composantes d'IA ou « systèmes décisionnels », cette approche est trop limitée. Il est primordial de vérifier que des décisions pouvant engendrer un dommage important ne soient pas prises. Dans le cadre des systèmes de justice prévisionnelle, on peut par exemple imaginer qu'un système ne retrouvant pas les bonnes décisions sur un contentieux déterminé pourrait conduire l'utilisateur à prendre une mauvaise décision. Cette mauvaise décision ayant des effets juridiques, cela entraîne des conséquences importantes pour la personne concernée.

Le travail sur l'analyse de risques consigné ici a été effectué au cours de l'année 2022, alors même que la norme ISO/IEC 23894 portant sur la gestion des risques pour les systèmes d'IA était en cours d'élaboration. Pour autant, le LNE participe activement à différents groupes de travail sur la normalisation en matière d'IA ce qui lui confère une connaissance du contenu des normes en cours d'élaboration. Par ailleurs il n'existe à ce jour aucune norme spécifique pour l'IA appliquée au droit et à la justice. Le travail accompli est donc relativement précurseur et prospectif. Il mériterait d'être poursuivi et étendu à d'autres outils, la difficulté tenant au caractère particulièrement évolutif de la technologie embarquée dans les systèmes. Les étapes de l'analyse de risques effectuée dans le cadre de cette recherche sont les suivantes : identification des modules d'IA présents dans le système étudié ; identification des causes de défaillance pour chaque module ; quantification du risque.

280. **Identification des modules d'IA.** La première étape a consisté à découper le système étudié en différentes briques fonctionnelles et à identifier celles qui incorporent des fonctionnalités d'IA.

Dans le cas de Lexbase (LegalMetrics), trois fonctionnalités d'IA ont été identifiées dans cette analyse initiale : la Thématisation automatique de décisions, l'Anonymisation des documents, et enfin la Correspondance des documents et la chaîne de contentieux. Le processus d'analyse de risques a été appliqué sur ces trois fonctionnalités. Par la suite, de nouvelles fonctionnalités d'IA ont été développées par Lexbase et étudiées dans le cadre des plans d'évaluation, mais ces

dernières n'ont pas suivi le processus d'analyse de risques. Dans le cas de LexisNexis (JurisData Analytics), une fonctionnalité d'IA a été identifiée pour le processus d'analyse de risques : la Thématization automatique de décisions. Les deux fonctionnalités sont similaires entre Lexbase et LexisNexis. Comme pour Lexbase, de nouvelles fonctionnalités d'IA ont été étudiées dans la suite de l'enquête mais n'ont pas suivi le processus d'analyse de risques.

Malheureusement, ce découpage n'est plus pertinent dans la mesure où les industriels ont fait énormément évoluer leurs outils sur le plan technologique.

281. **Identification des causes de défaillances.** Une fois les briques identifiées, la deuxième étape consiste à énumérer pour chaque brique les causes de défaillances pouvant entraîner des conséquences graves. Dans le cadre de la présente recherche, sept catégories de risques ont été identifiées :

1. **Automatisation du système**, où le niveau d'automatisation varie, de la présence d'un opérateur contrôlant la décision du système d'IA, à une autonomie totale de bout en bout. Un système avec une grande autonomie peut avoir un impact sur la sécurité des décisions prises. Dans un système de justice prévisionnelle, l'absence de contrôle humain dans la boucle d'anonymisation des jurisprudences peut avoir des conséquences importantes dans le cadre d'une erreur d'anonymisation.
2. **Transparence et explicabilité**, où la transparence correspond à la communication des informations d'une brique d'IA – par exemple l'algorithme utilisé ou les données d'apprentissage et de test, et l'explicabilité correspond à la capacité à comprendre les décisions faites par le système d'IA. Cette catégorie de risques peut avoir des conséquences importantes sur la confiance du public dans le système. Pour un système de justice prévisionnelle, si un organisme public ne peut pas avoir accès au processus de validation d'une des briques d'IA, l'impact sur la crédibilité du système sera très important.
3. **Complexité de l'environnement**, où le système doit être capable de gérer le contexte opérationnel, soit en anticipant l'ensemble des états de l'environnement dans lequel le système sera déployé, soit en étant capable de gérer l'incertitude du contexte d'utilisation. Dans le cadre des systèmes de justice prévisionnelle, une brique d'IA devra être par exemple capable de s'adapter aux différents formats de jurisprudence.
4. **Cycle de vie du système**, où les méthodologies et les processus sont insuffisants pour le cycle de vie de la brique d'IA et peuvent conduire à des risques. Parmi les risques identifiés, peuvent être cités : le *design* de l'IA, sa vérification et validation, son

déploiement, sa maintenance et sa mise à jour. Dans le cadre d'un système de justice prévisionnelle, une mauvaise validation de la performance du système après une mise à jour peut par exemple conduire à des régressions dans la sélection de jurisprudences pertinentes et ainsi amener de mauvaises décisions du juriste utilisant le système.

5. **Maturité technologique**, où le niveau de maturité de la technologie sur laquelle s'appuie la brique d'IA peut engendrer des risques. Une technologie peu mature peut engendrer des risques difficiles à évaluer, tandis qu'une technologie trop mature peut au contraire amener une trop grande confiance dans son fonctionnement et déboucher sur une accumulation de dettes techniques.
6. **Risques liés à l'apprentissage**, où le recours à des approches d'apprentissage automatique peut engendrer des risques liés à de mauvais processus de mise en place de ces approches. Ces risques peuvent aussi bien concerner la qualité des données utilisées pour entraîner ou évaluer le système, que le fait que ces données ne soient plus représentatives du contexte opérationnel. Pour un système de justice prévisionnelle où les décisions juridiques sont classées par catégorie, une base d'apprentissage non mise à jour pour prendre en compte l'évolution des types de décisions juridiques peut ensuite conduire à un mauvais fonctionnement de la brique d'IA.

En plus de ces six catégories, il est aussi généralement suggéré dans les groupes de travail d'étudier les problèmes liés au matériel, mais dans le cas des systèmes étudiés, cette catégorie n'était pas pertinente.

282. **Quantification du risque.** En s'appuyant sur la catégorisation décrite, une liste des risques peut ainsi être créée pour chaque brique d'IA identifiée. La dernière étape consiste alors à déterminer la criticité de chacun des risques. Cette criticité s'évalue à l'aide de deux critères : la gravité du risque et sa probabilité de survenance. Ces deux critères sont définis à l'aide de deux échelles : de 1 à 5 pour la gravité et de 1 à 4 pour la probabilité de survenance. L'estimation de la criticité d'un risque permet par la suite aux concepteurs de système de définir les priorités dans leur traitement et le type de solutions à apporter, mais aussi d'orienter le processus d'évaluation des briques d'IA : ces risques représentent potentiellement des cas rares par rapport au contexte opérationnel des systèmes. On pourra ainsi vouloir représenter dans la base de données d'évaluation un risque avec une probabilité de survenance moyenne – 2 sur 4 – car sa gravité a été estimée comme étant très importante – 4 sur 5. Si l'on reprend l'exemple de la brique d'IA d'anonymisation des jurisprudences, suite à l'estimation de la criticité, la gravité du risque a été définie comme étant majeure – 4 sur 5 – et sa probabilité faible – 1 sur 5. Du fait

de ces résultats, on souhaitera faire apparaître dans la base de test un nombre très faible d'exemples pouvant conduire à ce type d'erreurs, du fait de sa gravité. Pour autant, le nombre d'échantillons reste très faible, car peu fréquent.

À partir de cette définition de la démarche d'analyse de risques des systèmes, une organisation avec les partenaires industriels a été définie et est présentée dans la section suivante.

B. Le déroulement du processus de création avec les partenaires industriels

283. **Un travail collaboratif.** En s'appuyant sur la démarche précédemment décrite, une collaboration a été mise en place avec chacun des partenaires industriels pour effectuer l'analyse de risques des deux systèmes. Cette collaboration est divisée en trois réunions effectuées dans les locaux de chaque partenaire :

- première réunion d'analyse du système et d'identification des briques d'IA ;
- seconde réunion de travail sur une version temporaire de l'analyse de risques ;
- troisième réunion de travail sur la version finale de l'analyse de risques.

284. **Objectif de la première réunion.** La première réunion a eu pour objectif de permettre au partenaire de présenter les systèmes étudiés à un expert du LNE spécialisé dans l'évaluation des systèmes d'IA.

Outre la compréhension globale du système, cette première réunion a surtout permis d'identifier la ou les briques d'IA présentes dans le système. La réunion a aussi eu pour but de présenter aux industriels la démarche de création des analyses de risques et de répondre à leurs questions concernant ce processus.

285. **Objectif de la deuxième réunion.** À la suite de cette première réunion, l'expert du LNE a travaillé sur une version simplifiée de l'analyse de risques. N'ayant pas l'expertise métier des partenaires industriels, cette première mouture a été créée pour servir de base à la suite du travail effectué par les partenaires eux-mêmes. Néanmoins, les exemples proposés se sont appuyés sur l'expérience de l'expert du LNE, en lien avec les juristes, et avaient vocation à être pertinents et utilisables pour la version finale.

Cette analyse de risques, tout comme sa version finale, est représentée sous la forme d'un tableur disponible en annexe⁴⁸² et dont voici un exemple.

⁴⁸² Cf. Annexe n° 1

	Risque	Catégorie du risque	Description du risque	Gravité (1-5)	Probabilité de survenance (1-5)	
A1	Thématisation automatique de décisions					
AI.1.1	Corruption des données reçues par un tiers	Automatisation du système	Des acteurs malveillants ajoutent des données volontairement erronées dans les bases interrogées par le système pour ajuster des décisions juridiques fausses pouvant conduire par la suite à de mauvaises décisions par les utilisateurs.			
AI.1.2	Oublis de décisions pertinentes	Automatisation du système	Du fait d'une défaillance du système, certaines décisions émises par les cours ne sont pas récupérées, conduisant à avoir une base de décisions non à jour. Cela peut ensuite conduire des utilisateurs à ne pas s'appuyer sur le corpus le plus à jour et leur faire défaut dans les décisions juridiques à prendre.			
AI.2.1	Manque de documentation sur la validation de l'algorithme	Transparence et explicabilité	L'approche utilisée pour la recherche automatique de décisions juridiques n'a pas de documentation associée détaillant le processus de validation de l'algorithme, conduisant à un manque de confiance dans la performance du système.			

Tableau 1: Exemple de lignes du tableau de l'analyse de risques pour une brique d'IA

Lors de la deuxième réunion, cette première version de l'analyse de risques a été présentée aux partenaires industriels, permettant ainsi d'illustrer le processus de création. L'objectif de cette réunion étant principalement de répondre aux interrogations des partenaires industriels et de montrer comment l'analyse de risques s'adapte à leur contexte.

286. **Éléments du tableau d'analyse de risques.** Pour chaque brique d'IA du système d'un des partenaires industriels, tous les risques identifiés ont été énumérés et complétés d'un certain nombre d'informations :

- le nom du risque (ex. oublis de décisions pertinentes, manque de documentation sur la validation de l'algorithme, régression du système suite à une mise à jour, informations confidentielles non protégées, etc.) ;
- la catégorie à laquelle le risque appartient (ex. automatisation du système, transparence et explicabilité, cycle de vie du système, complexité de l'environnement, etc.) ;
- la description du risque expliquant son contexte et son impact (ex. : Du fait d'une défaillance du système, certaines décisions émises par les cours ne sont pas récupérées, conduisant à avoir une base de décisions non à jour. Cela peut ensuite conduire des utilisateurs à ne pas s'appuyer sur le corpus le plus à jour et leur faire défaut dans les décisions juridiques à prendre » ; « Les processus de validation et de non régression du système n'ont pas été mis en place ou ne sont pas suffisamment complet, conduisant à une non détection de la perte de performance du système suite à une mise à jour) ;
- la gravité du risque sur une échelle de 1 à 5 ;
- la fréquence d'apparition du risque sur une échelle de 1 à 4 ;
- la justification des deux critères de criticité, avec notamment les actions effectuées par les partenaires industriels pour endiguer le risque.

287. **Rôle des partenaires industriels.** Les partenaires industriels ont ensuite dû remplir le document d'analyse de risques en s'appuyant sur leur expertise. Ils ont également dû remplir un

questionnaire « compliance » élaboré par Aurore Hyde et Sophie Harnay pour évaluer la place des considérations éthiques et juridiques dans leur démarche de conception⁴⁸³.

288. **Objectif de la troisième réunion.** Une fois ce document finalisé, une troisième réunion a été organisée, pour valider le processus et partager les conclusions du LNE sur la démarche : l'exercice a-t-il semblé intéressant pour les partenaires ? l'analyse de risques était-elle adaptée aux systèmes de justice prévisionnelle ? etc. L'objectif était à la fois d'aider les partenaires à s'adapter à cet exercice et de mettre en adéquation la méthodologie et le contexte industriel des partenaires. Cette dernière réunion a montré la réussite de l'exercice : les documents initiaux d'analyse de risques ont été mis à jour par les partenaires en intégrant de nouveaux risques et des méthodes de mitigation de risques. Le LNE est revenu sur l'importance d'un tel processus : l'analyse de risques doit être mise en place dès le début du développement d'une fonctionnalité d'IA, et les méthodes de mitigation doivent être validées à la fin du cycle de production pour s'assurer que les risques sont bien traités. Si le travail présenté ici s'est concentré avant tout sur la construction des documents d'analyse de risques, les partenaires ont pris conscience de l'importance de la mise en place de nouveaux processus et de la documentation associée pour correctement traiter les risques.

Cette troisième réunion a également été l'occasion de revenir sur les réponses apportées au questionnaire « *compliance* ».

C. Nos conclusions sur l'analyse de risques et les suites du travail

289. L'approche par l'analyse des risques était un exercice nouveau pour les partenaires industriels. La démarche a été généralement très appréciée, avec un vrai apport pour le travail des partenaires. Par ailleurs, l'analyse de risques des briques d'IA semble répondre à de vrais besoins de transparence pour les acteurs. L'importance de la démarche dans la perspective de la création de systèmes d'IA performants et de confiance, ainsi que d'une future certification a été comprise. Les partenaires ont précisé vouloir intégrer cette méthodologie dans leurs futurs processus de création de fonctionnalités d'IA.

En s'appuyant sur le travail effectué pour l'analyse de risques, la suite de l'étude devait se concentrer sur la mise en place des plans d'évaluation. Bien qu'il n'ait pu aboutir, ce travail est néanmoins présenté.

⁴⁸³ Cf. questionnaire reproduit en annexe n° 3.

S3 – Les plans d'évaluation

290. À la présentation générale du plan d'évaluation (A) succèdera celle du processus d'élaboration du plan d'évaluation avec nos partenaires (B). Cela nous amène à pouvoir tirer des conclusions tant sur la création du plan d'évaluation (C) que sur la qualification des outils de justice prévisionnelle (D).

A. La présentation du plan d'évaluation

291. **Définition.** Le plan d'évaluation est le document permettant de décrire l'ensemble des informations nécessaires à l'évaluation d'une fonctionnalité d'IA. Ce document doit être impérativement rédigé au début de la production de la fonctionnalité d'IA : le fait de définir ce plan en amont du développement de la fonctionnalité d'IA permet d'assurer la confiance dans les résultats obtenus par le système lors de son évaluation. Par ailleurs, avoir un plan d'évaluation complet et correctement rédigé facilite la répétabilité de l'évaluation : ce dernier point est particulièrement important dans le cadre de la certification des systèmes d'IA. D'un point de vue légal, il est aussi attendu qu'un industriel soit capable de rejouer une évaluation et de prouver les résultats obtenus par son système.

292. **Contenu du plan d'évaluation.** Le plan d'évaluation doit contenir l'ensemble des informations nécessaires pour documenter et réaliser l'évaluation d'une fonctionnalité d'IA. Son contenu peut varier d'un projet à un autre : dans le cadre de cette recherche, le LNE a proposé que le plan contienne les éléments suivants.

- *La description de la tâche d'évaluation* : il faut définir précisément la fonctionnalité évaluée, sur quelle technologie la fonctionnalité est installée, la caractéristique de la fonctionnalité évaluée et enfin les éléments apportant de l'information supplémentaire pour l'évaluation.

Voici un exemple de description d'une tâche

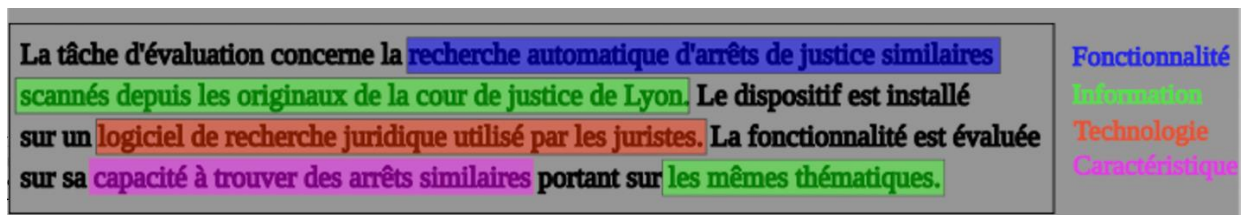


Figure 1: Exemple d'une description de tâche d'évaluation

- *La description des entrées et des sorties* : les données d'entrées de la fonctionnalité d'IA à évaluer doivent être décrites (par exemple des décisions de justice issues de cours de justice spécifiques), de même que les sorties produites par la fonctionnalité (par exemple le thème de ces décisions). Ces deux éléments sont primordiaux pour bien délimiter le périmètre de l'évaluation.
- *La description des données d'évaluation* : cette partie du plan d'évaluation est probablement la plus importante, car il s'agit de décrire les données qui vont être utilisées pour évaluer la fonctionnalité d'IA. Le plan d'évaluation doit en premier lieu décrire l'origine des jeux de données (par exemple interne à l'entreprise, collecté ou acheté), les processus mis en œuvre pour collecter les données et corriger les erreurs potentielles contenues dans le jeu de données ainsi que le processus d'annotation des données. L'annotation des données correspond à l'ajout de la vérité terrain sur les échantillons du jeu de données (par exemple le thème dans le cas d'un système d'IA devant identifier le « thème » d'une décision de justice). Enfin, il s'agit aussi d'identifier les facteurs d'influence, c'est-à-dire les caractéristiques des données pouvant avoir un impact sur la performance et le comportement du système. Très souvent, cette identification s'appuie sur l'analyse de risques effectuée en amont, avec en parallèle l'apport d'experts du domaine. Ces facteurs d'influence doivent être correctement représentés dans les données d'évaluation, et de manière équivalente aux données utilisées pour l'apprentissage. De ce fait, il est important de produire des analyses statistiques montrant un échantillonnage et une distribution des facteurs d'influence corrects et représentatifs. Enfin, il est important d'expliquer et justifier les quantités d'échantillons pour chaque valeur de facteurs : idéalement la littérature scientifique stipule d'avoir une centaine d'échantillons par valeur de facteurs. Cependant, cette règle est souvent difficile à atteindre selon le domaine d'application : le médical ou le juridique sont par exemple des domaines où l'accès à un nombre important de données

est complexe. Il est de ce fait d'autant plus important de justifier le nombre d'échantillons disponibles.

Facteur d'influence	Valeurs possibles	Impact supposé	Nombre d'échantillons (minimum arbitraire = 100)
	Assis ; Bras levés ; Debout	Fort	100 x 3 (valeurs possibles) x 3 (pondération)
	Standard H (1,75m, 75kg) ; Standard F (1,6m, 60kg) ; Grand H (>1,90m)	Faible	100 x 3 x 0.5
	Bon éclairage naturel ; Nuit avec spot ; Contrejour ; Eblouissement local	-	100 x 4 x 1
	Temps clair ; Pluie ; Neige ; Brouillard ; Poussière	-	100 x 5 x 1
	Pas d'occultation ; Coupe transversale ; Coupe sagittale	-	100 x 3 x 1

Crédit icônes: The Noun Project

Figure 2: Exemple d'échantillonnage pour une fonctionnalité de détection d'humain par caméra. L'importance d'un facteur pondère le nombre d'échantillons.

- *Les métriques d'évaluation* : les métriques d'évaluation sont les fonctions utilisées pour comparer les données de référence, contenant la vérité terrain, avec les sorties de la fonctionnalité d'IA. Cette comparaison permet d'obtenir un score ou un taux d'erreur, sur lequel l'analyse de la performance de la fonctionnalité d'IA est fondée. Les métriques utilisées dépendent de la tâche d'évaluation et de la fonctionnalité évaluée, et il est important de justifier leur utilisation. Étant donné qu'une métrique est une approximation de la différence entre les données de référence et les hypothèses de sorties d'une fonctionnalité, il est important d'en comprendre le fonctionnement pour bien analyser les résultats d'évaluation. Il existe différentes catégories de métriques qui là aussi dépendent de la tâche évaluée : comparaison par taux d'accord, comparaison par taux d'erreur, notation, etc. Il est à noter que l'on favorise généralement les métriques pouvant être calculées automatiquement si possible. Cependant, certaines tâches ne sont pour l'instant pas ou peu évaluables automatiquement. C'est par exemple le cas de fonctionnalités de résumé automatique ou de synthèse. On préfère dans ce cas faire appel à des métriques de notation s'appuyant sur l'évaluation humaine. Ce type de métrique a cependant un coût important par rapport à des métriques automatisables.

Voici un exemple de la métrique BLEU utilisée pour comparer les sorties d'un système de traduction automatique. Cette métrique compare les n-grams (suite de n mots) entre plusieurs références et une sortie du système – appelée ici hypothèse. Le taux d'accord final correspond à la moyenne géométrique des n-grams identiques entre les références et la sortie du système.

Références

la petite fille dessine dans le séjour
la jeune fille fait un dessin dans le séjour
la petite fille fait un dessin dans le salon

Hypothèse

	dans	le	salon	la	petite	fil	dessine	precision
1-gram	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	7/7
2-gram		✓	✓	✗	✓	✓	✓	5/6
3-gram			✓	✗	✗	✓	✓	3/5
4-gram			✗	✗	✗	✓		1/4
								bleu = 0.595

Figure 3: Exemple de BLEU, métrique de comparaison automatique pour des systèmes de traduction automatique

- *La définition du protocole d'évaluation* : l'objectif pour cette partie est de décrire le processus général utilisé pour évaluer le système : les méthodes de référence utilisées (article scientifique, normes ...), les différents tests réalisés s'il y en a plusieurs, les paramètres de configuration en fonction de l'environnement. C'est aussi dans cette partie que l'on décrit les différentes analyses qui seront mises en place dans le rapport d'évaluation : évaluation de la performance en fonction des facteurs d'influence, analyse statistique de la significativité des différents facteurs, etc. Là encore, il est important de correctement documenter le protocole pour assurer la répétabilité de l'évaluation.

Dans le cadre de l'évaluation d'une fonctionnalité d'IA, le plan d'évaluation est ensuite accompagné d'un rapport d'évaluation qui consigne les résultats obtenus selon les différents éléments décrits dans le plan d'évaluation.

B. Le déroulement du processus d'élaboration du plan d'évaluation avec les partenaires industriels

293. **Méthodologie.** L'objectif initial de cette partie de l'étude était de rédiger les plans d'évaluation des deux systèmes proposés par LexisNexis et Lexbase. Chaque plan devait décrire les informations nécessaires pour conduire l'évaluation des fonctionnalités d'IA identifiées lors du processus d'analyse de risques. Ces plans devaient être élaborés en lien avec les partenaires : quelles tâches d'évaluation sont pertinentes, quelles métriques utiliser et quelles les données sont à disposition pour procéder à l'évaluation. Pour ce dernier cas, outre les besoins potentiels de collecte et/ou d'annotation des données, il s'agissait d'analyser le nombre d'échantillons disponibles, point critique du fait du peu de disponibilité des données dans le domaine juridique. Une fois les plans d'évaluation construits, l'étape suivante était la réalisation des évaluations en tant que telles, puis la rédaction des rapports d'évaluation afférents.

L'organisation avec les partenaires devait suivre le même mode de fonctionnement que pour l'analyse de risques : des réunions en présence dans les locaux des industriels entrecoupés d'échanges complémentaires à distance.

294. **Objectif de la première réunion.** Une première réunion a été organisée avec chaque partenaire en juin 2023 : l'objectif était de s'accorder sur les fonctionnalités d'IA à évaluer, et de commencer à collecter les différentes informations nécessaires à l'élaboration des plans d'évaluation, notamment les métriques et les données disponibles. Lors de cette première réunion, Lexbase et LexisNexis ont présenté de nouvelles fonctionnalités d'IA en cours de production pour leurs systèmes de justice prévisionnelle. Du fait d'un intérêt important pour l'évaluation de ces systèmes, il a été accepté d'intégrer ces nouvelles fonctionnalités aux plans d'évaluation. Pour que les analyses de risques produites lors de la première phase de cette étude soient cohérentes, les partenaires ont accepté de les mettre à jour en intégrant les risques inhérents à ces nouvelles fonctionnalités.

295. **Suites de la première réunion.** Pour donner suite à cette première réunion, le LNE et les industriels devaient travailler chacun de leur côté avant d'organiser une nouvelle réunion d'avancement.

- Le LNE devait rédiger une première version des plans d'évaluation pour servir de base de travail à affiner en fonction des retours des partenaires.

- Les partenaires industriels devaient mettre à jour leurs analyses de risques respectives et commencer à fournir des données annotées pour construire le corpus d'évaluation.

Cependant, un ensemble de facteurs propres aux deux partenaires ont stoppé leur implication dans la présente recherche. Une dernière réunion en distanciel a pu être organisée courant décembre 2023 avec Lexbase, mais elle n'a pas permis l'accès aux informations nécessaires pour permettre au LNE de continuer son travail. LexBase n'a ensuite pas pu répondre aux sollicitations et relances du LNE. LexisNexis n'a de son côté pas pu dégager de temps après la première réunion pour travailler sur le projet et répondre aux sollicitations.

Par rapport à l'objectif initial de cette étude, il a néanmoins été décidé de produire des plans d'évaluation « exploratoires » : ces plans d'évaluation ne sont pas définitifs et s'appuient sur des hypothèses effectuées par le LNE sur différents points : format et disponibilité des données, facteurs d'influence du domaine, métriques... Cette approche a pour mérite de produire une base de travail pouvant être réutilisée dans des contextes extérieurs à la recherche, et montre aux partenaires le type d'attendus vis-à-vis d'une possible certification : type d'informations à fournir, transparence, traçabilité des processus et des décisions par exemple. Par ailleurs, cette base de travail est aussi utile pour produire des conclusions sur la maturité des deux partenaires industriels quant à une future certification, même si ces analyses resteront imparfaites du fait du manque d'informations fournies. Les deux plans d'évaluation exploratoires sont fournis en complément du présent document.

C. Nos conclusions sur la création des plans d'évaluation

296. **Réalisation de plans d'évaluation exploratoires.** Pour les raisons évoquées, les plans d'évaluation des deux systèmes de justice prévisionnelle n'ont pas pu être complétés. À la place, des plans d'évaluation exploratoires ont été créés avec une structure similaire à celle d'un plan normal. Si le contenu de certaines sections a été complété à partir d'hypothèses du fait de l'absence d'information des partenaires industriels, ces plans permettent néanmoins de montrer à quoi doit correspondre un plan d'évaluation complet⁴⁸⁴. Le plan d'évaluation est un document primordial à la fois pour s'assurer de correctement évaluer une fonctionnalité d'IA, assurer la confiance dans sa performance, mais aussi pour des besoins de transparence, traçabilité et répétabilité. Ces différentes caractéristiques sont des éléments fondamentaux des exigences de la réglementation de l'IA. Bien que la mission n'ait pu totalement aboutir, les analyses

⁴⁸⁴ Cf. le modèle de plan en annexe n° 2.

présentées dans les développements relatifs à l'analyse de risques et dans ceux relatifs aux plans d'évaluation permettent de tirer des conclusions sur la qualification des deux systèmes de justice prévisionnelle.

D. Nos conclusions sur la qualification des systèmes de justice prévisionnelle

297. **Généralités.** L'objectif principal de cette étude était de caractériser la chaîne de qualification des systèmes de justice prévisionnelle fournis par LexisNexis et Lexbase. Pour autant, cette étude s'est trouvée limitée dans sa profondeur du fait du manque d'informations fournies par les partenaires industriels lors de la conception des plans d'évaluation. Par ailleurs, cette étude n'a pas couvert tous les aspects du règlement européen sur l'intelligence artificielle (notamment, elle n'a pas intégré l'analyse documentaire poussée alors même que l'exigence d'une documentation importante couvrant les aspects de conception et de développement des systèmes d'IA est au cœur de la législation européenne). L'étude s'est focalisée sur les risques principaux tels que les biais, la corruption de données, le manque de données pertinentes, le manque de transparence et d'explicabilité.

298. **Appropriation du concept d'analyse de risques par les partenaires.** Il ressort de l'étude que les partenaires se sont approprié le concept d'analyse de risques pour les fonctionnalités d'IA. Au moment où cette étude a été menée, la norme correspondant à l'analyse de risques n'était pas publiée, et de ce fait les industriels n'étaient pas familiers de cet exercice. Cela étant, les réponses apportées au questionnaire « *compliance* » ont montré que les partenaires n'étaient pas plus familiers des normes publiées dans le domaine de l'IA comme l'ISO/IEC TR 24028 (IA de confiance), l'ISO/IEC TR 24027 (biais dans les systèmes d'IA et dans la prise de décision assistée par IA), ou encore ISO/IEC 20546 et ISO/IEC TR 20547 relatives au *big data*.

Le travail effectué en collaboration avec le LNE a montré que les partenaires étaient désormais suffisamment matures pour mettre en place des processus d'analyse de risques à chaque nouveau développement d'une fonctionnalité d'IA. De ce fait, le LNE estime que les exigences de la réglementation liées à l'analyse de risques seront correctement traitées par les industriels.

299. **Prise de conscience de l'importance de l'*ethics by design*.** Les échanges lors de la restitution des questionnaires « *compliance* » ont révélé que ces questionnaires avaient permis une prise de conscience des partenaires industriels de la nécessité d'adopter une démarche

d'éthique par la conception. Fait notable en pratique, nos partenaires ont parfois eu du mal à s'orienter pour trouver les personnes à même de répondre aux questions posées, spécialement toutes celles relatives à l'éthique et à la conformité aux principes issus de la Charte éthique de la CEPEJ.

300. Manque de données pertinentes pour formuler le résultat d'une véritable évaluation. Concernant les plans d'évaluation, les processus mis en place en interne par les partenaires pour leurs propres évaluations n'ont pas pu être examinés. De même, la performance des fonctionnalités d'IA n'a pas pu être évaluée par le LNE ni comparée avec les résultats obtenus en interne par les partenaires. Cependant, les échanges qui ont pu avoir lieu ont montré que ces derniers avaient l'expertise scientifique nécessaire pour conduire une évaluation correcte des fonctionnalités d'IA. Dans le cadre d'un audit de certification, les industriels doivent être capable de montrer leur maturité scientifique.

Du fait de ce manque d'informations, il est également compliqué d'estimer si les systèmes développés par Lexbase et LexisNexis sont certifiables. Par ailleurs, une analyse documentaire approfondie serait primordiale pour pouvoir donner un premier avis.

301. Certification envisageable. Néanmoins, la certification semble tout à fait atteignable : un travail important de qualification est par exemple déjà réalisé sur les données. L'aspect principal à développer pour les partenaires est donc de mettre en place une base documentaire si cette dernière n'existe pas encore. Cette base documentaire permettra également de répondre aux enjeux de traçabilité et de répétabilité liés à la législation européenne sur l'intelligence artificielle. Ce travail peut être coûteux. Il est difficile d'estimer le temps nécessaire pour mettre en place la base documentaire et les processus associés, mais la compréhension scientifique des partenaires est déjà suffisante et permettra de gagner du temps.

Pour le futur, il est possible pour les industriels de s'approprier les plans d'évaluation « exploratoires » fournis pour leurs propres besoins. Il leur est également possible de faire évoluer ces documents ainsi que leurs processus internes. Pour terminer, une analyse documentaire devra être conduite pour évaluer les besoins de mise en place des processus associés.

302. Conclusion du chapitre. Parmi les différentes mesures de régulation *ex ante*, la normalisation technique apporte une aide précieuse aux fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle pour se mettre en conformité avec les exigences légales mais aussi éthiques. En

la matière, la certification par un tiers indépendant apparaît non seulement possible mais aussi souhaitable pour assurer la confiance dans les systèmes.

Chapitre 2 – La mise en œuvre *ex post*⁴⁸⁵

303. Le droit actuel de la responsabilité civile est en mesure d'appréhender les dommages causés par les outils de justice prévisionnelle. En effet, de manière générale, l'intervention de l'intelligence artificielle dans un dommage ne change pas radicalement la donne s'agissant des responsabilités encourues (Section 1). Plus spécifiquement s'agissant du dommage causé par un outil de justice prévisionnelle, ce sont tant les règles de la responsabilité civile contractuelle (Section 2) que celle de la responsabilité civile extracontractuelle (Section 3) qui ont vocation à s'appliquer selon la nature du lien de droit unissant la victime à l'auteur du dommage.

Section 1 – L'application de la responsabilité civile au dommage causé par l'intelligence artificielle

304. **Abandon de l'idée d'attribuer la personnalité juridique aux robots.** En droit de la responsabilité civile, la problématique de la réparation des dommages causés par l'intelligence artificielle est très en vogue. Afin d'apporter une réponse satisfaisante aux besoins d'indemnisation des victimes, une première piste a été empruntée consistant à proposer l'attribution d'une personnalité juridique aux robots, entendus largement comme les objets animés par l'intelligence artificielle. Cette proposition a été largement débattue et semble aujourd'hui abandonnée par la majorité des auteurs, car il a été démontré que le détour par la personnalité juridique était à la fois inutile et préjudiciable⁴⁸⁶.

305. **Hétérogénéité des situations dommageables impliquant de l'IA.** Aujourd'hui, les débats se sont déplacés sur le point de savoir s'il faut élaborer un régime de responsabilité civile spécifique pour les dommages causés par l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle. À cet égard, les propositions sont nombreuses et détaillées⁴⁸⁷. Cependant, une objection majeure

⁴⁸⁵ Par Bénédicte Girard et Aurore Hyde.

⁴⁸⁶ Grimaldi C., « Responsabilité civile du fait du robot doué d'intelligence artificielle : faut-il donner une personnalité juridique au robot ? », *Contrats Concurrence Consommation*, 2018, p. 212 et s. ; Godefroy L., « Les algorithmes : quel statut juridique pour quelles responsabilités ? », *Contrats Concurrence Consommation*, 2018, étude 18 ; Lachièze C., « Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? », *Dalloz IP/IT*, 2020, p. 663 et s.

⁴⁸⁷ Parmi beaucoup d'autres références : Gout O. (dir.), *La responsabilité civile et l'intelligence artificielle*, Bruylant, 2022 ; Boine C., « La responsabilité civile liée à l'intelligence artificielle dans l'Union européenne », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 677 et s. ; Mérabet S., *Vers un droit de l'intelligence artificielle*, Dalloz, 2020 ; Nevejans N., *Traité de droit et d'éthique de la robotique civile*, LEH éd., 2017.

mérite d'être immédiatement formulée. En effet, les dommages susceptibles d'être causés par l'intelligence artificielle renvoient à des situations extrêmement hétérogènes : il y a par exemple peu de points communs entre les dommages corporels causés par un véhicule autonome et les atteintes à la liberté d'expression commises par les algorithmes de modération de contenus. Une approche sectorielle apparaît donc plus adaptée qu'un traitement uniforme.

306. Adaptabilité du droit positif français aux situations dommageables impliquant de l'IA. Surtout, il est loin d'être certain qu'une réforme importante du droit de la responsabilité civile – même par secteur – soit nécessaire : le droit positif offre d'ores et déjà des solutions satisfaisantes pour l'indemnisation de la plupart des victimes de dommages causés par l'intelligence artificielle sans qu'il soit nécessaire d'en modifier les règles.

D'une part, en matière de responsabilité civile, l'intervention de l'intelligence artificielle dans la survenance du dommage ne change pas radicalement les données du problème posé. Certes, l'intelligence artificielle est une technologie qui n'est pas entièrement maîtrisable et son implémentation dans des outils est susceptible de causer un dommage à autrui. C'est notamment ce qui est visé par la notion de risque, notion centrale dans le règlement européen sur l'IA mais dont l'approche n'est pas nouvelle⁴⁸⁸.

La question de la réparation des dommages causés par des choses dont le fonctionnement échappe partiellement à leurs concepteurs ou à leurs utilisateurs est loin d'être nouvelle. Au début du vingtième siècle, elle a même fait l'objet d'une réflexion doctrinale approfondie qui a conduit à un renouvellement théorique remarquable du droit de la responsabilité civile. C'est la théorie du risque (ou du risque-profit)⁴⁸⁹. La théorie du risque élaborée à cette époque l'a été spécialement pour répondre à cette problématique des dommages causés par des choses difficiles à maîtriser et s'avère tout à fait pertinente pour appréhender les outils d'intelligence artificielle⁴⁹⁰. En effet, selon cette théorie, celui qui tire profit d'une activité doit en assumer toutes les charges, en ce compris l'indemnisation des dommages causés par la réalisation des risques que cette activité engendre. Appliquée à l'IA, cela revient à considérer que « ceux qui tirent un avantage économique du déploiement de système d'IA (...) soient responsables en cas de dommages, qu'il y ait faute ou non »⁴⁹¹. Cette responsabilité a effectivement l'avantage

⁴⁸⁸ Latil A., *Le droit du numérique : une approche par les risques*, Dalloz, 2023, 1^e éd.

⁴⁸⁹ Carval S., *La construction de la responsabilité civile. Controverses doctrinales*, PUF, 2001.

⁴⁹⁰ Sur cette théorie : Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénédé F., *Droit civil. Les obligations*, Dalloz, 13^e édition, 2022, p. 1022 et s.

⁴⁹¹ Boine C., « La responsabilité civile liée à l'intelligence artificielle dans l'Union européenne », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 677 et s., spéc. p. 692.

d'être objective, ce qui facilite sa mise en œuvre pour la victime et non fondée sur la faute. On relèvera que dans sa résolution du 20 octobre 2020⁴⁹², le Parlement européen suggérait de retenir un régime de responsabilité objective pour les systèmes d'IA à haut risque, et un régime fondé sur la faute pour les autres systèmes d'IA. Cette distinction est assez discutable en matière de responsabilité civile dès lors que la théorie du risque-profit est toujours objective, quelle que soit l'intensité du risque. Ce qui importe, c'est qu'il se soit réalisé et qu'il ait causé un dommage. Cette distinction n'a pas été retenue dans la proposition de directive plutôt favorable à un régime de responsabilité pour faute⁴⁹³.

D'autre part, le droit français de la responsabilité se caractérise par la grande généralité des principes qui le composent et la plasticité des notions qu'il utilise. La faute, la garde ou encore la causalité sont depuis longtemps interprétées par le juge de manière extrêmement souple afin de pouvoir être appliquées aux nouvelles situations dommageables qui se présentent⁴⁹⁴. Ces notions pourront donc être mobilisées sans difficulté pour répondre aux demandes en réparation des dommages causés par l'intelligence artificielle. Des retouches peuvent parfois être nécessaires pour adapter parfaitement les solutions existantes, mais une réforme d'ampleur n'apparaît pas requise.

307. Transposition aux outils de justice prévisionnelle. Ces propos généraux sur la responsabilité civile du fait de l'intelligence artificielle s'appliquent particulièrement aux dommages causés par les outils de justice prévisionnelle, objet de la présente recherche. Sont exclus du champ de la recherche les dommages corporels ou matériels susceptibles d'être causés par une défectuosité de l'outil (par exemple lorsqu'un défaut de fabrication d'un logiciel de justice prévisionnelle endommage un poste informatique ou provoque une blessure à un utilisateur). Le cœur du sujet posé est en effet l'action en responsabilité qui peut être intentée lorsqu'une personne, utilisatrice ou tiers, se plaint que les informations fournies par un outil de justice prévisionnelle lui ont causé du tort, soit car ces informations ont induit en erreur la personne amenée à prendre une décision et l'ont incitée à faire le mauvais choix (cette personne peut essentiellement être un conseil juridique, un justiciable, un juge), soit car ces informations

⁴⁹² Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l'intelligence artificielle : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_FR.html#title1

⁴⁹³ Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2022 relative à l'adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l'intelligence artificielle (Directive sur la responsabilité en matière d'IA), COM(2022) 496 final : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0496>

⁴⁹⁴ Remy Ph., « Réflexions préliminaires sur le chapitre *des délits* », in F. Terré (dir.), *Pour une réforme de la responsabilité civile*, Dalloz, 2011, p. 15 et s.

étaient des données personnelles ou confidentielles et qu'elles n'ont pas reçu la protection qu'elles méritaient. Il convient donc de circonscrire la situation considérée : les dommages envisagés sont immatériels (atteinte à la vie privée, au droit au procès équitable, aux données personnelles, à la présomption d'innocence, à l'égalité, etc.). À cet égard, dans le régime européen, le premier type de dommage lié aux résultats pourrait relever du champ d'application de la directive sur la responsabilité de l'IA, alors que celui lié aux données personnelles ou confidentielles relèvera plutôt de la directive sur les produits défectueux nouvelle version. En effet, le premier texte a vocation à s'appliquer aux dommages causés par les résultats d'un système d'IA ou l'absence de résultat lorsque le système aurait dû en produire⁴⁹⁵, quand le second a vocation à s'appliquer aux cas de perte ou de corruption de données⁴⁹⁶.

Les demandeurs (victimes) seront donc soit des professionnels (avocats, magistrats, direction juridique, etc.) soit des non professionnels (justiciables), et ils pourront aussi bien être l'utilisateur de l'outil qu'un tiers concerné par la décision prise sur la base des probabilités offertes par l'outil.

Les défendeurs envisageables sont en revanche essentiellement des professionnels, qu'il s'agisse des fournisseurs de l'outil ou de ses utilisateurs (ou « déployeurs » pour reprendre la terminologie du RIA).

308. Caractère prospectif du sujet. Présenter le droit applicable à une situation dommageable résultant d'un outil de justice prévisionnelle ainsi que les pistes d'amélioration éventuellement envisageables est largement prospectif. L'objet de recherche est trop récent pour avoir donné lieu à un contentieux analysable. Les situations peuvent seulement être spéculées de même que les réponses apportées sur la base de l'analyse des textes existants. Toutefois, l'étude peut être nourrie du raisonnement par analogie car si les outils de justice prévisionnelle soulèvent des problématiques spécifiques, en ce qu'ils interviennent dans le domaine de la justice⁴⁹⁷, ils s'insèrent dans la problématique générale des algorithmes d'information et de recommandation⁴⁹⁸.

⁴⁹⁵ Art. 2 Proposition de directive du 20 octobre 2020.

⁴⁹⁶ Art. 4 § 6 Proposition de directive du 28 septembre 2022.

⁴⁹⁷ Sur ces problématiques : Garapon A. et Lassègue J., *Justice digitale*, PUF, 2018 ; Jeuland E. (dir.) Dossier : les défis de la justice numérique, *Les Cahiers de la Justice*, 2009, n°2, p. 193 et s.

⁴⁹⁸ Pour une étude d'ampleur : Huttner L., « La décision de l'algorithme », thèse précitée.

Section 2 – La réparation du dommage causé au moyen d'un outil de justice prévisionnelle par la responsabilité contractuelle

309. **Généralités.** La responsabilité contractuelle est engagée lorsque la victime du dommage est liée à l'auteur du dommage par un contrat et que le dommage résulte de l'inexécution du contrat. Cette voie s'envisage prioritairement en raison du principe du non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle⁴⁹⁹. En vertu de ce principe, lorsqu'une situation dommageable entre dans le champ d'application de la responsabilité contractuelle, la victime ne peut se fonder que sur ce terrain, à l'exclusion du terrain extracontractuel. Autrement dit, la victime n'a pas un droit d'option. Elle est obligée d'agir sur le terrain de la responsabilité contractuelle et sera irrecevable sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, quand bien même les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle ne seraient pas réunies.

En cas de dommage par un outil de justice prévisionnelle, il importe donc de commencer par vérifier que ce dommage ne résulte pas de l'inexécution du contrat, ce qui sera généralement le cas dans l'hypothèse de la victime utilisatrice à l'égard du fournisseur de l'outil ou encore de la personne concernée à l'égard de l'utilisateur. Cet utilisateur peut être un conseil juridique au sens large voire un juge mais pour simplifier les choses, nous avons cantonné l'étude à l'hypothèse dans laquelle l'utilisateur est un avocat, étant précisé que la plupart des développements peuvent être, autant que de raison, transposés à d'autres situations.

Il est à noter qu'en matière contractuelle, le dommage causé par un outil de justice prévisionnelle ne soulève aucune difficulté spécifique : la question essentielle à se poser ici est celle des obligations contractuelles, de leur étendue, de ce qu'elles impliquent véritablement, ainsi que des sanctions possibles en cas d'inexécution. Les spécificités de l'outil de justice prévisionnelle, et notamment le fait qu'il fasse intervenir l'intelligence artificielle, sont relativement indifférentes.

310. Précisons cela en envisageant d'abord la situation dans laquelle la personne concernée par le résultat de l'outil de justice prévisionnelle, ex. : le client, recherche la responsabilité de son avocat (§1) puis la situation dans laquelle l'utilisateur recherche la responsabilité du fournisseur de l'outil de justice prévisionnelle (§2). De manière tout à fait résiduelle, il est

⁴⁹⁹ Sur ce principe : Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénéde F., *Droit civil. Les obligations*, Dalloz, 13^e édition, 2022, n°1106 et s.

possible d'envisager l'hypothèse dans laquelle la personne concernée non-utilisatrice recherche la responsabilité contractuelle du fournisseur par le fondement d'une action directe (§3).

§1 – La responsabilité de l'avocat utilisateur de l'outil de justice prévisionnelle recherchée par son client

311. **Responsabilité des avocats.** L'avocat engage sa responsabilité civile lorsqu'il cause un dommage à autrui. Cette responsabilité est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, comme le rappelle les articles 26 et 27 du chapitre IV de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques. La responsabilité est de nature essentiellement contractuelle à l'égard du client⁵⁰⁰.

312. **Responsabilité de la décision finale et principe de maîtrise par l'utilisateur.** Les outils de justice prévisionnelle étant à l'heure actuelle de simples outils d'aide à la décision, la décision finale de la stratégie procédurale à adopter dans un litige est prise par l'avocat. Orientera-t-il son client vers une transaction pensant, à tort, que les chances de succès étaient trop faibles ? Se réfèrera-t-il, dans ses conclusions, à des résultats erronés pour fonder ses demandes de dommages et intérêts ? Abandonnera-t-il certaines prétentions en croyant, sur de mauvaises préconisations de l'outil de justice prévisionnelle utilisé, qu'elles étaient vaines ? Dans ces hypothèses, peu importe que sa décision finale ait été prise sous l'influence de résultats non pertinents proposés par un outil de justice prévisionnelle. Dès lors qu'il prend, en conscience, la décision finale, il doit en assumer la responsabilité. Il s'agit là du corollaire du principe de maîtrise par l'utilisateur⁵⁰¹. En effet, ce principe commande que la personne appelée à prendre la décision ne soit pas liée par les préconisations algorithmiques. Elle doit pouvoir conserver son esprit critique par rapport à la solution proposée afin de s'en écarter au besoin.

313. **Responsabilité de la décision finale et principe de compétence.** Un professionnel du droit ne saurait abandonner trop facilement son expertise juridique à la machine. Il doit vérifier la pertinence ou la véracité du résultat proposé⁵⁰². Tel est ce que commande le principe déontologique de compétence, de diligence et de prudence qui pèse sur les avocats à l'égard de

⁵⁰⁰ Civ. 1^{re}, 21 mars 2006, n° 05-14.136.

⁵⁰¹ Cf. supra, n° 195.

⁵⁰² Un parallèle peut être fait avec l'affaire relatée dans le *New York Times* l'année dernière et pointant un avocat américain ayant fondé sa demande sur six jurisprudences inexistantes, forgées de toute pièce par chat GPT : <https://www.nytimes.com/2023/05/27/nyregion/avianca-airline-lawsuit-chatgpt.html>

leur client⁵⁰³. Ce sont ces qualités que l'avocat doit mettre en œuvre lorsqu'il exécute son devoir d'information.

314. **Étendue du devoir d'information et de conseil de l'avocat.** Le devoir d'information et de conseil de l'avocat est rappelé à l'article 412 du Code de procédure civile. L'information consiste à fournir au client des informations exactes, objectives et complètes relatives à ses demandes⁵⁰⁴. Le conseil implique des diligences plus étendues et consiste à préconiser des démarches et des solutions à son client, à apprécier les chances de succès et à le mettre en garde sur les risques d'échec. Le devoir d'information et de conseil suppose donc la compétence de l'avocat, qui doit notamment suivre une formation continue⁵⁰⁵. L'avocat doit notamment connaître la jurisprudence⁵⁰⁶ et même anticiper certaines évolutions jurisprudentielles dès lors qu'elles sont déjà perceptibles dans certains arrêts⁵⁰⁷.

315. **Obligation de moyens.** L'avocat jouit d'une importante liberté dans l'exercice de sa profession et s'il est tenu de connaître la jurisprudence, le droit ne lui impose aucun moyen particulier pour y parvenir⁵⁰⁸. La responsabilité de l'avocat ne saurait donc être engagée seulement pour ne pas avoir utilisé un outil de justice prévisionnelle ou pour en avoir utilisé un. L'avocat est en effet libre d'utiliser les supports d'information qu'il souhaite, dès lors qu'il parvient à exécuter correctement ses obligations. En revanche, lorsqu'il a utilisé un outil de justice prévisionnelle, l'avocat ne peut pas se retrancher derrière la défaillance de l'outil si l'information proposée n'était pas pertinente. Il est précisément de sa compétence d'apprécier l'information qui lui a été délivrée, de vérifier qu'elle est la plus récente, la plus pertinente, etc. Le fait de ne pas avoir recoupé l'information avec d'autres pourra ainsi caractériser qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition pour satisfaire son devoir d'information et de conseil envers son client. En effet, compte tenu de l'aléa inhérent à toute procédure judiciaire, l'avocat est par principe tenu seulement d'obligations de moyens, ce dont il résulte que son client victime devra caractériser le fait qu'il n'a pas mis en œuvre tous les moyens à sa disposition. Le raisonnement est le même dans l'hypothèse où l'avocat n'a pas utilisé les

⁵⁰³ Règlement intérieur national (RIN) de la profession d'avocat, article 1.3 : <https://www.cnb.avocat.fr/fr/reglement-interieur-national-de-la-profession-davocat-rin>

⁵⁰⁴ Civ. 1^{re}, 2 nov. 2005, n° 03-20.739.

⁵⁰⁵ RIN, art. 1.3.

⁵⁰⁶ Civ. 1^{re}, 15 oct. 1985, n° 84-12.309.

⁵⁰⁷ Civ. 1^{re}, 7 mars 2006, n° 04-10.101.

⁵⁰⁸ Hyde A., « Avocat et intelligence artificielle : quelles obligations, quelles responsabilités ? Réflexions à partir d'une décision de la Cour supérieure de justice de l'Ontario du 22 novembre 2018 », *Recueil Dalloz*, 2019, p.2107.

services d'outils de justice prévisionnelle à sa disposition pour fonder sa décision et qu'il apparaît par la suite qu'en les utilisant, il aurait pu parvenir à une solution plus pertinente. Cependant une telle approche peut rendre les choses difficilement praticables. D'une part, les outils de justice prévisionnelle ne proposent pas tous exactement le même service (sinon la pluralité de l'offre sur le marché n'aurait aucun sens) et, selon l'outil utilisé, l'apport ne sera pas exactement le même. D'autre part, au sein d'une catégorie d'outils offrant des services similaires, les résultats peuvent varier⁵⁰⁹. L'avocat devrait donc, en théorie, croiser les solutions obtenues à partir d'une pluralité d'outils pour parvenir à la solution la plus pertinente. Faut-il alors qu'un avocat doive équiper son cabinet de l'ensemble des outils existants sur le marché ? Cela représenterait un coût exorbitant. À cet égard, les outils de justice prévisionnelle peuvent créer une fracture entre les cabinets ayant les moyens financiers de s'en équiper et les autres.

316. **Manquement aux obligations et obligation à la dette.** Lorsqu'un client parvient à rapporter la preuve d'un manquement de son avocat à son devoir d'information et de conseil et que ce manquement lui a causé un préjudice (principalement l'atteinte au droit d'accès au juge ou la perte de chance d'une issue plus favorable), l'avocat engagera sa responsabilité à son égard. Pour autant, l'avocat pourra rechercher la responsabilité du fournisseur de l'outil s'il apparaît que celui-ci ne recélait pas toutes les qualités attendues. En effet, le fournisseur peut être tenu responsable, vis-à-vis de l'utilisateur, du manque d'efficacité de son outil et appelé soit à garantir l'avocat, soit à contribuer à la dette à proportion de sa part.

317. **Aménagements contractuels de responsabilité.** Aux termes de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971⁵¹⁰, les honoraires d'avocat font l'objet d'une convention écrite et sont déterminés librement en accord avec le client, en fonction des usages et de différents critères comme la situation de fortune du client, la difficulté de l'affaire et l'importance des intérêts en cause, ou les diligences accomplies. Cette convention d'honoraires peut parfaitement contenir des clauses limitant la responsabilité de l'avocat (dans le sens d'un allègement donc voire d'une exclusion). Il peut s'agir d'une clause instituant un plafond de dommages-intérêts (on parle parfois de « clause limitative de réparation ») ou limitant les cas dans lesquels la responsabilité

⁵⁰⁹ Kirat Th. et Sweeney M., « Comparaisons d'applications de justice prédictive sur les indemnités pour licenciement abusif, 2012-2016 », intervention au séminaire e-juris (dir. M. Cottin et I. Sayn), MSH Lyon-Saint-Étienne, Lyon, 7 décembre 2018.

⁵¹⁰ Loi n° 71-1130 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.

du débiteur peut être engagée, par exemple en excluant précisément la responsabilité pour fondement juridique non pertinent (on parle alors de « clause limitative de responsabilité »).

Valables sur le principe en droit commun, elles peuvent néanmoins être remises en cause sur de nombreux fondements, ce que nous étudierons davantage en envisageant la responsabilité du fournisseur de l'outil⁵¹¹.

Surtout, cette convention d'honoraires est soumise au droit de la consommation et au régime des clauses abusives, lorsque le client est un consommateur ou un non professionnel⁵¹². Or, l'article R. 212-1 6° du Code de la consommation les présume irréfragablement abusives. Elles seront donc réputées non écrites et ne pourront avoir aucun effet.

§2 – La responsabilité du fournisseur recherchée par l'utilisateur

318. **Dualité d'hypothèses.** Par hypothèse, les outils de justice prévisionnelle sont des logiciels métiers qui s'adressent aux professionnels du droit, et en particulier aux avocats. C'est donc sur cette base que nous raisonnerons. Néanmoins, il convient d'étudier l'hypothèse dans laquelle l'utilisateur est un justiciable car il n'est pas impossible que les fournisseurs finissent par adresser ce marché. Pour autant, c'est seulement au stade de la validité des clauses limitatives de responsabilité que cette distinction aura son importance.

319. **Droit commun des contrats. Distinction des obligations de moyens et de résultat pour caractériser l'inexécution.** La responsabilité contractuelle du fournisseur de l'outil de justice prévisionnelle peut d'abord être engagée sur le fondement du droit commun des contrats, lorsque le non-respect d'une obligation prévue par le contrat a causé un préjudice au cocontractant utilisateur de l'outil. Cette responsabilité est fondée sur l'article 1231-1 du Code civil.

Elle dépend, au cas par cas, des obligations souscrites par les parties et de la manière dont ces obligations seront interprétées par le juge, notamment au regard de la distinction déjà évoquée des obligations de moyens et des obligations de résultat. Cette distinction a son importance car en présence d'obligation de résultat, l'inexécution n'a pas à être fautive pour engager la responsabilité du débiteur. La seule caractérisation de l'inexécution constitue en effet un fait générateur de responsabilité. En revanche, en présence d'une obligation de moyens, l'utilisateur devra caractériser la faute du fournisseur, autrement dit, le fait qu'il n'ait pas pris toutes les

⁵¹¹ Cf. infra, n° 327 et s.

⁵¹² Civ. 2^e, 27 octobre 2022, n° 21-10.739.

mesures. Par exemple, il n'a pas bien contextualisé les données ; il ne les a pas mises à jour régulièrement ; il ne s'est pas entouré de personnes suffisamment qualifiées pour déterminer les critères pertinents ; etc. Cependant, la gravité de la faute importe peu. En présence d'obligations de moyens, la faute d'étourderie ou d'inadvertance du fournisseur engagera autant sa responsabilité que la faute lourde et ce n'est qu'au stade du jeu des clauses limitatives de responsabilité que la gravité de la faute sera prise en considération.

En pratique donc, il s'agira par exemple de se demander si la fiabilité du résultat était une obligation du fournisseur et, le cas échéant, s'il s'agissait d'une obligation de moyen ou de résultat. À cet égard, il est possible d'envisager qu'un fournisseur prévoie un taux d'erreur possible de son système et que cette marge d'erreur soit contractualisée.

Autre exemple, si le contrat garantit que le système sera mis à jour mensuellement et fournira « la jurisprudence la plus pertinente eu égard à la date de mise à jour du système », il y aura lieu d'interpréter cette clause pour savoir s'il s'agit là d'une obligation de moyens ou de résultat (par exemple, si un revirement de jurisprudence n'a pas été intégré au système alors qu'il était disponible en *open data* au moment de la mise à jour).

320. Droit commun des contrats. Engagement de la responsabilité en cas d'inexécution dommageable. Dès lors qu'une inexécution du contrat est caractérisée, la responsabilité du fournisseur peut être engagée si l'utilisateur apporte la preuve que cette inexécution lui a causé un dommage.

L'étendue de la responsabilité du fournisseur de l'outil est cantonnée par une règle, propre à la matière contractuelle, selon laquelle le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts « qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat », sauf lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive⁵¹³.

La question du dommage prévisible est alors ouverte. Toutefois, il est assez évident qu'un outil ne donnant pas de résultats satisfaisants (ex. décisions obsolètes, sans rapport avec le litige, décisions non représentatives, etc.) cause un dommage à l'avocat, ne serait-ce parce que cette défaillance lui a fait perdre du temps en recherche supplémentaire. Par ailleurs, si les résultats l'ont induit en erreur et qu'il a dû dédommager son client, cela constitue également pour lui un préjudice. Pour autant, le lien de causalité sera discutable et sa caractérisation dépendra finalement de ce que l'on retient la théorie de l'équivalence des conditions ou celle de la causalité adéquate⁵¹⁴.

⁵¹³ Article 1231-3 du Code civil.

⁵¹⁴ Cf. infra n° 334.

321. Droit commun des contrats. Absence d'exonération pour cause de force majeure.

En revanche, le fournisseur de l'outil peut difficilement bénéficier de l'exonération de responsabilité en cas de force majeure. En effet, l'article 1218 du Code civil définit le cas de force majeure comme un « événement échappant au contrôle du débiteur, qui ne pouvait être raisonnablement prévu lors de la conclusion du contrat et dont les effets ne peuvent être évités par des mesures appropriées », qui « empêche l'exécution de son obligation par le débiteur ». La caractérisation d'un cas de force majeure entraîne l'exonération totale de responsabilité du débiteur. S'agissant des dommages causés par des outils de justice prévisionnelle, le fournisseur de l'outil pourrait être tenté d'invoquer la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité : l'intelligence artificielle étant difficilement maîtrisable, il pourrait arguer que le dommage causé par l'outil résulte d'un événement échappant à son contrôle, qu'il ne pouvait raisonnablement prévoir et dont les effets ne pouvaient être évités. Cependant, la jurisprudence interprète la condition selon laquelle l'événement doit échapper au contrôle du débiteur – dite également condition d'extériorité – comme s'opposant à ce que le fournisseur d'une chose invoque la force majeure lorsque le dommage est causé par un vice de la chose, même indécélable⁵¹⁵. En d'autres termes, les faits dommageables produits par les choses ne sont jamais considérés comme « extérieurs » aux fournisseurs. Il en résulte que les fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle ne sauraient invoquer la force majeure pour s'exonérer de leur responsabilité civile en cas de dommage causé par leurs produits.

322. Droit des contrats spéciaux. Au droit commun des contrats s'ajoutent de nombreux textes de droit spécial, en droit interne et en droit de l'Union européenne. S'agissant des outils de justice prévisionnelle, les contrats considérés sont principalement des contrats de licence de logiciel, qui obéissent à un régime spécifique⁵¹⁶. Ce régime prévoit diverses obligations dont la violation peut entraîner la responsabilité contractuelle du fournisseur en cas de préjudice causé à l'utilisateur. Il en est ainsi de l'obligation de délivrance conforme, qui implique d'une part la délivrance (c'est-à-dire la livraison du support matériel du logiciel le cas échéant, l'installation du logiciel sur l'ordinateur du client, et la mise en service), mais d'autre part et surtout la conformité, ce qui signifie que le logiciel doit être en état de fonctionnement et adapté aux

⁵¹⁵ Pour un exemple récent : Cass. Civ. 3, 16 février 2022, n° 20-19.047 B, *Recueil Dalloz*, 2022 p. 585, avis P. Brun.

⁵¹⁶ Sur ce régime : Le Tourneau Ph., *Contrats du numérique informatiques et électroniques*, Dalloz, 2022, p. 347 et s.

besoins de l'utilisateur. Dans une décision rendue par le tribunal commercial de Vienne le 21 janvier 2021, le fournisseur d'un logiciel a ainsi été condamné au paiement de dommages-intérêts pour violation de son obligation de délivrance conforme⁵¹⁷. Des actions en responsabilité peuvent ainsi être exercées à l'encontre des fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle. Elles ne sont toutefois pas au cœur du sujet de la présente étude car elles visent uniquement à indemniser l'utilisateur du fait que l'outil ne peut pas être utilisé correctement.

323. Validité de principe des stipulations contractuelles limitant la responsabilité. En pratique, la responsabilité contractuelle – qu'elle soit fondée sur le droit commun ou sur celui des contrats spéciaux – est fréquemment limitée par des stipulations contractuelles. La responsabilité du fournisseur de l'outil de justice prévisionnelle est donc largement dépendante de la manière dont ce dernier est parvenu à convenir avec son cocontractant de circonscrire sa responsabilité. À cet égard, il convient de distinguer deux types de clauses possibles, dont les régimes respectifs sont légèrement différents. Le premier type de clause est la *clause limitative d'obligation*, c'est-à-dire celle par laquelle le débiteur exclut ou limite l'une de ses obligations. Par hypothèse, elle se trouve dans les contrats nommés dans lesquels certaines obligations existent de manière générique, comme par exemple l'obligation de délivrance dans le contrat de vente. Il peut s'agir d'une clause exclusive d'obligation (qui supprime purement et simplement une obligation) ou une simple clause limitative d'obligation qui maintient une obligation tout en diminuant la portée (par exemple, en transformant une obligation de résultat en obligation de moyens). Le second type de clause est la *clause limitative de responsabilité au sens strict*. Il peut s'agir d'une clause instituant un plafond de dommages-intérêts (on parle parfois de « clause limitative de réparation ») ou limitant les cas dans lesquels la responsabilité du débiteur peut être engagée, par exemple en excluant la réparation pour certains types de dommages (on parle alors de « clause limitative de responsabilité »). Ces deux catégories de clauses sont soumises au même régime. En raison du principe de liberté contractuelle, elles sont en principe valables, qu'il s'agisse des clauses exclusives⁵¹⁸ ou, *a fortiori*, des simples clauses limitatives de responsabilité⁵¹⁹.

⁵¹⁷ T. com. Vienne, 21 janvier 2021, *Legalis.net*, *Dalloz IP/IT* 2021 p.342.

⁵¹⁸ Par exemple, Cass. civ. 1, 8 mars 1966, bull. civ. 1966 I n° 170 : « il est loisible aux parties d'insérer dans un contrat de bail des clauses dispensant le bailleur de certaines de ses obligations qui seraient normalement à sa charge en vertu de l'article 1719 ».

⁵¹⁹ Admettant la validité de telles clauses : Cass. 24 janvier 1874. Aujourd'hui, l'article 1231-3 admet implicitement la validité des clauses limitatives de responsabilité en énonçant que « le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat ».

324. Possible remise en cause des stipulations contractuelles limitant la responsabilité.

Malgré leur validité de principe, ces stipulations peuvent être remises en cause, en application du droit commun des contrats, sur quatre fondements.

325. D'abord, les clauses exclusives ou limitatives d'obligations sont à l'évidence nulles lorsqu'elles ont pour objet de supprimer ou limiter une obligation qui a été qualifiée, par le législateur ou par le juge, d'ordre public.

326. Ensuite, ces clauses peuvent être privées d'efficacité lorsque l'inexécution est due à une faute lourde ou dolosive du débiteur. Ce sera par exemple le cas s'il apparaît qu'un fournisseur a volontairement mal contextualisé les décisions de justice, ou s'il apparaît qu'il n'a pris aucune mesure pour sécuriser les données utilisées alors même qu'il avait conscience du risque de corruption de son système par un tiers notamment.

327. En outre, ces clauses peuvent être réputées non écrites sur le fondement de l'article 1171 du Code civil. Ce dernier texte énonce que « dans un contrat d'adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l'avance par l'une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite ». Le contrat passé avec un fournisseur d'outil de justice prévisionnelle pourra généralement être qualifié de contrat d'adhésion dans la mesure où il contient un ensemble de clauses non négociables et non négociées⁵²⁰. En conséquence, le dispositif de lutte contre les clauses abusives pourra lui être applicable et la clause exclusive ou limitative d'obligation pourra être réputée non écrite si elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties. Il est difficile de se prononcer abstraitement sur la validité d'une clause au regard de ce texte car tout dépend de l'équilibre global de chaque contrat. Cela étant, un raisonnement par analogie est permis avec le droit de la consommation qui, rappelons-le, fait des clauses limitatives de responsabilité des clauses noires, c'est-à-dire des clauses réputées irréfragablement abusives. À cet égard, cela implique que dans l'hypothèse où l'utilisateur serait un consommateur, les stipulations limitatives de responsabilité seraient réputées non écrites et privées de tout effet. On pourrait se demander si, en matière d'outil de justice prévisionnelle, le professionnel du droit ne peut pas être considéré comme un non professionnel au sens du droit de la consommation. Rappelons qu'un non professionnel est, en jurisprudence, une personne qui n'effectue pas un acte « en

⁵²⁰ Ce dernier est défini par l'article 1110 du Code civil comme « celui qui comporte un ensemble de clauses non négociables, déterminées à l'avance par l'une des parties ».

relation directe avec sa profession »⁵²¹, tel un promoteur immobilier (professionnel de l'immobilier) qui contracte avec un contrôleur technique (professionnel de la construction)⁵²². Cela pourrait être soutenu dans la mesure où le professionnel du droit est un profane en matière de conception d'outils dotés d'IA.

328. Enfin, ces clauses peuvent être réputées non écrites sur le fondement de l'article 1170 du Code civil, qui énonce que « toute clause qui prive de sa substance l'obligation essentielle du débiteur est réputée non écrite ». Une nouvelle fois, il est difficile de déterminer *a priori* si une clause excluant ou limitant une obligation d'un fournisseur d'outil de justice prévisionnelle est valable au regard de ce texte car tout dépend de la rédaction des clauses, des performances attendues de l'outil, et en définitive de ce qui a été considéré par les parties comme des obligations essentielles. Rappelons qu'en jurisprudence, la clause qui porte atteinte à l'obligation essentielle est celle qui contredit totalement la portée de l'engagement, ce qui n'est pas le cas d'une clause répartissant les risques entre les contractants⁵²³.

§3 – L'éventuelle action directe de la personne concernée contre le fournisseur

329. **Incertitude.** En cas de dommage causé à un tiers, le fournisseur de l'outil est susceptible d'engager sa responsabilité sur plusieurs fondements. Il peut engager sa responsabilité civile en raison d'une violation de ses obligations contractuelles, de deux manières. Tout d'abord et de manière exceptionnelle, il peut arriver que le tiers bénéficie d'une action contractuelle directe à l'encontre du fournisseur de l'outil. L'action contractuelle peut être prévue par le législateur ou être reconnue par le juge⁵²⁴. En effet, ce dernier peut accorder à un tiers une action contractuelle en responsabilité en présence de chaînes translatives de propriété. Une telle chaîne est *a priori* absente des situations dommageables visées par la présente étude, mais la variété des cas dans lesquels un dommage peut être causé par un outil d'intelligence artificielle, et surtout la versatilité de la jurisprudence dans la délimitation du champ des actions contractuelles⁵²⁵ directe conduit à ne pas écarter totalement la possibilité d'une action contractuelle directe de la victime à l'encontre du fournisseur d'outil de justice prévisionnelle.

⁵²¹ Com., 16 février 2016, n° 14-25.146.

⁵²² Com., 4 février 2016, n° 14-29.234 ; *Recueil Dalloz*, 2016, 639, obs. Péglion-Zika C.-M.

⁵²³ Com. 7 juillet 2021, n°19-22.807 ; *Revue trimestrielle de droit civil*, 2021, 881, obs. Barbier H.

⁵²⁴ Sur les actions contractuelles : Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénéde F., *Droit civil...*, précité, spéc. n° 1607 et suivants.

⁵²⁵ Sur ce point, voir Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénéde F., *Droit civil...*, précité, spéc. n° 1609.

Cependant, c'est principalement sur le terrain extracontractuel que la personne concernée non utilisatrice pourra rechercher la responsabilité du fournisseur.

Section 3 – La réparation du dommage causé au moyen d'un outil de justice prévisionnelle par la responsabilité extracontractuelle

330. En application du principe de non-cumul des responsabilités contractuelle et extracontractuelle, la responsabilité civile extracontractuelle pourra s'appliquer de manière résiduelle aux dommages subis par les utilisateurs d'outils d'intelligence artificielle. Mais surtout, ce régime a vocation à s'appliquer lorsque la victime – concernée par la décision – n'est pas liée par contrat contre la personne qu'elle estime être l'auteur de son dommage. Tel sera le cas lorsqu'elle recherche la responsabilité du fournisseur de l'outil de justice prévisionnelle (§1) voire du magistrat qui a rendu une décision en se fondant sur un résultat algorithmique (§2).

§1 – La responsabilité du fournisseur recherchée par la personne concernée

331. **Primat de la responsabilité pour faute.** Le principal fondement de responsabilité mobilisable en l'état actuel du droit positif est le principe de responsabilité pour faute énoncé à l'article 1240 du Code civil. Ce texte permet d'engager la responsabilité dès lors que trois conditions sont réunies : une faute, un préjudice et un lien de causalité entre les deux. Nous avons déjà exposé ce que serait le préjudice de la personne concernée⁵²⁶ et consacreront donc les prochains développements à envisager les deux autres conditions que sont la faute et le lien de causalité.

Ces notions sont extrêmement souples, la Cour de cassation ayant refusé de les enfermer dans des définitions précises. Il en résulte une grande marge de manœuvre pour le juge. S'agissant des outils de justice prévisionnelle, tout dépendra donc de la manière dont la jurisprudence les appréhendera : les juges pourront interpréter strictement les notions de faute et de lien de causalité afin de cantonner la responsabilité des fournisseurs d'outils dans le but de favoriser l'innovation. Ils pourront au contraire prendre le parti des victimes et retenir une interprétation de l'article 1240 du Code civil facilitant l'engagement de la responsabilité.

⁵²⁶ Cf. supra n° 310.

332. **Notion de faute.** Non définie par le Code civil, la faute est traditionnellement conçue comme la violation d'une obligation préexistante. Une telle obligation peut provenir de tout type de source juridique (textes, règles coutumières, etc.) et de tout domaine du droit (civil, pénal, social, etc.). Or le droit énonce un très grand nombre d'obligations. D'une part, il édicte de nombreuses règles prescrivant des comportements déterminés dans certaines situations. D'autre part, il énonce un devoir général de prudence et de diligence qui, bien que n'étant expressément affirmé par aucun texte, a été déduit de longue date par la jurisprudence de la notion de « bon père de famille », que l'on trouvait dans plusieurs dispositions du Code civil, et qui a été récemment remplacée par celle de « personne raisonnable ». Une faute peut donc être constituée par la violation d'une règle juridique particulière, mais aussi par la violation du devoir général de prudence et de diligence. S'agissant de la responsabilité des fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle, la faute peut donc, d'une part, être caractérisée par la violation de l'une des nombreuses obligations particulières qui leur incombent. Il est impossible d'en dresser une liste exhaustive⁵²⁷ : les devoirs d'information imposés par le droit commun des contrats ou le droit de la consommation, les exigences relatives à la protection des données personnelles résultant du RGPD, l'obligation de loyauté des plateformes issue de la loi pour une République numérique sont autant d'exemples de règles dont la violation serait susceptible de fonder une action en responsabilité pour faute. D'autre part, la faute peut être caractérisée par la violation du devoir de prudence ou de diligence. Enfin, l'inexécution d'une obligation contractuelle (ici du fournisseur à l'égard de l'utilisateur) peut toujours constituer une faute à l'égard d'un tiers de nature à lui permettre de mettre en œuvre la responsabilité extracontractuelle du débiteur en cas de dommage découlant de cette inexécution. En effet, la Cour de cassation a posé un principe d'identité des fautes contractuelle et extracontractuelle en vertu duquel tout manquement au contrat constitue une faute extracontractuelle dont les tiers peuvent se prévaloir pour obtenir réparation sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle pour faute⁵²⁸. Bien que critiquée comme octroyant une faveur excessive aux tiers, cette solution a été récemment confirmée par la Cour de cassation⁵²⁹. Il en résulte que tout manquement au contrat conclu par le fournisseur de l'outil de justice prévisionnelle – et notamment aux obligations prévues par le droit des contrats spéciaux étudiées précédemment – peut être invoqué par les tiers pour demander réparation du dommage que l'inexécution de ses

⁵²⁷ Pour un panorama de ces nombreuses obligations : Bacache M., « Chapitre 3 – Intelligence artificielle et droits de la responsabilité et des assurances », in Bensamoun A. et Loiseau G. (dir.), *Droit de l'intelligence artificielle*, LGDJ, 2019, p. 69 et s.

⁵²⁸ Cass. ass. plén., 6 octobre 2006, *Boot Shop*, n° 05-13.255.

⁵²⁹ Cass. ass. plén., 13 janvier 2020, *Sucrierie de Bois Rouge*, n°17-19.963.

obligations leur a causé. Cependant, pour ne pas déjouer les prévisions du débiteur, la Cour de cassation a récemment précisé qu'en dépit de la nature extracontractuelle de sa responsabilité en jeu, le demandeur pourrait se voir « opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants »⁵³⁰.

Le juge peut donc reprocher au fournisseur d'outil de justice prévisionnelle une imprudence ou un manque de diligence qui suffira à engager sa responsabilité. Afin d'affiner la comparaison entre le comportement du défendeur et celui qu'aurait dû avoir une personne raisonnable, le juge pourra notamment prendre appui sur les nombreux standards issus des textes de *soft law*, tels que la Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires⁵³¹, ou encore le règlement sur l'intelligence artificielle. En effet, même si les outils de justice prévisionnelle ne sont pas considérés à haut risque, le règlement peut inspirer le juge amené à apprécier le comportement du fournisseur au regard des diligences que l'on pouvait normalement attendre de lui. De manière prospective, il faut en outre rappeler que la proposition de directive relative à la responsabilité en matière d'intelligence artificielle⁵³² pourrait faciliter la preuve de la faute. Son article 3 permet en effet aux juridictions d'enjoindre les défendeurs à fournir des informations techniques nécessaires à la caractérisation de la faute, dans le respect du secret des affaires, dès lors que le demandeur a démontré la pertinence de sa requête. En cas de refus du défendeur, la faute sera réfragablement présumée.

333. Lien de causalité. S'agissant du lien de causalité, plusieurs auteurs expriment la crainte qu'il ne soit particulièrement difficile à caractériser en cas de dommage causé par l'intelligence artificielle, en raison de la complexité des mécanismes à l'œuvre. Cette crainte ne semble toutefois pas entièrement fondée car le lien de causalité est une notion d'une grande souplesse⁵³³. La Cour de cassation a jusqu'à présent refusé d'opter pour une définition précise de la causalité. Plusieurs théories de la causalité coexistent en jurisprudence, dont les deux principales sont la théorie de la causalité adéquate et celle de l'équivalence des conditions. Le juge a donc une importante marge de manœuvre qui lui permet de choisir, au cas par cas, une définition de la causalité lui permettant d'engager plus ou moins facilement la responsabilité. Même si le résultat issu d'un outil de justice prévisionnelle n'a fait que contribuer à la

⁵³⁰ Cass. com., 3 juillet 2024, n° 21-14.947.

⁵³¹ CEPEJ, Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, décembre 2018.

⁵³² Proposition de directive « sur la responsabilité civile en matière d'IA », 28 septembre 2022, COM (2022).

⁵³³ Sur ce point : Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénédé F., *Droit civil. Les obligations*, Dalloz, 13^e édition, 2022, p. 1212 et suivantes.

réalisation du dommage, le lien de causalité pourra ainsi être caractérisé sur le fondement de l'équivalence des conditions. À cela s'ajoute le fait que le juge peut recourir à des présomptions en cas d'incertitude sur la causalité. Ces présomptions peuvent être de fait ou de droit. Le contentieux relatif à la vaccination contre l'hépatite B a montré que les juges, avec l'aval de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE)⁵³⁴, pouvait présumer largement un lien de causalité dans un contexte d'incertitude scientifique. Il résulte de l'ensemble de ces remarques que la caractérisation d'un lien de causalité ne semble pas un obstacle insurmontable pour les victimes d'un dommage causé par un outil de justice prévisionnelle. En cas d'incertitude liée à la complexité du produit, le recours à des présomptions pourrait faciliter la charge probatoire de la victime. Les projets de droit européen sont d'ailleurs en ce sens : l'article 4 de la proposition de directive sur la responsabilité en matière d'intelligence artificielle institue une présomption de lien de causalité dès lors que la faute est caractérisée⁵³⁵.

334. **Hésitations relatives à la responsabilité du fait des choses.** L'application du principe général de la responsabilité du fait des choses aux dommages causés par les outils de justice prévisionnelle apparaît plus incertaine⁵³⁶. La difficulté principale réside dans le fait que l'application de la responsabilité du fait des choses à des choses incorporelles est débattue⁵³⁷. Le texte de l'article 1242 alinéa 1 ne s'y oppose nullement, mais la jurisprudence a jusqu'à présent cantonné le champ d'application de cette disposition aux seuls dommages causés par des choses corporelles et le projet de réforme du droit de la responsabilité civile confirme cette solution. S'agissant des outils de justice prévisionnelle, le principe général de responsabilité du fait des choses ne leur est donc, en l'état actuel du droit positif, applicable que lorsqu'ils sont incorporés dans un support matériel, ce qui ne sera généralement pas le cas. En imaginant que la jurisprudence évolue et admette que les choses incorporelles entrent dans le champ d'application de l'article 1242 alinéa 1 du Code civil, il resterait à caractériser les autres conditions de la responsabilité. La première est la garde, qui est définie largement depuis l'arrêt *Franck* de 1941 comme le « pouvoir d'usage, de direction et de contrôle de la chose »⁵³⁸. Une présomption de garde repose sur le propriétaire, à charge pour lui de prouver que la garde a été

⁵³⁴ CJUE, 21 juin 2017, aff. C-621/15.

⁵³⁵ Proposition de directive « sur la responsabilité civile en matière d'IA », 28 septembre 2022, COM (2022).

⁵³⁶ Sur ce point : Méribet S., *Vers un droit de l'intelligence artificielle*, Dalloz, 2020, p. 473 et suivantes.

⁵³⁷ Sur ce point : Tricoire E., « La responsabilité du fait des choses immatérielles », *Mélanges Philippe Le Tourneau*, Dalloz, 2008, p. 983 ; Fabre-Magnan M., *Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats*, PUF, 2021, n°264 ; Lachière C., « Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? », *Dalloz IP/IT*, 2020 p. 663.

⁵³⁸ Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, bull. 292 p. 523.

transférée, volontairement ou involontairement. La marge de manœuvre du juge est donc une nouvelle fois importante. En cas de dommage causé par un système d'intelligence artificielle, plusieurs auteurs ont observé que l'on pourrait s'inspirer de l'ancienne distinction entre la garde de la structure et la garde du comportement pour qualifier alternativement de gardien le concepteur, le fabricant ou l'utilisateur du système selon l'origine du dommage⁵³⁹. Un parallèle peut ici être fait avec la proposition de règlement sur l'intelligence artificielle (RIA)⁵⁴⁰, qui qualifie d'opérateurs l'ensemble des acteurs de la chaîne (fabriquant, fournisseur, mandataire, importateur, distributeur et utilisateur). La seconde condition de la responsabilité est le fait actif de la chose. Ce dernier est présumé lorsque la chose est en mouvement et est entrée en contact avec le siège du dommage, ce qui ne sera pas le cas dans les situations dommageables objets de la présente étude. En l'absence de présomption, le fait actif est défini par le critère de l'anormalité. Les victimes d'un dommage causé par un outil de justice prévisionnelle devront donc prouver que ce dernier a fonctionné de manière anormale, ce qui ne sera pas aisé. Afin d'alléger la tâche des victimes, il faudrait étendre les dispositifs envisagés par les projets européens dans le cadre de la responsabilité pour faute (injonction facilitant la collecte d'informations et présomption de lien de causalité). Au regard de ce qui a été vu, l'application de la responsabilité du fait des choses aux dommages causés par des outils de justice prévisionnelle n'apparaît pas théoriquement impossible, mais pratiquement délicate en l'état actuel de la jurisprudence. Et lorsque l'on étudie les projets à venir, l'orientation retenue ne semble pas favorable à la responsabilité du fait des choses en cas de dommage causé par un système d'intelligence artificielle. Ainsi, à l'échelle européenne, avait été un temps envisagé une responsabilité objective pour les dommages causés par les systèmes d'intelligence artificielle à haut risque. Mais cette voie a finalement été abandonnée au profit de la responsabilité pour faute dont la preuve est simplement facilitée⁵⁴¹. Certes, la proposition de directive sur la responsabilité civile en matière d'intelligence artificielle n'interdit pas aux États membres de recourir à la responsabilité du fait des choses. Son article 1 énonce que « les États membres peuvent adopter ou conserver des règles nationales plus favorables aux demandeurs lorsqu'il s'agit d'une action civile en réparation de dommages causés par une faute

⁵³⁹ En ce sens : Arhab-Girardin F. et Dugué M., « Intelligence artificielle et médecine. Rapport français », in Gout O. (dir.), *Responsabilité civile et intelligence artificielle*, Recueil des travaux du Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l'assurance (GRERCA), Bruylant, 2022 ; Loiseau G. et Bourgeois M., « Du robot en droit à un droit des robots », *La Semaine juridique Édition générale*, 2014, 1231.

⁵⁴⁰ Proposition de règlement « établissant des règles harmonisées concernant l'intelligence artificielle (législation sur l'intelligence artificielle) et modifiant certains actes législatifs de l'Union » dit « règlement sur l'intelligence artificielle » (RIA) du 6 décembre 2022, n°15698/22.

⁵⁴¹ Sur ce point : Grynbaum L., Le Goffic C. et Pailler L., *Droit des activités numériques*, Dalloz, 2023, p. 1057 et s.

extracontractuelle imputable à un système d'IA, pour autant que ces règles soient compatibles avec le droit de l'Union ». En outre, son considérant 14 précise que « la présente directive devrait suivre une approche d'harmonisation minimale. Cette approche permet aux personnes qui demandent réparation pour des dommages causés par des systèmes d'IA d'invoquer les règles plus favorables du droit national ». Les législateurs nationaux demeurent donc pour l'instant libres d'énoncer des règles de responsabilité sans faute, mais l'intention des auteurs des textes européens n'en est pas moins clairement en faveur d'une simple présomption de faute.

335. Exclusion de la responsabilité du fait des produits défectueux en l'état actuel du droit positif. Actuellement, la responsabilité du fait des produits défectueux n'est pas un fondement propice pour les actions en responsabilité civile dirigées contre les fournisseurs d'outils de justice prévisionnelle, car ces actions n'entrent pas dans le champ d'application de la directive de 1985. Il ne fait guère de doute que l'outil de justice prévisionnelle puisse être qualifié de « produit », dans la mesure où les institutions européennes se sont expressément prononcées en faveur de l'application de la directive aux logiciels⁵⁴². D'ailleurs, la directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux fait actuellement l'objet d'un projet de refonte⁵⁴³ notamment pour l'introduire expressément dans les « fichiers de fabrication numérique et les logiciels »⁵⁴⁴. Les outils de justice prévisionnelle entrent donc incontestablement dans la qualification de produit.

En revanche, la responsabilité du fait des produits défectueux n'est applicable qu'aux dommages corporels ou matériels résultant d'un défaut de sécurité du produit. Or les dommages causés par les outils de justice prévisionnelle sont immatériels (atteintes à la vie privée, au procès équitable, perte de chance d'une issue plus favorable, etc.), même s'ils peuvent évidemment engendrer des préjudices patrimoniaux comme extrapatrimoniaux. Si le projet de réforme de la directive sur les produits défectueux envisage d'étendre la catégorie des dommages réparables à la perte ou à la corruption de données, le dommage immatériel en demeure exclu. Le régime de responsabilité du fait des produits défectueux serait donc

⁵⁴² Position de la Commission européenne (JOCE, 8 mai 1989, réponse à la question écrite n°706/88) et du parlement européen (résolution contenant des recommandations à la commission sur un régime de responsabilité civile pour l'intelligence artificielle, 2020/2014 (INL), 20 octobre 2020). Sur ce point : Sabard O., « Les produits – rapport français », in *La responsabilité du fait des produits défectueux*, recueil des travaux du GRERCA, IRJS, 2013, p. 93.

⁵⁴³ Proposition de directive relative à la responsabilité du fait des produits défectueux, 28 septembre 2022, COM (2022).

⁵⁴⁴ Article 4 de la proposition de directive.

applicable de manière très partielle aux dommages causés par les outils de justice prévisionnelle. En effet, c'est seulement dans le cas précis où le défaut de l'outil conduirait à une perte ou à une corruption de données que la responsabilité du fait des produits défectueux pourrait être engagée.

Enfin, s'il est actuellement difficile de caractériser le défaut du produit, défini comme le fait qu'il « n'offre pas la sécurité à laquelle le grand public peut légitimement s'attendre compte tenu de toutes les circonstances »⁵⁴⁵, la proposition de directive apporte sur ce point une innovation importante en facilitant la preuve du défaut. D'abord, son article 8 prévoit d'habiliter les juridictions nationales, sur sollicitation de la victime ayant présenté des éléments de preuve étayant la plausibilité de sa demande, à ordonner au défendeur de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose. Ensuite, son article 9 institue une véritable présomption de défectuosité et de lien de causalité dès lors que certaines conditions sont réunies⁵⁴⁶. La liste des défendeurs est en outre élargie pour englober l'ensemble des opérateurs économiques dans la chaîne de conception, de fabrication et de distribution du produit⁵⁴⁷. En revanche, le champ des demandeurs est quant à lui restreint par rapport à celui que prévoit actuellement le droit français : ne sont plus visés que les consommateurs personnes physiques⁵⁴⁸, alors que la directive actuelle est applicable en France aux personnes morales et aux professionnels. La proposition de directive étant conçue comme d'harmonisation maximum, elle s'oppose à ce que le législateur français adopte des solutions plus favorables aux victimes dans le champ d'application de la directive.

⁵⁴⁵ Art. 6. Sur la difficulté de caractériser le défaut : Borghetti J.-S., « How can Artificial Intelligence be Defective? », in S. Lohsse, R. Schulze et D. Staudenmayer (dir.), *Liability for Artificial Intelligence and the Internet of Things*, Hart Publishing & Nomos, 2019, p. 63.

⁵⁴⁶ Article 9 : Charge de la preuve. 1. Les États membres veillent à ce que le demandeur soit tenu de prouver la défectuosité du produit, le dommage subi et le lien de causalité entre la défectuosité et le dommage. 2. La défectuosité du produit est présumée lorsque l'une des conditions suivantes est remplie : a) le défendeur n'a pas respecté l'obligation de divulguer les éléments de preuve pertinents dont il dispose conformément à l'article 8, paragraphe 1 ; b) le demandeur établit que le produit n'est pas conforme aux exigences de sécurité obligatoires prévues par le droit de l'Union ou le droit national qui sont destinées à protéger contre le risque du dommage survenu ; ou c) le demandeur établit que le dommage a été causé par un dysfonctionnement manifeste du produit lors d'une utilisation normale ou dans des circonstances normales. 3. Le lien de causalité entre la défectuosité du produit et le dommage est présumé lorsqu'il a été établi que le produit est défectueux et que le dommage causé est d'une nature généralement propre au défaut en question. 4. Lorsqu'une juridiction nationale juge que le demandeur rencontre des difficultés excessives, en raison d'une certaine complexité technique ou scientifique, pour prouver la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre sa défectuosité et le dommage, ou les deux, la défectuosité du produit ou le lien de causalité entre sa défectuosité et le dommage, ou les deux, sont présumés lorsque le demandeur a démontré, sur la base d'éléments de preuve suffisamment pertinents, ce qui suit : a) le produit a contribué au dommage ; et b) il est probable que le produit était défectueux ou que sa défectuosité est une cause probable du dommage, ou les deux. Le défendeur a le droit de contester l'existence de difficultés excessives ou la probabilité visée au premier alinéa. 5. Le défendeur a le droit de renverser toute présomption visée aux paragraphes 2, 3 et 4.

⁵⁴⁷ Article 7.

⁵⁴⁸ Article 1.

336. **Plaidoyer de certains auteurs pour un régime *ad hoc* de responsabilité objective.**

Certains auteurs plaident pour l'adoption d'un régime de responsabilité objective pour les fournisseurs de systèmes d'intelligence artificielle reposant sur l'apprentissage machine, afin de les inciter à se montrer prudents⁵⁴⁹. Cette solution apparaît pour eux la moins coûteuse car elle aide à renforcer la sécurité des systèmes et à limiter subséquemment le risque de dommage⁵⁵⁰.

§2 – La responsabilité des magistrats recherchée par la personne concernée

337. La responsabilité des magistrats est régie par l'article 11-1 de leur ordonnance statutaire qui énonce que « les magistrats du corps judiciaire ne sont responsables que de leurs fautes personnelles. La responsabilité des magistrats qui ont commis une faute personnelle se rattachant au service public de la justice ne peut être engagée que sur l'action récursoire de l'État »⁵⁵¹. En d'autres termes, la responsabilité civile des magistrats n'est engagée que lorsqu'ils commettent une faute personnelle détachable du service de la justice ou qui est dépourvue de tout lien avec celui-ci. Dans ce cas, les magistrats engagent évidemment leur responsabilité dans les conditions de droit commun. En revanche, dès lors que la faute se rattache au service, seule la responsabilité de l'État peut être recherchée sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire. L'État peut ensuite exercer une action récursoire contre le magistrat fautif. Il en résulte que la responsabilité des magistrats pour utilisation ou non utilisation d'un outil de justice prévisionnelle ne peut pas être engagée. Seule peut être engagée la responsabilité de l'État sur le fondement de l'article L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire pour fonctionnement défectueux du service public de la justice, ce qui suppose la preuve d'une faute lourde ou d'un déni de justice. Les éventuelles fautes commises par les magistrats dans l'utilisation des outils de justice prévisionnelle doivent donc être essentiellement appréhendées grâce aux voies de recours à l'encontre des décisions litigieuses.

338. À cet égard, la problématique des outils d'aide à la décision rejoint celle, depuis longtemps connue, des barèmes et référentiels. Si l'utilisation de certains barèmes est imposée

⁵⁴⁹ Deffains B. et de Montcuit G., « Proposition d'un régime de responsabilité objective applicable au dommage causé par une machine auto-apprenante », *Revue trimestrielle de droit civil*, 2022, p. 257 et s.

⁵⁵⁰ *Ibid.*, n° 53.

⁵⁵¹ Ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 portant loi organique relative au statut de la magistrature.

par la loi, la plupart d'entre eux ont été élaborés et diffusés par la pratique sans encadrement législatif. Les barèmes partagent avec les outils de justice prévisionnelle le fait d'être des outils d'aide à la décision, admettant « par construction l'existence de situations suffisamment similaires pour être traitées de façon comparable »⁵⁵². Le juge peut les utiliser mais cela ne le dispense aucunement de trancher en fait et en droit de manière indépendante. Il est donc inconcevable qu'une décision de justice soit remise en cause pour n'avoir pas appliqué un barème. Lorsque le juge a utilisé le barème, il ne doit pas utiliser ce barème comme fondement de sa décision. À l'exception du « barème Macron » propre aux indemnités de licenciement irrégulier ou sans cause réelle et sérieuse⁵⁵³, la Cour de cassation censure les décisions des juges du fond se référant à des barèmes d'indemnisation sans procéder à l'évaluation du dommage en fonction des seules circonstances de la cause⁵⁵⁴. Cette spécificité du barème Macron tient au fait qu'il a été introduit par une ordonnance⁵⁵⁵, à la différence des barèmes utilisés habituellement par les juridictions qui sont élaborés la plupart du temps en interne⁵⁵⁶ voire dans le cadre d'un interfaçage public-privé (comme le barème élaboré par la Banque de France et les compagnies d'assurances).

Ce raisonnement est tout à fait transposable aux outils de justice prévisionnelle qui sont des référentiels élaborés par des entreprises privées. Le magistrat n'engagera pas sa responsabilité pour les avoir utilisés ou pour avoir refusé de le faire. Quant à la décision de justice rendue, elle ne pourra être remise en cause qu'à la condition d'être expressément fondée sur l'usage d'un outil de justice prévisionnelle.

339. **Conclusion.** Bien qu'il soit toujours tentant de solliciter une action du législateur pour régir spécifiquement des situations dommageables apparaissant complexes, l'actuel droit de la responsabilité – contractuelle comme extracontractuelle – contient *a priori* les outils nécessaires pour réparer les dommages causés par l'utilisation des outils de justice prévisionnelle, que la victime soit l'utilisateur ou un tiers. Lorsque la victime est un tiers, l'utilisateur comme le

⁵⁵² « Les barèmes (et autres outils techniques d'aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice », dir. Sayn, I., Perrocheau, V., Favier, Y., Merley, N., 2019, Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, en ligne : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02283040v2>

⁵⁵³ Pour un ex. récent : Cass. soc., 3 avril 2024, n°23-13.452.

⁵⁵⁴ Cass. civ. 2^e, 22 nov. 2012, n° 11-25.988.

⁵⁵⁵ Ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, art. 2.

⁵⁵⁶ Vanneuville R. et Pélicand A., « Juger avec des barèmes. Outils d'aide à la décision et rapport au travail dans la magistrature », *Sociologie du travail* [En ligne] 2024, vol. 66, n°1 : <https://journals.openedition.org/sdt/45455>

fournisseur pourront être obligés à la dette, leur contribution finale effective devant se régler selon les règles classiques des recours entre coobligés⁵⁵⁷.

⁵⁵⁷ Ranouil M. *Les recours entre coobligés*, préf. Jourdain P., IRJS éditions, bibl. André Tunc, 2014.

Troisième partie – L’impact des outils de justice prévisionnelle sur la manière de faire du droit

340. Après une présentation de l’expérimentation conduite au tribunal judiciaire d’une grande ville pour mesurer l’incidence que les outils de justice prévisionnelle pouvaient avoir sur les pratiques des magistrats (Titre 1), nous livrerons une réflexion plus générale sur la place de ces outils parmi les sources du droit sur la base des travaux effectués sous l’égide des professeurs Loïc Cadiet et Cécile Chainais et du président de la chambre à la Cour de cassation Jean-Michel Sommer (Titre 2).

Titre 1 – L’incidence des outils de justice prévisionnelle sur les pratiques des magistrats⁵⁵⁸

341. Cette partie du rapport rend compte de l’expérimentation d’un outil informatique de recherche et de calcul basé sur des grandes bases de données de décisions judiciaires auprès de magistrats. La visée globale de cette expérimentation était de comprendre comment le travail des magistrats et leurs décisions pouvaient être affectés par la présence et l’usage de tels dispositifs. Les entretiens et plus largement la recherche sociologique ont donc visé deux objectifs. D’un côté, il s’agissait de comprendre, jusque dans un détail ethnographique, le travail et l’activité des magistrats concernés, sans la technologie expérimentée. De l’autre, sur la base de cette compréhension détaillée, il s’agissait de rendre compte de ce qui est affecté, déplacé ou ‘traduit’ dans les pratiques des magistrats, dès lors qu’elle est équipée par ces nouvelles ressources. La partie du rapport présentée ici suit les grandes lignes de cette démarche. Les chapitres 1 à 4 cherchent à jeter les bases d’une analyse détaillée de l’activité des juges, et des types de cas auxquels ils sont confrontés dans cette matière particulière que constituent les prestations compensatoires. Les chapitres 5 et 6 utilisent cette compréhension pour saisir ce qui change avec l’IA et discuter plus en détail l’un des points qui est apparu le plus significatif, le rapport des juges aux cas ‘précédents’.

⁵⁵⁸ Par Christian Licoppe.

342. **Protocole expérimental.** L'outil JurisData Analytics a été présenté et mis à disposition des magistrats du pôle des affaires familiales d'une juridiction située dans une grande ville française pendant trois mois (plus deux mois supplémentaires de prolongation), à compter du début de l'année 2021. Celui-ci comportait un module permettant une recherche de mots-clés sur une base de données judiciaires d'une dizaine de milliers de cas environ, permettant de faire remonter des décisions, ainsi que d'effectuer des statistiques sur les montants compensatoires alloués. En contrepartie les magistrats s'engageaient à chercher à l'utiliser autant que possible durant le cours de l'expérimentation.

Le travail de terrain fut contraint par une vague de pandémie de Covid, et dut être mené sur quelques semaines en juin 2022. Il consista en des entretiens semi-directifs menés avec les cinq magistrats du pôle, et d'observations diverses (des dossiers, des bureaux et des salles d'audience), avec recueil de quelques affaires et cas anonymisés, tout ceci durant environ deux heures. C'est sur la base de ce matériau empirique que ces développements du rapport ont été constitués.

Chapitre 1 – L'évolution des procédures de divorce vue à partir des entretiens

343. Les magistrats voient l'évolution du droit en matière de divorce comme pilotée par une transformation des perceptions sociales. Cette évolution, « *c'est aussi comment la société voit le mariage... La société ne voit plus le divorce comme quelque chose d'infâmant, comme ça a pu l'être avant* » (L). Avant 2004, il fallait une faute, et les affaires de divorce nécessitaient une collégialité à trois juges. Avec les réformes du droit qui suivent, cela se banalise, et un seul juge suffit. L'enquête s'étant déroulée juste après une nouvelle réforme, celle du 1er janvier 2021, les magistrats interviewés traitaient encore, au moment de l'enquête, de dossiers dans les deux procédures, cette période d'entre-deux étant censée durer jusqu'à l'été 2021 (pour les audiences de conciliation). Il est intéressant de voir ce qu'ils en disent pour mieux situer certaines de leurs déclarations.

344. Au fil des entretiens, ils résument ainsi les points saillants de la situation en matière de divorce avant cette dernière réforme. Les époux déposaient une requête en divorce, et étaient ensuite convoqués à une audience de conciliation obligatoire, où ils étaient en général présents (même si ce n'était pas toujours le cas), accompagnés ou non de leurs avocats. Lors

de cette audience, le juge aux affaires familiales (JAF) devait statuer sur des mesures provisoires fixant un cadre juridique temporaire jusqu'à la décision finale, comme l'attribution du domicile conjugal, les modalités matérielles et financières de garde des enfants, ou l'attribution d'une pension alimentaire au titre de secours à un époux, et autorisait les parties à engager la procédure. Chacune d'elles avait alors un délai de 36 mois pour saisir la juridiction, en faisant un choix quant au fondement de sa procédure de divorce qui pouvait être la faute, l'accord de principe ou l'altération définitive du lien conjugal, et pour prendre position sur les conséquences du divorce (le débat sur la prestation compensatoire n'apparaissant qu'à ce stade).

345. C'est lors de cette première audience que les JAF rencontraient les parties, la seconde phase de la procédure correspondant plus aux pratiques courantes en matière de justice civile, c'est-à-dire une procédure écrite, avec une phase de mise en l'état, où les avocats produisent, communiquent et stabilisent leurs conclusions. Cette phase était certes suivie d'une audience, mais centrée sur les avocats et leurs écrits, et si les parties pouvaient assister à l'audience elles n'étaient pas censées y intervenir. Comme le note une magistrate, même s'il s'agissait d'une audience, ce n'était « *que de la procédure écrite* ».

346. La réforme de 2021 renforce le caractère écrit de la procédure et oblige les deux époux à prendre un avocat dès le début. Elle est aussi marquée par la banalisation des divorces et le souci de raccourcir les délais : « *Le sens de la réforme, c'est de raccourcir les délais pour les gens qui ont des accords sur tout* ». Le demandeur est tenu dès l'assignation d'une part soit d'exposer le fondement de sa demande en divorce, soit d'en réserver le fondement (ce qui est obligatoire en cas de demande pour faute) et dans tous les cas d'indiquer s'il demandera des mesures provisoires pour la durée de l'instance et de les préciser. Ainsi, dès l'audience d'orientation, les conclusions des parties fixent les points d'accord ou de désaccord, et permettent de déterminer s'il est demandé des mesures provisoires. Si les parties en sont d'accord, le juge peut statuer sans plaidoirie soit sur les mesures provisoires, avant de renvoyer le dossier à la mise en état pour que les parties échangent leurs conclusions au fond, soit pour statuer directement sur le divorce si les avocats ont tenu le dossier prêt dès cette audience, ce qui est souvent le cas dans l'hypothèse d'un accord total des parties. Sinon, une audience est fixée pour plaidoirie sur les mesures provisoires lors de laquelle les parties peuvent comparaître, ou, si aucune mesure provisoire n'est sollicitée, le dossier est renvoyé en audience de mise en état pour les conclusions des deux parties (cette phase de mise en état est inchangée par rapport à ce qui se passait auparavant). C'est surtout la première phase qui est transformée puisque le

magistrat n'a plus besoin de voir les parties, « *on peut divorcer des gens sans les avoir jamais vus, ce qui n'existait pas dans l'ancienne procédure* ». En particulier, la réforme ne change aucunement la procédure d'attribution de prestations compensatoires. Soit les parties sont d'accord sur tout, et lors de la première audience d'orientation, le juge prononce le divorce et règle cette question, sans marge de manœuvre : « *Donc après, nous, on est un peu lié sur le montant, et on ne va pas faire grand-chose. On va prendre les éléments du dossier, vérifier si c'est bien, mais après, on est quand même lié par la demande des parties* ». Mais le cas le plus courant, c'est le désaccord, qui ouvre sur la phase de mise en état jusqu'aux conclusions récapitulatives des parties.

347. Un des points débattus de la réforme, était, au moment de l'enquête, le risque d'un changement radical dans les procédures d'attribution des dossiers. Avant, les avocats saisissaient le greffe, et celui-ci avait la maîtrise des attributions de dossiers dans les différents cabinets. La réforme actuelle doit permettre aux avocats de choisir dès le départ des dates d'audience. Comme les juges tiennent leurs audiences à des jours fixes, cela revient à dire que les avocats ont la possibilité de choisir leur juge. Le souci des magistrats lors des entretiens était de voir s'ils pouvaient s'organiser de manière à reprendre la main sur l'attribution des dossiers sans déroger aux prescriptions procédurales de la réforme. Ironiquement, cela renforcerait un des risques les plus souvent évoqués lorsque l'on parle d'outils d'aide à la décision basés sur le *big data* avec des magistrats, à savoir permettre la comparaison des décisions par ressort et par juge, et donc de permettre aux avocats des stratégies d'optimisation, en l'occurrence choisir le ressort ou le magistrat pour lesquels, sur une base statistique, le type de dossier dont ils ont la charge serait le mieux traité.

Chapitre 2 – La perception par les magistrats du travail de juge aux affaires familiales : l'organisation et le vécu de l'activité

349. Nous présenterons d'abord l'organisation et les magistrats (Section 1) avant de voir comment cette organisation a été mise à l'épreuve par l'avènement des cabinets (Section 2). Il ressortira que le travail est vécu comme tendu par une logique de flux (Section 3) alors que la matière laisse place « à la vie de tous les jours » (Section 4). Il s'agit en définitive de prendre en compte les attentes ordinaires (Section 5).

Section 1 – L'organisation et les magistrats

350. Les magistrats du pôle des affaires familiales (PAF) ont des trajectoires professionnelles assez variées (on trouve par exemple une ancienne greffière, deux anciens avocats). Une moitié d'entre eux a un fort ancrage régional, et ont fait toute leur carrière dans l'est de la France. Ils sont au nombre de six, sans compter le vice-président en charge du pôle, lui aussi ancien avocat. Ils ont été affectés par le président du ressort, le plus souvent après une demande de mutation sur un poste non spécialisé. Ils sont en gros des magistrats en début de carrière, jeunes ou ayant intégré récemment la profession.

Les affaires familiales, c'est « *le poids lourd de n'importe quelle juridiction* ». Comme « *une juridiction a d'autant plus de poids qu'elle a plus de dossiers, et les meilleurs temps de traitements de dossiers* » (H), il est stratégique pour les présidents d'assurer le bon fonctionnement de ce service, et de le pourvoir en postes suffisants, et ce d'autant plus que le président du ressort est tout particulièrement concerné et responsable des délais de traitement dans sa cour.

351. C'est aussi une juridiction avec un *turnover* important, le JAF étant souvent un poste assumé par des magistrats en début de carrière, car il présente une attractivité spécifique : « ce sont généralement des magistrats plutôt jeunes qui arrivent pour un premier poste, qui a l'avantage d'avoir un contentieux qui n'est pas le plus complexe qui soit, on n'est pas dans les brevets et modèles, qui a l'avantage également de rencontrer des gens, donc qui est assez attractif, parce que ça donne le sentiment de croiser des justiciables et puis de régler des situations, et qui n'est pas non plus dans le côté noir de la société, qui s'appelle le droit pénal, alors qu'on peut aimer ou ne pas aimer... » (*Aux affaires familiales*) *on rencontre des dossiers, c'est l'histoire de M. Tout-le-monde... Donc très souvent, en sortant de l'école, y a beaucoup*

de magistrats qui, s'ils n'ont pas une appétence particulière pour être juge d'instruction, juge pour enfants, se retrouvent à venir dans une juridiction, et les premiers postes, ce sont ceux qui sont sur la famille... c'est une porte d'entrée, un peu, dans... pour beaucoup de magistrats » (H). Et c'est vrai tout autant pour les jeunes magistrats que pour les « intégrés », qui apparaissent comme de « faux jeunes » (H).

À la différence de certaines autres juridictions, le pôle des affaires familiales (PAF) de cette juridiction a fait le choix de s'organiser en 'cabinets', un par juge aux affaires familiales (JAF). Les dossiers sont répartis entre les juges, et ceux-ci les traitent de bout en bout et, comme on le verra plus loin, de manière très indépendante. En dehors de rencontres informelles dans les couloirs, ils se côtoient surtout lors des réunions de service, où l'on traite des problèmes d'organisation.

352. Sur cette question de l'organisation, deux considérations s'avèrent essentielles.

- Il s'agit d'abord de l'autonomie du juge : *« le juge reste toujours maître de sa décision. Point. On te dit : l'affaire a été plaidée, mise en délibéré, c'est le juge qui rend la décision. Pas de débat »*.
- C'est encore le travail de mise en forme du dossier : *« Par contre, une affaire, elle est ce que l'on l'a fait devenir. C'est-à-dire qu'un divorce, c'est une assignation, et puis y a une mise en état, et puis y a des demandes incidentes : est-ce que... les pensions, les enfants ont changé de ceci, de cela, donc y a des incidents qui ont lieu »*.

353. Un premier système consiste à faire *« tourner les juges autour des dossiers ; on a des audiences, et ce ne sont pas forcément les mêmes magistrats, ce ne sont pas forcément les mêmes greffiers »*. Cela permet de régulariser les flux d'audiences et de compenser plus facilement, si un greffier ou un magistrat fait défaut, par des substitutions : *« ce qui permet d'avoir un système beaucoup plus régulier, au niveau du fonctionnement, parce que ça sera toujours le même nombre d'audiences, il y aura toujours quelqu'un, et puis si jamais il y a quelqu'un qui a la grippe, ben ça ne pose pas de problème. Donc administrativement, c'est bien mieux, et, ça évite toute une série de micro-problèmes : est-ce qu'il y en a plus dans un cabinet parce qu'il y en a un qui a travaillé plus vite... Et puis cela évite aussi l'attachement greffe-magistrat, qui est parfois une source de beaucoup de difficultés internes. Quand votre affaire, elle est renvoyée plus loin, parce que c'est les vacances de la greffière, et puis qu'elle est encore renvoyée parce que c'est les vacances du magistrat. Donc il y a des systèmes qui sont beaucoup plus fluides dans leur mode de fonctionnement »*.

354. Le défaut de ce système, c'est que plus personne n'est entièrement responsables des démarches accomplies ou pas au fil du dossier : « *Par contre, ce sont des systèmes dans lesquels, moi, je viendrai aujourd'hui, je passerai prendre la pile de dossiers qui vient le mardi après-midi, ou le mardi matin, et puis je dirai : "Bon, ben voilà, on me demande de faire telle investigation, je la fais, ou je ne la fais pas", etc. Et puis, ça sera quelqu'un d'autre qui reprendra le dossier après, en disant : "Mais cette décision d'investigation... Bon, il s'est fait berner par l'avocat, d'ailleurs, ou il n'a pas demandé ça, alors que moi, ce qui m'intéressait, c'est ceci ou cela". Donc on n'est plus maître de l'architecture de son dossier quand on est juge. Et donc, ce système de turnover, ça crée un double problème qui est que le magistrat qui traitera le dossier ne sera pas celui qui l'a suivi* ». C'est un problème organisationnel qui est plus critique dans les configurations à juge unique.

355. À l'inverse avoir le même juge tout au long de la procédure de traitement permet un meilleur suivi, et une meilleure connaissance du dossier : « *Juge unique... donc ça assure un meilleur suivi, parce que celui qui aura la décision, c'est celui qui aura vu le dossier, et qui l'aura, normalement, piloté pour arriver jusqu'au moment où il dira : "Il est prêt". Le suivi du dossier reflètera l'investissement du magistrat. Donc il y a un pilotage qui est fonction du degré d'investissement du magistrat dans chaque dossier... Donc cela crée un meilleur contrôle du dossier, par le magistrat* ». Au niveau du traitement des flux, cela responsabilise les magistrats parce qu'ils n'ont pas de possibilité de se défausser et parce qu'ils sont susceptibles de rendre des comptes sur les temps de traitement dans leurs cabinets : « *et puis au niveau traitement des flux, qui fait quand même partie de la réalité de la justice, ça oblige à se... Le fait d'avoir un dossier qui est pénible, qui est embêtant, c'est parfois très facile de trouver une petite difficulté supplémentaire, ou un point qu'on aimerait bien voir éclairci pour ceci ou pour cela. Et ça renvoie le dossier à un autre petit copain qui sera à l'audience du mois suivant. Tandis que quand on a la propre maîtrise de son dossier, on a également le contrôle du temps du dossier* ». In fine, l'interviewé est d'avis que ce mode d'organisation conduit à des traitements plus rapides : « *On a des délais qui sont beaucoup plus réduits, parce que chaque magistrat, il est maître de la complication qu'il induit dans son dossier, et puis de ce qu'il ne perd pas son temps en ayant des focales différentes* ». Il y a donc un intérêt à la fois intellectuel (juridique ?) et institutionnel à un traitement de bout en bout par le même magistrat : « *Il y a un vrai intérêt, intellectuel pour le magistrat, et institutionnel également, pour la juridiction, que ce soit le*

même magistrat qui suive et soit responsable du temps, de son dossier, et des éléments nécessaires à sa décision ».

356. Du point de vue de l'histoire du pôle des affaires familiales, cette organisation était déjà en place six ans auparavant, avant que le vice-président en poste aujourd'hui n'arrive. Toutefois, à cette époque les délais de traitement étaient beaucoup trop longs : *« il y avait, quand je suis arrivé, des délais... qui étaient de pratiquement une année avant d'être convoqué pour entendre parler de son divorce, et des délais pour rendre les décisions qui étaient absolument effroyables »*. De ce fait, ce dernier avait été nommé précisément avec la mission de casser cette organisation en cabinet (bien que cela soit aussi la seule qu'il ait connu dans sa propre vie professionnelle), avec le même de juge de bout en bout : *« (je suis arrivé) avec une mission qui était précisément de casser le système des cabinets, et de casser le système des greffes attachés à un cabinet »*. En effet, un audit de la situation mené par une société parisienne avait conclu que *« la seule solution, pour qu'il n'y ait pas un enkystement dans chaque cabinet de dossiers... (avec un système) de cabinets tous horizontaux... (était) la pyramide, bref, qu'il y ait un coordinateur, votre serviteur, et puis que ce coordinateur, justement, casse la logique des cabinets et des blocages entre greffe, magistrat, et les petites micro-rivalités qui existaient, pour que tout soit fluidifié »*.

Mais en fait, son arrivée s'est effectuée après le pic de la crise, et aussi après qu'il y ait *« une nouvelle équipe de JAF qui avait été changée, hein. Et qui s'était attaquée à la pile, qui avait déjà commencé à retrouver et à redescendre les stocks, les délais, etc. Et qui bossaient tous tellement bien, en s'étant approprié chacun son cabinet, que moi, je suis arrivé en disant : "Bon, écoutez, y a déjà un bon quart du chemin qui a été fait, moi, je veux bien tout casser, mais je ne suis pas sûr, justement, que ça va..." »*. Et de fait les retards ont été rattrapés en 18 mois, et le vice-président n'a plus jugé bon de basculer vers l'autre mode d'organisation. C'est ce qui explique qu'aujourd'hui la juridiction ait conservé cette organisation en cabinets horizontaux et indépendants.

Section 2 – La mise à l'épreuve de l'organisation en cabinets avec la nouvelle réforme

357. Du point de vue du vice-président, le choix d'un juge unique pour chaque dossier, dans une organisation où le service a la main sur l'attribution des dossiers aux différents cabinets, limite également la marge de jeu des avocats pour s'assurer un juge qu'ils pensent plus

favorable pour leur dossier : « *Ça ferme la porte aussi, à tout ce que j'étais avant comme avocat, le rôle de l'avocat étant de trouver la meilleure faille pour conduire son dossier, et le mettre en délibéré le jour où c'est le magistrat qui paraîtra le plus utile ou le plus favorable à son client. Donc ça consolide un petit peu le système* » (H). Or au moment de l'enquête, une des préoccupations organisationnelles les plus saillantes (elle occupait une grande part des réunions de service) concernait la manière dont la réforme récente des textes en matière de divorce, était susceptible d'offrir de nouvelles possibilités pour les avocats de « *choisir leur juge* ».

358. La nouvelle réforme permet en effet aux avocats de choisir leurs dates d'audience, et donc dans une certaine mesure leurs juges. Cela a conduit à une intense réflexion au sein du PAF pour voir quelle organisation adopter pour éviter cela et le risque que des juges soient préférés (ou délaissés) et que les cabinets ne se retrouvent plus « *au même calibrage* », ce qui pourrait poser des difficultés à la fois aux magistrats et aux greffes. Effectivement, en discutant, le vice-président a appris qu'une très bonne magistrate avait eu le choc de se retrouver avec quatre dossiers, alors que tous les autres en avaient 30 ou 35. Notons que, dans cette perspective, l'épreuve à laquelle est soumise l'organisation est requalifiée en termes logistiques (centrés sur la gestion des flux), plutôt qu'en termes moraux ou juridiques. Après de multiples discussions en réunion de service, l'idée a été de considérer que le problème était surtout celui de la régulation des flux, et donc d'avoir quelqu'un (en l'occurrence le vice-président) qui soit chargé de ventiler les demandes d'audience : « *On a convenu qu'un malheureux allait, une fois tous les quinze jours, ouvrir les droits des audiences de chaque magistrat, en fonction de ce que les autres avaient été remplis, pour être sûr que chacun ait à peu près le même nombre* ». Donc le problème est réglé, « *les cabinets sont équilibrés* », « *les avocats ont des délais d'audience qui sont relativement rapprochés* », « *tout le monde est content* ».

359. **Après quelques mois d'expérimentation de cet ajustement organisationnel, quelques conclusions intéressantes semblent émerger.** Tout d'abord, la magistrate qui avait très peu de dossiers, pouvait être considérée comme traitant ses dossiers de manière assez neutre, sans penchant reconnaissable. Cela suggère qu'accroître la possibilité pour les avocats d'orienter les dossiers vers certains magistrats offre « *une vraie prime à la singularité* ». L'avantage ainsi donné aux avocats sera d'autant plus grand qu'il existe des disparités reconnaissables plus importantes entre les styles des magistrats. Au cours des premiers mois, on ne voit pas de tendance nette se dégager selon les styles de magistrats, parce qu'il semble y avoir, selon le vice-président, une sorte de neutralisation des choix. En effet, les intérêts des

parties étant opposés, les deux avocats auraient tendance à aller vers des styles opposés de juge, en fonction de celui qui demande l'audience, et au final il semblerait que cela s'équilibre.

Section 3 – Un travail vécu comme tendu par une logique de flux

360. Les magistrats doivent rendre typiquement entre 80 et 100 décisions par mois, ce qu'ils comparent aux 30 à 40 dossiers mensuels traités par les magistrats de la chambre civile. Ils perçoivent leur travail comme organisé selon une logique de flux, qui en est constitutive et qui en fait un travail sous tension, même si la perception d'ensemble est que les conditions de travail sont bonnes dans la juridiction : *« les conditions de travail, franchement, elles sont géniales. Il y a de la masse, au JAF, c'est très dense, hein. Il faut donner de sa personne, ça c'est clair, vu le nombre de dossiers qu'on rend »* (E). *« Il y a une tension sur le chiffre, c'est-à-dire passer la pile qui est haute comme ça, de gauche, à faire, à droite, fait »* (N).

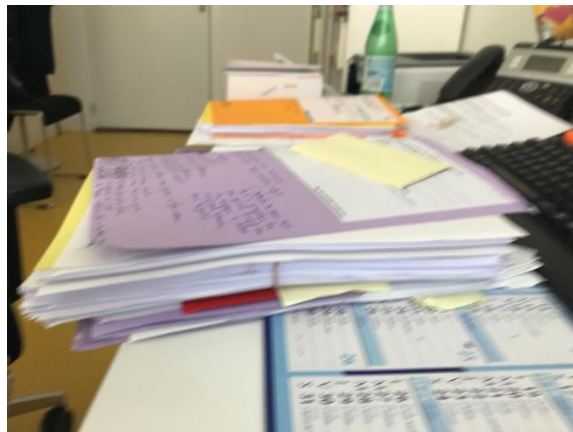


Figure 1. Les piles de dossiers

361. Un autre aspect de la manière dont le travail des JAF est vécu comme organisé par une logique de flux, c'est la façon dont les dossiers sont rapportés par tous les magistrats à des temps de traitement potentiels.

- Un dossier très simple (typiquement, où les parties sont d'accord), c'est donc un dossier où l'on passera en gros une demi-heure : *« Alors, un dossier tout facile, où ils sont d'accord sur tout, ça peut être une demi-heure, on peut aller très très vite, avec la trame »*.

- Un dossier consistant, où les parties sont en désaccord mais sans complexité excessive, prendra quelques heures, jusqu'à une demi-journée, parce qu'ils faut travailler sur les pièces et les conclusions des avocats : *« Un divorce où ils sont d'accord sur le fondement du divorce, déjà, et il y a juste un problème de prestation compensatoire et sur les enfants, où ils ne sont pas d'accord, moi, je vais dire, peut-être, une heure ou deux heures, pour juste la partie prestation compensatoire, parce qu'il faut quand même voir les pièces, récupérer les éléments »*.
- Un dossier singulier dans sa complexité pourra demander entre un et deux jours pour être traité : *« Le dossier le plus difficile, ça va être le divorce pour faute, parce que vous... savoir sur quel fondement du divorce vous devez statuer, donc là, vous avez des complications. S'il y a divorce pour faute, plus la prestation compensatoire, plus des dommages et intérêts, plus ils ne sont pas d'accord sur la résidence des enfants, des fois, vous pouvez passer une journée, voire deux jours, sur un divorce qui va être un peu exceptionnel, et qui va être long »* (L).

362. Et le temps perdu, que ce soit pour des audiences (*« quand t'es appelé ailleurs une journée, ou deux jours dans le mois, et que t'avais prévu ça pour rédiger, ça te manque, après... Même si de temps en temps, je rattrape, je travaille le week-end, et je fais des petits trucs pour m'avancer, mais après, deux journées, c'est tout de suite énorme en matière de rédaction »* (E)) ou pour des événements contingents tels qu'un entretien avec le sociologue de passage, cela a un impact direct sur la capacité à traiter des dossiers (*« le temps qu'on discute ... c'est un dossier que je ne traite pas cet après-midi »* (Y)). Cette pression sur le temps de rédaction a des conséquences sur le dispositif expérimental. Malgré toute la bonne volonté des juges, il ne faut pas que le temps d'apprentissage pour utiliser l'outil d'aide à la décision informatique soit trop long, sans doute une heure maximum.

363. Il faut aussi noter que, dans sa dimension organisationnelle, cette pression ne se traduit que rarement sur un dossier particulier : *« Non, alors... on ne peut pas venir me dire : "Ce dossier-là, ça ne va pas, etc.", et un responsable hiérarchique (le chef de service ou le président du tribunal) ne peut pas venir me dire "qu'est-ce que je devais faire dans le dossier" ; il va simplement dire : "Faut peut-être activer, ou faire des..."*. Voilà. Mais ce n'est pas lui qui va me dire : *"Vous mettez tant de prestation compensatoire, etc."* Comme je disais, on est indépendant » (Y). Il est possible de se voir demander des comptes sur un dossier trop ancien (*« Donc si moi, j'ai par exemple encore des procédures qui datent de 2015, à un moment donné,*

je pense qu'on va venir me demander qu'est-ce qui se passe », 'on' valant ici pour le chef de service et le président). Mais toute intervention est limitée d'un côté par l'exigence d'indépendance des juges et de l'autre par le fait que les magistrats considèrent n'avoir que peu de moyens d'action sur des experts ou des avocats récalcitrants : « *Moi, je sais que j'ai un dossier où j'ai une expertise notariée qui... ça fait plus d'un an, voire un an et demi qu'elle a été ordonnée, et l'expert ne rend pas son rapport. Et moi, j'ai pas beaucoup de moyens de pression sur lui. Et tant que je n'ai pas ce document ... voilà.* » (Y).

364. La possibilité de devoir rendre des comptes se joue plutôt au niveau d'une vision statistique plus générale : « *Après, de manière générale, on va me demander de bien tenir mon cabinet. Donc on a des statistiques, comme dans toutes les juridictions, on va comptabiliser le nombre de dossiers qui sont affectés à chaque cabinet, le nombre de dossiers qui a été rendu par chaque magistrat, et l'ancienneté des procédures* ». Cette analyse statistique 'par cabinet' est à replacer dans une vision plus intégrée au niveau de la cour, d'où part une forme de prescription d'objectifs strictement quantitatifs portant sur les délais : « *le président, avec divorce en moins d'un an, il est très content* » (Y). Cette '**accountability**' statistique renforce encore la perspective d'une activité dominée par les flux. Il convient enfin de remarquer que, durant l'enquête, il y avait un consensus sur le fait que la situation du tribunal sur les délais en matière de divorce était satisfaisante, à la différence d'autres juridictions similaires.

Section 4 – Une matière qui laisse place à la vie de tous les jours

365. Les JAF voient leur matière comme quelque chose qui, inévitablement, laisse place à une part de subjectivité parce qu'elle implique de l'humain. En cela, ils opposent le travail du JAF à ce que font leurs collègues de la chambre civile sur des dossiers d'indemnisation. Là on a une matière strictement technique, centrée sur du texte ou des barèmes, et où l'on ne rencontre en général pas les particuliers concernés, seulement les avocats lorsqu'ils présentent leurs conclusions : « *les collègues, là-bas, dans le couloir, qui font les chambres civiles, elles ne voient personne* » (E). Ce sont des magistrats « *qui aiment la technicité d'un contentieux, qui aiment aller chercher... à la bibliothèque ce qui pourrait faire solution à leur litige* » (N). Parce que ce genre de contentieux est comme séparé de la vie ordinaire par un mur d'écritures, on peut s'y cantonner à la mise en œuvre du seul raisonnement juridique : « *mes collègues de la chambre civile, elles ont à étudier si y a eu des malfaçons sur un mur fissuré, eh ben, elles*

ne peuvent pas adapter... elles peuvent avoir qu'un raisonnement juridique. Voilà, c'est plus technique, et elles ne peuvent pas dire : Ben, le maçon, ce jour-là, il était bourré, le pauvre, il a des soucis » (E). Par rapport à ce type de profil de magistrat, cette humanité des affaires familiales, jointe à une pression sur les flux de dossiers, peut rendre cette matière moins attractive : *« Alors ce qui effraie dans cette matière-là, c'est la conjonction de la masse et justement du côté personnel et intimité de la vie privée des justiciables » (E).*

Les affaires familiales, c'est très différent, la vie ordinaire infiltre la procédure et le traitement ordinaire des affaires : *« Alors que nous, au JAF, on a ce côté humain qui est quand même très présent, et qui ressort régulièrement, parce que c'est la vie des gens » (E).* Différentes médiations permettent cette hybridation de la procédure. Tout d'abord, au moins avant la réforme du 1^{er} janvier 2021 qui doit limiter ce type de contact, *« nous au JAF, on fait des audiences » (E)* qui donnent lieu à un contact avec les personnes concernées. C'est différent à la fois de la chambre civile où ce genre de rencontre est rare, mais également des audiences de la justice pénale, comme au niveau correctionnel *« où on a le contact, mais avec le décorum et l'écologie de l'audience en prétoire » (N)*, où la formalité des lieux et des rituels met une distance entre la procédure et ses acteurs professionnels et les personnes ordinaires. En revanche l'audience des affaires familiales se fait *« dans une petite salle où on vient discuter de son intimité, dans une audience non publique »*. La dimension humaine qu'apporte une audience plus « proche » qu'au pénal semble non seulement appréciée par une partie des JAF (*« j'aime aller aux audiences... je ne suis pas une espèce de rat de bibliothèque » (E)*), ce plaisir fait partie du métier, et il contribue à la décision : *« voir les personnes, les interroger soi-même, c'est plus facile après, pour rédiger une décision » (E).* C'est d'autant plus vrai que la présence de son client avec l'avocat *« donne un peu de feeling, car les avocats sont un peu secs parfois »*, et fournit une occasion de faire se raconter les personnes, de donner chair à leur demande. Une magistrate cite une audience où le père a dévoilé son attitude par rapport aux enfants, ce qui l'a conduite à réévaluer sa position sur les conditions de garde.



Figure 2. La salle d'audience d'une magistrate (durant la période de la pandémie de Covid, d'où le plexiglas) qu'elle a choisi d'humaniser avec des affiches de films et une plante

366. Ensuite, il semble au premier abord que le magistrat s'efforce de tenir à distance le vécu et l'intimité des personnes, et ce de différentes manières. Tout d'abord, parce que les JAF sont affectés par la confrontation avec l'intimité des demandeurs, ils doivent effectuer un travail sur eux-mêmes, rendu possible par leur position d'extériorité : *« à un moment, il faut évacuer, parce que... si on devait absorber toute la misère des gens qu'on voit, je crois que... si tu es dépressif ou pas bien dans ta tête, il ne faut pas faire JAF. Je suis sérieuse, ni juge des enfants »* (E). Ensuite parce que, même si *« personne d'autre (que la famille) ne sait mieux qu'eux ce qui s'y vit »*, le JAF ne travaille pas sur des déclarations, mais doit se cantonner aux éléments objectifs rapportés dans les conclusions des avocats : *« tout ce qui est allégations, on n'en tient pas compte, enfin moi, je les survole, je lis pas... ce qui m'intéresse, ce sont les éléments objectifs. Donc si j'ai aucun élément... Après, parfois, y a des reproches qui sont faits, mais... quand ce ne sont que des allégations, et que je n'ai aucun élément objectif, ça ne sert à rien »* (Y). Il peut être dit qu'un mari est violent, mais si ce n'est pas étayé par un témoignage écrit, ou, mieux, un jugement pénal de condamnation, alors il faut s'efforcer de ne pas en tenir compte. Enfin, parce qu'il s'agit pour les JAF de réinterpréter ces éléments objectifs au prisme des critères codifiés par la loi : *« On cherche à faire abstraction de notre vécu, à apprécier les choses par rapport à la grille de lecture que nous donne le code »* (Y).

367. **Mais ce travail de mise à distance et d'objectivation juridique n'est jamais complet.**

Il subsiste une dimension liée à l'humanité et la singularité du dossier : *« on est tous juges avec nos critères légaux, et on va rentrer dans nos dossiers individuellement, et on va essayer de faire les choses de manière la plus objective, mais voilà, y a à chaque fois une singularité à prendre en compte »* (Y). Le travail du JAF semble parfois être décrit comme l'art de faire tomber un cas singulier dans une caractérisation objective, via sa transformation en faits objectifs auxquels on appliquerait les critères du droit. C'est alors un art de l'ajustement habile (*« tout le monde bricole »* (T)), qui est formulé comme relevant d'une souplesse dans l'appréciation : *« mais ce qui est important pour moi, c'est que chaque magistrat garde sa souplesse d'appréciation. Parce que comme on disait, on statue sur de la singularité, et le code ne nous propose pas des méthodes de calcul, mais des critères, et qu'on puisse... 'fin, qu'on applique les critères, en fait »* (Y). Mais, le plus souvent, ce qui est constitutif de l'activité, c'est bien la rencontre et le compromis entre deux manières de raisonner et de questionner le dossier : *« Ben, la loi, ça va être de dire qu'un papa doit verser une contribution à l'enfant, sauf s'il est en état d'impécuniosité. Genre il a le RSA, ben je ne lui prendrai rien. Le raisonnement humain, c'est de dire : qu'est-ce-que cet enfant a besoin ? »*. C'est un art de l'hybridation : *« Et après, l'art du juge aux affaires familiales, on va dire, c'est de mixer les deux... voilà, de dire : oui, la loi impose que le papa doit payer, mais quel est l'intérêt de l'enfant, quels sont ses besoins ? C'est tout simple, en fait, c'est la vie de tous les jours, c'est... un raisonnement... Et ça, c'est très spécifique à la fonction du JAF »* (E).

368. Le travail du juge aux affaires familiales, qu'il soit plus ou moins orienté vers l'objectivation et l'application de critères juridiques, ou, *a contrario*, qu'il reconnaisse plus ou moins la dimension humaine des dossiers et la marge d'appréciation par rapport aux critères proprement juridiques qui en résulte, reste donc toujours un **art de l'hybridation, de l'ajustement, du bricolage**.

Section 5 – La prise en compte d'attentes ordinaires

369. Il découle de ceci une autre manière possible pour le travail des JAF d'être sensible à des logiques autres que juridiques, et relevant plus de la vie quotidienne. Un juge s'est ainsi déclaré très soucieux de ce que les personnes peuvent accepter : *« Je regarde les capacités*

contributives des gens en apparence... Bon, et puis je prends en compte des éléments... un peu d'intuition sur ce que... ce que les personnes peuvent accepter, de payer et de recevoir, ce qui paraît juste, susceptible d'être juste pour les gens, à l'intuition » (T). D'un côté, cela relève d'une sorte de principe de justice : « Parce que, rendre la justice, c'est comme en matière pénale. Hein, c'est que la peine qui est prononcée soit acceptée, si possible, à la fois par le condamné et par la victime » (T). De l'autre, c'est inhérent à une logique de gestion des flux, car les décisions non acceptables ou non acceptées risquent d'aller en appel, et donc finalement de rester longtemps non traitées, même si elles ne relèveront plus de la compétence du juge de première instance. Cette position offre un contraste avec celle du président de cour : « je me souviens en avoir discuté, soit avec ce président, soit avec un autre président avant, de ces questions-là ; eux, ils disent : "Mais vous vous en foutez... Perdez pas votre temps à ça, si les gens sont pas contents, il font appel". Bon, non, non. Voyez, on est dans une logique d'évacuation des dossiers, aussi, c'est ça qu'il faut voir, de temps, qui fait qu'on se débarrasse des dossiers. Ça délègue le problème à la cour d'appel » (T).

370. Parce que ces attentes des justiciables renvoient à des dimensions personnelles ou collectives d'ordre extra-juridique, cela rend justifiables des variations d'une cour à une autre : « Bon, mais franchement, les situations sont... financièrement et humainement très disparates. En plus... parce que, on peut dire : "C'est pas normal que, à Marseille, ça soit 100, et que ça soit 200 à Dunkerque". Mais si la sociologie marseillaise est telle que leur sentiment d'équité... Globalement, la population pense que c'est 100 qui est juste... Et tandis qu'à Dunkerque, ils estiment que c'est 200 qui est équitable » (T). Non seulement, **on peut concevoir, mais on peut comprendre ces variations, sur la base de cette sensibilité de la décision aux attentes ordinaires.** Face, par exemple, aux promoteurs de l'IA, qui assurent qu'un des avantages de l'usage de l'IA comme outil d'aide à la décision judiciaire serait d'éviter les disparités dans les décisions d'un juge à l'autre ou d'une cour à l'autre, il y a là un contre-argument intéressant.

Chapitre 3 – Le traitement des dossiers de divorce

371. S'il y a des sources de complexité dans les dossiers (Section 1), l'activité décisionnelle est équipée d'outils pour l'aider (Section 2). Une analyse de la réunion de service et de ses usages révèle une tension entre coordination et collaboration, d'une part, et entre autonomie et indépendance, d'autre part (Section 3).

Section 1 – Les sources de complexité dans les dossiers

372. Comme on l'a vu, les magistrats sont très sensibles au temps de traitement des dossiers, qui découle de leur complexité. Les dossiers, qui s'enracinent dans des biographies individuelles, sont assez variables, et plusieurs facteurs sont susceptibles de contribuer à leur complexité. De manière très générale, il y a une corrélation entre le degré de conflictualité et le degré de complexité du dossier. Plus spécifiquement, il y a la question des enfants, particulièrement susceptible d'articuler conflictualité et complexité, et à laquelle les magistrats attachent une grande importance : « *Oui, des dossiers difficiles. Violents, où y a un conflit parental, et que l'enfant est au milieu de ça, avec des disputes sur les heures de retour, sur ceci, sur cela... Voilà, vous avez des disputes, l'enfant est au milieu de ça, et ça, ça prend du temps. Et ça, je préfère me consacrer mon temps à ça, que à définir une prestation compensatoire* » (L). Le divorce pour faute, même s'il devient plus rare, est toujours associé par les magistrats à un grand degré de complexité des dossiers : « *Et donc, on a de moins en moins de divorces pour faute, par exemple. Et quand vous avez un divorce pour faute, faut aller voir... Est-ce qu'on lit les attestations ou pas, vous avez des... On vous donne une pile de trucs, c'est... c'est dans un désordre... C'est très long, très très long à étudier* » (T).

373. D'autres facteurs de complexité du dossier en général affectent beaucoup le problème de l'attribution des prestations compensatoires :

- la hauteur des demandes de prestation compensatoire en valeur absolue : « *La moyenne des demandes de pc, c'est quelques dizaines de milieu d'euros, le lourd et le compliqué ça va être des demandes plus grandes et disparates (800 000 d'un côté et 100 000 de l'autre), ça demande de prendre du temps* » (T) ;
- le degré de disparité des revenus des deux parties ;

- le fait qu'une des deux parties au moins dispose d'un patrimoine ou de revenus importants (des biens, des comptes, des assurances-vie, etc.). À l'appui de son argument, une magistrate cite le cas d'un chef d'entreprise, avec toutes sortes de revenu (fonciers, parts sociales, revenus de versements, comptes d'associés) : « *ce sont des situations qui sont difficiles pour se faire une appréciation objective de la situation* » (N) ;
- le cas des conjoints collaborateurs, où le mélange du personnel et du professionnel sur la durée complexifie les dossiers.

374. D'autres éléments plus contingents peuvent également rendre plus délicats le traitement des dossiers et le rendu des décisions. Il y a par exemple des configurations qui rendent difficiles de respecter les délais de convocation à l'audience, lorsqu'une partie est à l'étranger (Y). Ou encore, il arrive que des questions particulières doivent être prises en compte, alors qu'elles sont plus ou moins objectivables, comme l'état de santé : « *Après, vous avez certains qui ont des problèmes de santé ; donc là, ça devient quelque chose de plus subjectif, c'est-à-dire que : est-ce qu'il va démontrer des difficultés de santé ? Il va falloir les démontrer. Et la difficulté de santé, elle ne fait pas tout en elle-même, c'est une difficulté de santé qui va faire que sa capacité de travail et de percevoir des revenus va être limitée. Parce qu'en fait, au final, c'est toujours qu'une question d'argent* » (L). Enfin, une magistrate, citant un dossier avec des menaces de mort, indique que la pandémie de Covid, et les confinements auxquels elle a donné lieu, a multiplié les cas de violences domestiques dans les dossiers traités aujourd'hui (E).

Section 2 – L'activité décisionnelle comme activité équipée

375. Une fois l'affaire mise en état et éventuellement plaidée par les avocats à l'audience, les juges élaborent leurs décisions dans des écologies qu'ils ont adaptées et en exploitant une gamme de ressources, dont en premier lieu les trames informatiques qui facilitent la rédaction d'un jugement motivé.

- Telle magistrate, plus orientée vers le numérique, utilise une application du tribunal qui permet de voir les conclusions des avocats sans les imprimer. Elle aime bien avoir les pièces en main, imprimées, « *mais les conclusions c'est sur écran* ». Elle se met alors en mode double écran, avec les conclusions sur un et les trames créées par l'outil d'aide à la rédaction des magistrats.

- Telle autre magistrate, qui décrit la première comme travaillant de manière « dématérialisée », préfère imprimer les deux rapports et les disposer ainsi que sa note d'audience côte à côte sur son bureau, pour un « *confort de lecture* », tandis qu'elle rédige sur une trame à l'écran.

Dans les deux cas, que l'écologie de l'activité soit plus matérialisée ou plus dématérialisée, elle est conçue pour partir des conclusions et faciliter un va-et-vient entre les deux documents (et versions du cas de divorce), la note d'audience complétant cette lecture comparative si l'audience a donné lieu à de nouveaux débats. Ces écologies rendent visibles et concrétisent le fait qu'« *un litige c'est de toute façon un débat* », et tout particulièrement dans les affaires de divorce où les parties produisent des versions détaillées et différentes de leur vie familiale et domestique.

L'activité décisionnelle des JAF s'appuie en outre sur diverses ressources, en particulier les collègues, les forums professionnels et certains outils de calcul comme les barèmes.

Parmi ces ressources, nous nous sommes intéressés aux discussions avec les collègues (§1) et aux listes de discussion (§2).

§1 – Les discussions avec les collègues

376. Il convient tout d'abord de réaliser que l'idéal d'une indépendance complète du juge restreint l'inclinaison de celui-ci à discuter d'un cas, dans la mesure où cela pourrait suggérer son ignorance : « *Chaque dossier est la propriété d'un magistrat... Mon imperium, et ma responsabilité, est ma responsabilité par rapport aux gens, mais à mon avis aussi, ma responsabilité par rapport à moi-même, et peut-être par rapport à mes pairs. Un juge, à mes yeux, et probablement à ceux des autres, qui est en charge d'un dossier, et qui, s'il venait dire : "Je n'y comprends rien", aurait peut-être le sentiment de...* » Et cela pèse sur toute discussion, mais d'une manière que les magistrats ont en général du mal à formuler : « *Ça n'empêche pas de discuter, mais on est en...* » (H). Tout est dans ce « mais ».

Des transformations historiques sont souvent évoquées. D'un côté, il y aurait un monde d'avant, avec un droit stable, et des magistrats qui le maîtrisent de manière à construire sur lui une autorité individuelle : « *Mais les choses changent... Vu de mon grand âge, je suis rentré dans la magistrature parce que j'avais une vision de juges qui connaissaient le droit et qui savaient. Ça, c'est le point de vue de l'avocat que j'étais avant* » (H). Cette autorité presque hiératique, à dire le droit à partir d'une maîtrise individuelle du droit, semblait écarter tout besoin de discussion et de collaboration : « *Qu'un juge vienne dire : "Je ne connais pas tel truc", c'était*

limite inimaginable quand moi, je suis rentré dans la justice, c'était y a vingt ans... J'ai découvert que y avait une vraie fracture avec toute une série de vieux magistrats, qui venaient dire : "Je sais, je connais, je pense", et qui pour rien au monde, ne seraient venus abdiquer ce qui était leur propre image, en disant : "J'ai besoin d'aide, je ne comprends rien"... Il y a quelques années, voir un magistrat qui viendrait dire à un autre magistrat : "À propos, bon, alors maintenant, je dois siéger pour tel truc, mais je n'y connais strictement rien, tu pourrais avoir une trame ou me dire ceci ou cela", ça n'existait pas. Qu'un juge vienne dire : "Je ne connais pas tel truc", c'était limite inimaginable quand moi, je suis rentré dans la justice, c'était y a vingt ans » (H).

377. Le changement en la matière provient d'une accélération des réformes, un phénomène particulièrement sensible en ce qui concerne les affaires familiales : *« On a eu ces dernières années, et c'est malheureusement le moment où j'ai commencé à rentrer dans la justice, un vrai turnover absolu de textes qui fait que tout le monde est désorienté... mon code il est déjà périmé »*. Il subsiste un éthos de l'autonomie, rapporté à une forme de dignité professionnelle, qui est toujours réaffirmé sous une forme ou une autre : *« Mais pour autant, il reste quand même cette impression de dignité : je suis capable de traiter mon dossier... Il reste la vraie dignité du magistrat, qui est de se dire : "Je dois faire preuve... je vais être seul à faire face au problème" »*. Mais l'incertitude liée aux réformes pousse à la collaboration : *« Maintenant, on est tous dans le couloir à se dire : "Eh, à propos, l'intermédiation, qu'est-ce que... [petit rire] on en fait quoi ?". Parce que c'est considéré comme quelque chose qui va, qui vient, qui change, etc. Donc maintenant, y a une vraie communication sans problème »*.

378. **D'une manière générale, la discussion avec les collègues est facile du fait de l'organisation du service et des rencontres de couloir (tous les bureaux sont proches).** Cela fait donc sens de parler avec des collègues de cas délicats : *« l'avantage qu'on a (ici), c'est qu'on a un pôle avec six magistrats, qui sont tous plus expérimentés que moi en la matière, et bien sûr que, surtout au tout début, j'avais toqué très régulièrement pour discuter, alors c'est soit sur des questions juridiques que je ne connaissais pas ou que j'avais pas encore rencontrées, soit justement pour avoir un autre avis, en disant : "Voilà, j'ai cette situation, c'est un petit peu compliqué, j'envisage de faire ça, mais j'aimerais bien en discuter". Alors, ce n'est pas de la collégialité, parce qu'on est seul juge dans chaque dossier, mais néanmoins, c'est l'occasion d'échanger, et de voir quelles sont les pratiques des uns et des autres »* (Y). Les discussions portent donc soit sur les textes et des points de droit, ce qui ne pose aucun problème,

soit sur l'appréhension du cas dans son ensemble (dont on a vu qu'elle hybridait inévitablement raisonnements juridiques et raisonnements ordinaires, ce qui est plus délicat : « *Mais voilà, on va des fois continuer de confronter nos points de vue, et ça aide, en fait. Parce que des fois, quand vous devez exposer votre situation à un collègue, ben vous reprenez les arguments, et vous voyez les arguments qui portent, qui portent pas, et après, vous dites qu'est-ce que t'en penses ?* » (L). En effet, comme on le voit dans la citation précédente, chaque fois que les magistrats mentionnent ce genre de discussion, c'est pour réaffirmer l'indépendance du juge et se défendre vis-à-vis de la possibilité que ces discussions affecteraient leur décision et pourraient constituer une forme de collégialité (qui remettrait donc en cause l'indépendance des juges).

379. La discussion informelle entre magistrats a donc un statut ambigu. Pour être intéressante, elle doit avoir des effets, et donc affecter la perception du cas par le magistrat qui en est chargé, mais à la condition expresse qu'il puisse nier que sa décision résulterait d'une forme de collaboration, qui flirterait nécessairement avec la collégialité. La discussion des cas avec les collègues reste donc « *officieuse* », « *parce que je vais être seule à signer la décision, c'est pas ma collègue qui va la signer, on est des juges indépendants seuls responsables de nos décisions* ». « *Le code ne prévoit pas qu'on soit en collégialité* » (Y). La possibilité pour les protagonistes d'être affectés par les conséquences d'une telle discussion informelle entre collègues est comme réduite, ou tenue à distance, au moins lorsqu'il s'agit d'en rendre compte : « *les discussions individuelles sont plutôt utilisées par un magistrat... comme une manière d'exprimer ce qu'il pense, non pas véritablement dans un souci d'essayer d'intégrer le point de vue de l'autre, mais pour tester la validité de sa propre analyse* » (H).

380. **Le risque de se voir critiqué pour une forme dangereuse de collégialité est d'autant plus grand que la discussion a lieu avec les collègues du service.** Une magistrate note ainsi : « *je fais en fonction des éléments du dossier, de mon expérience, de... avant, moins maintenant, mais avant, des discussions que j'avais avec des collègues, à qui j'exposais la situation* », et elle ajoute que, maintenant, « *j'ai mon conjoint qui est magistrat aussi, donc j'ai plutôt tendance à discuter avec lui, quand on rédige, plutôt qu'ici... voilà. On a des discussions directement à la maison, quand on rédige chacun l'un à côté de l'autre, donc, c'est aussi pour ça que je discute moins avec mes collègues* ». Le conjoint n'est pas un collègue, et même si c'est un magistrat, la discussion reste dans un cadre privé, de sorte que le risque de remise en cause de la collégialité s'estompe.

381. **Un aspect plus formalisé de cet appui sur les collègues est lié au besoin et à l'émergence d'une 'jurisprudence de cour' qui font l'objet de discussions dans les réunions de service :** *« et on a quand même, on va dire une jurisprudence de chambre... On essaie quand même tous d'être à peu près de faire les mêmes choses, faire des jugements qui ont la même tête, côté formalisme. Ben, on a des réunions de service, de toute façon, régulièrement, et donc, quand on a des problèmes... une demande qu'on n'a jamais eue, qui est inédite, on en discute pour savoir quelle va être notre position, par rapport à ce genre de choses »* (E).

Ce besoin de jurisprudence se fera tout particulièrement sentir pour des cas où le texte de loi oriente les choses en ce qui concerne un critère de calcul, mais laisse néanmoins une grande marge de manœuvre aux juges dans l'appréciation de ce critère (voir un exemple plus bas dans le cas des prestations compensatoires).

382. Il faut noter que **la demande d'harmonisation peut venir de la cour elle-même**. Par exemple, sur la question de la durée de mariage seuil pour l'attribution de prestations compensatoires, il y a eu une réunion spécifique à la cour : *« Il y avait une réunion à la cour, justement et la Cour avait dit : "Mais bon, alors, c'est très bien, mais la durée de mariage, l'idée générale, c'est qu'en-dessous de cinq ans, on se pose pas trop de questions"... Et la cour était venue dire : "Maintenant, on pourrait peut-être envisager de passer à dix ans". Cela a généré des tensions. Bon, et là, il y a eu une sorte de petite bronca, qui tenait, non pas, spécifiquement, à la masse des magistrats, mais un certain nombre de personnalités, qui disent : "Ben non, ce n'est pas possible, c'est ceci, c'est cela", mais... »*. Ce genre de réunion et de message top-down n'arrive que rarement, mais cela ouvre sur des divergences possibles : *« Bon, mais il n'y a pas eu de discussion sur le principe lui-même, parce que y a pas eu d'accroche. Mais c'est la première fois que je voyais à la cour une réunion de ce type. Et cela laisse des traces, parce que la jurisprudence de tribunal ... qui était de dire : "En-dessous de cinq ans, y n'y a peut-être pas vraiment eu beaucoup de choix qui ont été faits, qui engagent", bon, elle a été un peu ébranlée, parce que quand la cour dit : "Ah ben nous, on se demande si en dessous de dix ans". Ce qui était une pure question, en tout cas, y a pas eu de démarche de jurisprudence de cour, mais y a eu des signaux »* (H).

§2 – Les listes de discussion

383. Il y a des listes de discussion, en particulier la liste JafNet, qui concerne tous les JAF et traite de sujets juridiques divers, et constitue à ce titre une ressource utilisée par l'ensemble des magistrats : « *Donc y a des questions diverses et variées, les tutelles, assignations en divorce... il y a plein de choses, plein de sujets, des espaces rencontre... voilà, des ordonnances de protection... Là, c'est la liste de tous les JAF de France. On peut aussi poser des questions là-dessus* » (T). Mais les échanges sont publics et écrits et donc l'usage de la liste tend à se focaliser sur les questions juridiques et procédurales (discuter des cas pourrait remettre en cause, et ce de manière publique, le critère d'indépendance du juge et du jugement). Cette magistrate déclare ainsi l'utiliser presque surtout pour des « *problèmes de procédure, pas les problèmes d'imperium du juge, non. C'est plus pour des problèmes de procédure, comment on interprète tel texte, comment on articule telle nouvelle procédure avec l'ancienne procédure, etc., c'est plus sur ça que je l'utilise* » (N). Même pour ces questions procédurales, les magistrats privilégient la discussion avec les collègues : « *Ça (la liste de discussion), c'est bien quand on est tout seul dans un tribunal, un pauvre JAF perdu, là, dans la cambrousse ; mais nous, on est plusieurs et on est proches* » (T). On se tournera vers la liste quand les collègues du couloir ne sont pas là (Y), ou pour un point de procédure très particulier et lorsque la discussion avec les collègues s'avère insuffisante.

Section 3 – La réunion de service et ses usages : la tension entre coordination et collaboration et autonomie et indépendance

384. La réunion de service est typiquement mensuelle. Elle vise à traiter les problèmes organisationnels et juridico-organisationnels (§1) mais il est difficile d'y discuter des cas (§2) malgré la tentative du vice-président en charge du pôle des affaires familiales de mettre en place à cette occasion des jeux de rôles (§3).

§1 – Traiter des problèmes organisationnels et juridico-organisationnels

Les premiers sujets traités (et, pourrait-on dire, le gros des sujets traités) concernent en général les problèmes organisationnels. Donc cela peut être des questions « purement » organisationnelles. Au moment de l'enquête, un des cabinets était spécialisé dans le traitement des dossiers hors divorce. Une magistrate ayant quitté le service pour prendre un autre poste, il

fallait se mettre d'accord sur la répartition de ses dossiers particuliers dans les autres cabinets, la jeune magistrate qui la remplaçait n'étant pas assez expérimentée pour traiter tout ce volume de cas. Mais ce sont aussi très souvent des questions d'articulation du juridique et de l'organisationnel, comme lorsque des changements dans les textes et les procédures ont des conséquences sur l'organisation du service.

Un exemple alors d'actualité était une réforme concernant le traitement financier des pensions alimentaires, qui articule de manière typique décisions juridiques, coordination organisationnelle, sous contrainte d'opérer à moyens constants : *« On a une nouvelle règle qui arrive, maintenant, avec l'intermédiation familiale... Avant, vous aviez une pension alimentaire à payer quand vous étiez le parent non-gardien. Ce parent non-gardien payait la pension alimentaire. Pour des cas de violences conjugales, pour éviter qu'en plus de la pension, madame reçoive un coup de couteau, on pouvait dire que le débiteur de la pension allait payer la CAF, et la CAF donnait l'argent à la mère, pour éviter toute rencontre »*. Ce qui n'était qu'une possibilité en cas d'ordonnance de protection est devenu la règle, et étendu à presque toutes les pensions alimentaires : *« Étape suivante, l'année dernière, sur impulsion présidentielle, les paiements de pension alimentaire sont devenus un élément prioritaire, et donc, une loi est passée en disant : à partir du 1^{er} mars, obligatoirement, le juge doit faire passer les paiements de pension alimentaire par la CAF, même si vous êtes dans les meilleurs termes avec votre ex, c'est la règle. Sauf si les deux parties sont d'accord, sauf si y a des risques de violences »*.

Mais déjà au départ, les juges (et les greffiers) étaient réticents, car cela demandait un temps supplémentaire de traitement : *« Sauf que tous les juges étaient réfractaires à ce système. Pas pour des questions d'éthique, mais parce que chaque fois que vous mettiez une pension alimentaire, il fallait rentrer ça dans un logiciel pour que ça aille à la CAF, pour que la CAF puisse avoir tous les éléments, et mettre en place cette intermédiation. Et chaque pension alimentaire, ça prenait minimum quinze ou vingt minutes de saisie pour un greffier. Ça veut dire qu'on était obligé d'avoir deux greffiers à plein temps, rien que pour rentrer les pensions. Donc les magistrats ont utilisé ça, mais très modérément »*. Donc maintenant il faut assurer ce surcroît de travail sans moyens supplémentaires, et comme toute modification des textes, cela demande des négociations et des coordinations pour traiter les dossiers en cours, et qui tombent dans une sorte d'entre-deux, entre le texte précédent et le nouveau texte : *« Bon, donc ça nous pose toute une série de problèmes, notamment parce que tous les jugements qui sont en délibéré, il faut qu'on statue sur ça, alors que les parties n'étaient pas encore avisées, n'ont pas pris de position »* (H).

385. Une autre configuration qui exige un travail de coordination susceptible de modifier la réunion de service, est celle où les textes nouveaux sont ambigus et les magistrats varient sur leur interprétation : « Là, passage 233, c'est : en matière de divorce accepté, les parties peuvent commencer par se faire la guerre, et puis après dire : "On est d'accord pour accepter le divorce". Mais la loi ne me paraît pas claire sur un certain nombre de points, et puis j'ai des juges qui varient un petit peu aussi, certains exigeant que le procès-verbal d'acceptation, soit signé par un avocat à l'occasion d'une réunion spécifique, ou bien avec deux actes séparés, faits par deux avocats qui ne se sont pas croisés. Donc bon, il faut qu'on tombe d'accord, hein » (H).

386. Un gros sujet au moment de l'enquête concernait la prise de dates pour les dossiers et les audiences, une réforme récente de la procédure permettant aux avocats de choisir leur date d'audience, et les juges craignant que du fait de cette licence, chaque magistrat ayant des jours d'audience déterminés, les avocats ne finissent par être en capacité de pouvoir « choisir leur juge ».

S2 – La difficulté à discuter des cas

387. D'un côté, le changement rapide des textes et l'enchaînement des réformes (qui augmentent l'incertitude sur les bons usages de la loi dans différentes situations concrètes), à quoi il faut ajouter les caractéristiques d'un contentieux pas complètement normé, qui laisse une place à l'appréciation subjective des magistrats, semblent propices à des discussions et des collaborations ordinaires de travail entre magistrats. De l'autre, ces discussions, qui existent, semblent toujours devoir obéir à une exigence de '*plausible deniability*' qui contraint et limite la collaboration : il faut qu'à tout moment le magistrat, qui a pu discuter d'un de ses cas avec un collègue, puisse se justifier de ce que cette discussion n'a pas empiété sur son *imperium*, et qu'en dépit de celle-ci, il a bien pris sa décision seul, en son âme et conscience

388. On retrouve cette tension sous d'autres formes dans la réunion de service. D'un côté, en fin de réunion, il arrive que certains discutent des cas qui leur posent problème. Déjà le fait que ce soit en fin de réunion, et selon ce qui reste de temps, montre bien que ce n'est pas un enjeu premier de la réunion de service. De l'autre, ces discussions restent travaillées par la même tension structurante. Ensuite, il y a, au niveau de la réunion de service, porté par la hiérarchie,

un souci d'harmoniser la décision au niveau de la chambre, qui pourrait lui aussi, s'il était mené à n'importe quel moment, empiéter sur l'*imperium* des magistrats.

389. Le vice-président en charge de la programmation et de la conduite de ces relations de service reconnaît bien cette tension. Il y a une grande autonomie du côté des juges, du fait que chaque décision leur appartient en propre, autonomie renforcée par le caractère parfois subjectif des questions de prestations compensatoires : « *Parce que mon rôle, est d'être coordinateur, et je me retrouve avec un système dans lequel chaque magistrat est maître de sa décision. Et, ce n'est pas un vain mot ; c'est-à-dire que les prestations compensatoires, ce n'est pas facile à déterminer, cela se rattache à des éléments qui sont assez subjectifs, et qui finalement, touchent, à mes yeux, c'est mon impression, véritablement, le pouvoir décisionnel... Le risque qu'il y a, c'est le subjectivisme absolu* ». Or le vice-président peut être interpellé par les avocats si un magistrat apparaît rendre des décisions trop spécifiques : « *parce que moi, je me retrouve avec, quand même, des avocats, ou des gens qui viennent dire : "Bon, ben... vous savez, tel juge... c'est plus ou moins..."... Bon, on n'est pas vraiment dans le même moule* ». Cette tension traverse donc les dimensions organisationnelles et managériales : « *en tout cas, chaque juge a le sentiment qu'il est attaché à sa liberté de décision ; moi, je n'ai aucun moyen de contraindre quiconque à quoi que ce soit, et mon rôle, c'est même, normalement, de préserver le... la liberté de chacun ; mais en même temps, c'est un petit peu paradoxal, il faut effectivement que j'arrive à essayer de rapprocher les uns et les autres* ».

La discussion collective (ou même la confrontation à d'autres opinions sous des formes variées) apparaît comme une ressource, mais ce vice-président la perçoit comme susceptible de menacer l'*imperium* des juges : « *la confrontation, à mes yeux, pour chaque magistrat, de ce que les autres ont pu ressentir, c'est d'une certaine manière, à la fois, une sorte d'ouverture, mais c'est également quelque chose qui porte un peu atteinte à soi, c'est-à-dire que... quand on est persuadé que c'est ça la bonne décision, que l'on voit d'autres personnes qui viennent dire, avec les mêmes éléments : "Je ne suis pas d'accord", ça introduit une notion de doute et de crainte* ».

Mais il est très rare que cette réunion prenne la forme d'une discussion portant sur un problème spécifique, à partir d'un cas : « *ce type de réunion, sur un problème spécifique, ça n'a jamais cours* ».

§3 – Les jeux de rôle

390. Lorsqu'il a pris ses fonctions cinq ans auparavant, le vice-président en charge du pôle des affaires familiales a essayé d'introduire un dispositif de discussion, une sorte de jeu de simulation, adapté à cette tension : *« on a fait ça deux, trois fois, hein, pour jouer à des petits jeux de rôle. n les jeux de société, des choses comme ça »*. Cela paraissait constituer une manière de discuter, de se confronter à d'autres opinions, sans porter atteinte à l'autonomie des juges : *« Donc il n'y a rien de mieux que de jouer à des jeux comme ça, pour voir que chacun a des fourchettes, et ça permet de réduire, un peu, les écarts qui peuvent exister »*.

391. Le jeu de rôles travaille sur la combinatoire des éléments constitutifs du dossier : *« Le petit jeu de rôles, ça consiste à mettre en vrac toute une série de paramètres, et que chacun dise : "Je m'attache plus ou moins à tel paramètre, tel paramètre, tel paramètre, et puis je tourne la marmite, et puis il en sort quelque chose". Et puis, tous ces multicritères, ça donne une vraie liberté au juge, ce qui veut dire que, suivant que on attache la sensibilité au nombre d'enfants, à la retraite, à la durée du mariage, on grossira ou on réduira les choses. Et, dans un petit tour de table, on arrive comme ça, à venir dire : "Ben voilà, y a ça, y a ça, y a ça, et je privilégie ça, parce que ceci ou cela". Donc c'est très facile à faire, on part d'éléments »*. Mais les éléments eux-mêmes, comme la durée de mariage à partir de laquelle on attribue des prestations compensatoires, peuvent poser des difficultés, c'est une donc une occasion de les discuter collectivement, et d'aller vers une certaine harmonisation : *« Par contre, quand on discute après, les problèmes dont vous parlez, ce sont des problèmes qui concernent les éléments eux-mêmes, et pas le panorama des éléments. Et là, quand on arrive, alors, sur des problèmes, sur certains éléments, là, effectivement, il nous est arrivé d'avoir des réunions pour venir dire : "Bon, ben voilà, alors vingt ans de mariage, oui, mais deux ans de vie commune, est-ce qu'on doit privilégier la durée du mariage ou bien la durée de la vie commune ?". Et là, on arrive à une sorte d'homogénéité »* (H).

392. Après cette période d'essai, basée sur des jeux de rôles, ce vice-président en est revenu à des discussions sur des cas en fin de réunion, lorsqu'il reste le temps, sur le mode d'un tour de table : *« Ben alors, on est tous bien élevés, on écoute tous... Ah c'est une sorte de tour de table... chacun dit : "Moi, c'est ça que je..."*. Chacun dira ce qu'il peut penser, et puis après, chacun votera tout ce qu'il veut, mais on est au même stade, on discute, ou quand on parle d'un dossier, la formule, c'est : *"Ah oui, ben moi, si j'étais à ta place, je ferais ça"* ». Cela signifie

que chacun donne son opinion, mais sans supposer que cela puisse affecter l'autre, ou sans chercher effectivement à argumenter : « *Chacun donne son opinion. Et on en reste là... mais on ne va pas en argumentant : "T'as pas vu, elle a jamais travaillé... elle est pas... etc."* » (H).

Chapitre 4 – La question des prestations compensatoires

393. Les prestations compensatoires ne concernent que les personnes qui ont été mariées. Cela constitue l'un des points parmi d'autres que les juges doivent traiter dans les décisions de divorce, à côté des questions de nom, de la situation des enfants, de révocation des intérêts matrimoniaux, de pension alimentaire, ainsi que de l'éventuelle demande de dommages et intérêts s'il y a un divorce pour faute, etc. « *Voilà, donc je dirais qu'en général, on a sept ou huit points au minimum à aborder, et la prestation compensatoire, c'est un point* » (Y). Cette question n'est pas présente dans tous les dossiers, elle ne concernerait qu'entre un tiers et une moitié des affaires, voire moins que cela pour un autre, de l'ordre d'une dizaine d'affaires par mois. D'un côté, cela tend à diminuer, pour des raisons que les magistrats rapportent à une évolution de la sociologie du couple et de la famille : « *Je pense que les gens n'ont plus la même conception du mariage qu'avant, les femmes sont plus indépendantes, travaillent... "C'est fini, ça ne colle plus entre nous, basta, et je ne vais pas demander de l'argent". Enfin, il y a une multitude de raisons, il faudrait demander aux gens, à des sociologues, d'étudier ça* » (T). De l'autre, c'est une question qui est d'autant plus importante dans les dossiers que les revenus et le patrimoine mis en jeu sont importants et ouvrent à des différences importantes entre les parties : « *Dans les gros dossiers avec des gens riches, c'est un point qui est très important* » (Y).

394. C'est une question qui diffère d'autres formes d'indemnisation traitées par la justice civile, pour différentes raisons. C'est une matière qui est encadrée juridiquement, mais qui, à l'instar de la procédure de divorce, est travaillée par des questions et des attentes humaines, au sens du quotidien et de l'ordinaire (voir la section suivante pour un exemple précis). Pour autant, il ne s'agit pas de réparer un préjudice d'ordre moral : « *Voilà, et la prestation compensatoire, elle n'est pas là pour le préjudice moral ; ça, c'est dans le cadre des dommages et intérêts* » (L).

De ce fait, c'est une matière moins technique, et qui fait moins appel à la jurisprudence antérieure : « *il y a quelques points juridiques qui posent question, mais après, comme je disais, c'est quand même très très humain, la matière qu'on a à trancher, les articles qu'on vise, c'est toujours les mêmes ; c'est beaucoup moins technique que ce que font les collègues de la chambre civile, par exemple. Donc l'appel à la jurisprudence, chez nous, est plus limité que... Nous, c'est très très factuel, ce qui va se passer, c'est : oui, monsieur s'occupe bien des enfants, y a untel et untel qui le disent, la maîtresse qui le dit...* » (Y). Ce point sur la relation à la

jurisprudence est important, car il conditionne les usages de l'outil d'aide à la décision, dans la mesure où cet usage se porte souvent sur des cas délicats, le logiciel étant alors utilisé pour trouver des cas relativement comparables, et met donc en jeu une forme de relation à une 'jurisprudence'.

395. Enfin il semble y avoir deux manières pour les décisions en matière de prestations compensatoires d'être contestées, l'appel et le procès en révision, qui est aussi une procédure écrite, si une partie démontre que, quand le juge a statué, des éléments cruciaux ont été cachés par l'autre partie. Mais c'est un cas très spécial : « *La révision, c'est très très particulier* » (N).

396. Il faut envisager leurs modalités de calcul (Section 1) avant de voir que leur détermination hybride des raisonnements juridiques et ordinaires (Section 2).

Section 1 – Le calcul des prestations compensatoires

397. Les prestations compensatoires, c'est essentiellement une affaire financière : « *ce qui concerne les prestations compensatoires... c'est une question de sous. De sous, et de justification de, justement, du sacrifice qui a été réalisé, et de ce qui crée la disparité, non seulement des revenus, mais surtout des conditions de vie. Donc là, le texte est quand même relativement clair. Voilà, donc si vous voulez, moi, ce qui m'importe, là, enfin voilà, je n'ai besoin de rien d'autre que des documents justificatifs, de l'évolution de la carrière de madame, des documents justificatifs des revenus et des charges de chacun, et de la situation qui sera créée par la rupture du mariage* » (N). Et donc, pour cette raison, ce qui compte, ce sont les pièces du dossier et les conclusions écrites. L'audience ou la rencontre avec les parties ne sont pas pertinentes, ou beaucoup moins : « *Après, sur les aspects financiers, pour moi, c'est moins important de les voir en direct. C'est vrai que sur ça, on statue plus sur pièces, et sur explications techniques des avocats* » (Y).

398. Les prestations compensatoires, cela constitue donc un des aspects de la procédure de divorce, où la connaissance 'vécue' du couple et de la vie familiale, ainsi que l'histoire de leur rupture, ne sont pas pertinentes : « *Le seul cas où l'on serait tenté de prendre en compte l'histoire du couple, c'est le divorce pour faute où le demandeur de prestation compensatoire, c'est le fautif. Autrement, l'histoire de la rupture n'a pas de conséquences sur la décision de prestation compensatoire* » (N). Comme on l'a vu dans la section précédente, cela ne veut pas

dire que des raisonnements, appréciations et attentes ordinaires n'entrent pas dans la décision de prestations compensatoires, mais que cela passe par un autre biais que le vécu du couple, et bien plutôt par les critères de pondération qu'il convient d'appliquer sur des questions comme par exemple l'importance de la durée de vie commune.

399. C'est sans doute pourquoi les magistrats du pôle des affaires familiales semblent considérer que les prestations compensatoires ne s'inscrivent pas dans le même type d'analyse que la pension alimentaire. Le calcul d'une pension alimentaire semble ainsi plus simple et plus cadré que celui des prestations compensatoires : *« la pension alimentaire, c'est entre guillemets plus simple ; c'est-à-dire qu'on va regarder quels sont les revenus et les charges de chacune des parties à un instant T, donc c'est vraiment plus à un instant T, on va apprécier quels sont les besoins des enfants, si y a des besoins spécifiques en regard de leur âge, de leur scolarité, de leurs activités, d'un éventuel handicap, etc., et on fait une pondération de tout ça, pour arriver à un montant mensuel »* (Y). C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut s'appuyer très directement sur un barème pour calculer des contributions : *« Vous connaissez la grille de calcul, vous vous êtes penché là-dessus ? Bon, l'État a conçu un truc, moi, que j'utilise, hein. Parce que là, ça donne une idée, c'est simple. C'est un barème... L'idée, elle est intelligente. Vous avez des économistes qui se sont penchés sur la question, et qui ont dit qu'au fond, ce qui compte, ce sont les revenus du débiteur peu importe combien gagne celui à qui on va verser la pension alimentaire, c'est statistiquement, et toute personne, quand vous avez un enfant, vous consacrez... Si vous avez un seul enfant, et que vous le recevez de temps en temps chez vous, de manière classique, vous consacrez 13,5 % de votre budget pour l'enfant. Si vous avez deux enfants, ben pour chacun des enfants, vous dépensez 11,5. Ce qui veut dire que pour les deux enfants, ça vous fait 23 % de votre budget, disponible, après avoir déduit le minimum vital, 550. Voilà votre faculté contributive »* (T).

400. Il apparaît donc qu'une des raisons de la relative simplicité du calcul des pensions alimentaires tient au fait qu'elle repose sur une photographie instantanée de la situation administrative et économique de la famille. Outre le fait qu'il vise des objectifs différents, ce n'est pas le cas pour le calcul des prestations compensatoires : *« la prestation compensatoire, c'est plus subtil ; elle est là pour compenser une disparité dans les conditions de vie des époux, qui survient du fait de la rupture du mariage. Et donc, **il faut qu'on ait une image globale de ce qui s'est passé pendant le mariage**, des choix que les époux ont pu faire ensemble, et qui a une incidence sur leur situation au moment du divorce »* (Y).

Le site des éditions Dalloz donne ainsi une liste des critères généralement pris en compte par les juges⁵⁵⁹ :

- la durée du mariage ;
- l'âge et l'état de santé des époux ;
- leur qualification et leur situation professionnelles ;
- les conséquences des choix professionnels faits par l'un des époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants et du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne ;
- le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu'en revenu, après la liquidation du régime matrimonial ;
- leurs droits existants et prévisibles ;
- leur situation respective en matière de pensions de retraite en ayant estimé, autant qu'il est possible, la diminution des droits à retraite qui aura pu être causée, pour l'époux créancier de la prestation compensatoire, par les sacrifices professionnels qu'il aurait faits afin de favoriser la carrière de son conjoint ou pour se consacrer à l'éducation des enfants.

Afin de pouvoir déterminer le droit à prestation compensatoire, il convient donc d'établir :

- un audit patrimonial de la situation [...] consistant à déterminer le montant des revenus et du patrimoine estimé ou prévisible de chacun des époux afin d'estimer si une disparité existe entre eux ;
- un audit compensatoire de la situation [...] correspondant à l'évaluation des critères posés par l'article 271 du Code civil, autre que les critères financiers et patrimoniaux.

401. Dans la pratique, certains de ces critères vont être considérés comme objectifs : « *Alors après, les éléments objectifs, ça va être les déclarations de revenus, les fiches de paie. Des fois, vous avez quarante pièces, mais si vous avez tout qui date d'il y a cinq ans, ça ne vous aide pas beaucoup, il faut des éléments récents... Les enfants, est-ce que les enfants sont encore à charge, pas encore à charge, combien il va falloir encore déboursier pour pouvoir les entretenir. Ça va être quel est le patrimoine des parties, le patrimoine commun, est-ce que, au vu du patrimoine commun, y aura beaucoup d'argent à partager, pas beaucoup d'argent à partager ? Donc ça, ce sont déjà les éléments objectifs* » (L). Il y a d'autres éléments objectifs, mais qui engagent une épaisseur biographique, et qui commencent déjà à demander une forme

⁵⁵⁹ <https://www.boutique-dalloz.fr/prestation-compensatoire-fc>

d'appréciation, comme les droits à la retraite : « *Après, les éléments qu'on n'a pas toujours, mais qui sont objectifs, ça va être les droits à la retraite... Quand ils ont 30 ans, les droits à la retraite, ça paraît un peu compliqué de les prendre en compte, parce que les années de cotisation vont encore être longues. Si vous avez des gens qui arrivent très proches de la retraite, ben là, ça va commencer à être des éléments objectifs, parce que vous vous dites : ben peut-être que dans les huit, dix ans, ça y est, ils sont en retraite, et le montant des revenus ne va pas beaucoup évoluer* » (L). Et puis, il y a des éléments pertinents, comme la santé, mais qui sont plus difficiles à objectiver : « *Après, vous avez certains qui ont des problèmes de santé ; donc là, ça devient quelque chose de plus subjectif, c'est-à-dire que : est-ce qu'il va démontrer des difficultés de santé ? Il va falloir les démontrer. Et la difficulté de santé, elle ne fait pas tout en elle-même, c'est une difficulté de santé qui va faire que sa capacité de travail et de percevoir des revenus va être limitée. Parce qu'en fait, au final, ce n'est toujours qu'une question d'argent* » (L).

402. À rebours de ce qui se passe pour les pensions alimentaires, le calcul des prestations compensatoires doit, tout en s'appuyant sur des éléments objectifs ou suffisamment objectivés, appréhender l'histoire du couple et de la famille à la fois globale et sur la durée, pour non seulement calculer une contribution, mais aussi le laps de temps durant lequel elle sera pertinente : « *Pour les prestations compensatoires, je vais dire : "Il y a une disparité, quelle est la capacité, on va dire du mari pour simplifier, de compenser cette disparité compte tenu de ses ressources et de son patrimoine". Et je vais, en fait, intuitivement, appliquer une sorte de pourcentage. Je vais dire : "Eh ben, il va consacrer, sur son patrimoine ou sur ses revenus", il va consacrer X% de ça, à compenser cette disparité, **pendant un temps qui me paraît raisonnable*** » (T). Comme on le verra dans la section suivante, cette durée relève de l'appréciation du juge et n'est pas fixée seulement sur des critères juridiques.

403. Certes il convient de partir des textes, qui définissent les critères pertinents pour le calcul des prestations compensatoires : « *Il y a tout d'abord le texte, qui indique les critères légaux sur lesquels fonder la décision... Cela permet de construire une idée du tableau familial et de la construction familiale, ce qui explique pourquoi, au moment du divorce, on arrive à une situation financière à l'instant T, de madame qui a tant, et de monsieur qui a tant, et leur patrimoine qu'ils ont pu constituer, ou de leurs dettes qu'ils ont constituées, parce que parfois, on arrive avec des passifs* » (Y). Mais cela ne suffit pas à déterminer le calcul. Celui-ci n'est pas mécanique, ne relève pas d'un barème, mais toujours d'une appréciation : « *Donc c'est*

l'appréciation... Moi, je ne suis pas une mathématicienne, je ne suis pas là à faire des calculs... Je n'ai pas un tableau Excel que je remplis » (Y). Il s'agit d'apprécier la manière de prendre en compte les critères généraux que fournit le code sur un cas donné : *« nous, ce à quoi on est tenu et qu'on apprécie, littéralement, ce sont les critères du code »* (Y). Le code n'est qu'un cadre, et il faut mettre en œuvre des modes de raisonnement qui ne relèvent pas du pur calcul, mais d'une sorte de sagesse pratique, une 'métis', basée sur l'expérience : *« Donc il y a ça, et l'expérience, et puis un petit peu... Ce n'est pas une science exacte, hein, c'est bien le problème aussi de tout le monde, et des avocats, de... peu importe... On ne sait pas, en fonction des tribunaux, on ne sait pas combien on va avoir... »* (L). C'est pourquoi il existe une variabilité potentielle des décisions.

404. Il y a bien des outils et des méthodes pour calculer les montants des prestations compensatoires, comme la « méthode Saint-Léon »⁵⁶⁰, mais ceux-ci aussi, forcément, relèvent d'un certain arbitraire dans l'appréciation : *« Donc il y a plusieurs méthodes de calcul, il y a la méthode dite Saint Léon, y a la méthode... Où justement, sur tous les critères qu'on a indiqués là, il y a un coefficient qui est appliqué. Voilà, ce qui n'est pas idiot, bon, mais pourquoi on va accorder plus d'importance à la durée du mariage que à l'âge des époux, et tout ça, comment tout ça a été calculé, pourquoi, personne n'en sait rien. Il y a un magistrat, un ancien JAF, qui, y a quinze, vingt ans, a réfléchi à la question, il avait un pote qui était économiste, ils se sont mis autour d'une table, et ils ont dit : "On va essayer de définir des critères, intelligents, de pondérer chaque critère, là, prévu par la loi, et qu'est-ce qui paraît intéressant, justement, la durée de la vie commune, je la pondère à combien par rapport au reste ?". Voilà. Et ils ont dit : "Ben voilà, nous... Voilà, ma méthode, c'est ça" »* (T). Et le même juge de poursuivre en déclarant qu'il ne suit pas les prescriptions de ces outils, qui au fond ne constituent que des appuis et des guidages souples pour l'appréciation du cas par les juges, bien loin de la prescription des barèmes pour des calculs plus 'mécaniques' comme les pensions alimentaires ici, au pôle des affaires familiales, ou celui des indemnités pour préjudices corporels à la chambre civile.

Le problème, c'est que certaines données objectives, bien que pertinentes, ne sont pas prises en compte par les outils de calcul papiers ou logiciels : *« (parlant d'un cas) Si vous voulez, pour moi, ce qui est déterminant, c'est essentiellement la perte des droits à retraite. C'est-à-dire, la femme, la plupart du temps, a travaillé à 80 %, et elle, de ce fait, ses droits à retraite vont être*

⁵⁶⁰ C'est celle qui a le plus été mentionnée par les juges, mais ceux-ci ont aussi évoqué un outil produit par Dalloz, ainsi que le logiciel PilotePC, mais toujours d'une manière qui dénotait un rapport assez lâche à leur usage.

plus faibles que ce qu'ils auraient été si jamais elle avait travaillé à 100 % et que le mari avait contribué autant à... Voilà, pour moi, c'est ça le critère essentiel. Mais, le problème, c'est qu'aucun de ces outils ne me dit quelle est la perte des droits à retraite de l'épouse » (T). Les spécificités du système français font d'ailleurs que, à la différence de pays limitrophes, ce genre de données est quasiment impossible à obtenir, et difficile à recalculer ou estimer pour le juge, même à la main : « Dans le système suisse ou allemand, le conjoint peut demander au moment où il liquide sa retraite, à bénéficier de la moitié des droits à retraite de l'autre conjoint. Ce qui n'est pas mal du tout, ce qui est très intelligent à mon avis. En France, c'est pas le cas. Mais la femme, moi, je ne sais pas comment tout ça fonctionne, hein, j'ai essayé de me renseigner, mais c'est impossible. Quand vous avez des enfants, on vous donne des trimestres. Et puis y a des compensations. Donc je ne sais absolument pas » (T).

405. Cela signifie également que ces logiciels ne peuvent être un simple outil, dans la mesure où la décision sur les prestations compensatoires ne peut être réduite à un pur calcul. Il faudrait pour les juges des formations, et pouvoir rentrer dans la cuisine des logiciels : « Si vous voulez, pour moi, ce qui est important, c'est qu'on reçoive une formation là-dessus ; qu'on essaie de définir collectivement, c'est ce qu'ont essayé les méthodes Saint Léon et machin, de pondérer comme ci, comme ça. Mais à partir du moment où on vous balance un truc, sans vous dire le sens, la signification, le pourquoi, le comment, comment on a raisonné, on n'est qu'une machine à appliquer bêtement un chiffre qui sort d'on ne sait où. Et donc, la perte pour la femme de ses droits à retraite, je l'ignore complètement, et tout le monde l'ignore. Donc on est dans le flou » (T).

Section 2 – Les prestations compensatoires et l'hybridation des raisonnements juridiques et des raisonnements ordinaires

406. Les patrimoines importants ne font pas que complexifier le dossier. Ils renvoient aussi à un style de vie et des attentes normatives qui ne relèvent plus de l'expérience ordinaire (entendue ici comme celle des juges) : « Souvent, ça va être sur des gros patrimoines, où à un moment donné, on perd un peu le fil de la notion courante d'un train de vie, de ce genre de choses, quand vous avez des fois des demandes de prestation compensatoire à plus de 500 000 €, un million d'euros, là, on perd un petit peu la... On ne rentre plus dans des critères normaux de la vie de tous les jours, qu'on peut intégrer, en fait » (E). On notera ici comment les raisonnements sur les prestations compensatoires mobilisent à la fois des raisonnements

ordinaires et des raisonnements juridiques, mais également comment les attentes et l'expérience quotidienne des juges deviennent ici un étalon de ces attentes ordinaires d'équité et de justice.

407. Dans un autre cas, en fonction des données financières disponibles un magistrat doit estimer une prestation compensatoire pour un couple ayant trente ans de vie commune. Dans son calcul, il estime un montant annuel en fonction des différentiels de revue et de patrimoine, du niveau de vie, etc., et il se pose ensuite la question de pondérer en fonction de la durée de la vie commune. Sa tentation est de multiplier par quinze (ce qui revient à utiliser pour critère de pondération la moitié de la vie commune) : « *Alors, pourquoi moitié de la durée de la vie commune, c'est que c'est une idée qui avait circulé, à un moment, chez les JAF, chez les avocats. Puisque la loi prévoit que c'est fonction de la durée de la vie commune, ben, on peut dire, pourquoi pas la moitié ? ... Il n'y a aucune raison, hein ? Il n'y a aucune raison, mais c'est comme les 3 % de déficit, qui a été calculé sur un coin de table, il n'y a pas de raison* » (T). Le problème auquel se retrouve confronté le magistrat, c'est que la loi demande de pondérer selon la durée de la vie commune, mais que les textes ne fixent pas cette pondération.

408. La tentation pourrait être de multiplier tout simplement par la durée de la vie commune, mais cela semble pour ce magistrat contre son idée de l'esprit des lois sur le divorce : « *C'est, intuitivement, on se dit... vous avez vécu trente ans avec cette dame, et... vous allez devoir payer encore pendant trente ans. Et, dans la volonté du législateur, il y a l'idée quand même que, à un moment donné, eh bien si y a rupture, il y a rupture, chacun va de son côté, et il ne faut pas maintenir ce lien indéfiniment. Et donc, si on dit trente ans, on sent qu'on maintient un lien artificiellement pendant trop longtemps* ». Mais la question reste entière de trouver un critère de pondération adéquat : « *vous avez des critères légaux, comment on les pondère, voyez ?* » (T). Cela introduit à nouveau des appréciations extra-juridiques des dossiers, et une variabilité potentielle de la décision, non seulement d'un juge à un autre, mais pour le même juge : « *Le problème, c'est que tout le monde fait ça au pif. Et c'est très aléatoire. Et c'est-à-dire que, ce dossier-là, je le juge le lundi, je vais mettre 28 000 €. Je le juge le mardi, je me suis réveillé du pied droit au lieu de me réveiller du pied gauche, je vais mettre 15 000 €* » (T).

409. Cette variabilité pour le même juge semble toutefois rester une possibilité hypothétique. C'est en effet pour régler ce genre d'arbitrage que peut émerger une jurisprudence de cour qui s'appuie sur les ressources offertes par l'organisation d'un même ressort (proximité des magistrats, réunions de service). Par exemple, toujours sur cette question des pondérations selon

la durée de la vie commune, il se pose la question d'un seuil minimal de vie commune, en dessous duquel les personnes n'auraient pas droit à des prestations compensatoires, parce que leurs vies et leurs trajectoires professionnelles et économiques n'auraient pas été affectées par une vie commune trop courte. Ce seuil renvoie à nouveau à une forme d'arbitraire possible, et donc de variations, en particulier d'un ressort à l'autre : *« par exemple, ici, la cour d'appel de X (autre juridiction proche) nous a dit, à une réunion, là, y a deux, trois ans : "Nous, en dessous de dix ans de mariage, on considère qu'en équité, il n'y a, sauf exception, pas lieu à prestation compensatoire. On estime que les gens n'ont pas été mariés suffisamment longtemps pour que ça ait du sens". On a découvert ça »* (T). On voit ici, d'une part, comment, sur des questions de ce genre, émergent des 'jurisprudences de cour' et, d'autre part, comment les magistrats peuvent ignorer ces variations (c'est d'ailleurs un des enjeux des applications judiciaires basées sur le *big data* de rendre visibles de telles variations des décisions judiciaires).

410. D'autant qu'en plus, ces jurisprudences évoluent dans le temps, tout simplement parce que les personnes changent : *« C'est la cour de X, à un moment donné de son histoire. Le président, il disait, il faut, en équité..., il faut que tout le monde fasse à peu près la même chose. On regarde ce que fait la cour d'appel de X, qui elle-même va regarder ce que font d'autres cours, etc... Oui, d'accord, je vais regarder ce que la cour d'appel de X a jugé y a trois ans, ou quatre ans, quand elle était présidée par untel, qui considérerait que... ou que la formation, à cette époque-là, collégialement, ils étaient d'accord pour dire : "En dessous de dix ans, on ne donne pas de prestation compensatoire, sauf exception". Puis, ... vous tombez sur une autre collégialité, qui va dire : "Ben non, moi... je trouve qu'il n'y a pas de raison, ... et je vais mettre la barre à cinq ans". Et voyez, il y a un décalage dans le temps. Donc moi, si je me fie sur un truc d'y a trois ans ou quatre ans, bon, je vais rendre ma décision maintenant, et les gens vont faire appel, ils vont tomber sur une autre formation, qui va avoir une appréciation différente »* (T).

En tout cas, du côté de la jurisprudence de cour actuelle dans ce tribunal, en ce qui concerne le seuil de prise en compte de la durée de vie commune pour les prestations compensatoires, on penche plutôt pour cinq ans, après discussion au sein du service : *« quand on a discuté entre nous, l'ensemble des collègues de première instance, on trouvait que c'est intéressant de savoir que la cour de (autre juridiction proche) juge ça, mais... que mettre la barre à dix ans, c'est quand même beaucoup. On était tous plutôt du côté de cinq ans, quoi ; c'est-à-dire, en dessous*

de cinq ans de durée de mariage, bon ben voilà, ça va bien, quoi » (T). C'est une nouvelle instance du « tout le monde bricole » (T).

Chapitre 5 – Les usages de l’outil JurisData Analytics

411. Il apparaît que la distribution des usages est assez typique pour ce genre d’expérimentation (Section 1) et qu’il existe quelques freins à l’usage pour la question des prestations compensatoires (Section 2).

Section 1 – Une distribution des usages assez typique pour ce genre d’expérimentation

412. Les six magistrats qui participaient à cette expérimentation d’usages reflètent bien l’ensemble des enjeux et des difficultés inhérents à ce genre d’approche expérimentale auprès des magistrats. En effet, d’un côté les magistrats manifestent une relative bienveillance vis-à-vis du processus, qui de plus était soutenu par la présidence, mais ils sont indépendants et se vivent comme tels, et sont soumis à la pression des flux de dossiers, comme on l’a vu plus haut. Les usages observés sur deux à trois mois sont tendus par ces deux orientations opérant en sens contraire.

413. Plus précisément, les usages de l’outil ont été limités par le temps disponible pour les magistrats.

- Deux magistrates ne l’ont pas utilisé, faute de temps, l’une d’entre elles se justifiant au titre de ce qu’on « *ne peut pas se permettre de perdre plus de dix minutes par affaire* ».
- Une autre l’a utilisé trois ou quatre fois, avant d’être ralentie par un problème de connexion, qui a fini par être résolu avec l’assistance technique de LexisNexis.
- Un autre a délégué en partie l’usage du dispositif à un stagiaire, étudiant en master avec une spécialité numérique, à qui il a demandé une exploration autour de deux cas délicats pour gagner du temps, et un rapport.
- Une autre, parce que son cabinet est particulier et fait beaucoup de hors divorce, n’a eu pour la période que six dossiers avec demandes de prestations compensatoires, et pour trois d’entre eux les parties étaient d’accord entre elles. Dans ce cas, elle s’est quand même efforcée de faire tourner le logiciel pour voir ce que cela donnait, même si ce n’était pas forcément des cas qui le justifiait. C’est aussi un problème récurrent de ce type d’expérimentation que, suivant l’organisation des services, certains des participants n’ont sur deux ou trois mois que peu de dossiers qui correspondent au spectre d’application du logiciel.
- Enfin, deux magistrates l’ont utilisé un peu plus pour une dizaine d’affaires environ.

In fine, on observe donc un spectre d'usage assez typique pour ce genre de configuration expérimentale, assez similaire avec ce qui avait pu être observé lors d'une précédente recherche à la chambre civile, pour une expérimentation de JurisData Analytics portant sur les affaires de dommages pour préjudice corporel.

414. En ce qui concerne le type de cas sur lesquels ont porté ces usages, on peut distinguer deux grandes configurations d'usage. Dans la première, les magistrats visent une confirmation par le logiciel, qui est donc mis en œuvre après qu'ils ont étudié le dossier et sont déjà arrivés à une décision plus ou moins finalisée. C'est d'ailleurs ce type d'usage qu'envisagent souvent les non-utilisateurs. Pour une magistrate qui a traité trois cas, et qui s'inscrit bien dans cette perspective des usages confirmatifs (*« j'avais tendance à déjà décider, et après je regardais pour voir si j'étais dedans ou pas, je n'ai jamais regardé avant le dossier, avant de rédiger »* (L)), elle s'est retrouvée confrontée à deux cas où les recherches menées avec le logiciel sur des cas similaires ont conforté sa décision, et un où elle n'a pas trouvé de cas similaire ce qui est assez typique.

415. **Le second cas d'usage, qui est le plus fréquent, est aussi celui pour lequel les magistrats s'attendent à trouver une utilité à ce type de logiciel et concerne les affaires assez complexes et singulières** de sorte que les juges ont du mal à les formaliser et ne peuvent pas vraiment s'appuyer sur une expérience antérieure ou sur l'intuition ordinaire : *« En fait, je pense que je l'utiliserais dans des cas vraiment importants, compliqués, pour conforter une décision. C'est-à-dire que je pense que dans... la grosse majorité des cas, j'aurais pas besoin de l'utiliser, mais par contre, sur un cas particulier, d'une décision, justement, qui sort un peu de l'ordinaire, où... Souvent, ça va être sur des gros patrimoines, où à un moment donné, on perd un peu le fil de la notion courante d'un train de vie, de ce genre de choses, quand vous avez des fois des demandes de prestation compensatoire à plus de 500 000 €, un million d'euros, là, ... on ne rentre plus dans des critères normaux de la vie de tous les jours, qu'on peut intégrer, en fait »* (T). Une autre magistrate évoque aussi comme cas complexe où le logiciel pourrait être utilisé, outre les grandes disparités de revenus, le cas des 'conjoints collaborateurs', qui complexifie le lien biographique entre les parties. C'est aussi parce que ces cas sont un peu déstabilisants que les magistrats peuvent être plus enclins à utiliser le logiciel comme ressource, sans garantie de trouver des cas similaires pour les dossiers vraiment atypiques : *« Donc madame, donc ils étaient en séparation de biens, madame me demandait à l'origine une*

prestation de quatre millions cinq cent mille euros... ça me faisait un peu peur, quatre millions cinq cent mille, je me suis dit : faut pas que je me plante, ma vieille, donc j'avais effectivement déjà regardé si il y avait des cas similaires. Il y avait des grosses sommes, effectivement, oui, qui ne ressemblaient pas à mon cas, en séparation de biens... mais (après) de toute façon, j'avais plus à trancher, puisqu'ils ont trouvé un accord, du coup, ça tombait bien » (E).

416. **C'est beaucoup moins utile pour le tout-venant**, lorsque l'on « *est capable d'avoir, comme vous disiez, une jurisprudence, ou de se souvenir de situations similaires, ou des choses qu'on peut appréhender ; quelquefois, on a quand même des cas vraiment très particuliers, qui sortent complètement de l'ordinaire, et là, je pense que oui, ça peut aider d'avoir accès à des décisions autres que celles, juste, de la juridiction* ». Comme le résume une magistrate, « *le cas simple, je n'ai pas besoin de la machine* ».

417. **Pour les cas complexes, l'idée d'un usage purement confirmatif, après décision, apparaît moins nettement**, puisque plus le cas est singulier et le juge décontenancé, plus le logiciel va être utilisé pour trouver des cas similaires, en amont de la rédaction d'une décision, ou de manière concomitante à celle-ci. Dans ce cas, si l'usage du logiciel confirme quelque chose, c'est plus un mélange de raisonnements juridiques et d'intuitions ordinaires sur l'économie domestique, comme dans l'exemple suivant, où c'est une question de pension alimentaire qui alerte la juge : « *Et j'ai eu un dossier avec (X). Voilà. Donc j'ai eu à statuer pour cet homme-là, qui a un enfant qui a 3 ans. Et, effectivement, dans ce dossier-là, le papa, X, il versait plus de 3 000 € de pension alimentaire pour une enfant de 11 ans, ce qui m'avait paru aberrant. Énorme. Puisque cette enfant, je ne sais plus, je crois qu'elle ne faisait rien d'onéreux, elle n'avait pas de besoins particuliers, donc je me suis dit : si à 11 ans, elle reçoit 3 000 € tous les mois, qu'est-ce que ça va être quand elle sera étudiante... Bon, d'accord, le type, il gagne bonbon, mais à un moment, il faut quand même rester un peu rationnel, et j'étais persuadée qu'en fait, la maman utilisait cet argent pour elle* » (E). C'est donc pour confirmer cette appréciation de la situation que la juge utilise le logiciel : « *Donc, mais quand même, j'ai regardé, et évidemment, il n'y avait aucun arrêt, où y avait un cas similaire* », en fait parce que les revenus du père étaient trop importants.

418. Néanmoins, malgré leur différence, les cas qui remontent restent instructifs, précisément pour valider cette intuition ordinaire concernant ce que sont les besoins raisonnables pour un enfant : « *la plus haute pension que j'ai trouvée, c'était 1 500 euros par mois, donc c'était*

encore loin des 3 300 qu'il versait. Mais ça m'a donné une idée quand même.... Il y avait des frais pour les enfants, des enfants qui faisaient de l'équitation, des loisirs onéreux, ou des cours de piano, voilà, qui justifiaient. Mais là, ma petite fille de X, elle ne faisait rien de particulier. Donc ça m'a aussi guidée, de dire : ah ben, celui-là, oui, il donne 1 500 €, mais l'enfant fait... je sais plus ce qu'elle faisait, enfin bref. Voilà, y avait des choses concrètes, et... du coup, ça m'a quand même confortée dans mon idée, que M. X, il donne trop de sous... j'ai baissé, oui, j'ai baissé de beaucoup. Et pour l'instant, la madame n'a pas fait appel » (E).

419. En définitive, ce n'est effectivement que sur les cas les plus complexes et les plus singuliers que le temps passé sur le logiciel se justifie, pour trois raisons. D'abord, cela prend du temps de trouver des cas pertinents, et ce d'autant plus que le cas est singulier. Ensuite, on ne trouve que très rarement des cas vraiment similaires. Enfin, il faut lire le jugement dans le détail (et pas seulement le résumé) pour savoir en quoi il peut apporter quelque chose : « *Je pense que cet outil-là est intéressant pour une sorte de méta-analyse intellectuelle... pour étudier ça, ce que ça donne, faudrait recouper ça avec tout un tas de trucs. Mais c'est beaucoup de temps, beaucoup de recherches... Il faut voir les arrêts qui sortent. Pour arriver à voir si ça correspond à votre cas... Il faut passer au moins une demi-heure... Lire un arrêt, pour voir ce qu'il y a dedans, c'est très long. Vous avez le résumé : il gagne tant, etc., mais pour vous imprégner de la situation exacte, dans quelle mesure ces critères... Parce que la personne qui a rentré tous ces critères-là, c'est ce qui figure dans l'arrêt, mais quel est le critère qui a été déterminant pour la cour d'appel, on n'en sait rien, et donc... si je trouve un précédent, il faut que je me plonge dedans, que je compare avec un autre... les situations sont beaucoup trop spécifiques » (T).*

Section 2 – Quelques freins à l'usage de l'outil JurisData Analytics pour les décisions concernant les prestations compensatoires

420. Une variété de facteurs limite l'intérêt de recourir à l'outil dans une démarche d'aide à la décision en matière de prestations compensatoires. Les premiers sont d'ordre pratique, et relèvent de la difficulté à trouver des cas similaires. En particulier, dès qu'on rentre trop de critères, on ne trouve plus rien : « *donc après, on ne peut pas rentrer beaucoup de critères, parce que plus on rentre de critères, et moins on a de décisions, et c'était plus pertinent. Donc je crois que j'ai rentré les critères des revenus de monsieur, revenus de madame, le nombre d'enfants, les années de mariage, je crois que c'est à peu près tout, parce que, alors, je fais de*

mémoire, mais il me semble que si je rajoutais d'autres critères, j'avais plus assez de décisions ». Il y a donc un équilibre délicat à trouver entre rentrer assez de critères pour capturer la singularité et la complexité d'un cas, et avoir un nombre raisonnable (ni nul, ni trop élevé) de décisions suffisamment similaires : *« j'avais des situations similaires, mais qui étaient quand même un peu éloignées, mais si je rajoutais un critère plus de cas »* (L). Le jeu en vaut néanmoins la chandelle : *« il y en a un où j'ai trouvé un cas similaire, et à ce moment-là, quand y a un cas similaire, ben à ce moment-là, il y a un vrai intérêt à aller voir la décision, de qu'est-ce qui a été décidé, quels sont les arguments qui ont été pris en compte »* (L).

421. **La difficulté de cet art de la recherche de cas similaires dans de grandes bases de données renvoie à l'organisation de l'outil.** Dans ce cas d'espèce, le nombre de cas intégrés dans la base de données paraît un peu juste : *« mais après, c'est le problème de la base de données, hein, qui s'arrête à un certain... Il y a 10 000 décisions, dedans, donc elle n'est pas non plus énorme, la base de données »* (L). La fraîcheur des données, point qui renvoie à l'alimentation et la mise à jour régulières de la base, constitue aussi un facteur qui peut limiter l'obtention de cas similaire, du fait des évolutions observables des dossiers, et qui renvoient à des transformations d'ordre historique dans la sociologie de la famille : *« et il faudrait des décisions récentes, aussi. Parce que la vie des gens, elle évolue. Les gens, je trouve, ils vivent de plus en plus à crédit ; ça, je le vois clairement. De plus en plus d'enfants de papas différents. C'est aussi à la mode. Et là, les dernières décisions, je crois que c'est 2016, ou je ne sais plus quand, oui, parce que y a ce fameux délai, où l'on ne peut pas publier. Voilà, et donc il faudrait un peu qu'ils se remettent quand même à la page, pour qu'on ait des choses plus récentes »* (N).

422. Du côté des magistrats, cela suppose aussi une certaine **habileté pour mener ce type de recherche multicritères**. Prenons par exemple un cas que le juge résume ainsi (relisant le document qu'il a rédigé) et pour lequel il a fait une recherche : *« Je vais vous montrer. Alors, situation matérielle des époux... N'a quasiment pour toute ressource que des allocations de prestations familiales et sociales... alors, j'ai mentionné : "Elle avait cessé toute activité professionnelle à la naissance de son premier enfant". Lui, il travaille en Allemagne, salaire de l'ordre de 3 000 €, mais avec des frais réels importants, il a fait l'objet d'un licenciement pour motif économique, il perçoit désormais de Pôle emploi une allocation d'aide au retour à l'emploi de 1 675 €. Voilà, donc on se retrouve avec quelqu'un, qui pendant des années a gagné 3 000 €, et puis l'avant-veille du jugement, hop, il est au chômage. Qu'est-ce qu'on fait avec*

ça ? Ben autant vous dire que les arrêts de cour d'appel ne... C'est impossible de répondre à ça sur un... Voilà. Et des situations comme celle-là, c'est à chaque fois comme ça. C'est-à-dire, c'est des situations qui sont, à chaque fois, très spécifiques, très particulières, et arriver à trouver un cas identique, sauf à y passer un temps fou » (T). Ce qui rend le cas singulier, c'est ici un changement de situation professionnelle juste avant le jugement, et cela va mettre en jeu une certaine habileté dans la recherche de cas, pour trouver non pas un cas similaire, mais plusieurs cas qui éclairent chacun sous un certain angle cette situation atypique : « *qu'est-ce que je vais rentrer comme éléments sur les ressources de monsieur ? Pour avoir une idée, est-ce que je vais rentrer les 1 600 qu'il gagne actuellement ? Est-ce que je vais rentrer les 3 000 €, qui étaient ses revenus habituels ? Hein, qu'est-ce que je vais rentrer comme critères ? Et donc, pour bien faire, ben faudrait dire : "Tiens, je vais regarder quand quelqu'un gagne 3 000 et que l'autre ne gagne rien, qu'est-ce que ça donne ? Et s'il gagne que 1 675, qu'est-ce que ça donne ?". Et puis j'aurai une idée, comme ça. Et puis je verrai ce que je fais, est-ce que je vais taper entre les deux, est-ce que... Voilà, mais tout ça, c'est du temps, pour arriver à ça* » (T).

423. Non seulement la mise en œuvre d'une telle habileté dans la recherche de cas prend du temps, mais on n'a aucune garantie au départ que les cas qui vont remonter seront pertinents, au-delà d'une similarité apparente des critères. On retrouve ici le fait, assez spécifique à ce genre de dossiers (ce ne serait par exemple pas du tout le cas à la chambre civile sur les dossiers de dommages et intérêts) que les cas ne se limitent pas à un ensemble de critères objectivables, mais sont imprégnés d'un vécu qu'il convient également d'apprécier : « *Et en fait, à chaque fois, les critères changent, et donc, des fois, vous pouvez avoir exactement la même disparité de revenus, le même nombre d'enfants, le même âge des parties, mais pas du tout le même vécu familial, et c'est ça qui est difficile. Et c'est ça qui est difficile... parce que ce n'est pas objectivable de la même manière qu'un préjudice corporel, où vous avez tel bébé, telle souffrance* » (L).

424. Un autre frein pratique, qui semble se manifester sur une fraction significative des cas, tient au fait que **même si on trouve des cas assez similaires, les décisions correspondantes ne sont pas pertinentes parce que les magistrats sont tenus par les demandes des parties** : « *la grande variable qui ne permet pas forcément d'utiliser ce fonds documentaire comme on le souhaiterait, c'est qu'on est tenu aussi par les demandes des avocats. Et en réalité, dans certaines situations, vous avez un avocat qui va demander 300 000 € de prestation compensatoire, et un autre qui va en demander 50 000. Et en réalité, ben même si les différentes*

règles de calcul, ou si les décisions que j'ai trouvées, mettent 150 000 ou 200 000, ben moi, je suis obligée de mettre 50 000. Mais, ben du coup, je mets le max', mais en même temps, je suis tenue par les demandes des avocats » (L). Une autre magistrate évoque à titre d'exemple le cas d'un homme qui accepte tout ce que demande son épouse par culpabilité, alors qu'elle aurait statué différemment, de manière plus « *raisonnable* » (N).

425. Puis, d'autres considérations, à la fois morales et juridiques, peuvent venir contraindre l'usage de ces logiciels par les magistrats. On retrouve bien sûr ici la crainte de déléguer trop la décision à l'outil, ce qui menacerait l'indépendance et l'*imperium* du juge : « *Après, j'espère que je garde, que je suis en capacité de garder mon libre-arbitre, et de pas me faire... Mais on est influencé, nécessairement* » (L). Mais cette crainte semble moins présente et saillante que lors d'une expérimentation similaire sur le calcul des dommages pour préjudice corporel à la chambre civile. Or, dans ce dernier cas, il d'agit d'une matière qui relève d'un calcul beaucoup plus cadré, encadré plus rigide par des barèmes, et moins vulnérable à des appréciations 'humaines' et des intuitions ordinaires que dans le cas des affaires familiales. On comprend bien dans cette perspective que les JAF puissent être moins sensibles à l'idée que le logiciel puisse en quelque sorte déterminer leur décision.

426. Par contre, il a été évoqué un autre argument moral, à savoir le **risque de céder à une facilité excessive en utilisant de tels outils logiciels, et de ne pas 'faire le boulot'** : « *Ce que j'ai trouvé, c'est que des fois, quand on manque de temps pour rédiger, qu'on est un peu à la bourre, de savoir qu'on a une solution de facilité, en allant vite regarder, je trouve que ce n'est pas bien. Ben du coup, tu fais plus l'effort de réflexion* » (E). Ce risque est amplifié par la pression exercée par les flux de dossiers, qui poussent les juges à aller toujours plus vite. Il ne s'agit pas là d'une considération abstraite, mais bien d'une préoccupation qui oriente cette magistrate dans un usage de l'outil où il fallait aussi en quelque sorte 'résister' : « *Donc effectivement, quand on est pressé, au lieu de faire d'abord la démarche de réflexion, de déterminer qu'est-ce que je vais donner à cette dame, ou qu'est-ce que je vais donner à ce monsieur comme prestation compensatoire, la nature humaine voudrait qu'on se précipite sur le logiciel, je trouve, et qu'on regarde "tiens, qu'est-ce qu'ils ont mis les autres ?". Oui, voilà. Et donc là, je me suis dit : "attention, là, c'est un piège, il ne faut pas que tu rentres là-dedans". J'ai été tentée, mais je me suis auto-raisonnée immédiatement. J'ai quand même regardé, mais je me suis dit : "attention, là, tu ne fais plus ton travail de réflexion"... Ben, tu ne te foutes pas ou t'as pas le temps, tu regardes vite, tu colles un truc. C'est dangereux, j'ai trouvé ça*

dangereux... Non, ce n'est pas la machine le juge, c'est toi. Et tu te dois de faire ton raisonnement habituel, d'analyser les pièces, et de pas regarder, et d'avoir un truc tout fait qui te sort... Et c'est toujours quand j'ai pas le temps. Quand on a le temps, ben, on est moins sous pression, peut-être, et... on prend le temps de faire les choses, et du coup, on est plus dans la réflexion » (E).

Chapitre 6 – Retour sur la question du précédent. Deux configurations d’usage pour l’outil d’aide à la décision reposant sur le *big data* pour deux contentieux différents

427. L’idée est ici de contraster l’usage de l’outil LexisNexis pour deux types de contentieux en justice civile, la fixation des dommages et intérêts pour préjudices corporels à la chambre civile et l’attribution de prestations compensatoires dans les affaires de divorce traitées au pôle des affaires familiales. Ainsi, à l’issue de deux expérimentations, il apparaît que dans un contentieux cadré et ‘technique’, il existe le risque d’un rapport trop ‘rigide’ à l’outil d’aide à la décision (Section 1), alors que dans un contentieux plus ouvert, il existe un rapport plus ‘souple’ à l’outil d’aide à la décision (Section 2).

Section 1 – Le cas d’un contentieux cadré et ‘technique’ : le risque d’un rapport trop ‘rigide’ à l’outil d’aide à la décision

428. Le traitement des dommages et intérêts pour préjudices corporels présente à la fois des similarités et des différences avec le cas des affaires familiales. C’est également une procédure écrite, avec une phase de mise en état et une remise de conclusions que les avocats plaident lors d’une audience. Dans sa décision, le juge est tenu par les demandes des avocats, et s’appuie le plus possible sur les faits objectifs qui y sont présentés. Au niveau des différences on peut noter en particulier que :

- les magistrats ne traitent en général qu’avec les avocats et ne voient pas les parties ;
- contrairement aux affaires familiales, où ils doivent faire sens de la relation entre deux personnes présentant chacune une version de leur vie domestique, ils évaluent ici, sur la base de rapports médicaux, un préjudice lié à l’incapacité de travailler en particulier ;
- ils s’appuient sur des outils existants, en particulier un référentiel validé au niveau national, le « référentiel MORNET » ;
- il s’agit bien d’une réparation, encadrée par le principe de la « réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit » fixé par la Cour de cassation. En revanche, « *la prestation compensatoire, elle n’est pas là pour le préjudice moral* » (L).

429. Tout ceci explique la perception des JAF qu’il s’agit d’une matière à la fois plus technique et plus écrite. Cela conduit aussi les juges de la chambre civile à évoquer très différemment leur marge d’appréciation. Il y a bien un peu de ‘feeling’ mais les choses sont

cadrées par des ‘fourchettes’ (notion inexistante dans les entretiens auprès des JAF) : il faut « *se placer dans la fourchette. Alors ça c’est, honnêtement, c’est un peu au feeling quand même. Parce qu’il n’y a pas, de toute façon vous savez ? C’est un peu une gageure de vouloir, enfin de vouloir, de prétendre en tout cas, réparer un préjudice du type préjudice quel qu’il soit esthétique, ou souffrances, avec de l’argent, on n’a pas d’autre moyen c’est le seul moyen qu’on a, mais voilà. Est-ce que c’est dix-mille euros, douze-mille euros, quinze-mille euros ? Honnêtement, c’est pour ça qu’il faut qu’on ait un, un, une fourchette. La fourchette ça me paraît indispensable* ». Contrairement au cas des dossiers des affaires familiales, pour lesquels une part de subjectivité était constitutive des affaires, et qui engageait donc une marge d’appréciation pour les juges, dans les cas de dommages et intérêts, plus enserrés dans des critères objectifs, la marge des juges est encadrée par des fourchettes qui résultent de la combinaison des référentiels existants et de l’écart entre les demandes des avocats (les juges ne peuvent statuer ni *infra petita* ni *ultra petita*). En cas de doute, le juge cherchera à s’aligner sur l’avis majoritaire afin d’unifier la jurisprudence.

430. Examinons de manière détaillée, comment un magistrat de la chambre civile a utilisé le logiciel JurisData Analytics. Comme leurs collègues des affaires familiales, c’est essentiellement sur des cas posant problème qu’ils avaient utilisé le dispositif, lors d’une expérimentation similaire.

Il pouvait s’agir d’une bagarre de rue, dans laquelle un mécanicien, qui travaillait à ce moment comme monteur de câble, a été blessé. Son père avait un garage, et le fils mécanicien affirmait qu’il allait reprendre la succession, mais il n’y avait pas de document établissant qu’il travaillait comme mécanicien auto, ou qu’il allait bien succéder à son père. L’avocat demandait 25 000 euros de dommages du fait de l’incidence des blessures par rapport à un métier physique. Le magistrat hésitait entre deux positions extrêmes : « *j’oscillais entre un rejet total, et quand même accorder quelque chose, aussi faible que cela fût, mais j’oscillais entre ça* ». Il aurait pu décider le rejet total, faute de preuves suffisantes. D’un autre côté, même si les preuves étaient légères, l’intuition ordinaire lui suggérerait qu’il y avait bien préjudice : « *les conséquences de cette agression sur le plan professionnel, elles ne sont pas nulles... puis avec un peu de bon sens, aussi, nous allons tous dans des garages, nous voyons tous les mécaniciens travailler, on voit quand même que c’est un métier physique, y a pas que de l’électronique, donc, je voyais bien que c’était un métier physique* ». Mais même en privilégiant cette alternative, il paraissait difficile d’accorder au fils la totalité des dommages demandés par son avocat : « *je me suis dit, je ne peux pas lui donner 25 000 €, c’est pas possible, parce que 25 000 €, c’est pas son*

préjudice, y a une incidence professionnelle, mais pas à cette hauteur-là, puis 25 000 €, ça l'aurait incité à... ».

La compréhension par le juge du comportement et de la situation du fils allait aussi dans le sens de ne pas accorder la totalité des dommages demandés : *« bon le père, à mon avis, n'était pas forcément dans les meilleurs termes avec son fils, qui était un peu... en pleine semaine, il traînait en boîte de nuit, donc, à 4h du matin, ça veut dire que c'était pas un acharné... et il était au RSA, donc... c'était un peu un loser, quand même ».*

En plus, accorder ce niveau de dommages aurait conduit à ce que le cas se porte vers le fonds de solidarité, c'est-à-dire à faire payer le contribuable : *« le problème, aussi, et là, il n'y a pas d'assureur, c'est une bagarre, ce sont des violences, ce n'est pas un accident de la circulation, donc en principe, ce sont ces trois loustics-là qui devraient payer, mais on sait parfaitement qu'ils ne vont pas payer... Monsieur va se retourner vers la communauté nationale, c'est-à-dire la Commission d'indemnisation des victimes d'infraction... Oui, et c'est vous et moi qui payons, parce que nous payons, nous payons sur nos contrats d'assurance, donc, ça aussi, il ne faut pas le perdre de vue, parce que, rendre une belle décision avec des sommes importantes, et après on n'arrive pas à les exécuter, et on se retourne vers la solidarité nationale, bon, il ne faut pas non plus pousser mémé dans les orties ».*

431. Pour ce cas où il hésitait donc entre deux décisions très différentes, il a choisi d'utiliser JurisData Analytics : *« l'occasion a fait le larron, puisque j'avais l'instrument... l'intérêt d'Analytics, c'est que toutes les rubriques préjudice corporel sont détaillées et suivent la "nomenclature Dintilhac". Donc je perds beaucoup moins de temps que d'aller dans la base ordinaire ».* On voit que, pour ces questions d'indemnisation pour préjudices corporels, plus formalisées, il y a un ajustement possible entre les critères de recherche et les points de nomenclature qui importent juridiquement. Il a ainsi pu croiser pas mal de variables, incidence professionnelle, fourchette d'indemnisation, victime directe ou indirecte, et comme en plus *« la base est riche, de ce point de vue-là, elle l'est beaucoup plus que la base générale »*, il a pu *« y aller en entonnoir »* et obtenir 5-6 décisions similaires : *« l'instrument est tout à fait remarquable. Il est très bien fait, il est très bien fait, alors parfois, je ne trouve pas, mais en tout cas, y a une sélection de critères, qui fait que je ne suis pas obligé de parcourir des centaines de décisions ».* En particulier, parmi les quelques décisions similaires que lui remontaient le dispositif, il a *« trouvé une situation, qui s'est passée outre-mer, assez proche... Je les ai toutes parcourues, mais c'est celle qui répondait le mieux à mon cas ».*

Ce n'était « *pas forcément une bagarre, mais une incidence professionnelle, avec des preuves assez légères, où l'incidence professionnelle n'était pas nulle, elle était existante, et où les collègues de la cour d'appel de Fort-de-France ont limité l'indemnisation. Je suis allé également dans ce sens-là. Faute d'éléments probants suffisants* ». C'était un cas proche, mais pas exactement similaire parce que les sommes mises en jeu étaient plus faibles : « *là, c'était beaucoup plus faible, bon, je veux dire, ils ont donné 400 ou 500 €, mais la demande initiale n'était pas à la hauteur de 25 000 €. Donc je n'ai pas trouvé de demande aussi importante que celle que j'ai eu à traiter* ». Mais ce qui l'intéressait, c'était le raisonnement (ce qui veut dire également lire en détail la décision), tandis que sur les sommes il a adapté la décision à son propre cas : « *mais ce qui m'intéressait, c'était le raisonnement, ce n'était pas le quantum. Parce que les 2 000 €, ce n'est pas Fort-de-France qui m'a inspiré à donner 2 000 €, j'ai fait la balance, la proportion entre l'incidence professionnelle, ses conséquences, et puis, ben, ce qu'il faisait réellement, est-ce qu'il exerçait vraiment son métier de mécanicien, je n'en étais pas tout à fait sûr* ». Justement parce qu'il s'agissait d'une décision en appel, les motivations étaient relativement précises et détaillées, et de plus elle n'avait pas suscité de pourvoi en cassation : « *Alors, c'est une décision d'appel, déjà, donc il y a une première décision ; elle n'a pas été frappée d'un pourvoi, donc... et puis, bon, elle était correctement motivée, j'ai compris ce qui s'était passé* ». Et il trouve là une confirmation de son raisonnement : « *c'est le raisonnement, d'ailleurs, c'est le raisonnement que j'aurais tenu* ».

432. Dans un premier temps, ce magistrat précise d'abord s'être inspiré de la décision, sans se l'être 'appropriée' : « *Donc, je ne me la suis pas appropriée, je m'en suis inspiré, mais en disant, bon...* ». Cette nuance apparaît comme défensive, elle vise à se garder de donner l'impression que le juge a traité le cas comme un précédent contraignant, c'est-à-dire comme une source du droit, comme le montrent les justifications qu'il fournit immédiatement après : « *C'est parce qu'en France, contrairement à d'autres jurisprudences, d'autres systèmes jurisprudentiels d'autres pays, on n'a pas la culture du précédent ; donc le précédent ne s'impose pas, ce qui est le propre de la culture anglo-saxonne, et de la jurisprudence anglo-saxonne. Nous, on a un système légal, la jurisprudence étant une source, une des sources, mais on ne doit pas rendre ce qu'on appelle d'arrêts de règlement* ». C'est qu'on ne peut pas 's'approprier' le cas, c'est-à-dire reprendre la motivation telle quelle : « *l'approprier, ça aurait été, effectivement, de dire, bon, je prends exactement la motivation, et je la reproduis telle que, et là, j'aurais créé un précédent* ». On ne peut pas non plus faire référence au cas antérieur, il faut à chaque fois statuer à nouveau : « *on ne peut pas dire, référence jurisprudence telle, on*

applique exactement la même chose que la jurisprudence précédente, on doit, cas par cas, statuer ». Et il faut que le fait que l'on statue effectivement sur le cas soit rendu manifeste par des technologies scripturales : *« alors, mon raisonnement, pour justement ne pas prendre la règle du précédent, et pour ne pas appliquer purement la jurisprudence, je rappelle toujours, en début de chaque poste de préjudice, la règle de droit »*.

433. **Le point intéressant pour cette expérimentation, c'est le caractère défensif de ces justifications.** C'est bien parce qu'il y a un risque que l'on ait l'impression que les cas similaires trouvés puissent agir comme des précédents, et donc que le rapport à l'outil JurisData Analytics soit 'rigide' et contraignant qu'il convient de s'en défendre. On comprend d'ailleurs bien que ce risque va être d'autant plus grand que le contentieux est cadré et formalisé autour de critères objectivables, et surtout quantifiables, et que le logiciel est plus capable de remonter des cas comparables et très proches. Ces deux critères sont d'ailleurs liés, car plus le contentieux est cadré par des « conventions de forme » (Thévenot, 1994), plus il sera facile de trouver des cas apparentés via une recherche par critères au moyen du logiciel, et mieux les magistrats seront à même de juger de leur proximité et de leur degré d'équivalence avec le cas initial.

434. Ce lien entre la formalisation du dispositif et le rôle du logiciel comme outil d'aide à la décision apparaît d'ailleurs clairement s'agissant de la question de faire référence ou non à des jurisprudences antérieures, comme celles de la Cour de cassation. D'un côté la règle veut qu'on ne fasse pas référence : *« Ah non, du tout, j'ai pas fait une référence... Normalement, bon, dans les décisions, normalement, on ne fait jamais de référence à la jurisprudence de la Cour de cassation... on ne met pas explicitement... cass. civ. 2^e, et avec la date de la décision, et entre parenthèses... on ne le fait pas, et on met l'arrêt de principe, on le recopie, sans faire la référence »*. Le juge ne peut se contenter de faire référence à une jurisprudence antérieure, car plus il le fait, moins on a l'impression qu'il a statué effectivement sur le cas. Mais pourtant, il y a une tentation d'aller vers cela que manifeste une certaine marge de tolérance vis-à-vis des écarts à cette règle : *« bon parfois, je m'affranchis de cette règle, notamment vis-à-vis des avocats et vis-à-vis des justiciables, en mettant la référence quand même entre parenthèses... Normalement, il ne faut pas le faire, mais bon, la Cour de cassation, si jamais y a une cassation, ou la cour d'appel, ne nous en tiendront pas rigueur, mais dans la pureté des formes, on ne devrait pas le faire »*. Et on retrouve ces hésitations dans les choix de conception de l'outil logiciel. Les concepteurs du dispositif, en mettant en forme la base de données, ont trouvé des paragraphes de décisions pris dans des décisions antérieures, sans citation. Ils se sont demandé

s'ils devaient ou non rendre le lien visible avec le système, leur incertitude étant liée à ce débat. On voit donc que la conception même du dispositif peut influencer sur la manière de mettre en relation le cas actuel et des cas antérieurs.

435. Avec les dossiers d'indemnisation pour préjudice corporel, on est donc dans le cas d'un contentieux formalisé, 'barémisé', où la marge d'appréciation du juge est encadrée par des fourchettes. Lorsque l'usage du logiciel JurisData Analytics remonte un cas suffisamment similaire et que le magistrat s'en 'inspire', cela ouvre alors le risque de traiter le cas comme un précédent, et le logiciel comme une forme de prescription contraignante plutôt qu'un outil d'aide à la décision. La généralisation des usages au-delà de cette expérimentation pose aussi la question d'une normalisation possible des décisions et d'une réduction de l'autonomie des juges. Nous allons voir maintenant que, pour un contentieux où la marge d'appréciation des juges est plus grande, pour des raisons constitutives des cas (il s'agit d'évaluer des descriptions de relations de couple et de manière de vivre ensemble plutôt que des états corporels individuels), l'usage du dispositif conduit à des médiations plus souples entre les cas similaires trouvés et la décision judiciaire à prendre.

Section 2 – Le cas des prestations compensatoires et des affaires familiales : un rapport 'souple' à l'outil d'aide à la décision

436. Dans un cas, la JAF utilise le logiciel par curiosité, et trouve le résultat « *intéressant, mais pas très aidant* » (N). Comme dans la plupart des usages au cours de cette expérimentation, il s'agit d'un cas inhabituel, qui justifie l'effort passé à trouver des cas similaires : « *c'était justement une situation un peu particulière, qui sortait un peu de l'ordinaire, où on avait un monsieur qui avait une profession un peu spéciale, enfin, il était assez spécialiste dans son domaine, et gagnait évidemment beaucoup d'argent, et une dame qui, elle, avait été en quelque sorte invitée, parce qu'elle le souhaitait aussi, mais je pense que monsieur voyait ça aussi d'un bon œil, à rester à la maison, avant même qu'ils aient des enfants, puis ensuite pour s'occuper des enfants. Donc en gros, elle a largement profité du train de vie que lui proposait monsieur. Mais c'était tellement exceptionnel comme situation, que je me suis dit, tiens, je vais quand même voir s'il n'y a pas des collègues qui ont déjà eu ce type de situation-là* ». Le caractère singulier tient en fait à une combinaison de trois facteurs, le caractère un peu particulier de la profession du mari, les disparités de revenus entre les deux parties, et un

arrangement de la vie conjugale qui paraît un peu daté par rapport à la sociologie contemporaine du mariage : *« C'était une telle différence de niveau de vie, et un monsieur qui était très impliqué dans sa profession, qui participait à des conférences, et qui, du coup, retirait beaucoup d'argent, évidemment, de son activité professionnelle. C'était plus la disparité, et l'organisation, en fait, de leur vie maritale, qui était, finalement, un petit peu exceptionnelle, dans le sens où, c'est vrai que de nos jours, on voit quand même pas non plus, même si monsieur gagne très très bien sa vie, des femmes relativement jeunes, qui se disent : "Bon, ben voilà, moi, je vais rester à la maison". Parce qu'elle était aussi relativement jeune. Et j'ai trouvé intéressant de trouver plusieurs décisions, qui avaient déjà eu ce cas de figure ».*

437. Les critères de recherche sont les revenus des parties, et surtout la profession du mari : *« j'ai cherché sur la profession, j'ai cherché sur les revenus, qu'est-ce que j'ai mis, les revenus de madame, les revenus de monsieur, et la profession, en particulier. Je sais plus du tout ce que c'était, hein, mais ça avait l'air hyper passionnant et très très rémunérateur... Et j'avais trouvé intéressant de savoir que d'autres personnes se sont penchées également sur cette situation ».* L'objectif est bien de trouver des cas proches. La profession du mari est un premier filtre assez important, mais il faut quand même rajouter d'autres critères pour focaliser : *« il y a eu plusieurs affaires. Alors, l'avantage, c'est de pouvoir continuer dans le renseignement des différents items... Alors, évidemment, vu la particularité de la profession, il n'y en avait pas 50 000, mais j'ai, par la suite, changé les critères en rajoutant le nombre d'enfants, enfin je sais plus ce que j'avais renseigné, mais j'avais encore réussi à réduire la recherche ».*

438. In fine, l'aspect intéressant d'un tel cas d'espèce, c'est que les décisions prises dans les cas proches auxquels elle a finalement abouti divergent de ses propres appréciations : *« Alors j'ai trouvé ça intéressant. Pour autant j'ai trouvé que ce qu'avaient mis les collègues, ce n'est jamais ce que j'aurais mis... Enfin, d'ailleurs, c'est pas du tout ce que j'ai mis. Et, en réalité, si vous voulez, j'ai trouvé intéressant de voir qu'on n'est pas seul au monde, et qu'on n'est pas les seuls à avoir ce type de problème-là, mais j'étais pas du tout en phase avec la décision qui avait été prise. Voilà. Et j'étais pas du tout dans la fourchette de ce que j'ai trouvé ».*

On peut noter ici deux points intéressants.

- Tout d'abord, lorsque le logiciel parvient à fournir des cas similaires, il engendre aussi le sentiment d'appartenir à un collectif, une communauté de juges confrontés à la mise

en ordre d'un monde complexe et rapprochés par la similarité des cas auxquels ils font face.

- Ensuite, non seulement les décisions antérieures ne correspondent pas à sa propre appréciation, mais elle ne se laisse pas guider par elles, et produit une décision différente.

439. De plus, cela ne semble pas lui avoir posé de problème de se trouver en situation d'avoir un jugement très différent des cas proposés par l'outil d'aide à la décision. Son ressenti est d'avoir été très peu contrainte par celui-ci : *« alors, ça ne me pose [riant] aucune difficulté d'être à rebours de quoi que ce soit. Et j'avais, en réalité, déjà ma petite idée, de ce que j'envisageais de décider... je cherchais une confirmation, et l'avantage, aussi, c'est que quand je suis rentrée dans la décision en tant que telle, et que j'ai vu les explications qui en étaient données, je me suis dit : oh non. Voilà, je n'étais pas convaincue, en réalité, par les éléments qui ont été fournis, pour fixer la prestation compensatoire, au montant auquel elle a été fixée... Oh, après, on a toujours un petit : "Ah bon, ouais, OK, est-ce que je suis pas un petit peu rigide, sévère ?". Voilà, mais enfin, ça a duré le temps de se poser la question, et après, c'était terminé »*. Cette légèreté apparente de l'effet du dispositif fait que l'on peut parler d'un guidage souple par l'outil logiciel.

440. Ce qui rend possible cette souplesse dans le guidage par l'outil d'aide à la décision, qui prend ici la forme d'une indépendance par rapport aux cas trouvés (et qui n'agissent donc pas comme des 'précédents' ou des sources du droit), c'est cette **particularité des affaires familiales de combiner un appui systématique sur des éléments objectifs et des textes** (le raisonnement proprement juridique) **et une appréciation de ce qui peut être équitable dans des arrangements domestiques, qui est irriguée par des intuitions ordinaires**, que les juges décrivent parfois comme 'appréciation', ou 'interprétation' : *« Non, parce que je n'étais pas dans le même raisonnement. Si vous voulez, les éléments objectifs étaient sensiblement identiques ; pas identiques, évidemment, à 100 %, mais sensiblement identiques. Mais l'interprétation que j'ai faite de ces éléments objectifs, n'a pas du tout été la même que celle des collègues dont j'ai trouvé la décision »*.

441. Cette interprétation met en jeu à la fois une analyse des configurations dans lesquelles les femmes peuvent rester à la maison, et un jugement sur celles-ci. Le choix de rester à la

maison par calcul économique semble alors s'opposer au choix de le faire par convention bourgeoise : *« Enfin, pour moi, il n'y a pas de : ah, la pauvre, elle est restée à la maison, enfin, il y a quand même toujours une décision plus ou moins commune... Je ne dis pas dans les situations dans lesquelles on fait son calcul en se disant : "Bon, alors là, je gagne 1 200, si je reste à la maison, je peux avoir 900, mais aller gagner 1 200, pour finalement avoir 500 € de frais de garde, ben tant qu'à faire, je reste à la maison". Je ne parle vraiment pas de ces situations-là, je parle vraiment d'une sorte de grande bourgeoisie, où c'est aussi très très bourgeois que madame reste à la maison et profite du train de vie offert par son époux. Voyez, on était plus dans cette situation-là »*. Et cette dernière posture, parce qu'elle sort des attentes communes concernant les manières ordinaires de vivre sa vie, ne suscite pas l'affiliation empathique qui justifierait une certaine manière d'attribuer juridiquement des prestations compensatoires : *« Et moi, je n'arrivais pas à me dire que, la pauvre, elle était restée à la maison, pour finalement, aller faire du cheval, des UV, enfin voilà »*.

442. Ces jugements, ces 'interprétations' ouvrent une marge de manœuvre : *« On a quand même des interprétations. Après, ces éléments-là ont l'air très très objectifs, mais quand on parle des incidences du déroulement de la vie commune, sur la manière dont les conditions de vie vont être dégradées, à moyennement dégradées, ou pas du tout dégradées, on a quand même une marge de manœuvre, quoi. Chacun a sa vision de la manière dont les choses ont pu se mettre en œuvre »*. Et non seulement cela permet une certaine variabilité des décisions (dont on a vu plus haut qu'elle était à la base de préoccupations comme celle d'arriver à une jurisprudence de cour), mais c'est également cela qui rend le juge plus autonome par rapport aux cas similaires que lui présente le logiciel à partir de ses bases de données étendues : *« Voilà, comme je vous ai dit, ça ne me dérangeait pas d'être à contre-courant »*.

443. Cette autonomie sera peut-être aussi d'autant plus fort que les juges revendiquent explicitement et fortement des positions et des engagements sur les questions sociales : *« ça ne me dérange pas d'être cash, j'ai quand même été amenée une fois à dire dans une décision que le mariage n'était pas un investissement, hein »*. Dans ce cas particulier, la revendication féministe de la magistrate semble bien jouer un rôle, en orientant une 'interprétation' de ce genre de cas : *« Ce côté féministe, moi, je l'interprète moi-même comme étant en lien avec ça... on n'est quand même pas, en 2021, comme les femmes des années 50... Et que les époux sont pas là pour être des vaches à lait. Maintenant... Et je suis mariée (rire) »*. Mais c'est quelque

chose qui est lié à la nature de ces affaires, et d'autres juges apprécieraient selon d'autres positions et attentes ordinaires. Le point intéressant pour cette expérimentation est qu'il y a donc un lien entre la nature de ce contentieux et la capacité du juge à tenir à distance les cas que le logiciel met en exergue, à ne pas les traiter comme un genre de 'précédent' qui orienterait trop rigidelement sa propre décision.

444. De manière plus générale, cela veut dire que l'on ne peut pas penser l'introduction d'outils basés sur l'IA auprès des magistrats de manière uniforme. D'un contentieux à l'autre, la médiation que le dispositif exerce vis-à-vis de la décision sera différente.

445. **Conclusion.** À titre provisoire, on souligne trois éléments qui émergent de ce volet de la recherche à tester comme hypothèse de travail.

- Il s'agit de se demander si l'outil peut favoriser une certaine homogénéisation des décisions (ce qui pourrait rendre les avocats plus indifférents au juge qui traitera le dossier).
- Mais s'il y avait des effets de ce type, cela voudrait aussi dire que les décisions sont affectées par ces dispositifs, ce qui met à l'épreuve l'idéal-type du juge complètement indépendant, décidant en son for intérieur et avec une pleine autorité. Les logiciels basés sur l'IA reconfigureraient ainsi la tension entre collaboration et autonomie et, dans le cadre du travail décisionnel, le type de rapport aux cas similaires remontés par les dispositifs basés sur les grandes bases de données (précédent ou guidage souple), dont nous avons vu à quel point ils étaient constitutifs de l'ethos et des pratiques interactionnelles et décisionnelles des magistrats.
- Ces effets devraient varier d'un type de contentieux à un autre, en particulier selon que ceux-ci sont plus formalisés et quantifiables d'un côté (comme ce serait le cas du côté des indemnités pour préjudices corporel) ou au contraire semblent laisser plus de marge de manœuvre à des appréciations subjectives des magistrats, parfois basées sur des intuitions ordinaires (comme ce serait plus le cas pour les dossiers de divorce aux affaires familiales).

Titre 2 – L’incidence des outils de justice prévisionnelle sur la jurisprudence⁵⁶¹

446. **Objet de l’étude : un rapport sur « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence ».** La diffusion massive des données jurisprudentielles, rendue possible avec les lois et décrets relatifs à l’*open data* des décisions de justice⁵⁶², a conduit auteurs de doctrine et praticiens du droit à s’interroger sur les conséquences de ce changement dans la connaissance des décisions sur cette source du droit qu’est la jurisprudence. La réflexion sur ce sujet est essentielle, car comme l’a noté Monsieur F. Zenati-Castaing, « le modèle de la jurisprudence que nous connaissons depuis deux siècles, celui de la jurisprudence de cassation, est aujourd’hui mis à l’épreuve par la révélation intégrale de la jurisprudence des tribunaux et par son traitement à l’aide de l’intelligence artificielle »⁵⁶³. Les présents développements entendent, à ce sujet, mettre en lumière les principaux apports d’un rapport sur « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence »⁵⁶⁴, dont il s’agit de faire une présentation synthétique en y apportant une appréciation critique et en enrichissant cette réflexion d’autres travaux réalisés sur ce sujet, et plus particulièrement ceux concernant un thème central à cet égard : la hiérarchisation des décisions de justice⁵⁶⁵. Dès lors que celles-ci vont désormais devenir accessibles, les décisions des juridictions du fond, ou du moins les plus intéressantes d’entre elles, vont nécessairement avoir une influence sur la construction jurisprudentielle. Toutefois, sans outil, de justice prévisionnelle notamment, permettant de classer entre elles ces décisions, cet apport pourrait rester lettre morte. Aussi, une hiérarchisation est indispensable pour tirer le meilleur profit de l’*open data* dans un objectif d’amélioration de l’élaboration et du contenu de la jurisprudence en tant que source du droit.

⁵⁶¹ Liza Veyre et Aurore Hyde.

⁵⁶² Cf. supra, n° 17.

⁵⁶³ Zenati-Castaing F., « Des décisions de justice à la jurisprudence - Vers une post-cassation », in *Quelle jurisprudence à l’ère des données judiciaires ouvertes ?*, actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s’est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70019.

⁵⁶⁴ Cadiet L., Chainais C. et Sommer J.-M. (dir.), Jobert S. et Jond-Necand E. (rapp.), « La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation, juin 2022 : <https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/06/14/la-diffusion-des-donnees-decisionnelles-et-la-jurisprudence-quelle>.

⁵⁶⁵ Il sera principalement pris appui sur les actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s’est tenu à la Cour de cassation : « Quelle jurisprudence à l’ère des données judiciaires ouvertes ? » (Publication à *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024).

447. **Propos introductifs sur le rapport.** Ce rapport sur la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence, remis à la première présidente et au procureur général de la Cour de cassation le 14 juin 2022, répond à la lettre de mission que ces derniers avaient adressée au groupe de travail dirigé par Loïc Cadiet, Cécile Chainais et Jean-Michel Sommer aux fins d'évaluer les incidences de l'*open data* sur la valeur et la portée jurisprudentielle d'une décision de justice, au regard du développement des outils de jurimétrie (outils « dits de mesure scientifique des décisions de justice, dont l'objectif est la quantification de ces décisions à l'aide de modélisations mathématiques »⁵⁶⁶), mais aussi au regard d'outils qualitatifs, proposés par des *legaltechs*, mettant en rapport les décisions de justice entre elles afin d'y trouver des arguments et motivations identiques susceptibles de conduire aux mêmes décisions⁵⁶⁷. L'*open data* des décisions de justice et l'utilisation de ces données ouvertes en masse au moyen de ces nouveaux outils, invite en effet à « reconsidérer la notion même de jurisprudence » et ainsi à se poser la question de savoir « dans quelle mesure la connaissance d'une telle masse de décisions (...) peut (...) conduire à la reconnaissance, consacrée ou imposée, d'une jurisprudence "horizontale", au point de conférer une valeur normative et régulatrice aux décisions des juridictions du fond »⁵⁶⁸. Les enjeux sont pratiques (utilisation des données jurisprudentielles par les praticiens), économiques (utilisation par les *legaltechs* à des fins marchandes) et théoriques (office du juge, valeur des décisions de justice, organisation judiciaire). Le rapport part du constat qu'avec les données judiciaires ouvertes, la connaissance des décisions de justice rendues publiquement sera désormais plus facile pour les praticiens, les universitaires et les justiciables, ce qui devrait conduire à « un changement dans la façon dont la jurisprudence doit être appréhendée »⁵⁶⁹. Il propose ainsi une réflexion sur les rapports que peuvent entretenir la diffusion des décisions de justice et de la jurisprudence, conformément à l'objectif de diffusion des données judiciaires posé par la loi pour une République numérique⁵⁷⁰, et l'essor des technologies numériques.

448. **Notion de jurisprudence.** Les effets sur la jurisprudence de cette diffusion massive des données décisionnelles et de leur traitement par l'intelligence artificielle doivent commencer à être appréhendés dès à présent. Pour ce faire, le rapport commence par définir le sens à donner à la notion de jurisprudence. Le mot est polysémique, en ce qu'il est entendu à la fois comme

⁵⁶⁶ Lettre de mission, p. 2.

⁵⁶⁷ Lettre de mission, p. 2.

⁵⁶⁸ Lettre de mission, p. 3.

⁵⁶⁹ Rapport, p. 21.

⁵⁷⁰ Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016.

« ensemble des décisions de justice rendues pendant une certaine période soit dans une matière (jurisprudence immobilière), soit dans une branche du Droit (jurisprudence civile, fiscale, etc.), soit dans l'ensemble du Droit » (définition que le rapport décrit comme quantitative) et comme « tendance habituelle d'une juridiction déterminée ou d'une catégorie de juridictions à juger dans tel sens » (définition qualitative)⁵⁷¹. Si le groupe de travail n'a exclu aucune des acceptions de la notion de jurisprudence, il se concentre toutefois sur la jurisprudence « qualitative », liée à la motivation des décisions, qui intéresse au premier chef la Cour de cassation, garante de l'unité de l'interprétation des lois. Effectivement, ce sont certainement ces décisions de justice, cette jurisprudence d'« interprétation de la loi »⁵⁷² des juridictions du fond, qui vont prendre une importance grandissante avec l'*open data* des décisions de justice. Le groupe de travail remarque d'ailleurs que les entretiens réalisés avec les praticiens ont fait ressortir que les décisions des juridictions du fond sont souvent recherchées pour examiner la façon dont les questions de droit ont été abordées par les juges. Remarquons néanmoins que la jurisprudence « quantitative », constituée par une masse de décisions des juges du fond décidant de manière similaire, aura certainement elle aussi une influence sur la façon de juger⁵⁷³, ce que le rapport analyse également, comme il sera vu plus loin.

449. Nécessité de hiérarchisation de la masse des décisions de justice diffusées. La diffusion des décisions de justice en ce qu'elle permet leur connaissance peut être perçue comme une condition préalable à l'existence de la jurisprudence. L'avènement de l'*open data* apparaît dès lors susceptible d'avoir un impact sur le statut de la jurisprudence parmi les sources du droit, et particulièrement sur le statut des décisions du fond. En effet, l'essor de la diffusion des décisions des juridictions du fond et de leur traitement par les *legaltechs*, doit permettre de faire ressortir plus facilement les tendances parmi ces décisions. Cette question des effets sur la jurisprudence et doit être appréhendée, précise le rapport, en prenant en compte cette particularité française, qui « exclut que le juge puisse être en quelque manière lié par les décisions précédemment rendues par d'autres juridictions à propos d'une question de droit identique »⁵⁷⁴. La difficulté va alors être de repérer les décisions « importantes », c'est-à-dire celles pouvant nourrir la réflexion juridique, de par leur motivation, leur interprétation des

⁵⁷¹ V° Jurisprudence, sens 1 et 5, in *Vocabulaire Juridique* (dir. Cornu G.), 14e éd., PUF, 2022.

⁵⁷² Deumier P., « la hiérarchisation des décisions de justice - La hiérarchisation des décisions en amont et en aval », in *Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ?*, actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s'est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, 2024, n° 1007, 70014.

⁵⁷³ V. notamment, sur ce sujet, Deumier P., « Open Data - Une autre jurisprudence ? », *La Semaine juridique Édition générale*, n° 10, 9 mars 2020, doct. 277.

⁵⁷⁴ Rapport, p. 28.

règles de droit ou encore leur positionnement relativement à un débat doctrinal ou jurisprudentiel. Il va donc falloir réussir à différencier ce type de décisions de la masse des autres décisions rendues, c'est-à-dire qu'il faudra réussir à les hiérarchiser. À défaut, le risque est que cette diffusion massive des décisions de justice n'enrichisse pas la réflexion. Au contraire même, elle pourrait l'appauvrir. La hiérarchisation des décisions de justice est ainsi au cœur de la réflexion sur le renouveau de la jurisprudence. Comme l'a bien identifié J.-M. Sommer lors d'une intervention orale postérieure à la publication du rapport, les enjeux de la hiérarchisation sont en effet multiples : il s'agit d'abord de déterminer les finalités de cette hiérarchisation (sélection des décisions, référencement, lutte contre l'indifférenciation, préservation de la créativité normative), ensuite d'identifier le « responsable de la hiérarchisation », qui pourrait être « le producteur de la donnée, son destinataire, des tiers avisés comme l'université ou encore d'autres acteurs, les systèmes algorithmiques », et enfin de déterminer « le mode opératoire de la hiérarchisation, son processus, l'implication et la participation des acteurs, etc. »⁵⁷⁵.

450. **Plan.** Le rapport, issu d'un travail collectif, d'entretiens et de réunions avec des praticiens et des universitaires, mais aussi des éditeurs juridiques et des représentants de *legaltech*, indique tenter de saisir le thème de la diffusion des décisions de justice et de la jurisprudence dans toutes ses dimensions, sans toutefois développer particulièrement la question de l'encadrement éthique de la réutilisation des données, confiée à un autre groupe de travail copiloté par la Cour de cassation. Trente-trois recommandations sont formulées qui, précise d'emblée le rapport, doivent s'accompagner de la prise en compte de la charge qu'elles impliquent, et donc de moyens matériels et humains. Après une première partie dressant un état des lieux de la diffusion des décisions et de la jurisprudence aujourd'hui, le rapport dessine dans une deuxième partie, qui contient les recommandations du groupe de travail, les perspectives ouvertes par l'*open data*. Nous reprendrons ici ce découpage en nous centrant sur l'incidence des outils de justice prévisionnelle sur la jurisprudence, incidence qui devrait prendre une tout autre ampleur une fois le mouvement d'*open data* des décisions de justice achevé. La diffusion massive des décisions des juridictions du fond et son traitement par les outils algorithmiques entraînera nécessairement des changements quant à son influence sur la façon de juger de tout magistrat, juge du fond comme juge de cassation, et donc un changement

⁵⁷⁵ Sommer J.-M., « La hiérarchisation des décisions de justice », in *Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ?* », actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s'est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70012.

sur la jurisprudence elle-même. Si la justice prévisionnelle n'a pas encore vraiment eu d'incidence sur la jurisprudence (Chapitre 1), elle en aura certainement une fois le mouvement d'*open data* accompli (Chapitre 2).

Chapitre 1 – L'absence d'incidence actuelle de la justice prévisionnelle sur la jurisprudence

451. **Les raisons de l'absence d'incidence actuelle.** Antérieurement à la mise en œuvre de l'*open data* des décisions de justice, des outils numériques étaient déjà proposés aux praticiens du droit ou en voie de développement aux fins de traiter les décisions diffusées⁵⁷⁶, mais ces outils n'ont pas eu d'incidence sur la construction jurisprudentielle. En effet, faute d'une connaissance suffisante des décisions rendues par les juridictions du fond et donc faute d'identification suffisamment fiable de tendances dans la manière de juger, le traitement algorithmique des quelques décisions des juridictions du fond diffusées ne pouvait avoir et n'a donc pas encore d'impact sur la jurisprudence. La présentation particulièrement précise, par le rapport sur « la diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », de l'état des lieux de la diffusion des décisions de justice permet de mieux comprendre en quoi l'essor de l'*open data* va opérer un changement radical dans l'ampleur de cette diffusion et donc dans le traitement qui pourrait ensuite en être fait.

452. **Modes de diffusion des décisions de justice avant l'*open data*.** Ainsi que l'explique clairement le rapport, actuellement, en attendant la mise en œuvre complète de l'*open data* des décisions de justice, la diffusion des décisions de justice est protéiforme, en ce qu'à côté d'une diffusion légalement encadrée, des modes de diffusion spontanés ont une existence assez peu connue mais bien réelle⁵⁷⁷.

453. **Diffusion légalement encadrée.** La diffusion légalement encadrée est interne à l'institution judiciaire. Elle a considérablement évolué avec le temps et se compose aujourd'hui, dans l'ordre judiciaire, de Jurinet (base de données créée en 2005, commune aux décisions et avis de la Cour de cassation et à des décisions sélectionnées des juridictions du fond) et de JuriCa (base créée en 2008 qui contient toutes les décisions des cours d'appel).

⁵⁷⁶ Cf. supra, n° 1 et n° 41 à 43.

⁵⁷⁷ Rapport, p. 32 à 54, ci-après résumées.

Sur Jurinet, sont diffusées les seules décisions des cours et tribunaux présentant un intérêt particulier.

454. **Diffusion avec sélection préalable.** À l'extérieur de l'institution judiciaire, certaines décisions de justice font d'ores et déjà l'objet d'une diffusion. Là aussi sont sélectionnées pour diffusion les décisions présentant un intérêt particulier. Tout d'abord, la diffusion par la Cour de cassation de ses arrêts remonte à 1797. La Cour de cassation réalise elle-même une sélection et hiérarchisation dans la diffusion de ses arrêts, et depuis 2021 les arrêts jugés les plus importants sont publiés au bulletin (signalés « B ») et contenus dans le rapport annuel (signalés « R »). À côté de cette diffusion à l'origine sur support papier, un canal public de diffusion électronique et moins sélectif s'est développé. Il s'agit de la base Légifrance recensant principalement des décisions de la Cour de cassation (publiées comme inédites) et certaines décisions du fond de cours d'appel. Le secteur privé a créé quant à lui la base de données JurisData, contenant initialement des résumés d'arrêts de cours d'appel collectés notamment par un réseau d'ateliers régionaux.

Ce n'est donc que depuis la mise en application de l'*open data* des décisions de justice, organisé par différents textes⁵⁷⁸, qu'existe un canal de diffusion sans sélection préalable. Aux termes du décret précité, la mise à disposition des décisions sous format électronique est confiée à la Cour de cassation pour l'ordre judiciaire. Cette diffusion a commencé en 2021 et l'ensemble des décisions de justice devrait être en ligne fin 2025, ce qui va entraîner un considérable changement d'échelle dans la diffusion des décisions de justice : d'environ 15 000 décisions diffusées chaque année via Légifrance, la diffusion en concernera alors environ 3 millions grâce à l'*open data*. Et c'est bien la jurisprudence du fond, entendue ici dans le sens de l'ensemble des décisions des juridictions du fond, qui va être au cœur de ce changement d'échelle considérable.

455. **Autres canaux de diffusion.** Le rapport relève par ailleurs pertinemment que la jurisprudence du fond se construisait également grâce à des modes parallèles aux canaux de diffusion légale : la diffusion spontanée s'est en effet aussi développée, d'abord au sein de l'institution judiciaire, que ce soit au niveau de la Cour de cassation ou au niveau des juridictions du fond, notamment par des rencontres, des panoramas ou encore, par le développement de listes de discussions entre magistrats, leur permettant d'échanger sur des

⁵⁷⁸ Cf. supra, n° 17.

thématiques diverses (procédures collectives, attributions relevant du juge des contentieux de la protection, etc.) et, en cela, d'initier une forme de jurisprudence collective. En outre, en dehors de l'institution judiciaire, des modes de diffusion ont été créés hors de tout cadre légal ou réglementaire, comme les lettres des chambres de la Cour de cassation, les communiqués, etc. Des cours d'appel travaillent par ailleurs avec des universités dans le cadre d'ateliers de jurisprudence ou de publications de notes commentant certains de leurs arrêts. Les acteurs de cette diffusion ne sont pas que les juridictions : il peut également s'agir des auteurs de doctrine et des éditeurs juridiques notamment⁵⁷⁹.

456. **Réception des décisions de justice diffusées.** Les modes de diffusion des décisions de justice décrits, le rapport s'intéresse à leur réception. Le développement de la portée jurisprudentielle des décisions de justice passe en effet par leur diffusion, souligne le rapport. La connaissance des décisions de justice, surtout issues de la Cour de cassation, permet d'abord de connaître le droit applicable et de le comprendre, mais aussi, ensuite, de s'en servir dans un contentieux afin de convaincre de la décision à prendre. L'autorité de la décision rendue a bien sûr une influence très forte : les arrêts de la Cour de cassation, du fait de la hiérarchie des juridictions, ont la plus grande autorité et donc la plus grande portée jurisprudentielle. L'autorité des décisions de cours d'appel a également une certaine importance, notamment devant les juridictions de degré inférieur, mais aussi lorsque ces arrêts tranchent une question nouvelle ou lorsqu'ils ne sont pas soumis au contrôle de la Cour de cassation (appréciation souveraine ou contentieux échappant par nature à ce contrôle). L'importance de la diffusion de la décision ou encore son signalement par la doctrine ont également une influence réelle. Il ressort de l'étude, indique le rapport, une réception inégale des décisions de justice⁵⁸⁰.

457. **Insuffisances de la hiérarchisation actuelle des décisions de justice.** Effectivement, si les décisions des juridictions du fond ne sont pas encore toutes diffusées, une certaine hiérarchisation – par la sélection de certaines d'entre elles en amont de leur diffusion – existait déjà avant l'*open data*. Comme l'écrit Pascale Deumier, déjà « du temps des rotatives et des recueils, la hiérarchisation se faisait par la diffusion : seules étaient diffusées les décisions présentant un intérêt »⁵⁸¹.

⁵⁷⁹ Rapport, p. 44 à 54.

⁵⁸⁰ Rapport, p. 54 à 75.

⁵⁸¹ Deumier P., « la hiérarchisation des décisions de justice - La hiérarchisation des décisions en amont et en aval », art. préc.

Cette hiérarchisation par la diffusion des seules décisions présentant un intérêt particulier n'est toutefois pas correctement réalisée, ce qui empêche les juridictions du fond de pouvoir jouer un rôle plus important dans la construction jurisprudentielle. Ce sont aux magistrats de déterminer, selon des critères préalablement établis, les décisions qui mériteraient d'être diffusées. Or, comme le relève Madame Lebreton, la sélection n'est pas dans leurs priorités⁵⁸². Faute de disposer de temps suffisant, et percevant difficilement la qualité et la valeur de leurs propres décisions, les magistrats se montrent réticents à proposer la diffusion de décisions qui pourtant le mériteraient certainement. Pour cette magistrate, « les juridictions du fond contribuent donc de fait à l'effacement de leur propre jurisprudence, tant en raison de leur difficulté à se décaler de leur mission première, qui est de statuer sur des litiges, pour avoir une analyse en surplomb de leurs décisions, qu'en raison d'un défaut réel de moyens pour le faire »⁵⁸³. Ainsi, ajoute l'auteure, l'ensemble des décisions des juridictions du fond « se présente comme une masse riche mais encore indifférenciée », au sein de laquelle « il est complexe d'y distinguer objectivement les décisions ayant de la valeur pour l'évolution du droit et pouvant constituer une référence pour le raisonnement juridique et la solution du litige, de celles qui ne rentrent pas dans cette catégorie »⁵⁸⁴. Dès lors, si les outils de justice prévisionnelle existent d'ores et déjà et s'ils se sont développés avant même l'essor de l'*open data* des décisions de justice, le nombre insuffisant des décisions nourrissant ces outils entraîne, *de facto*, une absence d'incidence de leur part sur la construction jurisprudentielle. L'influence actuelle des décisions des juridictions du fond sur la jurisprudence semble ainsi aujourd'hui très limitée. Le succès de la hiérarchisation future devant accompagner l'*open data* des décisions de justice ne pourra donc se réaliser sans une prise en compte des difficultés de sélection et sans l'appui des outils de justice prévisionnelle.

458. Après cet état des lieux, le rapport s'intéresse aux perspectives ouvertes par l'*open data* des décisions de justice quant à la jurisprudence. Ce sont ces perspectives, ci-après présentées et éclairées par d'autres regards, qui permettront d'essayer de comprendre dès à présent l'incidence que pourrait avoir la diffusion massive des décisions des juridictions du fond sur la jurisprudence de demain.

⁵⁸² Lebreton V., « La hiérarchisation des décisions de justice - À la recherche d'une hiérarchisation à parfaire - La pratique des juges du fond », *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70013.

⁵⁸³ *Ibid.*

⁵⁸⁴ *Ibid.*

Chapitre 2 – L’incidence attendue de la justice prévisionnelle sur la jurisprudence avec l’*open data* des décisions de justice

459. **Perspectives exposées dans le rapport.** Comme le montre bien le rapport, l’*open data* des décisions de justice ouvre des perspectives immenses quant aux évolutions qui pourraient affecter la jurisprudence. La jurimétrie, « avec l’usage de logiciels capables de lire un écrit et d’en communiquer le sens qui n’en sont eux-mêmes qu’à leurs débuts – est le moyen de relever le défi que représente l’exploitation d’une quantité inédite de décisions de justice »⁵⁸⁵. L’*open data* pourrait notamment augmenter, dans une certaine mesure, la portée jurisprudentielle des décisions des juridictions du fond, aujourd’hui difficilement accessibles. Mais les perspectives, qu’elles suscitent crainte ou espérance, sont encore bien plus larges. La diffusion massive des décisions des juridictions du fond pourrait en effet avoir des conséquences très diverses sur la façon de rendre la justice et de dire le droit, dont certaines peuvent susciter des inquiétudes si des cadres ne sont pas posés. Le rapport entend ainsi, par une série de recommandations, d’une part prévenir les risques liés à l’*open data* des décisions de justice et, d’autre part, proposer des pistes pour en tirer un meilleur profit.

460. **Prévention du risque d’indifférenciation des décisions de justice.** L’un des principaux risques identifiés est l’indifférenciation des décisions de justice. Une décision d’un tribunal de première instance n’a évidemment pas la même valeur qu’un arrêt de la Cour de cassation par exemple. Toutes les décisions vont bientôt devenir accessibles et elles ne doivent pas être mises sur le même plan : certaines ont une valeur normative, tandis que d’autres peuvent seulement servir d’exemple aux avocats pour des affaires similaires. Pour différencier au sein de la masse les décisions méritant d’être mises en avant car présentant un intérêt particulier, plusieurs propositions sont formulées. Le rapport suggère de rationaliser la diffusion des décisions tout d’abord en limitant davantage le nombre de décisions accessibles sur Légifrance. Ainsi, seules devraient y être publiées les décisions de la Cour de cassation, voire parmi elles uniquement celles ayant une valeur normative. Ce changement permettrait de bien faire la différence entre Judilibre, la base de données contenant l’ensemble des décisions de justice et Légifrance, qui est la base de données des décisions les plus importantes⁵⁸⁶. Un tel changement dans le contenu des décisions accessibles sur Légifrance ne serait pas sans susciter

⁵⁸⁵ Rapport, p. 92.

⁵⁸⁶ Recommandation n° 1.

quelques réserves. En effet, le contenu accessible à partir de Légifrance est aujourd'hui très bien identifié par les praticiens du droit et les universitaires. En particulier, la distinction entre les arrêts « inédits », c'est-à-dire, qui n'ont pas reçus les honneurs d'une publication au bulletin de la cour de cassation, et les arrêts « publiés » au bulletin de la cour de cassation et qui sont ainsi mis en avant. Il existe ainsi bel et bien une hiérarchisation entre les arrêts de la haute juridiction sur Légifrance. Pour autant, le fait de pouvoir accéder aux arrêts inédits permet d'en prendre connaissance et de mesurer leur portée réelle par rapport aux arrêts publiés.

Par ailleurs, la Cour de cassation effectue elle aussi une hiérarchisation et une classification de ces décisions afin d'éviter toute indifférenciation de valeur et de portée entre elles. Jusqu'au 15 juin 2021, les arrêts que la cour entendait porter à l'attention du public étaient signalés « P.B.R.I »⁵⁸⁷. Depuis cette date, le siglage des arrêts a évolué en « B » et « R » au regard de leur portée jurisprudentielle, et en « L » et « C » pour préciser qu'il s'agit d'arrêts pour lesquels la Cour de cassation souhaite communiquer plus largement⁵⁸⁸.

461. **Vers une hiérarchisation des décisions du fond.** Par ailleurs, selon le rapport, une hiérarchie entre les décisions des juridictions du fond pourrait également être faite dans les bases de données grâce à une classification opérée par les juridictions du fond puis *in fine* par la Cour de cassation⁵⁸⁹. Cette hiérarchisation s'opèrerait selon les critères exposés ci-après. D'un point de vue formel, est considérée comme présentant toujours un intérêt juridique particulier :

- une décision opérant un renvoi préjudiciel à la Cour de justice de l'Union européenne ;
- une décision de transmission d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
- une décision conduisant à la saisine du Tribunal des conflits aux fins de règlement d'un conflit d'attribution entre les deux ordres de juridiction.

⁵⁸⁷ Le « P » visait les arrêts publiés au Bulletin de la Cour ayant une portée doctrinale, le « B » faisait référence à la publication au *BICC*, le « R » marquait les arrêts analysés dans le *Rapport annuel* de la Cour de cassation et dont la portée doctrinale sortait renforcée, et le « I » signalait une mise en ligne de l'arrêt le jour même sur le site internet de la Cour.

⁵⁸⁸ Le « B » vise les arrêts publiés au *Bulletin des arrêts* de la Cour de cassation (et correspond à l'ancien « P »). Le « R » vise toujours les arrêts publiés et commentés dans le *Rapport annuel* d'activité de la Cour de cassation. Le « L » indique la présence de l'arrêt dans les *Lettres de chambre* et le « C » que l'arrêt a fait l'objet d'un *Communiqué* : <https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2021/06/15/la-nouvelle-classification-des-arrets>

⁵⁸⁹ Recommandations n° 2, 3 et 4.

Suivant un critère substantiel, peut être identifiée comme présentant un intérêt juridique particulier :

- une décision qui procède à un contrôle de conventionalité au regard de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
- une décision qui tranche une question de droit sur laquelle la Cour de cassation ne s'est pas prononcée (texte nouveau, problème nouveau d'articulation de plusieurs textes) ;
- une décision qui statue sur une question inédite ou qui adopte une qualification ou une interprétation nouvelle, spécialement lorsqu'elle est rendue dans un domaine relevant de l'appréciation souveraine des juges du fond ou si elle n'est pas susceptible de pourvoi en cassation ;
- une décision qui marque une inflexion de la position antérieure de la juridiction ;
- une décision portant sur une question qui donne lieu à un débat jurisprudentiel ou doctrinal bien identifié ;
- une décision ayant une importance sociétale ;
- une décision rendue dans le cadre d'un contentieux rare ou d'un contentieux émergent, spécialement lorsqu'elle est susceptible de concerner un grand nombre de juridictions⁵⁹⁰.

On relèvera, à propos de ces critères, que Pascale Deumier, considérant que la pertinence des critères peut être discutée à l'infini, invite aussi à réfléchir autrement, en sélectionnant « non par sélection des décisions intéressantes mais par exclusion des décisions n'ayant aucun intérêt pour la jurisprudence »⁵⁹¹.

462. Difficultés de sélection des décisions importantes. Pour réaliser cette sélection à partir de ces critères préétablis, le rapport propose notamment la solution suivante : « Au sein des cours d'appel, il appartiendra aux présidents de chambre d'identifier les décisions présentant un intérêt juridique particulier »⁵⁹².

Il y aura en outre un référent de la Cour de cassation au sein des cours d'appel. Il jouera un rôle important de coordination en s'assurant, notamment, du respect de la méthode et des critères établis par la Cour de cassation dans la mise en œuvre de sa politique de sélection et de communication des décisions rendues par les cours d'appel.

⁵⁹⁰ Rapport, p. 83 à 86.

⁵⁹¹ Deumier P., « la hiérarchisation des décisions de justice - La hiérarchisation des décisions en amont et en aval », art. préc., n° 6.

⁵⁹² Rapport, p. 82.

On notera que cette hiérarchisation ne pourra être assurée sans trouver de solutions aux difficultés actuelles de sélection des décisions présentant un intérêt particulier par les magistrats du fond. Comment donner les moyens aux présidents d'identifier les décisions présentant un intérêt particulier ? Comment s'assurer que ce qui ne fonctionne pas aujourd'hui fonctionnera demain ? Un renforcement de moyens humains et matériels apparaît indispensable⁵⁹³, en attendant, à l'avenir, un traitement par des outils algorithmiques. Il semble en effet que, malgré les pistes avancées par le rapport, sans un traitement aidé par la machine, la hiérarchisation des décisions des juridictions du fond sera très difficile. Les outils d'analyse algorithmique pourront en revanche certainement plus aisément dégager des tendances habituelles, sans hiérarchisation aucune ou presque, ce qui pourrait alors conduire au deuxième risque identifié par le rapport, celui d'un raisonnement juridique appauvri par la reproduction de la façon de juger des autres juges par effet d'imitation.

463. Développement d'une culture excessive du précédent et risque d'appauvrissement du raisonnement juridique. Un autre risque identifié dans le rapport est celui d'un raisonnement juridique appauvri pouvant résulter de l'identification de solutions récurrentes passées par l'intelligence artificielle⁵⁹⁴. Le rapport pointe à juste titre le risque que ces outils développent « une culture excessive du précédent, étrangère à la tradition juridique française »⁵⁹⁵. Or, une telle culture est susceptible, indirectement, « d'appauvrir les débats judiciaires et d'altérer les capacités d'interprétation des magistrats, aboutissant ainsi à une factuelisation du droit et une stérilisation de la jurisprudence »⁵⁹⁶.

464. Prévention du risque de standardisation des décisions. Le groupe de travail relève par ailleurs que le risque d'un raisonnement juridique appauvri pourrait aussi venir d'une forme de standardisation des décisions, qui ne prendraient pas suffisamment en compte les spécificités de chaque espèce, mais aussi de leur motivation, notamment dans les contentieux de masse, et ce par conformisme avec la façon de juger des autres juges connue grâce à l'*open data*. Le « précédent » ne doit pas être un carcan. Il doit seulement être, à la rigueur, un mode d'argumentation, une source d'inspiration.

⁵⁹³ Lebreton V., art. préc., n° 31 et 32.

⁵⁹⁴ Rapport, p. 92.

⁵⁹⁵ Rapport, p. 96.

⁵⁹⁶ Rapport, p. 96. V. égal., not. : Buat-Menard E., « La justice dite “prédictive” : prérequis, risques et attentes - l'expérience française », *Les Cahiers de la Justice*, 2019, p. 269 et s.

Pour le moment, le risque d'altération des capacités d'interprétation des magistrats n'est pas ressorti de l'expérimentation menée dans le cadre de cette recherche. Il est plutôt ressorti que les magistrats ayant pris part à l'expérimentation ont utilisé le logiciel mis à leur disposition pour confirmer leur analyse ou pour tenter de trouver des situations similaires à des cas complexes qu'ils avaient à traiter. Pour les cas simples, les magistrats n'ont pas jugé que son utilisation leur serait utile, y voyant au contraire une perte de temps. Une expérimentation menée par ailleurs par Étienne Vergès et Géraldine Vial tend également à montrer une utilisation vertueuse et raisonnée de ces outils par les magistrats, qui ne perdent en rien leur indépendance et leur vivacité d'analyse⁵⁹⁷.

Néanmoins, une recommandation du groupe de travail semble particulièrement opportune afin de montrer en quoi la connaissance des cas similaires déjà jugés peut être utile au raisonnement judiciaire : « Tout en évitant l'écueil d'une motivation "par référence", [il s'agit de] permettre aux juridictions du fond de faire état de décisions précédemment rendues par des juridictions du fond entre d'autres parties, spécialement les décisions des juridictions du fond signalées par la Cour de cassation pour leur intérêt particulier » et d'« admettre que la Cour de cassation, dans les motifs de sa décision, puisse, le cas échéant, faire état de décisions des juridictions du fond, sans leur donner pour autant valeur de précédent obligatoire »⁵⁹⁸. Ce faisant, il devient possible de porter à la connaissance les décisions qui, sans constituer un fondement juridique en tant que tel, auront été inspirantes.

465. Instauration d'un débat contradictoire sur les décisions applicables au stade de la mise en état ? Le rapport formule également les recommandations suivantes : « permettre, lors de l'audience d'orientation devant le président, ou devant le juge ou le conseiller de la mise en état, l'instauration d'un débat contradictoire à propos des décisions antérieurement rendues dans des affaires similaires, afin, le cas échéant, d'éclairer les parties sur l'opportunité de mettre en œuvre un mode amiable de règlement des différends ou sur l'opportunité de se désister purement et simplement de leurs demandes. Devant la Cour de cassation, favoriser un tel débat contradictoire lors de la phase de pré-orientation des pourvois au sein des chambres. Permettre que le choix d'un circuit simplifié puisse se fonder, notamment, sur l'existence de décisions antérieurement rendues »⁵⁹⁹. Outre que ces recommandations semblent peu réalistes au regard des pratiques actuelles, et notamment de l'absence de réelle mise en état intellectuelle, leur mise

⁵⁹⁷ Vergès E. et Vial G., Dossier : L'impact des algorithmes sur la décision de justice, *Recueil Dalloz*, 2022 p. 1919.

⁵⁹⁸ Recommandation n° 10.

⁵⁹⁹ Recommandation n° 11.

en œuvre conduirait indéniablement à conférer une plus grande normativité aux décisions du fond.

Cela étant dit, l'idée de l'instauration d'un débat à propos des décisions antérieurement rendues semble avoir tout son sens en audience de règlement amiable devant le tribunal judiciaire. Ce nouveau mode amiable, qui n'était qu'au stade de l'élaboration lors des travaux du groupe de réflexion, est aujourd'hui une réalité et la connaissance grâce à l'*open data* des décisions antérieures des juges du fond, que le juge chargé de l'audience de règlement amiable pourrait rechercher, serait sans doute fort utile pour convaincre les parties de résoudre rapidement et à l'amiable leur litige.

466. **Formation des utilisateurs.** Une utilisation raisonnée et maîtrisée des outils algorithmiques ne saurait toutefois, comme le souligne le rapport, se faire sans une formation spécifique de leurs utilisateurs actuels, mais également des étudiants en droit, futurs utilisateurs. L'avenir de l'enseignement du droit passera donc par une plus grande familiarisation des étudiants avec les décisions des juridictions du fond mais aussi avec les outils à proprement parler, leurs atouts comme leurs limites, ce qui implique en définitive une connaissance minimale par les enseignants en droit⁶⁰⁰.

467. À propos de la formation des professionnels du droit, et particulièrement du personnel judiciaire, il faut noter l'initiative de l'UNESCO qui a développé un programme de formation sur l'IA et l'État de droit. Ce programme se décline sous forme de cours en ligne accessibles gratuitement (MOOC)⁶⁰¹ et de séminaires en présentiels dans le monde entier sur la base d'un manuel de formation réalisé sur le même thème⁶⁰². Du 8 au 10 juillet 2024, s'est notamment tenu l'acte I d'un séminaire de formation organisé sur ce thème conjointement par l'UNESCO, l'European Judicial Training Network et l'École nationale de la magistrature⁶⁰³.

468. Le besoin de formation implique en outre que les universités puissent avoir un accès dédié aux logiciels. De manière générale, et comme le relève le rapport, la formation des praticiens ne pourra se faire sans une démocratisation de l'accès aux outils. À cet égard, le rapport préconise de mutualiser, à l'échelle des barreaux, l'abonnement à ces nouveaux

⁶⁰⁰ Rapport, p. 106 et s.

⁶⁰¹ <https://www.iau-hesd.net/action/unesco-mooc-artificial-intelligence-and-rule-law#:~:text=The%20Massive%20Open%20Online%20Course,on%20the%20rule%20of%20law.>

⁶⁰² https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387331_fre

⁶⁰³ Aurore Hyde y a participé en qualité d'experte.

services, comme cela se fait déjà dans certains barreaux pour les bases de données, et de permettre l'accès à ces mêmes services aux magistrats et aux juges non professionnels⁶⁰⁴. Cet accès doit être accompagné d'une formation adaptée, pédagogique et critique, commune aux magistrats et aux avocats, « afin de permettre la confrontation des idées, des approches et des pratiques et de favoriser l'émergence d'une culture commune »⁶⁰⁵.

Par ailleurs, nous avons déjà soutenu que les outils devraient être fournis gratuitement aux juridictions dans la mesure où leur matière première est constituée de données publiques⁶⁰⁶.

Toutes ces questions relatives à l'accès aux outils amènent à réfléchir aux modèles économiques sur lesquels reposent les sociétés commerciales qui conçoivent ces outils.

469. Création d'un Conseil des données judiciaires ouvertes. Enfin, pour endiguer l'ensemble des risques liés à l'usage des services algorithmiques permettant le traitement des décisions de justice, le groupe de travail propose de créer une instance de concertation nationale, sous l'autorité de la Cour de cassation, dénommée Conseil des données judiciaires ouvertes, qui aurait pour mission principale de centraliser les informations et, notamment, les difficultés relatives à la mise en œuvre de la diffusion des décisions de justice. Il s'agirait d'un organe de réflexion, d'échanges et de recommandations sur les pratiques, les méthodes de travail et les outils mis en œuvre dans le cadre de l'*open data* des décisions de justice. Il pourrait être utile de nouer et développer des partenariats aux niveaux européen et international afin de coordonner les actions d'application des réflexions et recommandations issues des travaux du Conseil.

Il nous semble également que la création d'une entité spécialement dédiée aux enjeux de l'*open data* des décisions de justice serait une bonne chose. Ce pourrait également être le lieu de la réflexion sur la manière de créer intelligemment de la donnée judiciaire directement publiable pour éviter tout le travail de mise en forme et de pseudonymisation qui échoit aujourd'hui à la Cour de cassation. Cette donnée judiciaire publique publiable ou « DJPP » était appelée de ces vœux par Fabien Waechter⁶⁰⁷ lors de nos échanges en réunions.

470. Espérance d'amélioration de la construction jurisprudentielle. S'agissant désormais des opportunités offertes par l'*open data* des décisions de justice, le rapport considère que la

⁶⁰⁴ Recommandation n° 13.

⁶⁰⁵ Recommandation n° 14.

⁶⁰⁶ Cf. *supra*, n° 180.

⁶⁰⁷ Feu Fabien Waechter était le PDG de la société Lexbase, partenaire du projet.

diffusion massive des décisions de justice peut être l'occasion d'améliorer la construction jurisprudentielle à la fois par la limitation des décisions rendues en sens contraire sur des points identiques, grâce à la connaissance de la façon de juger des autres juges sur une même question et par l'amélioration de la qualité des décisions rendues, car celles-ci auront été nourries de l'expérience des juridictions du fond.

À cet égard, il est à noter que la Cour de cassation étudie actuellement comment l'IA pourrait lui permettre d'identifier plus facilement les divergences de jurisprudence entre ses chambres.

471. **Plus grande sécurité juridique.** La réduction des décisions en sens contraire vise à satisfaire une plus grande sécurité juridique, entendue comme la « qualité d'un ordre juridique qui assure au citoyen lisibilité et confiance dans ce qui constitue le droit à un moment donné et ce qui, selon toute probabilité, sera le droit dans l'avenir »⁶⁰⁸. Il est effectivement indéniable que le traitement des décisions en *open data* mettra en évidence, avec une force particulière, des formes d'insécurité juridique jusqu'alors simplement soupçonnées ou du moins non véritablement mesurées, en faisant voir toute l'ampleur « des décisions par lesquelles les juges du fond résistent à une jurisprudence de la Cour de cassation et prennent des décisions en contradiction manifeste avec cette dernière ou, encore, des décisions qui s'opposent entre elles relativement à une question n'ayant pas encore été tranchée par la Cour de cassation »⁶⁰⁹. Aussi le traitement des décisions en *open data* par l'intelligence artificielle permettra-t-il d'assurer une plus grande harmonisation des décisions de justice, avec cette réserve cependant que la similarité des affaires ne permet pas de les réduire à l'identique. Il y a toujours entre deux affaires similaires quelques points de distinction pouvant justifier un traitement différencié. Par ailleurs, ce n'est pas parce que les décisions du fond semblent se rejoindre sur la solution à apporter à un cas donné que la solution proposée est nécessairement la bonne ou qu'elle n'est jamais susceptible d'évoluer. En effet, nous ne saurions pas exiger pour les décisions du fond ce que nous n'exigeons pas pour les décisions statuant uniquement en droit, à savoir, un droit acquis à une jurisprudence figée⁶¹⁰. L'évolution du droit vivant est nécessaire pour assurer l'adaptation de la règle de

⁶⁰⁸ Calmes S., *Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français*, Dalloz, coll. Nouvelle bibliothèque des thèses, 2001, n° 66, p. 163.

⁶⁰⁹ Rapport, p. 115.

⁶¹⁰ Solution constante depuis Civ. 1^{re}, 9 oct. 2001, n° 00-14.564, *Bull. civ.* 2001, I, n° 249 ; CEDH, *Unédic c. France*, 18 décembre 2008, n° 20153/04, § 71 : « les exigences de la sécurité juridique et de protection de la confiance légitime des justiciables ne consacrent pas de droit acquis à une jurisprudence constante ».

droit par essence pérenne. L'objectif de prévisibilité du droit trouve ainsi sa limite dans l'évolution indispensable du droit⁶¹¹.

472. **Consolidation du rôle unificateur de la Cour de cassation.** Une plus grande harmonisation des décisions de justice entre elles et donc une plus grande sécurité juridique pourraient passer par une consolidation du rôle unificateur de la Cour de cassation. En effet, selon le rapport, les divergences d'interprétation d'une même règle de droit par plusieurs juridictions pourraient être davantage connues grâce à l'*open data*. La Cour de cassation pourrait ainsi quantifier la résistance des juges du fond à l'égard de ses décisions. En outre, l'*open data* pourrait « révéler des oppositions, voire des contradictions, entre les décisions prises par des juridictions du fond, au sujet de questions non tranchées par la Cour de cassation », phénomène qui peut aujourd'hui passer inaperçu⁶¹². Le phénomène jurisprudentiel pourrait être ainsi mieux appréhendé et l'autorité de la Cour de cassation être mieux mesurée. La fonction unificatrice pourrait être ainsi renforcée de manière spontanée, car la Cour de cassation, davantage consciente des résistances des juges du fond, pourrait alors tenter d'asseoir avec plus de force sa jurisprudence, notamment par une plus grande publicité.

Ensuite, ce rôle unificateur de la Cour de cassation pourrait être consolidé par la mise en place de pratiques nouvelles, à savoir organiser une veille des divergences pour les identifier de manière précoce, faciliter la saisine de la Cour de cassation pour avis, bénéficier d'une procédure d'arrêt pilote ou encore promouvoir le pourvoi dans l'intérêt de la loi. Il est notamment préconisé de confier au Conseil des données judiciaires ouvertes la veille des divergences de décisions et de confier plus spécialement au sein du Conseil cette mission à une cellule pilotée par le Service de la documentation des études et du rapport (SDER)⁶¹³. Cela pourrait « permettre le signalement des divergences entre décisions de justice par une application accessible sur le site de la Cour de cassation aux utilisateurs inscrits »⁶¹⁴.

Une autre voie envisageable est celle consistant à assouplir la saisine de la Cour de cassation pour avis lorsque la question posée présente une difficulté sérieuse dès lors que le juge sera en mesure de faire état de divergences d'interprétations entre juridictions du fond⁶¹⁵ en supprimant la condition tenant à ce que la question se pose dans de nombreux litiges⁶¹⁶. Il serait notamment

⁶¹¹ Hyde A., 20. « Intelligence artificielle et droit au procès équitable », *in*, L'intelligence artificielle et les droits fondamentaux, dir. V. Barbe, Éditions de l'Épitoque, 2022, p. 115 et s., spéc. p. 120

⁶¹² Rapport, p. 117.

⁶¹³ Recommandation n° 17.

⁶¹⁴ Recommandation n° 18.

⁶¹⁵ Recommandation n° 19.

⁶¹⁶ Recommandation n° 20.

utile d'ajouter à cela, selon le rapport, la création d'une procédure de décision pilote après identification par le Conseil des données judiciaires ouvertes de difficultés réelles d'interprétation dans un contentieux sériel⁶¹⁷.

473. Création de l'Observatoire des litiges judiciaires. Conformément à ses préconisations dans son rapport « Cour de cassation 2030 », la haute juridiction a lancé avec trois cours d'appel pilotes (Nancy, Rennes et Versailles), fin 2022, la phase expérimentale du dispositif de l'Observatoire de litiges judiciaires (OLJ), afin de mieux identifier les contentieux émergents, complexes, sériels ou d'intérêt public majeur et de garantir une justice plus efficace.

L'objectif est de développer un espace fiable d'échanges et de mutualisation de l'information, avec le soutien du ministère de la Justice. L'OLJ répond ainsi au souci de mieux harmoniser les solutions rendues par les juges du fond. En effet, ses principales missions sont notamment de :

- repérer les litiges ciblés grâce à un mécanisme de remontée d'informations ;
- soutenir le traitement des contentieux en identifiant les dossiers similaires de juridiction à juridiction, en rendant compte de leur état d'avancement, tout en leur consacrant des travaux de recherche et d'analyse approfondis.

Toutes les juridictions ont par ailleurs la possibilité de participer à ses travaux via des pages dédiées du site intranet de la Cour de cassation préfigurant une future plateforme spécifique.

474. Plus grande cohérence des décisions des juridictions du fond. La mise à profit de l'*open data* dans un objectif de plus grande sécurité juridique pourrait également consister en une incitation à une plus grande cohérence entre les décisions des juridictions du fond⁶¹⁸. Il ne faut pas, souligne le rapport, que ces divergences créent de l'incohérence dans l'application du droit, au point de le rendre inintelligible et de susciter un sentiment d'injustice et d'inégalité face à l'application différente du droit à des situations semblables. L'*open data* pourrait favoriser une plus grande cohérence dans la jurisprudence du fond. En effet, « en permettant d'accéder très largement aux décisions de justice et en mettant les magistrats en situation de prendre connaissance des pratiques jurisprudentielles des autres juridictions et, partant, d'y comparer leur propre pratique, l'*open data* des décisions de justice devrait *de facto* tendre à ce que les juges soient plus naturellement amenés à identifier des divergences et à les interroger le cas échéant, conduisant ainsi à un plus grand souci d'harmonisation »⁶¹⁹.

⁶¹⁷ Recommandations n° 21 et 22.

⁶¹⁸ Rapport, p. 129 à 136.

⁶¹⁹ Rapport, p. 131.

Pour exploiter au mieux cette opportunité, la recherche des décisions rendues antérieurement par une juridiction pourrait être facilitée, grâce à la mise en place de bureaux virtuels en son sein et par l'affinement des nomenclatures⁶²⁰.

Le rapport franchit un pas de plus vers une forme de « commonlawisation » du droit en préconisant que, lorsqu'un juge s'écarte, en connaissance de cause, de décisions précédemment rendues par des juridictions du fond, une motivation poussée soit réalisée afin de donner confiance aux justiciables dans l'institution judiciaire au risque sinon de les laisser sur un sentiment d'injustice et d'inégalité⁶²¹. Pour cette raison, le groupe de travail demeure prudent et ne suggère pas de rendre obligatoire une telle motivation. Il entend simplement la promouvoir en tant que bonne pratique.

475. Développement du droit. Comme le rappelle le rapport, les juridictions du fond participent au développement du droit : premières à connaître d'un contentieux nouveau, elles sont une source d'innovation et peuvent se monter audacieuses, tout en étant tempérées au niveau des cours d'appel. Une meilleure connaissance par la Cour de cassation de la jurisprudence du fond l'inspirera certainement pour créer sa propre jurisprudence. En effet, « grâce à la connaissance de l'intégralité de la pratique contentieuse, les cours suprêmes seront mieux éclairées et rempliront avec davantage de précision leur mission d'unification. Elles verront plus objectivement quelle est la tendance des valeurs de leur temps telles qu'elles ont été arbitrées dans les prétoires et feront leur arbitrage en connaissance de cause »⁶²². En outre, il est probable que l'influence de l'expérience judiciaire sur la Cour de cassation sera « beaucoup plus grande, car l'image qu'elle en recevra sera complète et plus représentative qu'auparavant »⁶²³. La Cour de cassation pourrait être davantage amenée « à suivre les tendances de cette expérience que la lettre de la loi »⁶²⁴.

Pour exploiter au mieux cette potentialité nouvelle qu'offre la connaissance de l'ensemble des décisions des juridictions du fond, il conviendrait notamment, propose le rapport, d'« inviter les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à exploiter dans leurs mémoires les

⁶²⁰ Recommandation 24 : « Dans le ressort de chaque cour d'appel, développer des bureaux virtuels sur lesquels seront accessibles toutes les décisions rendues par l'ensemble des juridictions du ressort. Affiner et mettre à jour plus régulièrement la nomenclature des affaires civiles, notamment en lien avec les travaux actuels conduits à la Cour de cassation sur la nomenclature des affaires orientées. Diffuser plus largement ces nomenclatures et les rendre exploitables dans le cadre des recherches effectuées sur Judilibre ».

⁶²¹ Recommandation n° 25.

⁶²² Contribution écrite du Professeur Zenati-Castaing, citée dans le rapport note 378, p. 119.

⁶²³ Zenatti-Castaing, F. Zénati-Castaing, « Des décisions de justice à la jurisprudence - Vers une post-cassation », in *Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ?*, article précité.

⁶²⁴ *Op. cit.*

décisions des juridictions du fond précédemment rendues dans des affaires analogues, lorsque cela est de nature à enrichir la démonstration et à éclairer la Cour »⁶²⁵ et de « prévoir une recherche et une analyse systématiques des décisions des juridictions du fond par les rapporteurs et les avocats généraux lorsqu'un pourvoi est orienté, dans le cadre des circuits différenciés, vers le circuit approfondi ; dans les autres cas, inviter seulement à une telle recherche »⁶²⁶.

476. Enfin, la recherche universitaire doit prendre toute sa place dans l'exploitation de ces nouvelles opportunités de développement du droit grâce à l'*open data*. Aussi est-il notamment proposé de « développer les espaces de publication pouvant accueillir des travaux universitaires exploitant les ressources offertes par l'*open data* des décisions de justice »⁶²⁷. À cet égard, il faut relever, en 2022, la création d'une revue spécialement dédiée à la jurimétrie, sous la responsabilité scientifique de Christophe Quézel-Ambrunaz et Vincent Rivollier⁶²⁸.

Il importe encore de favoriser l'essor de recherches collectives en ce domaine⁶²⁹ et de « promouvoir la conclusion de partenariats entre les universités et les juridictions afin de mieux traiter les ressources offertes par l'*open data* des décisions de justice et, spécialement, les décisions signalées »⁶³⁰. Ceci illustre parfaitement tout l'intérêt de la présente recherche collective, laquelle mériterait d'être poursuivie dans le temps, notamment du fait de l'évolution des outils analysés. Cependant, cela supposerait de pouvoir avancer la recherche suffisamment rapidement pour conserver l'intérêt des industriels dans le projet et assurer leur participation. En effet, le travail d'évaluation d'une certaine version d'un outil tend à perdre rapidement de son intérêt pour les partenaires dès lors qu'ils travaillent en interne à des versions bien plus avancées. La recherche devrait donc pouvoir avancer aussi vite que l'industrie si elle veut être opérationnelle.

477. **Conclusion.** Quelle jurisprudence se dessine à l'ère de l'*open data* des décisions de justice et de leur traitement par les outils de justice prévisionnelle ? Un accès facilité aux décisions de justice devrait favoriser une plus grande connaissance des décisions ayant une portée jurisprudentielle. Il ne faudrait toutefois pas que toutes les décisions rendues se voient

⁶²⁵ Recommandation n° 27.

⁶²⁶ Recommandation n° 26.

⁶²⁷ Recommandation n° 31.

⁶²⁸ *Jurimétrie – Revue de la mesure des phénomènes juridiques* : <https://www.fac-droit.univ-smb.fr/fr/revue-jurimetrie/>

⁶²⁹ Recommandation n° 31.

⁶³⁰ Recommandation n° 32.

reconnaître une telle portée ni que les juges tendent à se conformer mécaniquement aux décisions déjà rendues. Des propositions ont été formulées pour endiguer ces risques, notamment la hiérarchisation des décisions des juridictions du fond. Ce faisant, on conférerait un caractère normatif à certaines décisions du fond ce qui aurait nécessairement un impact sur les sources du droit et sur la manière de travailler des professionnels du droit. En effet, une physionomie nouvelle de la jurisprudence se dessinerait avec une plus grande considération pour les décisions des juridictions du fond et l'espoir de processus plus justes et plus cohérents d'élaboration de la jurisprudence⁶³¹.

La doctrine continue d'enrichir la réflexion sur les transformations de la jurisprudence avec l'*open data* des décisions de justice. Ainsi, pour Frédéric Zenati-Castaing, le changement pourrait être encore plus grand dans la mesure où la divulgation de la jurisprudence du fond et sa « mise en forme grâce à l'intelligence artificielle » serait « susceptible de faire naître une source rivale de celle des arrêts de la Cour de cassation »⁶³². La légitimité de ce droit découvert grâce au progrès technique est telle, conclut l'auteur, « qu'elle s'imposera peu à peu et en fera un rival du droit de l'État contenu dans les lois et dans leur interprétation par les organes de cassation »⁶³³. Mais nous sommes là dans le domaine très incertain de la prédiction, voire peut-être même de la « juris-fiction »⁶³⁴, et il faudra encore de nombreuses recherches pour apprécier ce qu'il en est réellement.

⁶³¹ Cadiet L., « Des décisions de justice à la jurisprudence », in *Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ?*, actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s'est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70016.

⁶³² Zenati-Castaing F., « des décisions de justice à la jurisprudence », art. préc.

⁶³³ *Ibid.*

⁶³⁴ Deumier P., « Open Data - Une autre jurisprudence ? », art. préc., n° 2.

Conclusion générale⁶³⁵

478. Au terme de ce rapport, il est manifeste que les outils de justice prévisionnelle (OJP) peuvent œuvrer à l'amélioration du système judiciaire (notamment en permettant une meilleure connaissance de l'activité judiciaire, en offrant une plus grande prévisibilité et donc une meilleure sécurité juridique, voire en encourageant le traitement amiable de certains litiges). Cependant, il est tout autant manifeste que l'utilisation des OJP peut aussi nuire à la qualité des décisions de justice, aux garanties découlant du droit au procès équitable ou au droit à la non-discrimination.

Dans ces conditions, l'auto-régulation du marché des OJP nous est apparue insuffisante pour garantir la confiance dans le système judiciaire. Au contraire, le rapport pointe la nécessité d'élaborer des procédures d'évaluation et de rendre ces procédures obligatoires. En effet, le travail conduit avec le Laboratoire national de métrologie et d'essais a montré que cette évaluation était possible à condition d'y consacrer le temps et les moyens nécessaires.

Par ailleurs, le rapport constitue un appel à la vigilance des utilisateurs d'OJP notamment en ce qu'il met en lumière leurs limites. Celles-ci peuvent être tant intrinsèques (sécurité insuffisante des données et risque de manipulation par un tiers ; non représentativité des données ; non pertinence des critères ou des paramètres ; confusion entre corrélations et causalités ; etc.) qu'extrinsèques (absence de véritable bénéfice dans l'utilisation ; appauvrissement du raisonnement ; suivisme ; privatisation de la justice ; etc.). Il est donc de la responsabilité des utilisateurs d'OJP de bien comprendre leur fonctionnement afin d'interpréter correctement le résultat produit. La vigilance implique en outre de conserver un haut niveau de compétence métier et d'expertise pour apprécier de manière critique le résultat proposé et ne pas hésiter à s'en extraire, ne serait-ce que par intuition. En effet, en matière de droit et de justice, il faut savoir faire preuve de sérendipité, autrement dit, conserver de l'intuition mais aussi de l'empathie. Le réel n'est pas entièrement réductible à de la « *data* », pas plus qu'une décision de justice n'est réductible à de la pure logique. Faire du droit ne se limite pas à faire du calcul, à viser la réalisation efficace d'objectifs mesurables prospères. Faire du droit c'est mettre en œuvre la pensée complexe chère à Edgar Morin⁶³⁶ : autrement dit associer la pensée critique, la pensée créative, et la pensée responsable.

⁶³⁵ Aurore Hyde

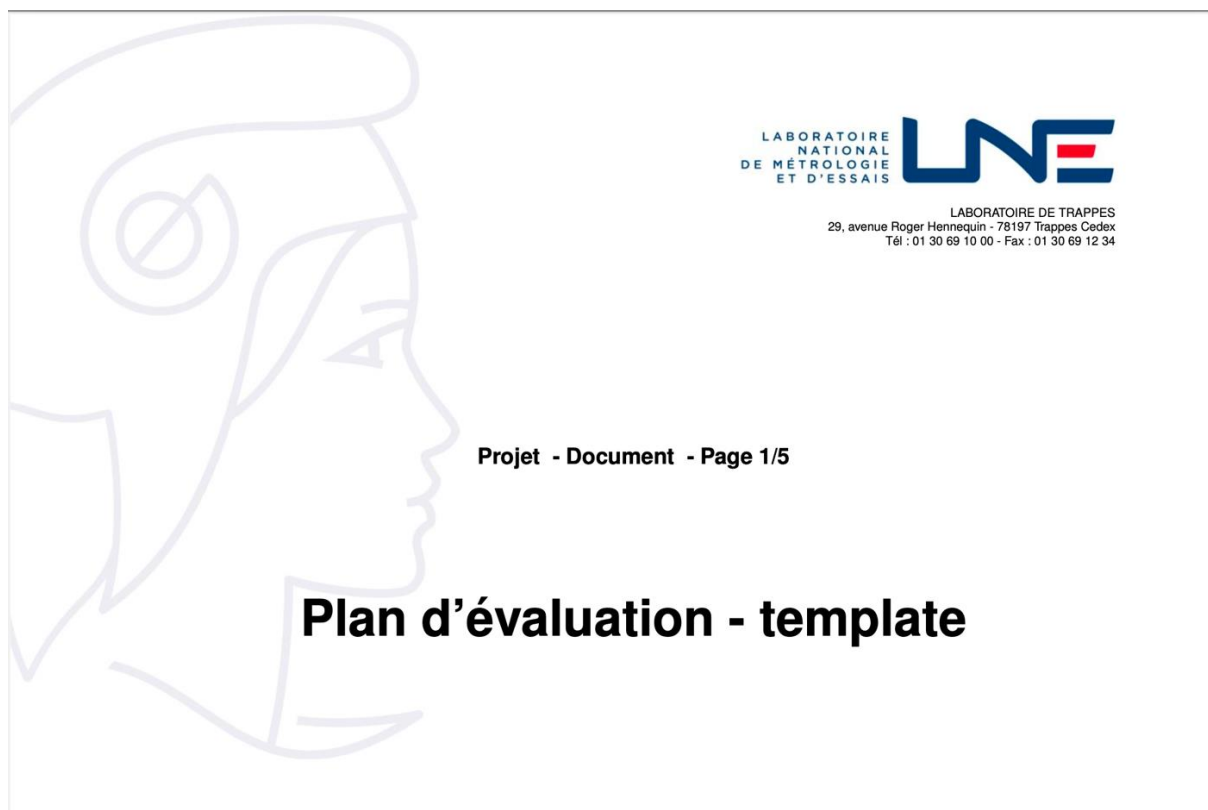
⁶³⁶ E. Morin, *Introduction à la pensée complexe*, Points, Essais, 2005

Annexe 1 – Modèle « analyse de risques »

(ici, Lexbase, pour LexisNexis le modèle est le même pour les risques liés à la thématisation)

Risque	Catégorie du risque	Description du risque	Gravité (1-5)	Probabilité de survenance (1-4)	Justification
Thématisation automatique de décisions					
Corruption des données reçues par un tiers	Automatisation du système	Des acteurs malveillants ajoutent des données volontairement erronées dans les bases interrogées par le système pour alourdir des décisions juridiques fausses pouvant conduire par la suite à de mauvaises décisions par les utilisateurs.			
Outils de décisions pertinentes	Automatisation du système	Du fait d'une défaillance du système, certaines décisions émises par les cours ne sont pas récupérées, conduisant à avoir une base de décisions non à jour. Cela peut ensuite conduire des utilisateurs à ne pas s'appuyer sur le corpus le plus à jour et leur faire défaut dans les décisions juridiques à prendre.			
Manque de documentation sur la validation de l'algorithme	Transparence et explicabilité	L'approche utilisée pour la recherche automatique de décisions juridiques n'a pas de documentation associée détaillant le processus de validation de l'algorithme, conduisant à un manque de confiance dans la performance du système.			
Variabilité des décisions juridiques	Complexité de l'environnement	La structure des décisions juridiques peut fortement varier dans le temps, conduisant le système à ne pas détecter les décisions pertinentes à récupérer, conduisant à faire à une base non à jour.			
Régression du système suite à une mise à jour	Cycle de vie du système	Les processus de validation et de non régression du système n'ont pas été mis en place ou ne sont pas suffisamment complets, conduisant à une non détection de la perte de performance du système suite à une mise à jour.			
Accumulation de la dette technique	Maturité de la technologie	L'approche utilisée étant déjà mature technologiquement, une trop grande confiance dans la performance de l'algorithme a conduit à une augmentation importante de la dette technique. Cela implique un coût de correction des problèmes de l'approche élevé.			
Données d'apprentissage biaisées	Risques liés à l'apprentissage Problèmes liés à l'hardware	Les données utilisées pour entraîner le système ne sont pas représentatives de tous les types de décisions juridiques pertinentes à récupérer, conduisant à des pertes pour la base de données. La base n'étant pas à jour, cela a un impact direct pour les décisions prises ensuite par les utilisateurs.			
Anonymisation des documents					
Informations confidentielles non anonymisées	Automatisation du système	Suite à une défaillance du système, certaines données confidentielles présentes dans une décision juridique ne sont pas anonymisées, conduisant directement à un tort pour la personne concernée.			
Manque de documentation sur la validation de l'algorithme	Transparence et explicabilité	L'approche utilisée pour l'anonymisation de décisions juridiques n'a pas de documentation associée détaillant le processus de validation de l'algorithme, conduisant à un manque de confiance dans la performance du système.			
Variabilité de la structure des documents	Complexité de l'environnement	La structure des décisions juridiques peut fortement varier dans le temps, conduisant le système à ne pas toujours anonymiser les informations critiques dans les documents.			
Régression du système suite à une mise à jour	Cycle de vie du système	Les processus de validation et de non régression du système n'ont pas été mis en place ou ne sont pas suffisamment complets, conduisant à une non détection de la perte de performance du système suite à une mise à jour. Cela peut conduire à la non anonymisation de données confidentielles.			
Immaturité de l'algorithme d'anonymisation	Maturité de la technologie	L'approche utilisée repose sur une technologie encore très expérimentale, ce qui conduit à un nombre important d'erreurs potentielles d'anonymisation.			
Correspondance des documents – chaîne de contenu					
Données d'apprentissage trop limitées	Risques liés à l'apprentissage	Du fait d'un corpus d'apprentissage d'une taille trop limitée, l'algorithme n'est pas à même d'anonymiser correctement tous les documents, conduisant à laisser visible des informations confidentielles, ou au contraire anonymiser des parties non pertinentes dans le document.			
Chaîne de contenu erronée	Automatisation du système	La création des chaînes de contenu est erronée à ne pas avoir une chaîne de contenu complète. Ce manque d'information a ensuite un impact direct sur les informations à disposition des utilisateurs.			
Manque de documentation sur la validation de l'algorithme	Transparence et explicabilité Complexité de l'environnement	L'approche utilisée pour l'anonymisation de décisions juridiques n'a pas de documentation associée détaillant le processus de validation de l'algorithme, conduisant à un manque de confiance dans la performance du système.			
Régression du système suite à une mise à jour	Cycle de vie du système	Les processus de validation et de non régression du système n'ont pas été mis en place ou ne sont pas suffisamment complets, conduisant à une non détection de la perte de performance du système suite à une mise à jour.			
Immaturité de l'algorithme d'anonymisation	Maturité de la technologie	L'approche utilisée repose sur une technologie encore très expérimentale, ce qui conduit à des chaînes de contenu souvent erronées.			
Données d'apprentissage trop limitées	Risques liés à l'apprentissage	Du fait d'un corpus d'apprentissage d'une taille trop limitée, l'algorithme n'est pas à même de mettre en relation les mots clés de tous les documents, empêchant ainsi de créer une chaîne de contenu complète.			

Annexe 2 – Modèle « plan d'évaluation »



La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.

Laboratoire national de métrologie et d'essais • Établissement public à caractère industriel et commercial
Siège social : 1, rue Gaston Boissier 75724 Paris Cedex 15 • Tél. : 01 40 43 37 00 • Fax : 01 40 43 37 37
info@lne.fr • lne.fr • RCS Paris 313 320 244 • NAF : 7120B • TVA : FR 92 313 320 244

Table des matières

1	Glossaire	3
2	Introduction	4
	2.1 Contexte	4
	2.2 Organisation du travail	4
3	Plan d'évaluation	4
	3.1 Description des tâches	4
	3.2 Entrées et sorties du système	4
	3.3 Description des données d'évaluation	4
	3.4 Métriques d'évaluation	4
	3.5 Définition du protocole d'évaluation	4

1 Glossaire

Métrique d'évaluation : formule mathématique qui sert à évaluer ou à apprécier les résultats d'une évaluation.

Critère d'évaluation : élément ou propriété d'après lequel un jugement d'évaluation est forgé. Pour porter ce jugement, il est nécessaire de disposer, pour ce critère, d'une métrique servant de point de comparaison, ou d'un seuil de succès.

Système : une composante/brique technologique qui gère une tâche (prédiction d'une population, détection sur image).

Tâche d'évaluation : action que la solution devra effectuer dans certaines conditions et qui sera soumise à l'évaluation.

2 Introduction

2.1 Contexte

2.2 Organisation du travail

3 Plan d'évaluation

3.1 Description des tâches

Définir précisément la fonctionnalité évaluée, sur quelle technologie la fonctionnalité est installée, la caractéristique de la fonctionnalité évaluée et enfin les éléments apportant de l'information supplémentaire pour l'évaluation.

3.2 Entrées et sorties du système

Description des données d'entrées de la fonctionnalité d'IA à évaluer – par exemple des décisions de justice issues de cours de justice spécifiques – et les sorties produites par la fonctionnalité – par exemple le thème de ces décisions.

3.3 Description des données d'évaluation

Description des données qui vont être utilisées pour évaluer la fonctionnalité d'IA. Doit décrire l'origine des jeux de données (par exemple interne à l'entreprise, collecté ou acheté), les processus mis en œuvre pour collecter les données et corriger les erreurs potentielles contenues dans le jeu de données, le processus d'annotation des données et l'identification des facteurs d'influence, c'est-à-dire les caractéristiques des données pouvant avoir un impact sur la performance et le comportement du système.

3.4 Métriques d'évaluation

Décrire les métriques d'évaluation utilisées pour comparer les données de référence avec les sorties de la fonctionnalité d'IA.

3.5 Définition du protocole d'évaluation

Décrire le processus général utilisé pour évaluer le système : les méthodes de référence utilisées (article scientifique, normes . . .), les différents tests réalisés si il y en a plusieurs, les paramètres de configuration en fonction de l'environnement ainsi que les différentes analyses qui seront mises en place dans le rapport d'évaluation : évaluation de la performance en fonction des facteurs d'influence, analyse statistique de la significativité des différents facteurs, etc.

Trappes, 26 août 2024

Expertise et rapport :

Guillaume BERNARD,
Ingénieurs en évaluation des systèmes d'IA, LNE

Validation :

Virginie BARBOSA, Chef de projets IA et de cybersécurité, LNE



Annexe 3 – Questionnaire « *compliance* entreprise legaltech »

Nous vous remercions d'avoir accepté de répondre à l'enquête ci-jointe. Les informations transmises ont vocation à alimenter la réflexion pour les axes 1 et 2 du projet de recherche. Vous pouvez bien entendu nous préciser les éléments que vous souhaitez nous communiquer exclusivement à titre confidentiel.

I. L'entreprise

- 1) Pourriez-vous présenter votre entreprise (date de création, forme, objet social, effectif, chiffre d'affaires, appartenance à un groupe, etc.) ?
- 2) Accepteriez-vous de nous communiquer les principales évolutions de votre chiffre d'affaires depuis la création de l'entreprise (ou sur une plus courte période) ?
- 3) Quelle est la part du chiffre d'affaires affectée à la recherche et développement en général (et à l'innovation si spécifique ou différent) ?
- 4) Quelle est la composition de la main d'œuvre dans l'entreprise ? Avez-vous des difficultés à recruter certains profils ?
- 5) Y-a-t-il dans l'entreprise un « *compliance officer* » ?
- 6) Si oui :
 - a. Depuis quand ?
 - b. Quelle est sa formation ?
 - c. Pourriez-vous décrire son activité (domaine et modalités d'intervention) ?
 - d. Serait-il possible de le rencontrer pour un entretien ?
- 7) Si non :
 - a. Avez-vous mis en place, de manière générale, des procédures de *compliance* dans l'entreprise ?
 - b. Auquel cas, quelles sont les personnes (leurs fonctions) affectées à ces missions ?
- 8) De manière générale, est-ce que les outils de *compliance* vous paraissent utiles pour assurer la dimension éthique de votre activité ? Quelles sont éventuellement leurs limites ? Par rapport à votre expérience et à vos besoins, que suggèreriez-vous pour les améliorer ?
- 9) Votre entreprise a-t-elle un comité éthique ? Auquel cas, pourriez-vous présenter sa composition et ses attributions ?

II. Présentation de l’outil de justice prévisionnelle

- 1) Pouvez-vous présenter le fonctionnement de votre OJP ?
- 2) Quelle est actuellement votre méthode de récupération des données judiciaires brutes ?
- 3) Que va changer pour vous l’*open data* ? Que pensez-vous de ce changement ?
- 4) Comment vos bases de données sont-elles actualisées (temporalité, moyens, etc.) ?
- 5) Quelle est la valeur ajoutée de votre outil par rapport aux données judiciaires brutes ? Quels sont les choix opérés pour le traitement des données brutes (critères, procédures, organisation et classement des données, etc.) ? Et comment ces choix sont-ils faits ?
- 6) Diriez-vous que votre outil intègre de l’intelligence artificielle ? Si oui, pourquoi ? Si non, pourquoi ?
- 7) Depuis quand travaillez-vous à la conception de votre outil ? Quelles ont été les évolutions importantes ?
- 8) Qui sont les acteurs impliqués en interne dans la sélection et le traitement des données (en nombre, et en profil-métier) ?
- 9) Des activités sont-elles externalisées ? Si oui, lesquelles ? Pourquoi ce choix organisationnel ?
- 10) Quelles sont les principales difficultés que vous avez rencontrées dans la conception de cet outil ? Avez-vous rencontré des difficultés de financement ?
- 11) Quelle est la proportion de la R&D (ou de l’innovation si différent) affectée à la conception de votre outil ?

III. Considérations d’ordre éthique et juridique

- 1) Avez-vous rencontré des problèmes éthiques dans la conception de votre outil ? Si oui, lesquels ? Comment les avez-vous réglés ?
- 2) Avez-vous pris connaissance de la Charte éthique de la CEPEJ sur l’utilisation de l’IA dans les systèmes judiciaires et leurs environnements ? Le cas échéant :
 - a. Pensez-vous avoir une vision claire des principes et recommandations qu’elle formule ?
 - b. Quel impact cet instrument a-t-il eu sur vos pratiques quant à la conception de votre outil de jurimétrie ?
 - c. Avez-vous intégré les exigences de la charte dans votre R&D ? Comment ?

- 3) Avez-vous une procédure de *compliance* spécifique pour la conception de votre outil de jurimétrie ? Si oui, pourriez-vous la décrire ? Sinon, pourquoi ?
- 4) Comment assurez-vous la sécurité et la confidentialité des données ?
- 5) Avez-vous pris des mesures spécifiques pour assurer une conception et une mise en œuvre des outils compatibles avec les droits fondamentaux, comme une analyse d'impact par exemple ? Si oui, lesquelles ?
- 6) Comment veillez-vous à prévenir la création ou le renforcement de discriminations entre les groupes d'individus ?
- 7) Comment garantissez-vous que les données traitées n'ont pas été modifiées par rapport aux données sources ?
- 8) Les méthodologies de traitement des données sont-elles facilement compréhensibles par l'utilisateur (accessibilité et intelligibilité) ?
- 9) Dans quelle mesure l'utilisateur peut-il maîtriser la fiabilité des résultats proposés ?
- 10) Tenez-vous à jour une documentation décrivant les processus de conception, de développement, et d'évaluation de votre outil ? Auquel cas, que contient précisément cette documentation (par item) ?

IV. Normalisation technique

- 1) Avez-vous connaissance du référentiel pour la certification de l'IA élaboré sous l'égide du Laboratoire national de métrologie et d'essais ?
- 2) Quelle connaissance avez-vous des normes techniques internationales, notamment pour une vue d'ensemble des thématiques liées à l'IA de confiance (ISO/IEC TR 24028), ou pour l'analyse des biais propres à l'IA (ISO/IEC TR 24027), ou encore à propos du Big Data (ISO/IEC 20546 et ISO/IEC TR 20547) ?
- 3) Vous référez-vous à ces normes dans la conception de votre outil de jurimétrie ?

V. Analyse des risques

- 1) Êtes-vous familier des méthodologies d'analyse de risques pour les outils informatiques ?
- 2) Avez-vous déjà réalisé une analyse de risques pour votre outil de jurimétrie ?
- 3) Quelle connaissance avez-vous des ressources documentaires des Techniques de l'Ingénieur sur l'analyse des risques, ainsi que des projets de normes en cours sur l'analyse de risques pour les systèmes d'IA (ISO/IEC 23894) ?

VI. Analyse du marché

- 1) À qui s'adresse principalement votre outil ? Et subsidiairement ?
- 2) Quels sont les besoins des utilisateurs satisfaits par votre outil ? Pourquoi ?
- 3) Quelle est la nature des services offerts relativement à votre outil (logiciel « brut », services d'accompagnement et de formation au logiciel, maintenance, mise à jour, etc.) ?
- 4) Quel est le prix de vos prestations ? Proposez-vous des offres adaptées en fonction des catégories de clients, des besoins des utilisateurs, etc. ?
- 5) Quelle a été l'évolution du chiffre d'affaires de votre outil de jurimétrie ?
- 6) Vos contrats prévoient-ils des clauses limitatives ou exclusives de responsabilité à votre profit ? Auquel cas, s'agit-il de clauses-types ou de clauses négociées ? Pouvez-vous nous les communiquer ?
- 7) Quels sont vos principaux concurrents ?
- 8) Comment la concurrence s'exerce-t-elle (prix, différenciation des services, disponibilité, etc.) ?
- 9) Quel est le coût de production de vos services ? Comment fixez-vous vos prix par rapport à ce coût ?
- 10) Comment décririez-vous votre avantage compétitif par rapport à vos principaux concurrents ?
- 11) Quelle sera selon vous la probable évolution du marché dans les 5 ans à venir ?
- 12) Diriez-vous que le marché des outils de jurimétrie est un marché comme les autres ? Le cas échéant, quelles sont les contraintes particulières pesant éventuellement sur votre activité ?

Bibliographie

NB : il existe une différence de présentation des références bibliographiques selon le domaine de recherche, en l'occurrence droit ou économie. Les références ont été laissées telles qu'elles ont été utilisées par leur auteur selon sa discipline d'origine.

Thèses, essais, monographies

Andler D., *Intelligence artificielle, intelligence humaine : la double énigme*, Gallimard, Essais, 2023

Andreu L. (dir.), *Des véhicules autonomes. Une offre de loi*, Dalloz, 2018

Benezech L., *La diffusion des droits fondamentaux dans l'ordre juridique interne sous l'influence de la Convention européenne des droits de l'Homme. : contribution à l'étude de la fondamentalisation des droits*, thèse Clermont-Auvergne, 2019

Bradford A., *Digital Empires. The Global Battle to Regulate Technology*. Oxford University Press, 2023

Brownsword R., *Law, Technology and Society: Reimagining the Regulatory Environment*, Routledge, New York, 2019

Calmes S., *Du principe de protection de la confiance légitime en droits allemand, communautaire et français*, Nouvelle bibliothèque des thèses, Dalloz, 2001

Carval S., *La construction de la responsabilité civile. Controverses doctrinales*, PUF, 2001

Cassart A., Catteau A. et Coton F., *Le droit des MachinTechs (FinTech, LegalTech, MedTech...) : état des lieux et perspectives*, Larcier, 2018

Desmoulin S. et Le Metayer D., *Décider avec les algorithmes. Quelle place pour l'Homme, quelle place pour le droit ?*, Dalloz, 2020

Diver L. E., *Disprudence: Code as Law Rebooted*, Future Law, 2023

Domingo P., *The Master Algorithm*, Penguin, Science/Tech, 2015

Epstein L., J. Knight, 1998. *The Choices Justices Make*, Washington, DC, CQ Press

Eidenmüller H., Wagner G., *Law by algorithm*, Mohr Siebeck, 2021

Franck P., « La normalisation des produits industriels », PUF, 1981

Garapon A., *Bien Juger. Essai sur le rituel judiciaire*, Odile Jacob, 2001

- Garapon A. et Lassègue J., *Justice digitale*, PUF, 2018
- Garapon A. et Lassègue J., *Le numérique contre le politique*, PUF, 2021
- Goodsell C. T., *The social meaning of civic space: studying political authority through architecture*, University Press of Kansas, 1988
- Harcourt B. E., 2006. *Against Prediction: Profiling, Policing, and Punishing in an Actuarial Age*, Chicago, IL: University of Chicago Press
- Houlou-Garcia A. et Maugenet Th., *Le théorème d'hypocrite. Histoire de la manipulation par les chiffres*, Albin Michel, 2020
- Huttner L., *La décision de l'algorithme, Étude de droit privé sur les relations entre l'humain et la machine*, préf. J. Rochfled, Dalloz, coll. Nouv. bibliothèque des thèses, vol. 235, 2024
- Jacquemin H. et De Streel A., *L'intelligence artificielle et le droit*, Larcier, 2017
- Jean A., *De l'autre côté de la machine*, Éditions de l'Observatoire, coll. « De facto », 2019
- Jean A., *Les algorithmes font-ils la loi*, Éditions de l'Observatoire, coll. « Essais », 2021
- Karpik L., 2007. *L'économie des singularités*, NRF Gallimard
- Katsh E. & Rainbinovich-Einy O., *Digital justice. Technology and the Internet of Disputes*, Oxford University Press, 2017
- Laffont J-J., J. Tirole, 1993. *A Theory of Incentives in Procurement and Regulation*, MIT Press.
- Latil A., *Le droit du numérique : une approche par les risques*, Dalloz, 2023
- Loury, G. C., 2008. *Race, Incarceration, and American Values*, Cambridge, MA: MIT Press
- Markou C. & Deakin S., *Is law computable? Critical Perspective on Law and Artificial Intelligence*, HART, 2020
- Méneceur Y., *L'intelligence artificielle en procès*, Bruylant, coll. « Macro droit – Micro droit », 2020
- Méneceur Y., *L'intelligence artificielle générative et les professionnels du droit*, LexisNexis, coll. Numérique & Droit, 2024
- Mérabet S., *Vers un droit de l'intelligence artificielle*, Dalloz, coll. « Nouvelle bibliothèque des thèses », 2020
- O'Neil C., *Weapons of Math Destruction: How Big Data increases inequality and threatens democracy*, NY Broadway Books, 2016
- Pasquale F., *The Black Box Society. The Secret Algorithms That Control Money and Information*, Harvard, Harvard University Press, 2015

Poinas E., *Le tribunal des algorithmes : juger à l'ère des nouvelles technologies*, Berger-Levrault éd., 2019

Ranouil M., *Les recours entre coobligés*, préf. Jourdain P., IRJS éditions, coll. « Bibliothèque André Tunc », 2014

Schneps L. et Colmez C., *Les maths au tribunal*, Seuil, coll. Science ouverte, 2015

Supiot A., *La gouvernance par les nombres*, Fayard, coll. « Poids et mesures du monde », 2015

Susskind R., *Tomorrow's Layers*, Oxford University Press, 2016

Thaler R.H, C. R. Sunstein 2010, *Nudge. La méthode douce pour inspirer la bonne décision*, Vuibert (traduction de Thaler R.H, C.R. Sunstein, 2008, *Nudge: Improving decisions about health, wealth and happiness*, New Haven, Yale University Press

Van den Branden A., *Les robots à l'assaut de la justice. L'intelligence artificielle au service des justiciables*, préf. Alexandre L., avant-propos Buyle J.-P., postface Garapon A., Bruylant, 2019

Vuitton X., *Le procès équitable. L'article 6-1 de la CEDH : état du droit et perspectives*, préf. Ch. Jamin, LGDJ, coll. Systèmes 2019

Violet F. et Schmidt-Szalewski J., *Articulation entre la norme technique et la règle de droit*, PUAM, 2003

Manuels, traités, autres ouvrages

Carbonnier J., *Droit civil – vol. I : Introduction*, PUF, coll. « Quadrige », 2004

Fabre-Magnan M., *Droit des obligations. Responsabilité civile et quasi-contrats*, PUF, 2021

Frison-Roche M.-A., *Droit de la compliance*, Dalloz, coll. « Précis », 2024 (à paraître)

G'sell F., *Justice numérique*, Dalloz, coll. « À savoir », 1^e éd., 2021

G'Sell F., *Regulating Under Uncertainty. Governance Options for Generative AI*, Stanford Cyber Policy Center, août 2024 (à paraître), disponible en ligne https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4918704

Grynbaum L., Le Goffic C. et Pailler L., *Droit des activités numériques*, Dalloz, 2023

Le Tourneau Ph., *Contrats du numérique informatiques et électroniques*, Dalloz, 2022

Manuel de formation sur l'intelligence artificielle et l'État de droit, UNESCO, 2023 : https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387331_fre

Nevejans N., *Traité de droit et d'éthique de la robotique civile*, LEH éd., 2017

Sudre F. et al., *Droit européen et international des droits de l'homme*, PUF, coll. Classiques, 2021, 15^e éd.

Terré F., Simler P., Lequette Y., Chénéde F., *Droit civil. Les obligations*, Dalloz, 13^e édition, 2022

Ouvrages collectifs, actes de colloques, dossiers spéciaux

Amrani-Mekki S. (dir.), *La justice prédictive*, actes du colloque du 12 février 2018 organisé par l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation à l'occasion de son bicentenaire, en partenariat avec l'université Paris-Dauphine PSL, Dalloz, 2018, 122 p.

Barbé V., Koumpli Ch. et Mauclair S. (dir.), *Droits fondamentaux et intelligence artificielle*, Éditions l'Épitoge, 2022

Bensamoun A. et Loiseau G., *Droit de l'intelligence artificielle*, LGDJ, 2022

Benyekhief K. et Gélinas F., *Le règlement en ligne des conflits : enjeux de la cyberjustice*, préf. Canivet G., éd. Romillat, 2004

Benyekhlef K., Bayley J., Burkell J., Gélinas F., *e-Access to Justice*, University of Ottawa Press, 2016

Blanc N. et Mekki M. (dir.), *Le juge et le numérique : un défi pour la justice du XXI^e siècle*, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2019

Borga N., Marin J.-Cl. et Roda J.-Ch. (dir.), *Compliance : l'entreprise, le régulateur et le juge*, coll. « Thèmes et commentaires », Dalloz 2018

Breen E. (dir.), *Évaluer la justice*, PUF, Paris, 2002

Boy L., « Normes techniques et normes juridiques », *Cahiers Cons. constit.* 2007, n° 21

Brake J., « Co-régulation or Capitulation ? Addressing conflicts arising by AI and standardization », *Lex-Electronica.org*, n° 25-2, 2020

Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant (dir.), *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, Bruylant, 2023

Clavier J.-P. (dir.), *L'algorithmisation de la justice*, Larcier, Coll. « Création Information Communication », 2020

Frison-Roche M.-A. (dir.), *Régulation, Supervision, Compliance*, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2017

Frison-Roche M.-A. (dir.), *Pour une Europe de la Compliance*, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2019

Frison-Roche M.-A. (dir.), *Les outils de la compliance*, Dalloz, coll. « Thèmes et commentaires », 2021

Gout O. (dir.), *La responsabilité civile et l'intelligence artificielle*, Bruylant, 2022

« La justice prédictive », *Archives de philosophie du droit*, Dalloz, t. 60, 2018

Jeuland E. (dir.), « Les défis de la justice numérique », Dossier spécial in *Les Cahiers de la Justice*, 2009, n°2, p. 193 et s.

Le Goff J. et Onnée S. (dir.), *Puissances de la norme : défis juridiques et managériaux des systèmes normatifs contemporains*, Caen, EMS, 2017

« Les fondements juridiques de la responsabilité numérique », Dalloz IP/IT, 2020 p. 656 et s.

« Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ? », actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s'est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024

Sayn I. (dir.), *Le droit mis en barèmes*, Dalloz, 2014

Thibierge C. (dir.), *La force normative. Naissance d'un concept*, LGDJ, Hors collection, 2009

Articles, chapitres d'ouvrages

Abiteboul S. et G'ssell F., « Les algorithmes pourraient-ils remplacer les juges ? », in *Le Big Data et le droit*, Dalloz, coll. « Thèmes et Commentaires », 2019 : <https://inria.hal.science/hal-02304016v2/>

Adomavicius G., J. C. Bockstedt, S. P. Curley, J. Zhang, 2013. "Do Recommender Systems Manipulate Consumer Preferences? A Study of Anchoring Effects", *Information Systems Research*, 24, n° 4, p. 956-975.

Akerlof G. A., 1970. "The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism", *The Quarterly Journal of Economics*, 84, n° 3, p. 488-500.

Aletras N., D. Tsarapatsanis, D. Preoimiuc-Pietro, V. Lampos, 2016. « Predicting judicial decisions of the European Court of Human Rights: a Natural Language Processing perspective », *PeerJ Computer Science*, p. 3-19.

Alon-Barkat S., M. Busuioc, 2023. “Human–AI Interactions in Public Sector Decision Making: “Automation Bias” and “Selective Adherence” to Algorithmic Advice”, *Journal of Public Administration Research and Theory*, 33, p. 153–169.

Angwin J., Larson J., Mattu S., Kirchner L., May 23, 2016, “Machine Bias”, *Propublica* : <https://www.propublica.org/article/machine-bias-risk-assessments-in-criminal-sentencing>

Anwar S., P. Bayer, R. Hjalmarsson, 2012. “The impact of jury race in criminal trials”, *Quarterly Journal of Economics*, 127, n° 2, p. 1017 et s.

Anwar S., P. Bayer, R. Hjalmarsson, 2019a. “Politics in the courtroom: Political ideology and jury decision making”, *Journal of the European Economic Association*, 17, n° 3, p. 834 et s.

Anwar S., P. Bayer, R. Hjalmarsson, 2019b. “A Jury of Her Peers: The Impact of the First Female Jurors on Criminal Convictions”, *The Economic Journal*, 129, n° 618, p. 603 et s.

Archambault L., « La réparation des dommages causés par l’intelligence artificielle : le droit français doit évoluer », *La Gazette du Palais*, 2018, n°9, p. 17.

Ares C., A. Rankin, H. Sturz, 1963. “The Manhattan Bail Project: An Interim Report on the use of Pre-Trial Parole”, *New York University Law Review*, 38, p. 67 et s.

Arnold D., W. S. Dobbie, P. Hull, 2020. “Measuring Racial Discrimination in Bail Decisions”, NBER Working Paper 26999

Artificial Intelligence », *La Revue des juristes de Science Po*, 2024, n° 25

Artificial Intelligence », *La Revue des juristes de Science Po*, 2024, n° 25, p. 42 et s.

Auby, J.-B., « Le dialogue de la norme étatique et de la compliance », in *Régulation, Supervision, Compliance*, Frison-Roche M.-A. (dir.), Dalloz, coll. Régulation, 2017, p. 101 et s.

Auger A., La justice prévisionnelle : état des lieux, *Expertise des systèmes d’information*, 01/05/2018, n° 435, p. 184 et s.

Bacache M., « Chapitre 3 – Intelligence artificielle et droits de la responsabilité et des assurances », in Bensamoun A. et Loiseau G. (dir.), *Droit de l’intelligence artificielle*, LGDJ, 2019, p. 69.

Bacache-Beauvallet M., « Les indicateurs de performance au sein des services publics : difficultés et effets pervers », in *Évaluer la justice*, dir. Breen E., 2002, p. 221 et s.

Barraud B., « Un algorithme capable de prédire les décisions des juges : vers une robotisation de la justice ? », *Les Cahiers de la Justice*, 2017/1, p. 121 et s.

Barraud B., « Le droit en datas : comment l’intelligence artificielle redessine le monde juridique – Partie I : La dictature des algorithmes ou l’intelligence artificielle à la source du droit », *Revue Lamy droit immatériel*, 2019, n° 64, p. 49 et s.

Barraud B., « Le droit en datas : comment l'intelligence artificielle redessine le monde juridique – Partie II : Les nouvelles technologies juridiques ou l'intelligence artificielle au service du droit », *Revue Lamy droit immatériel*, 2019, n° 65, p. 44 et s.

Beaudouin V., W. Maxwell, 2023. « La prédiction du risque en justice pénale aux États-unis : l'affaire propublica-compas : l'éthique de l'IA en action », *Réseaux*, 4, n° 240, p. 71 et s.

Bensamoun A. et Loiseau G., « la gestion des risques de l'intelligence artificielle. De l'éthique à la responsabilité », *La Semaine juridique Édition générale*, 2017, 1203

Benyekhlef K. et Zhu J., « Intelligence artificielle et justice : justice prédictive, conflits de basse intensité et données massives », (2018) 30, *Les Cahiers de propriété intellectuelle*, p. 789 et s.

Bernatchez S., « La certification en tant que droit de la gouvernance », *Revue internationale d'éthique sociétale et gouvernementale* 2019, vol. 21, n° 1 : <https://journals.openedition.org/ethiquepublique/4248>

Besse Ph., Castets-Renard C., Garivier A., « Loyauté des décisions algorithmiques », Contribution au débat public initié par la CNIL : Éthique et numérique, 2017, hal-01544701 : <https://hal.science/hal-01544701/document>

Besse Ph. Et Castets-Renard C., « Responsabilité ex ante de l'AI act : entre certification et normalisation, à la recherche des droits fondamentaux au pays de la conformité », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 597 et s.

Bessermann B., « Les enjeux du développement de la responsabilité numérique pour les assureurs », *Dalloz IP/IT*, 2020, p.170.

Bidou G., Q. Hillebrand, Z. Hu, H. Pouzet, J. Rayssac, R. Rozenberg, J. Shi, M. Turlan, « COMPAS: Un outil impartial ou biaisé ? », in *Les controverses des Mines Paris*, 2022 : <https://controverses.minesparis.psl.eu/public/promo21/COMPAS.pdf>

Blumstein A., 2015. "Racial Disproportionality in Prison.", in R. Bangs et L. E. Davis (dir.), *Race and Social Problems*, p. 187–93, New York: Springer.

Boillot C., « Les dommages causés aux tiers par les objets connectés », in M. Behar-Touchais (dir.), *Les objets connectés*, IRJS, 2018, p. 81 et s.

Boine C., « La responsabilité civile liée à l'intelligence artificielle dans l'Union européenne », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 677 et s.

Bordalo P., N. Gennaioli, A. Shleifer, 2015. "Salience theory of judicial decision", *Journal of Legal Studies*, 44, n° 2, p. 803-843

Bordère C., « Le pantin algorithmique, ou l'omniabsence du justiciable face à la numérisation de la justice », *Les Cahiers de la Justice*, 2024, n° 1, p. 129 et s.

Borghetti J.-S., « Civil liability for artificial intelligence: what should its basis be ? », in Lohsse S., Schulze R. and Staudenmayer D., *Liability for artificial intelligence and the internet of things*, Nomo, 2018, p. 63 et s.

Bourreau-Dubois C., M. Doriat-Duban, B. Jeandidier, J-C. Ray, 2020. "Does gender diversity in panels of judges' matter? Evidence from French child support cases", *International Review of Law Economics*, vol. 63, article 105929

Buat-Ménard E. et Giambiasi P., « La mémoire numérique des décisions de judiciaires », *Recueil Dalloz*, 2017, p. 1483 et s.

Buat-Menard E., « La justice dite “ prédictive” : prérequis, risques et attentes - l’expérience française », *Les Cahiers de la Justice*, 2019, p. 269

Burrell J., 2016. “How the machine ‘thinks:’ Understanding opacity in machine learning algorithms”, *Big Data & Society*, 216, p. 1–12.

Butcher K., K. Park, A. Morrison Piehl, 2017. “Comparing Apples to Oranges: Differences in Women’s and Men’s Incarceration and Sentencing Outcomes”, *Journal of Labor Economics*, 35 (S1), p. 201–234

Cadiet L., « Technologies de l’information. Les promesses d’une justice dite prédictive reposant sur des décisions de justice déjà rendues sont à tempérer », *Revue Pratique de la prospective et de l’innovation*, 2018, entretien 2

Calzoialo E., « Intelligence artificielle et décisions de justice, dans une perspective comparatiste », *Revue Lamy droit civil*, 2019, n° 175, p. 1 et s.

Cappellina B., « Changer les tribunaux par la comparaison : la gouvernance européenne de l'organisation de la justice », *Les Cahiers de la Justice*, 2022, n°3, p. 435-446

Cappellina B., 2017a. « Évaluer l’administration de la justice dans les pays européens. Une co-construction entre Union européenne et Conseil de l’Europe », *Revue française d'administration publique*, vol. 1, n° 161, p. 59-72.

Cappellina B., 2017b. « Quantifier la qualité de la justice entre droits de l’homme et modernisation Une étude de la fabrique d’instruments d’évaluation des systèmes judiciaires au niveau européen », *Revue française de socio-économie*, 2, n° 19, p. 27-46.

Cassuto Th., « La justice à l’épreuve de sa prédictibilité », *Actualité juridique Droit pénal*, 2017, p. 334 et s.

Castets-Renard C., « Le livre blanc de la commission européenne sur l’intelligence artificielle : vers la confiance ? », *Recueil Dalloz*, 2020 p. 837 et s.

Champeil-Desplats V., « Droit, pluralité des modes de normativité et internormativité », *Revue des droits de l’homme*, 2019, n° 16 : <https://journals.openedition.org/revdh/6328>

Chassagnard-Pinet S., « Les usages des algorithmes en droit : prédire ou dire le droit », *Dalloz IP/IT*, 2017, p. 495 et s.

Chen D. L., A. Philippe, 2023. « Clash of norms judicial leniency on defendant birthdays », *Journal of Economic Behavior & Organization*, 211, p. 324-344.

Chen D. L., T. J. Moskowitz, K. Shue, 2016. “Decision Making under the Gambler’s Fallacy: Evidence from Asylum Judges, Loan Officers, and Baseball Umpires”, *Quarterly Journal of Economics*, 131, n°3, p. 1181–1242.

Chollet D., « La justice prédictive et les principes fondamentaux du procès civil », in « La justice prédictive », *Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 223 et s.

Christin A. 2017. “Algorithms in practice: Comparing web journalism and criminal justice”, *Big Data & Society*, July–December, p. 1–14.

Colombet H. et Gouttefangeas A., « La qualité des décisions de justice. Quels critères ? », *Droit et société*, 2013/1, n° 83, p. 155 et s. : <https://shs.cairn.info/revue-droit-et-societe1-2013-1-page-155?lang=fr>

Coulon C., « Du robot en droit de la responsabilité civile : à propos du dommage causé par des choses intelligentes », *Responsabilité civile et Assurances*, 2016, étude 6

Courtois G., « Robots intelligents et responsabilité : quels régimes ? Quelles perspectives ? », *Dalloz IP/IT*, 2016, p. 345 et s.

Cui G., ‘Evidence-Based Sentencing and the Taint of Dangerousness’, *Yale Law Journal*, vol. 125, 29 Feb 2016, <http://www.yalelawjournal.org/forum/evidence-based-sentencing-and-the-taint-of-dangerousness>

Czarnitzki D., G. P. Fernández, C. Rammer, 2023. « Artificial intelligence and firm-level productivity », *Journal of Economic Behavior and Organization*, 211, p. 188–205.

Danjaume G., « La responsabilité du fait de l’information », *La Semaine juridique Édition générale*, 1996, I, 3895

De Jong N., « État des lieux des legaltechs en France », *La Semaine juridique Édition générale*, 2019, suppl. n° 44-45, p. 31 et s.

Deffains B. et de Montcuit G., « Proposition d’un régime de responsabilité objective applicable au dommage causé par une machine auto-apprenante », *Revue trimestrielle de droit civil*, 2022, p. 257 et s.

Depew B., O. Eren, N. Mocan, 2017. “Judges, Juveniles, and In-Group Bias”, *Journal of Law and Economics*, 60, n° 2, p. 209-239.

Deumier P., « la hiérarchisation des décisions de justice - La hiérarchisation des décisions en amont et en aval », in *Quelle jurisprudence à l’ère des données judiciaires ouvertes ?*, Actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s’est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, 2024, n° 1007, 70014

Deumier P., « La justice prédictive et les sources du droit : la jurisprudence du fond », in « La Justice prédictive », *Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 49 et s.

Deumier P., « Open Data - Une autre jurisprudence », *La Semaine juridique Édition générale*, 2020, p. 473 et s.

Dietvorst B. J., J. P. Simmons, C. Massey, 2015. “Algorithm Aversion: People Erroneously Avoid Algorithms after Seeing Them Err”, *Journal of Experimental Psychology*, 144, n°1, p. 114–126

Doha K., S. Yeosol, K. Songyie, L. Sewang, W. Yanqin, S. Jungwoo, L. Daeho, 2023. « How should the results of artificial intelligence be explained to users? Research on consumer preferences in user-centered explainable artificial intelligence », *Technological Forecasting & Social Change*, 188, article 122343.

Dondero B., « Justice prédictive, la fin de l’aléa judiciaire ? », *Recueil Dalloz*, 2017, p. 532 et s.

Douville Th., « DataJust, une contribution à la transformation numérique de la justice », *La Semaine juridique Édition générale*, 2020, n° 19

Dupré J. et Lévy Véhel J., « L’intelligence artificielle au service de la valorisation du patrimoine jurisprudentiel », *Dalloz IP/IT*, 2017. 500

Dupré J., « Du droit saisi par l’IA au droit saisissant l’IA, éléments de réflexion », in « La justice prédictive », *Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 103 et s.

Englich B., Mussweiler T., Strack F., 2006. “Playing Dice With Criminal Sentences: The Influence of Irrelevant Anchors on Experts’ Judicial Decision Making”, *Personality and Social Psychology Bulletin*, 32, p. 188–200.

Épineuse H. et Garapon A., « Les défis d’une justice à l’ère numérique de “stade 3” », *Enjeux numériques*, n° 3, sept. 2018, Annales de l’école des Mines, p. 18 et s.

Eren O., Mocan, N., 2018. “Emotional judges and unlucky juveniles”, *American Economic Journal : Applied Economics*, 10, n° 3, p. 171–205.

Espeland W. N., Sauder M., 2007. “Rankings and reactivity: How public measures recreate social worlds”, *American Journal of Sociology*, 113, n°1, p. 1–40.

Fassiaux S. 2023. “Preserving Consumer Autonomy through European”Union Regulation of Artificial Intelligence: A Long-Term Approach”, *European Journal of Risk Regulation*, 14, n°4, Special Issue on Long-Term Risks and Future Generations, p. 710-730

Finkelstein M. O. & Fairley W. B., “A Bayesian Approach to Identification Evidence”, 83 *Harvard Law Review*, 489 (1970)

Finkelstein M. O. & Fairley W. B., “The Continuing Debate over Mathematics in the Law of Evidence: A Comment on “Trial by Mathematics””, 84 *Harvard Law Review*, 1801 (1971)

Fischer F. 2019. « L’éthique by design du numérique : généalogie d’un concept », *Sciences du design*, 2, n° 10, p. 61-67.

Fischman J. B., D. S. Law, 2009. “What Is Judicial Ideology, and How Should We Measure It?”, *Washington University Journal of Law & Policy*, 29, n° 1, p. 133-214.

Forest D., « La régulation des algorithmes, entre éthique et droit », *Revue Lamy droit de l’immatériel*, 2017, n° 137, p. 38 et s.

Frison-Roche M.-A., « Compliance et conformité : les distinguer pour les articuler », février 2024 : <https://mafr.fr/fr/article/compliance-et-conformite-les-distinguer-et-les-art/#:~:text=Distinguer%20les%20deux%20permet%20de,rôle%20majeur%20pour%20ce%20faire>

G'Sell F., « Vers l'émergence d'une « responsabilité numérique ? », *Dalloz IP/IT*, 2020, p. 153 et s.

Galbois-Lehalle D., « Responsabilité civile pour l'intelligence artificielle selon Bruxelles : une initiative à saluer, des dispositions à améliorer, *Recueil Dalloz*, 2021, p. 87 et s.

Garapon A., « Les enjeux de la justice prédictive », *Revue Pratique de la prospective et de l'innovation*, 2016, étude 4

Garoupa N., Gómez-Pomar F., Segura A., 2022. “Ideology and Career Judges: Reviewing Labor Law in the Spanish Supreme Court”, *Journal of Institutional and Theoretical Economics*, 178, n° 2, p. 170-190.

Garoupa N., Gómez-Pomar F., Grembi V., 2013, “Judging Politically: An Empirical Analysis of Constitutional Review Voting in the Spanish Constitutional Court”, *Journal of Law, Economics and Organization*, 29, n°3, p. 513-534.

Gazal-Ayal O., R. Sulitzeanu-Kenan, 2010. “Let My People Go: Ethnic In-Group Bias in Judicial Decisions—Evidence from a Randomized Natural Experiment”, *Journal of Empirical Legal Studies*, 7, n° 3, p. 403-428

Gélinas F., Camion C. & Bates K., « Forme et légitimité de la Justice – Regard sur le rôle des rituels judiciaires », *Revue interdisciplinaire d'études juridiques*, 2014, n° 72, p. 37 et s.

Gebu T., Morgenstern J. et alii, “Datasheets for Datasets”, working paper, 23 Mar 2018 (V1), Revised 19 Mar 2020: arXiv:1803.09010v7 [cs.DB]

Gérard L. et Mougenot D., « Justice robotisée et droits fondamentaux », in *Le juge et l'algorithme : juges augmentés ou justice diminuée*, dir. J.-B. Hubin, H. Jacquemin, et B. Michaux, Larcier, 2019, p. 13 et s.

Girard B., « L'algorithmisation de la justice et les droits fondamentaux du justiciable », in *L'algorithmisation de la justice*, dir. J.-P. Clavier, Larcier, Coll. « Création Information Communication », 2020, p. 181 et s.

Girard-Chanudet C., 2023. « ‘Mais l’algo, là, il va mimer nos erreurs !’ - Contraintes et effets de l’annotation des données d’entraînement d’une IA », *Réseaux*, 4, n° 240, p. 111-144.

Godefroy L., « Les algorithmes : quel statut juridique pour quelles responsabilités ? », *Contrats – Concurrence – Consommation*, 2018, étude 18

Goffi E., « L’institutionnalisation des normes éthiques dans le domaine de l’intelligence artificielle : une construction sociale à dépasser », *Revue Éthique et Numérique* 2022, 1, p. 18 et s., hal-03609891 : <https://hal.science/hal-03609891/document>

Goldszlagier J., « L’effet d’ancrage ou l’apport de la psychologie cognitive à l’étude de la décision judiciaire », *Les Cahiers de la Justice*, 2015/4, p. 507 et s.

Gornet M. et Maxwell W., « Intelligence artificielle : normes techniques et droits fondamentaux, un mélange risqué », *The Conversation*, 28 sept. 2022 : <https://theconversation.com/intelligence-artificielle-normes-techniques-et-droits-fondamentaux-un-melange-risque-189587>

Grimaldi C., « Responsabilité civile du fait du robot doué d’intelligence artificielle : faut-il donner une personnalité juridique au robot ? », *Contrats – Concurrence – Consommation*, 2018, p. 212 et s.

Grimaldi C., « Responsabilité civile du fait du robot doué d’intelligence artificielle : faut-il donner une personnalité juridique au robot ? », *Contrats – Concurrence – Consommation*, 2018, p. 212 et s.

Guiraud E., « Le rôle de l’éthique dans la mise en place d’une certification pour l’utilisation d’algorithmes dans le système juridique », *Éthique publique*, 2019, 21, n° 1, 18 p.

Gunning D., 2017. XAI – Explainable artificial intelligence (xAI), Tech. rep., Defense Advanced Research Projects Agency (DARPA)

Guthrie C., J.J. Rachlinsky et A.J. Wistrich, 2001. “Inside judicial mind”, *Cornell Law Review*, 86, p. 777-830.

Guthrie C., Rachlinski, J.J., Wistrich, A.J., 2007. “Blinking on the bench: how judges decide cases”, *Cornell Law Review*, 93, n°1, p. 1–44.

Hakenes H., I. Schnabel, 2014. “Regulatory capture by sophistication”, CEPR Discussion Paper No. DP10100, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2531688

Hao K., 2019. “Police across the US are training crime-predicting AIs on falsified data”. A new report shows how supposedly objective systems can perpetuate corrupt policing practices. *MIT Technology Review*, February 13, 2019 : <https://www.technologyreview.com/2019/02/13/137444/predictive-policing-algorithms-ai-crime-dirty-data>

Harnay S., T. Sachs, 2018. « La régulation de la gouvernance d’entreprise : de l’autorégulation à la co-régulation », *Revue d’économie financière*, n° 130, p. 42-53.

Heyes A., S. Saberian, 2019. “Temperature and Decisions: Evidence from 207,000 Court Cases”, *American Economic Journal: Applied Economics*, 11, n° 2, p. 238–265.

Hoekstra M., B. Street, 2021. “The Effect of Own-Gender Jurors on Conviction Rates”, *Journal of Law and Economics*, 64, n° 3, p. 513-537.

Homoki P., « Quelques usages de l’IA par les avocats », *Cahiers de droit de l’entreprise*, n°4, juillet 2019, dossier 2019

Hyde A., « Avocat et intelligence artificielle : quelles obligations, quelles responsabilités ? », *Recueil Dalloz*, 2019, p. 2107 et s.

Hyde A., « La compliance en matière d’IA », in *Memento Compliance*, dir. M. Roussille, E. Breen, A. Gaudemet, Éditions Francis Lefebvre, 2024 (à paraître)

Hyde A., « La loyauté de l’intelligence artificielle », *Expertises*, 2024 (à paraître)

Hyde A., « Plaidoyer pour l’inclusion des outils de jurimétrie dans le futur règlement européen sur l’intelligence artificielle », *La Semaine juridique Édition générale*, 2023, doct. 1112

Hyde A., « Procès équitable et intelligence artificielle », in *Droits fondamentaux et intelligence artificielle*, dir. Barbé V., Koumpli Ch. et Maclair S., Éditions l’Épitoque, 2022, p. 115 et s.

Hyde A., « Vers une cyber-éthique de la justice dite prédictive », « Vers une cyber-éthique de la justice dite prédictive », *Dalloz IP/IT*, 2019, p. 324 et s.

Hyde A., « La justice prédictive : enjeux et perspectives », déjeuners-débats IRJS, École de droit de la Sorbonne, 28 février 2019. Le document de travail est disponible aux Archives ouvertes, réf. hal-02149092 : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02149092/document>

Jensen M. C., W. H. Meckling, 1976. « Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure », *Journal of Financial Economics*, 3, n° 4, p. 305-360.

John-Mathews J-M., 2023. « Un cadre d’autorégulation pour l’éthique de L’IA : opportunités et défis », *Vie & sciences de l’entreprise*, 1, n° 216-217, p. 288- 311.

Johnson B., 2014. “Judges on Trial: A Reexamination of Judicial Race and Gender Effects across Modes of Conviction”, *Criminal Justice Policy Review*, 25, n°2, p. 159–184.

Kennedy R., 2001. “Racial Trends in the Administration of Criminal Justice”, in *America Becoming: Racial Trends and Their Consequences*, vol. 2, p. 1–20.

Kirat Th. et Sweeney M., « Comparaison d’applications de « justice prédictive » : le cas du contentieux de l’indemnisation du licenciement abusif, 2012-2016. Predictice, Dalloz-Jurisprudence chiffrée et JurisData Analytics », in « Justice et numérique : quelles révolutions ? », actes du séminaire e-juris Septembre 2018-Février 2019, coord. Sayn I., *La Semaine juridique Édition générale*, 2019, supplément au n° 44-45, p. 53 et s.

Kleinberg J., H. Lakkaraju, J. Leskovec, J. Ludwig, S. Mullainathan, 2018. “Human Decisions and Machine Predictions”, *Quarterly Journal of Economics*, 133, n°1, p. 237–93.

Kling, J. R., 2006. “Incarceration Length, Employment, and Earnings”, *American Economic Review*, 96, n° 3, p. 863–76.

Knepper M., 2018. “When the Shadow Is the Substance: Judge Gender and the Outcomes of Workplace Sex Discrimination Cases”, *Journal of Labor Economics*, 36, n°3, p. 623–664.

Kolkman D., F. Bex, N. Narayan, M. van der Put, 2024. “Justitia ex machina: The impact of an AI system on legal decision-making and discretionary authority”, *Big Data & Society*, April-June, p. 1–14.

Lachière C., « Intelligence artificielle : quel modèle de responsabilité ? », *Dalloz IP/IT*, 2020, p. 663 et s.

Lacour S., D. Piana, 2019. « Faites entrer les algorithmes ! Regards critiques sur la « justice prédictive », *Cités*, 4, n° 80, p. 47-60.

Lambert-Abdelgawad E., 2016. « La mesure de la performance judiciaire de la cour européenne des droits de l’homme : une logique managériale à tout prix ? », *Revue française d'administration publique*, vol. 3, n° 159, p. 819-834.

Lambin X. et Raizonville A., “From black box to glass box: algorithmic explainability as a strategic decision”, June 4, 2024 : https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4455428

Lamoureux M., « La causalité juridique à l’épreuve des algorithmes », *La Semaine juridique Édition générale*, 2016, p. 731 et s.

Lassègue J., « L’intelligence artificielle, technologie de la vision numérique du monde », *Les Cahiers de la Justice*, 2019/2, p. 205 et s.

Lebreton V., « la hiérarchisation des décisions de justice - À la recherche d'une hiérarchisation à parfaire - La pratique des juges du fond », *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70013

Lebreton-Derrien S., 2018. « La justice prédictive Introduction à une justice "simplement" virtuelle », *Archives de philosophie du droit*, tome 60, n°1, p. 3-21.

Lewkowicz G. et Sarf R., « Taking Technical Standardization of Fundamental Rights Seriously for Trustworthy Artificial Intelligence », *La Revue des juristes de Sciences Po*, n° 25, février 2024, p. 42-46

Lucas A., « La responsabilité civile du fait des choses immatérielles », in *Mélanges en l’honneur de Pierre Catala*, 2001, p. 817 et s.

Ludwig J., S. Mullainathan, 2021. “Fragile Algorithms and Fallible Decision-Makers: Lessons from the Justice System”, *Journal of Economic Perspectives*, 35, n° 4, p. 71–96.

Marique E. et Strowel A., « Gouverner par la loi ou les algorithmes : de la norme générale de comportement au guidage rapproché des conduites », *Dalloz IP/IT*, 2017, p. 517 et s.

Markou C. & Deakin S., « Ex Machina Lex: The Limits of Legal Computability » disponible sur https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3407856

Maxwell W. J., « Le contrôle humain pour détecter les erreurs algorithmiques », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 707 et s.

May-Ferrié S., « Les algorithmes à l'épreuve du procès équitable », *La Semaine juridique Édition générale*, 2018. 297

Mazeau L., « Technologies de l'information. Intelligence artificielle et responsabilité civile : le cas des logiciels d'aide à la décision médicale », *Revue Pratique de la prospective et de l'innovation*, 2018, n°1

Mazeau L., « Les enjeux de la normalisation technique dans le domaine de l'intelligence artificielle », *Cahiers Droit, Sciences & Technologies*, 2019, n° 6 : <https://journals.openedition.org/cdst/878>

Mekki M., « If code is law, then code is justice ? Droit et algorithmes », *La Gazette du Palais*, 27 juin 2017, n° 297, p. 10 et s.

Mendoza-Caminade A., « Le droit confronté à l'intelligence artificielle des robots : vers l'émergence de nouveaux concepts juridiques ? », *Recueil Dalloz*, 2016, p. 445 et s.

Méneceur Y., « DataJust face aux défis de l'intelligence artificielle », *La Semaine juridique Édition générale*, 2020, p. 1708 et s.

Méneceur Y., « Analyse des principaux cadres supranationaux de régulation de l'Intelligence artificielle : de l'éthique à la conformité », *Les temps électriques*, 27 mai 2021 : <https://lestempsselectriques.net/index.php/2021/05/27/analyse-des-principaux-cadres-supranationaux-de-regulation-de-lintelligence-artificielle-de-lethique-a-la-conformite/>

Méneceur Y., « Droits de l'homme, numérique et intelligence artificielle. La perspective du Conseil de l'Europe », in *Un droit de l'intelligence artificielle. Entre règles sectorielle et régime général, perspectives comparées*, dir. Castets-Renard C. et Eynard J., Bruylant, 2023, p. 135 et s.

Miller A. P., 2018. « Want Less-Biased Decisions? Use Algorithms », *Harvard Business Review*, 26 juillet, <https://hbr.org/2018/07/want-less-biased-decisions-use-algorithms>

Mitchell M., Wu S. *et alii*, "Model Cards for Model Reporting", FAT* '19: Conference on Fairness, Accountability, and Transparency, January 29-31, 2019, Atlanta, GA, USA : [arXiv:1810.03993v2](https://arxiv.org/abs/1810.03993v2) [cs.LG]

Mocan N., E. Tekin, 2010. « Ugly Criminals », *Review of Economics and Statistics*, 92, 1, p. 15-30.

Mouriesse E., 2018. « Quelle transparence pour les algorithmes de justice prédictive ? », *Archives de philosophie du droit*, tome 60, n°1, p. 125-145.

O'Neil C., *Weapons of Math Destruction: How Big Data increases inequality and threatens democracy*, NY Broadway Books, 2016

Ogus A., 1995. « Rethinking Self-Regulation », *Oxford Journal of Legal Studies*, vol. 15, p. 97-108.

Ouss A., A. Philippe, 2018. « “No Hatred or Malice, Fear or Affection”: Media and Sentencing », *Journal of Political Economy*, 126, n° 5, p. 2134-2178

Parasuraman R. & Riley V., “Humans and Automation: Use, Misuse, Disuse, Abuse”, *Human Factors*, 1997, Vol. 39, Issue 2

Pasquale F., G. Cashwell, 2018. “Prediction, persuasion, and the jurisprudence of behaviourism”, *University of Toronto Law Journal*, 68, Supplement 1, p. 63-81.

Peri M., 2017. « La régulation de l’“ubérisation” », *Dalloz IPIT*, n° 3, p.144-147.

Philippe A., 2020. « Gender Disparities in Sentencing », *Economica*, 87, n° 348, p. 1037-1077.

Philippe, A., 2015. « Vous jurez de n'écouter ni la haine ou la méchanceté... Les biais affectant les décisions de justice », *Les Cahiers de la Justice*, n° 4, p. 563 à 577.

Piana D., « La justice numérique : un panorama européen », *Les Cahiers de la Justice*, 2019/2, p. 257 et s.,

Ponsot D., « Le contrôle de proportionnalité en matière de contrats : l'exemple de cautionnement », in *Le juge judiciaire face au contrôle de proportionnalité*, Agresti J.-P. (dir.), PUAM, Coll. Droits, pouvoirs & sociétés, 2018, p. 108 et s.

Posner R. A., 1993. “What Do Judges and Justices Maximize? (The Same Thing Everybody Else Does)”, *Supreme Court Economic Review*, 3, p. 1-41

Pruss D., 2023. “Ghosting the Machine: Judicial Resistance to a Recidivism Risk Assessment Instrument.”, in *Proceedings of the 2023 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, p. 312–23. Association for Computing Machines.

Przygodzki-Lionet N., F. Laval, C. Blancher-Boulay, J. Forrierre, F. Vasseur-Lambry, 2024. « Juger contre soi-même. Perceptions des « biais de jugement » chez les auditeurs de justice », *Les Cahiers de la Justice*, 1, n° 1, p. 145-161.

Remy Ph., « Réflexions préliminaires sur le chapitre des délits », in F. Terré (dir.), *Pour une réforme de la responsabilité civile*, Dalloz, 2011, p. 15

Richardson R., J. M. Schultz, K. Crawford, 2019. “Dirty Data, Bad Predictions: How Civil Rights Violations Impact Police Data, Predictive Policing Systems, and Justice”, *New York University Law Review*, 94, p. 192-232.

Rivollier V. et Quézel-Ambrunaz Ch., « Pour une étude raisonnée de la jurimétrie », *Jurimétrie - Revue de la mesure des phénomènes juridiques*, 2022, 1, p. 5 et s., halshs-03813731

Roberge J.-F., « Le sentiment de justice. Un concept pertinent pour évaluer la qualité du règlement des différends en ligne ? », *Revue juridique de la Sorbonne* 2020, n°1 p. 5 et s.

Rochfeld J., « L'encadrement des décisions prises par algorithmes », *Dalloz IP/IT*, 2018, p. 39 et s.

Rouland M., « La normalisation technique (instrument de concurrence à la loi) », intervention lors du colloque : « Le droit mou, une concurrence faite à la loi », Université Paris Nanterre, 3 décembre 2004, intervention reprise sous forme d'article et accessible sur [glose.org : http://www.glose.org/CEDCACE7.pdf](http://www.glose.org/CEDCACE7.pdf)

Rouvière F., « La justice prédictive, version moderne de la boule de cristal », *Revue trimestrielle de droit civil*, 2017, p. 527 et s.

Rudin C., C. Wang, B. Coker, 2020. "The Age of Secrecy and Unfairness in Recidivism Prediction", *Harvard Data Science Review*, n° 21, hiver, 53 p.

Sayn I., B. Jeandidier, C. Bourreau-Dubois, 2012. « Les enjeux d'une table de référence pour fixer la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant », *Les Cahiers de la Justice*, 1, n°1, p. 141- 157.

Schanzenbach M., 2005. "Racial and Sex Disparities in Prison Sentences: The Effect of District-Level Judicial Demographics", *Journal of Legal Studies*, 34, n° 1, p. 57–92.

Scherer M., « Regulating artificial intelligence systems: risks, challenges, competencies, and Strategies ». *Harvard Journal of Law & Technology*, 29, 2016, 354

Segal J. A., H. J. Spaeth, 1993. *The Supreme Court and the Attitudinal Model*, Cambridge University Press.

Serverin E., « De l'informatique juridique aux services du justice prédictive, la longue route de l'accès du public aux décisions de justice dématérialisées », in « La Justice prédictive », *Archives de philosophie du droit*, 2018, t. 60, p. 23 et s.

Sommer J.-M., « La hiérarchisation des décisions de justice », in « Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ? », actes du colloque du 27 novembre 2023 qui s'est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70012

Spence M., 1973. "Job Market Signaling", *The Quarterly Journal of Economics*, 87, n° 3, p. 355-374.

Starr S. B., 2014. "Evidence-based sentencing and the scientific rationalization of discrimination", *Stanford Law Review*, 66, n° 4, p. 803–887.

Steffensmeier D., C. Hebert, 1999. "Women and Men Policymakers: Does the Judge's Gender Affect the Sentencing of Criminal Defendants?", *Social Forces*, 77, n°3, p. 1163–1196.

Tarissan F., « Algorithm and Machine Learning. The biases of predictive models under scrutiny », Workshop on Big Data in the Counter Terrorism Context, Asser Institute & ICCT, 25 January 2021

Taroni F. et Mangin P., « L'interprétation de la preuve scientifique : les juristes, les scientifiques et les probabilités », *Médecine et droit*, 1998, n° 30, p. 6 et s.

Tribe L. H., "Trial by Mathematics: Precision and Rituals in the Legal Process", 84 *Harvard Law Review*, 1329 (1971)

Tribe L. H., "The Continuing Debate over Mathematics in the Law of Evidence: A Further Critique of Mathematical Proof", 84 *Harvard Law Review*, 1810 (1971)

Tricoire E., « La responsabilité du fait des choses immatérielles », in *Mélanges en l'honneur de Philippe le Tourneau*, 2008, p. 983 et s.

Tversky A. & Kahneman D., "Judgement under Uncertainty: Heuristics and Biases", *Science*, vol. 185, n° 4157, p. 1124 (1974)

Vamparys X., « Ethique de l'intelligence artificielle : expliquer l'explicabilité », *Revue Banque* 2020, n° 842 : <http://www.revue-banque.fr/management-fonctions-supports/article/ethique-intelligence-artificielle-expliquer-explic>

Vanneuville R. et Pélicand A., « Juger avec des barèmes. Outils d'aide à la décision et rapport au travail dans la magistrature », *Sociologie du travail* [En ligne] 2024, vol. 66, n°1 : <https://journals.openedition.org/sdt/45455>

Vergès E., « Le juge face à la boîte noire : l'intelligence artificielle au tribunal », *Recueil Dalloz*, 2022, p. 1920 et s.

Vermeys N., « Le règlement en ligne des différends de cyberconsommation », in Lafond P.-Cl. et Gautrais V., *Le consommateur numérique : une protection à la hauteur de la confiance ?*, Cowansville, Yvon Blais, 2016, p. 257 et s.

Veyre L., « Les listes de discussion entre magistrats : vers une nouvelle forme de création et d'unification de la jurisprudence ? », *La Semaine juridique Édition générale*, 2017, p. 1336 et s.

Vuarin L., V. Steyer, 2023. « Le principe d'explicabilité de l'IA et son application dans les organisations », *Réseaux*, 4, n° 240, p. 179 et s.

Weller J.-M., « Les appuis matériels du raisonnement juridique : décider avec des papiers », in *Ethnographies du raisonnement juridique*, Colemans J., Dupret B. (dir.), LGDJ, 2018 : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01786932>

Wickers Th., « L'appropriation des technologies numériques par les professions réglementées – L'exemple de l'avocat », *Cahiers de droit de l'entreprise*, 2018, n° 3, dossier 18

Yeomans M., A. Shah, S. Mullainathan, J. Kleinberg, 2019. "Making sense of recommendations", *Journal of Behavioral Decision Making*, 32, 4, p. 403 et s.

Zenati-Castaing F., « Des décisions de justice à la jurisprudence - Vers une post-cassation », in « Quelle jurisprudence à l'ère des données judiciaires ouvertes ? », actes du colloque du 27

novembre 2023 qui s'est tenu à la Cour de cassation, *La Semaine juridique Édition générale*, supplément au n° 7 du 19 février 2024, 70019

Rapports, études, dossiers, fascicules

« Algorithmes : : contrôle des biais S.V.P. », Rapport de l'Institut Montaigne, mars 2020 : <https://www.institutmontaigne.org/ressources/pdfs/publications/algorithmes-contrôle-des-biais-svp.pdf>

« Algorithmes : biais, discrimination et équité », dir. Bertail P., Bounie D., Cléménçon S., Waelbroeck P., Telecom ParisTech, Fondation Abeona, février 2019 : <https://www.telecom-paris.fr/wp-content-EvDsK19/uploads/2019/02/Algorithmes-Biais-discrimination-equite.pdf>

« Algorithmes et droits humains. Étude du Conseil de l'Europe », Comité d'experts sur les intermédiaires d'internet (MSI-NET), DGI(2017)12, publiée en mars 2018, spéc. p. 46

« Chantiers de la justice – Transformation numérique », Beynel J.F. et Casas D., Rapport pour Madame la Garde des Sceaux, ministre de la justice, 2018

« Comment le numérique transforme le droit et la justice vers de nouveaux usages et un bouleversement de la prise de décision », dir. Godefroy L., Lebaron F., Lévy-Véhel J., Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2019

« Comment permettre à l'homme de garder la main ? », CNIL, 2017 : https://cnil.fr/sites/cnil/files/atoms/files/cnil_rapport_garder_la_main_web.pdf

« Donner du sens à l'intelligence artificielle », dir. Villani C., Rapport pour une stratégie nationale et européenne, 2018

“Draft UNESCO Guidelines for Use of AI Systems in Courts and Tribunals”, 2024 : <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000390781>

Fasc. 988 - « Droit de l'intelligence artificielle (droit international et droit européen) », Latil A., – *JurisClasseur Communication*, 24 juillet 2024

“Ethical Impact Assessment: A Tool of the Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence”, UNESCO, 2023 : <https://www.unesco.org/en/articles/ethical-impact-assessment-tool-recommendation-ethics-artificial-intelligence>

“Ethics by Design and Ethics of Use Approaches for Artificial Intelligence”, Guidance Note, European Commission, November 2021 : https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/docs/2021-2027/horizon/guidance/ethics-by-design-and-ethics-of-use-approaches-for-artificial-intelligence_he_en.pdf

« Étude relative à l'incidence des technologies de l'information et des communications sur la gestion de l'information dans l'administration québécoise », dir. Vermays N., Demoulin M., Amar E., Gaiffe C., Benyekhlef K., Étude préparée à l'attention du ministre de la Justice du Québec, 2017

“Harmonizing Artificial Intelligence: The role of standards in the EU AI Regulation”, McFadden M., Jones K., Taylor E., Osborn G., Oxford Information Labs, 2021 : <https://oxcaigg.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/11/2021/12/Harmonising-AI-OXIL.pdf>

« L'apport du droit de la compliance à la gouvernance d'Internet », Frison-Roche M.-A., Rapport au ministre en charge du Numérique, Avril 2019

« L'IA Act : Réglementation européenne de l'IA et impacts sur les Systèmes utilisés dans le champ du droit et de la justice », Claire Strugala, Ministère de la Justice, Secrétariat général, 2024, disponible sur le site de l'association OpenLaw : <https://cloud.openlaw.fr/s/G7mq4zNMs2aPaHx>

« L'open data des décisions de justice », dir. Cadet L., Rapport à Madame la garde des Sceaux, 2017

« La barémisation de la justice : une approche par l'analyse économique du droit », dir. Bourreau-Dubois C. Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2019 : <http://www.gip-recherche-justice.fr/publication/la-baremisation-de-la-justice-une-approche-par-lanalyse-economique-du-droit/>

« La barémisation de la justice », dir. Gerry-Vernières S., Rapport pour la Mission de recherche Droit et Justice, 2019: <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02490767>

« La diffusion des données décisionnelles et la jurisprudence », dir. Cadet L., Chainais C. et Sommer J.-M, rapp. Jobert S. et Jond-Necand E., Rapport remis à la première présidente de la Cour de cassation et au procureur général près la Cour de cassation, juin 2022 : <https://www.courdecassation.fr/toutes-les-actualites/2022/06/14/la-diffusion-des-donnees-decisionnelles-et-la-jurisprudence-quelle>

« Le dépôt technologique des documents », dir. Vermeys N., Amar E., Gautrais V., Étude présentée au ministère de la Justice du Québec, 2016

« Le droit souple », *Étude annuelle du Conseil d'État*, La documentation française, 2013

« Le e-règlement extrajudiciaire des différends. Le déploiement d'une justice alternative en ligne », dir. S. Chassagnard-Pinet, rapport pour l'Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, décembre 2021 : <https://gip-ierdj.fr/fr/publications/le-e-reglement-extrajudiciaire-des-differends-le-deploiement-dune-justice-alternative-en-ligne/>

« Le juge du 21^{ème} siècle. Un citoyen acteur, une équipe de justice », Delmas-Goyon, P., Rapport à Madame la garde des Sceaux, 2013 : <https://www.vie-publique.fr/rapport/33709-le-juge-du-21eme-siecle-un-citoyen-acteur-une-equipe-de-justice>

« Les barèmes (et autres outils techniques d'aide à la décision) dans le fonctionnement de la justice », dir. Sayn, I., Perrocheau, V., Favier, Y., Merley, N., Rapport pour la Mission de

recherche Droit et Justice, 2019, en ligne : <https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-02283040v2>

« Les enjeux de la normalisation technique internationale : entre environnement, santé et commerce international », dir. Brosset E. et Truilhé-Marengo È., La documentation française, 2006

« Lignes directrices sur la conduite du changement vers la Cyberjustice : Bilan des dispositifs déployés et synthèse de bonnes pratiques », CEPEJ, 7 décembre 2016 : <https://edoc.coe.int/fr/efficacite-de-la-justice/7498-lignes-directrices-sur-la-conduite-du-changement-vers-la-cyberjustice-bilan-des-dispositifs-deployes-et-synthese-de-bonnes-pratiques.html>

« L'intelligence artificielle générative et les métiers du droit : agir plutôt que subir », Rapport d'information du Sénat, n° 216 (2024-2025), du 18 décembre 2024 : <https://www.senat.fr/notice-rapport/2024/r24-216-notice.html>

« Livre blanc des étudiants de la Clinique de l'École de droit : les enjeux éthiques de la justice prédictive », Sciences Po Paris, Wolters Kluwer, Predictice, 2018 : <https://app.hubspot.com/documents/4129959/view/31036626?accessId=85b854>

McFadden M., Jones K., Taylor E., Osborn G., “Harmonizing Artificial Intelligence: The role of standards in the EU AI Regulation”, McFadden M., Jones K., Taylor E., Osborn G., Oxford Information Labs, 2021, p. 20 : <https://oxcaigg.oii.ox.ac.uk/wp-content/uploads/sites/11/2021/12/Harmonising-AI-OXIL.pdf>

« Mécanisme d'une justice algorithmisée », Basdevant A., Jean A., Storchan V., Fondation Jean Jaurès éditions, coupdata.fr, 2021 : <https://www.jean-jaures.org/publication/mecanisme-dune-justice-algorithmisee/>

« Modalités de régulation des algorithmes de traitement des contenus », Pavel I., Rapport pour la Direction de l'information légale et administrative, 2016 : <https://www.vie-publique.fr/rapport/273514-modalites-de-regulation-des-algorithmes-de-traitement-des-contenus>

« Open-data des décisions de justice 2016-2019 : une mise en œuvre problématique », Garcia-Solek H., <https://www.juriconnexion.fr/wp-content/uploads/2019/05/Bibliographie-OpenData.pdf>

“Policy and Investment Recommendations for Trustworthy AI”, AIHLEG, June 2019: <https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/policy-and-investment-recommendations-trustworthy-artificial-intelligence>

« Pour une intelligence artificielle maîtrisée, utile et démystifiée », Rapport de l'OPECST, Rapport n° 464, 15 mars 2017 : <https://www.senat.fr/notice-rapport/2016/r16-464-1-notice.html>

« Rapport du cycle d'ateliers sur l'éthique de la réutilisation des décisions de justice » : <https://www.courdecassation.fr/publications/autre-publication-de-la-cour/rapport-du-cycle-dateliers-sur-lethique-de-la-l>

« Responsabilité civile et intelligence artificielle », dir. Gout O., Recueil des travaux du Groupe de recherche européen sur la responsabilité civile et l'assurance (GRERCA), Bruylant, 2022

« Tableau comparatif sur l'encadrement de l'accès en données ouvertes aux décisions de justice, Synthèse des réponses », Ministère de la Justice, 2023 : https://www.justice.gouv.fr/sites/default/files/2023-04/rapport_pfue_sem_cmjn%20%281%29.pdf

“Towards a Standard for Identifying and Managing Bias in Artificial Intelligence”, Reva S., Vassilev A., Greene K., Perine L. *et al.* (2022), National Institute of Standards and Technology, Gaithersburg, MD, [online], <https://doi.org/10.6028/NIST.SP.1270>, https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=934464 (Accessed September 11, 2024)

« Vers une régulation des systèmes d'IA. Perspectives internationales sur l'élaboration d'un cadre juridique fondé sur les normes du Conseil de l'Europe dans le domaine des droits de l'homme, de la démocratie et de l'État de droit », CAHAI, décembre 2020

Instruments juridiques

Arrêté du 28 avril 2021 pris en application de l'article 9 du décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administrative

Avis n° (2011)14 du Conseil consultatif des juges européens, Justice et technologies de l'information, novembre 2011, <https://www.euromed-justice.eu/fr/system/files/CCJE-Avis-N-14-Justice-et-technologies-de-l'information.pdf>

Charte éthique européenne d'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires, CEPEJ, 3-4 décembre 2018 : <https://rm.coe.int/charte-ethique-fr-pour-publication-4-decembre-2018/16808f699b> (consulté le 23 décembre 2020)

Décret n° 2009-697 du 16 juin 2009 relatif à la normalisation

Décret n° 2011-194 du 21 février 2011 portant création d'une mission « Etalab » chargée de la création d'un portail unique interministériel des données publiques.

Décret n° 2020-797 du 29 juin 2020 relatif à la mise à la disposition du public des décisions des juridictions judiciaires et administratives.

Décret n° 2021-1276 du 30 septembre 2021 relatif aux traitements automatisés de données à caractère personnel dénommés « Décisions de la justice administrative » et « Judilibre »

Directive (UE) 2016/943 du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2016 sur la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d'affaires) contre

l'obtention, l'utilisation et la divulgation illicites : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32016L0943>

Directive (UE) 2019/1024 du Parlement européen et du Conseil, *Journal officiel de l'Union européenne* L 172/60 du 26 juin 2019 : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019L1024&from=EN>

Directive (UE) 2024/2852 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE du Conseil (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) : <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2024/2853/oj/eng>

Loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique, qui prévoit une mise à disposition des données détenues par les administrations, dont les décisions de justice.

Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, qui autorise le traitement algorithmique des données en open data.

Loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires

Loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2015-8-2022 pour la justice, qui prévoit la mise en application de la diffusion des décisions de justice.

Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés

Outil d'évaluation pour l'opérationnalisation de la Charte éthique européenne sur l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement, CEPEJ, 2023 : <https://rm.coe.int/cepej-2023-16final-operationalisation-de-la-charte-ethique-ia-fr/1680adcc9d>

Proposition de directive du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2022 relative à l'adaptation des règles en matière de responsabilité civile extracontractuelle au domaine de l'intelligence artificielle (Directive sur la responsabilité en matière d'IA), COM(2022) 496 final : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A52022PC0496>

Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679>

Règlement (UE) 2018/1807 du Parlement européen et du Conseil du 14 novembre 2018 établissant un cadre applicable au libre flux des données à caractère non personnel dans l'Union européenne : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=celex%3A32018R1807>

Règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne, modifiant les directives 89/686/CEE et 93/15/CEE du Conseil ainsi que les directives 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE et 2009/105/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la décision 87/95/CEE du Conseil et la décision n° 1673/2006/CE du Parlement européen et du Conseil : <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R1025>

Résolution du Parlement européen du 20 octobre 2020 contenant des recommandations à la Commission sur un régime de responsabilité civile pour l'intelligence artificielle : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2020-0276_FR.html#title1

U.S. Department of Justice, National Institute of Justice, 1981. Pretrial Release: A National Evaluation of Practices and Outcomes: <https://www.ojp.gov/dffiles1/Digitization/81061NCJRS.pdf>

Communications

Bourcier D., « Cyberjustice : ennemie ou alliée du droit », Intervention dans le cadre de la 1^e Conférence Cyberjustice Europe 2016, organisée par l'IHEJ devant le Conseil de l'Europe le 5 décembre 2016. Toutes les conférences de cette journée sont accessibles sur : <http://ihej.org/agenda/1ere-conference-cyberjustice-europe-2016/>

Sauvé J.-M., Intervention à l'occasion du colloque organisé à l'occasion du bicentenaire de l'Ordre des avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation le 12 février 2018, accessible sur le site du Conseil d'État : <http://www.conseil-etat.fr/Actualites/Discours-Interventions/La-justice-predictive>

Table des matières

Introduction	5
Première partie – La nécessité de réguler les outils de justice prévisionnelle	18
Titre 1 – La justice prévisionnelle, une forme de réutilisation des données judiciaire en open data	19
Chapitre 1 – Le contexte de l’open data des décisions de justice	19
Section 1 – Le choix français	19
Section 2 – La comparaison avec d’autres choix possibles	23
Chapitre 2 – Les enjeux de l’open data des décisions de justice	27
Section 1 – Les enjeux de transparence et de connaissance de l’activité judiciaire	27
Section 2 – Les enjeux pour le droit au procès équitable	29
Titre 2 – Réguler les outils de justice prévisionnelle pour garantir la qualité de la décision de justice : une analyse économique	35
Chapitre 1 – Les effets des outils de justice prévisionnelle sur la qualité de la décision judiciaire : un bilan coûts-avantages incertain	39
Section 1 – Les difficultés de l’évaluation des effets des OJP sur la qualité de la justice : qu’évaluer ?	39
§1 – La diversité des OPJ sur le marché	40
A. La place des OJP dans les <i>legaltechs</i>	40
B. De nombreuses expériences d’utilisation des OJP par les professionnels de justice	45
§2 – Quelle définition de la qualité de la justice ?	48
§3 – La cible de l’évaluation	49
§4 – La mesure quantitative et qualitative des effets	51
Section 2 – Les effets des OJP sur la qualité de la décision judiciaire – réduire l’aléa judiciaire, expliquer et prévoir la décision du juge	52
§1 – Repérer les biais décisionnels des juges	52
A. L’analyse empirique des déterminants de la décision judiciaire et biais décisionnels des juges	52
B. Les OJP comme outils de détection des biais décisionnels et de prévision de la décision judiciaire	54
§2 – Repérer les biais cognitifs des juges	55
A. L’importance des biais cognitifs des juges	55
B. Les OPJ comme outils de détection des biais cognitifs	57
§3 – Les OJP comme outils de correction des biais humains : corriger l’aléa judiciaire grâce aux OJP	57
§4 – Biais humain versus biais algorithmique : Dr Human contre Mr Algo ?	60
A. Le problème de la qualité intrinsèque des OJP : les OJP comme artefacts humains	60
1. Le choix des critères présidant à la conception des OJP – le choix des outcomes (résultats) et des variables	60
2. Le choix des critères présidant à la conception des OJP – le choix des architectures de choix des utilisateurs	64
3. Biais et données	65
4. Biais humains contre biais algorithmiques : suivre ou ne pas suivre les recommandations de l’OJP ?	67
B. Quel effet prescriptif et performatif des OJP sur la décision judiciaire ?	69
Section 3 – Les OPJ et l’efficacité managériale de l’institution judiciaire	72
§1 – OJP, gains de productivité et efficacité productive des tribunaux	73
§2 – Les OJP, des outils de réduction de la charge judiciaire	75

Chapitre 2 – La régulation des outils de justice prévisionnelle et l’information des utilisateurs : informer pour garantir la qualité de la décision judiciaire	79
Section 1 - Les asymétries d’information, un motif de régulation pour l’analyse économique	79
§1 – L’opacité des algorithmes, à l’origine d’asymétries informationnelles	79
A. L’asymétrie informationnelle entre juges et concepteurs des OJP	80
B. L’asymétrie informationnelle entre juges et justiciables	81
C. Asymétries informationnelles et comportements opportunistes de la partie informée	83
§2 – Réguler les OJP pour lutter contre les effets négatifs des asymétries informationnelles	85
A. Réguler les OJP pour garantir la qualité de la décision judiciaire	85
B. Quelle régulation ?	88
Section 2 - Le contenu de la régulation : informer pour réduire les asymétries informationnelles	92
§1 – Accroître la transparence des choix de conception des OJP	92
§2 – Accroître la transparence des usages	94
§3 – Organiser l’explicabilité pour garantir la transparence des OJP	96
Section 3 – L’effectivité de la régulation des OJP : quelle forme de la régulation en présence d’asymétries informationnelles ?	100
§1 – Asymétries informationnelles entre le régulateur public et les offreurs d’OJP : les limites d’une régulation directe par la puissance publique	101
§2 – Associer les acteurs régulés à la production et la mise en œuvre de la régulation des OJP : la voie de l’autorégulation et de la co-régulation	102
A. L’association des acteurs privés à la production et la mise en œuvre de la régulation	102
B. Une régulation caractérisée par un degré élevé de généralité et d’abstraction	104
C. L’acceptabilité d’une régulation générale et abstraite	105
§3 – Quelle effectivité d’une régulation des OJP ?	107

Deuxième partie – Les cadres de la régulation des outils de justice prévisionnelle **111**

Titre 1 – L’analyse des cadres réglementaires **111**

Chapitre 1 – Les dispositions spéciales applicables aux outils de justice prévisionnelle	111
Section 1 – Les textes français relatifs à la réutilisation des décisions de justice en <i>open data</i>	111
Section 2 – Les principes issus de la Charte éthique européenne d’utilisation de l’intelligence artificielle dans les systèmes judiciaires et leur environnement	115

Chapitre 2 – Les dispositions générales applicables aux systèmes d’intelligence artificielle	129
Section 1 – Les instruments issus d’organisations intergouvernementales	129
§1 – Les cadres d’adoption des instruments	129
§2 – Les points de convergence et de divergence entre les instruments	132
Section 2 – Les textes européens sur l’intelligence artificielle	138
§1 – Le règlement sur l’intelligence artificielle (RIA)	139
§2 – Les propositions de directive en matière de responsabilité de l’IA	147
A. La proposition de directive sur la responsabilité de l’IA	148
B. La directive réformant la responsabilité des produits défectueux	149

Titre 2 – La mise en œuvre des mesures réglementaires des outils de justice prévisionnelle **153**

Chapitre 1 – La mise en œuvre <i>ex ante</i>	154
Section 1 – Les limites de la régulation des outils de justice prévisionnelle par la <i>compliance</i>	154
Section 2 – La normalisation technique, accompagnement dans la mise en conformité des outils de justice prévisionnelle	156
Section 3 – Notre étude de faisabilité de la certification de deux outils de justice prévisionnelle	169
§1 – Une présentation générale	170
§2 – L’analyse de risques	172
A. La démarche	173

B. Le déroulement du processus de création avec les partenaires industriels _____	176
C. Nos conclusions sur l'analyse de risques et les suites du travail _____	178
§3 – Les plans d'évaluation _____	179
A. La présentation du plan d'évaluation _____	179
B. Le déroulement du processus d'élaboration du plan d'évaluation avec les partenaires industriels _____	183
C. Nos conclusions sur la création des plans d'évaluation _____	184
D. Nos conclusions sur la qualification des systèmes de justice prévisionnelle _____	185
Chapitre 2 – La mise en œuvre ex post _____	188
Section 1 – L'application de la responsabilité civile au dommage causé par l'intelligence artificielle _____	188
Section 2 – La réparation du dommage causé au moyen d'un outil de justice prévisionnelle par la responsabilité contractuelle _____	192
§1 – La responsabilité de l'avocat utilisateur de l'outil de justice prévisionnelle recherchée par son client _____	193
§2 – La responsabilité du fournisseur recherchée par l'utilisateur _____	196
§3 – L'éventuelle action directe de la personne concernée contre le fournisseur _____	201
Section 3 – La réparation du dommage causé au moyen d'un outil de justice prévisionnelle par la responsabilité extracontractuelle _____	202
§1 – La responsabilité du fournisseur recherchée par la personne concernée _____	202
§2 – La responsabilité des magistrats recherchée par la personne concernée _____	209
Troisième partie – L'impact des outils de justice prévisionnelle sur la manière de faire du droit _____	212
Titre 1 – L'incidence des outils de justice prévisionnelle sur les pratiques des magistrats _____	212
Chapitre 1 – L'évolution des procédures de divorce vue à partir des entretiens _____	213
Chapitre 2 – La perception par les magistrats du travail de juge aux affaires familiales : l'organisation et le vécu de l'activité _____	216
Section 1 – L'organisation et les magistrats _____	216
Section 2 – La mise à l'épreuve de l'organisation en cabinets avec la nouvelle réforme _____	219
Section 3 – Un travail vécu comme tendu par une logique de flux _____	221
Section 4 – Une matière qui laisse place à la vie de tous les jours _____	223
Section 5 – La prise en compte d'attentes ordinaires _____	226
Chapitre 3 – Le traitement des dossiers de divorce _____	228
Section 1 – Les sources de complexité dans les dossiers _____	228
Section 2 – L'activité décisionnelle comme activité équipée _____	229
§1 – Les discussions avec les collègues _____	230
§2 – Les listes de discussion _____	234
Section 3 – La réunion de service et ses usages : la tension entre coordination et collaboration et autonomie et indépendance _____	234
§1 – Traiter des problèmes organisationnels et juridico-organisationnels _____	234
§2 – La difficulté à discuter des cas _____	236
§3 – Les jeux de rôle _____	238
Chapitre 4 – La question des prestations compensatoires _____	240
Section 1 – Le calcul des prestations compensatoires _____	241
Section 2 – Les prestations compensatoires et l'hybridation des raisonnements juridiques et des raisonnements ordinaires _____	246
Chapitre 5 – Les usages de l'outil JurisData Analytics _____	250
Section 1 – Une distribution des usages assez typique pour ce genre d'expérimentation _____	250
Section 2 – Quelques freins à l'usage de l'outil JurisData Analytics pour les décisions concernant les prestations compensatoires _____	253

Chapitre 6 – Retour sur la question du précédent. Deux configurations d’usage pour l’outil d’aide à la décision reposant sur le <i>big data</i> pour deux contentieux différents	258
Section 1 – Le cas d’un contentieux cadré et ‘technique’ : le risque d’un rapport trop ‘rigide’ à l’outil d’aide à la décision	258
Section 2 – Le cas des prestations compensatoires et des affaires familiales : un rapport ‘souple’ à l’outil d’aide à la décision	263
Titre 2 – L’incidence des outils de justice prévisionnelle sur la jurisprudence	268
Chapitre 1 – L’absence d’incidence actuelle de la justice prévisionnelle sur la jurisprudence	272
Chapitre 2 – L’incidence attendue de la justice prévisionnelle sur la jurisprudence avec l’ <i>open data</i> des décisions de justice	277
Conclusion générale	290
Annexe 1 – Modèle « analyse de risques »	292
Annexe 2 – Modèle « plan d’évaluation »	294
Annexe 3 – Questionnaire « compliance entreprise legaltech »	300
Bibliographie	304
Table des matières	328

La recherche s'intéresse à la régulation des outils de justice prévisionnelle. Techniquement, ces outils sont des applications informatiques utilisant des technologies plus ou moins avancées en matière d'apprentissage machine (*machine learning*) et de traitement du langage naturel (*Natural Language Processing*) pour analyser un grand volume de décisions antérieures. Ces technologies sont utilisées dans le but de reproduire, par la machine, le travail de dépouillement des décisions judiciaires qu'une personne humaine aurait pu faire, dans une moindre mesure, pour effectuer un gigantesque travail de tri et d'analyse de leur texte.

En rendant visible à grande échelle l'état du contentieux sur un problème donné, ces outils vont bien au-delà d'une simple fonction de recherche documentaire et ont vocation à influencer, *in fine*, la décision du professionnel du droit qui les utilise.

Par ailleurs, en conférant de l'importance aux décisions des juges du fond jusqu'alors relativement méconnues, les outils de justice prévisionnelle influencent l'ordonnancement des sources du droit et créent un risque de « factualisation » du droit.

Enfin, ils ont une incidence sur les garanties découlant du droit au procès équitable tels que l'accès effectif à un juge indépendant et impartial ou encore l'égalité des armes.

Dans ces conditions, la manière dont ils sont conçus et utilisés ne saurait être abandonnée aux seules lois du marché. Notre recherche a donc vocation à esquisser une réflexion, dans une approche globale – mêlant économie, droit, métrologie, sociologie – sur la manière de garantir la confiance dans le service public de la justice à l'aune des outils de justice prévisionnelle.

Après avoir montré la nécessité de réguler le marché des outils de justice prévisionnelle, les travaux conduits dans l'axe droit-économie ont eu vocation à interroger les modalités de cette régulation. Ont ainsi été étudiées tant les modalités d'une régulation *ex ante* des outils de justice prévisionnelle, en analysant l'approche moderne de la mise en conformité notamment, que les modalités d'une régulation *ex post*, en s'intéressant à la responsabilité des acteurs en la matière.

La recherche dans l'axe droit-métrologie avait pour ambition de compléter l'approche théorique relative à la mise en conformité en étudiant la faisabilité de l'évaluation des outils de justice prévisionnelle dans la perspective de leur éventuelle certification. Ce travail, conduit en partenariat avec des experts du Laboratoire national de métrologie et d'essais (LNE), a permis d'élaborer un premier cahier des charges pour conduire une analyse de risques et un plan d'évaluation selon un référentiel certifiable.

L'axe droit-sociologie avait pour objectif de réfléchir, dans une perspective à la fois pratique et théorique, à la manière dont les outils de justice prévisionnelle peuvent modifier la manière de faire du droit et de rendre la justice. Les travaux réalisés ont notamment mis en lumière le besoin de formation professionnelle en la matière et la nécessité de hiérarchiser les décisions du fond selon une méthode qui reste à construire.

Au terme du rapport, il est apparu que la recherche académique et la puissance publique au sens large avait un rôle crucial à jouer pour assurer que ces technologies améliorent véritablement l'accès à la justice, tout en préservant les principes fondamentaux du droit.

Aurore HYDE, Professeure de droit privé à l'université Reims Champagne-Ardenne

Agnès DELABORDE, Docteure en informatique, responsable de département au LNE